

APUNTES DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

MARÍA IGNACIA VIAL UNDURRAGA

ARTURO SAFFIE VEGA

Introducción y Aspectos Generales.

El mundo se divide en estados y el estado se define como la nación política y jurídicamente organizada. Lo relevante es que todas las relaciones jurídicas pueden internacionalizarse. El problema que se plantea en el derecho internacional privado es determinar cuál de los ordenamientos jurídicos vigentes se aplican a la relación jurídica en cuestión. El derecho internacional privado es una especie de derecho civil y comercial internacional. Asimismo, existen ordenamientos plurilegislativos en los que dentro de cada estado existen diversos ordenamientos (por ejemplo, en Estados Unidos con los estados federados, en España con los fueros catalanes o gallegos, o en Kenia rigen diversos ordenamientos como el derecho consuetudinario de la tribu, se aplica el ordenamiento de Kenia y, eventualmente, el sistema de la Commonwealth).

Habitualmente se ha estudiado el derecho en una perspectiva unidimensional, pero en el derecho internacional privado surge una perspectiva tridimensional, ya que, por ejemplo, se aprende que no siempre el contrato de compraventa constituye un título traslativo de dominio. Es habitual que, dependiendo del ordenamiento que se aplique, se puede llegar a una solución diversa.

Hay dos casos interesantes que muestran la relevancia del derecho internacional privado. Por una parte, en una época se diseñó un avión (concorde) que viajaba superando la velocidad del sonido. Este avión hacía el trayecto entre París y Nueva York. En una ocasión, el concorde capota en Bahamas y fallecen todos los ocupantes (en su mayoría, de nacionalidad alemana) por una falla técnica. ¿Dónde podían demandar los parientes alemanes? Podían demandar en Francia porque Air France es una compañía francesa con sede principal en ese país; en Bahamas donde cae el avión; y en Alemania donde estaban domiciliadas las víctimas. Todos esos países tenían jurisdicción potencial, pero los abogados de los familiares terminan demandando en Estado Unidos ante los tribunales de Nueva York. Esto porque los parientes fueron a una oficina internacional y la oficina dijo que demandarían en EE.UU. (mayores montos indemnizatorios), porque Air France estaba ofreciendo una indemnización muy baja. La pregunta era cómo lograr que Nueva York tuviese jurisdicción sobre el caso, los abogados dijeron: (i) Air France tiene oficinas en Nueva York; y (ii) encontraron que un pasaje del concorde había sido vendido por la oficina de Air France en Nueva York. Con ello argumentaron que Nueva York tenía jurisdicción y, frente a eso, Air France aumentó la oferta y se arregla por transacción el caso.

Por otra parte, está la historia de la Dama de Oro, que era un retrato de Gustave Klint y que pertenecía a una familia judía en Austria. Ese cuadro fue robado por nazis y, eventualmente, terminó siendo exhibido en un museo. La nieta de la retratada solicita la entrega del cuadro, ya que era la única descendiente de su abuela. En principio, los tribunales austriacos rechazaron la solicitud. Sin embargo, un día, el abogado de la nieta visitó un museo en Nueva York y se percató que en la tienda se vendía un libro con el retrato de la Dama de Oro y editado por el museo austriaco. El abogado argumentó la competencia de los tribunales en Nueva York porque el museo austriaco estaba comercializando el retrato y demanda al museo en Estado Unidos. El tribunal de Nueva York condena al museo austriaco a devolver el cuadro y la dueña de él no lo quería por razones materiales sino sentimentales, así que lo presta nuevamente en exhibición.

I. PARTE GENERAL.

I. Definición y ámbito del Derecho Internacional Privado, el problema multinacional.

A. Nombre: Derecho Internacional Privado (países de Derecho Codificado; *loi internationale privé* en Francia o *diritto internazionale privato* en Italia) y *Conflict of Laws* (mundo anglosajón y del *Common Law*).

B. Surgimiento del Problema Jurídico Multinacional: las relaciones jurídicas internacionales e interestatales entre privados son cada vez más frecuentes. Todos se pueden ver afectados por situaciones de derecho internacional privado.

Elas provocan problemas jurídicos con contactos o lazos con dos o más sistemas legales de Estados distintos. En el mundo coexisten una diversidad de ordenamientos jurídicos estatales o nacionales igualmente obligatorios y de equivalente jerarquía, que pueden gobernar un mismo problema jurídico multinacional.

C. Tres Problemas a Resolver:

1. **¿Cuál es el ordenamiento jurídico o ley aplicable a un acto o problema multinacional?**
Este problema surge porque hay varios y distintos ordenamientos nacionales o estatales que tienen contactos o relaciones con él y debe determinarse cuál de ellos se aplica. Se trata de conflictos de leyes.
2. **¿Cuál es la jurisdicción o foro estatal competente para decidir acerca de las eventuales disputas judiciales que surjan a raíz de él?** Es necesario identificar qué tribunales de un Estado tienen jurisdicción para resolver el problema multinacional porque está ligado a varios distintos. Se trata de conflictos de jurisdicción internacional.
3. **¿Cómo se reconocerán los actos, documentos, instrumentos, declaraciones y decisiones judiciales o arbitrales fuera del Estado donde han sido celebrados, emitidos o dictados?** Se trata del reconocimiento extraterritorial de actos y decisiones judiciales. Por ejemplo, cómo se reconoce en Chile una sentencia arbitral emitida en el extranjero, cómo se reconoce en Chile un contrato de compraventa celebrado en Guatemala, entre otros

D. Importancia del Derecho Internacional Privado: cada ordenamiento nacional de Derecho Internacional Privado debe resolver estos conflictos de leyes y de jurisdicción y las condiciones de reconocimiento para otorgar justicia y certeza jurídica de las partes. Las soluciones jurídicas que brindan los distintos Estados a un mismo problema multinacional difieren entre sí. Hay que saber identificar un problema de derecho internacional privado y, luego, saber resolver ese problema; siendo muy importante la estrategia. Se pueden dar dos ejemplos:

1. La empresa francesa Metallurgia celebra con una empresa chilena Brokers Mineros S.A. un contrato de agencia para que lo represente en la compraventa de cobre a Codelco Chile. El contrato se celebra por un intercambio electrónico de firmas de las partes, las órdenes de compra y ratificaciones también se harán por vía electrónica. El pago del agente se hará por transferencia electrónica a una de sus cuentas corrientes en Nueva York. Se observa que esta relación jurídica tiene, desde su inicio, vínculos jurídicos con el ordenamiento jurídico

francés, el chileno y el del Estado de Nueva York y, por ello, cada uno de esos ordenamientos es potencialmente aplicable a ella. Al redactar el contrato, deberán preverse:

- a. ¿Cuáles serán los posibles foros jurisdiccionalmente competentes? Podría eventualmente demandarse en Nueva York (lugar del pago), en Chile (incumplimiento del contrato de agencia) o en Francia (domicilio de la empresa francesa).
 - b. ¿Qué legislación regirá ese contrato? Podría ser la ley francesa, chilena o neoyorquina.
 - c. ¿Tendrán eficacia en todos los Estados donde deban hacerse valer las órdenes electrónicas, facturas y demás documentos del contrato?
2. Andrea Scapini y Michelle Torretti, italianos residentes en Chile, celebran un contrato por escritura pública ante un Notario de Talca de prestación de servicios de asesoría financiera por tres años. Se acuerda que los servicios deben prestarse en Talca. En el contrato las partes no elijen expresamente la ley chilena para gobernar ese contrato. Posteriormente, Andrea se traslada a vivir a Modena (Italia) y deja inconclusa la asesoría comprometida. Por ello, Michelle lo demanda ante el juez de su domicilio en Modena pidiendo una indemnización de perjuicios por incumplimiento de este contrato. El tribunal de Modena será competente para conocer de esta causa (porque el demandado está domiciliado ahí) y aplicará la normas italianas de derecho internacional privado para determinar qué ley regirá el contrato y la indemnización de perjuicios por su incumplimiento (según el Art. 57 de la Ley de DIPRI Italiana aplicará las normas del Reglamento de la U.E. sobre ley aplicable a los contratos). Según esta normativa, si las partes no han elegido ley aplicable, un contrato de prestación de servicios debe regirse por la ley del país donde el prestador de servicios tenga su residencia habitual (Art. 4 N°1 letra b), es decir, podría aplicar la ley italiana a ese contrato celebrado en Chile, para cumplirse en Chile. Aquí hay una situación jurídica que, en un primer momento, estaba regulada íntegramente por el derecho chileno pero que después se “internacionalizó” por el hecho de que una de las partes cambió su domicilio al extranjero. El contrato pasó a regirse por otro derecho y hubo que demandar su incumplimiento en el extranjero. Además, se debió probar la existencia del contrato chileno en el extranjero.

E. Ámbito de Estudio del Derecho Internacional Privado: en general, el derecho internacional privado estudia cuál es la legislación aplicable a casos multinacionales o casos con elementos extranjeros. En cuanto a las materias concretas reguladas por el derecho internacional privado:

1. Resolución de conflictos de leyes, es decir, determina cuál es el derecho o ley aplicable a las situaciones privadas internacionales de entre los varios derechos nacionales que tienen vínculos con esa situación.
2. Resolución de conflictos de jurisdicción y sus normas de resolución, es decir, determina la competencia judicial internacional de un tribunal nacional, de entre los distintos Estados vinculados con el asunto litigioso internacional.
3. Determinación de la validez extraterritorial de actos, instrumentos y decisiones judiciales extranjeras en un Estado distinto de aquel en que se han emitido.
4. Resolución de conflictos de nacionalidad. En algunos sistemas jurídicos (no tanto en Chile, pero sí en los países europeos), la nacionalidad es un factor de conexión importante para determinar la aplicación de un determinado ordenamiento y puede originar conflictos de

nacionalidad. Por ejemplo, una persona tiene un hermano chileno y, por matrimonio con una norteamericana, tiene pasaporte norteamericano; para el derecho chileno, es un chileno y, para el derecho norteamericano, es un norteamericano; pero para el derecho colombiano, se podrá producir un conflicto entre la nacionalidad originaria y la nacionalidad adquirida. Esto no es tan importante para el derecho chileno porque no se considera la nacionalidad como un factor relevante, salvo excepciones, para la aplicación de la ley chilena. Para España, por ejemplo, las sucesiones se regulan por la ley de la última nacionalidad del causante.

F. Definición: Andrés Bello define al derecho internacional privado como el conjunto de reglas que sirven para dirimir conflictos de leyes. Esta definición, aunque correcta para su época, resulta hoy incompleta porque no incluye los conflictos de jurisdicción ni la validez extraterritorial de instrumentos o sentencias extranjeras. Andrés Bello desechó el criterio de nacionalidad (en esa época había muchos españoles), por lo que copia la regla de la normativa francesa y que se refleja en el criterio de territorialidad del Art. 14 CC (obligatoriedad de la ley chilena para todos los habitantes de la república, incluso los extranjeros). Las normas de derecho internacional privado son normas nacionales, es decir, cada país establece sus propias normas para resolver sus problemas de derecho internacional privado. Entonces, si resuelve un juez chileno o un juez estadounidense el mismo caso, la solución puede ser diversa precisamente porque la norma correspondiente que deben aplicar puede ser diversas.

Es aquella rama del ordenamiento jurídico de un país que se avoca a la regulación de un conjunto de normas internas orientadas a la resolución de conflictos de aplicación de leyes, determinación de competencia jurisdiccional y ejecución de decisiones jurídicas en el marco de relaciones privadas internacionales.

G. Algunos Problemas de Derecho Internacional Privado: Casos Jurídicos Multinacionales.

(1.) Juan Carlos Zañartu, chileno, domiciliado en Nueva York, otorga ahí un poder de administración general de sus bienes a su hermano Guillermo, chileno domiciliado en Santiago. Algunos de sus bienes se ubican en Chile.

1. ¿Qué elementos internacionales pueden influir en la regulación de este acto?
 - a. Nacionalidad de las partes.
 - b. Domicilio del otorgante en Nueva York y domicilio del apoderado en Santiago.
 - c. Ubicación de los bienes en Chile.
 - d. Lugar de celebración (Nueva York).
2. ¿Qué problemas se presentan?
 - a. ¿Qué ley rige su capacidad para otorgar ese poder? El Art. 15 CC somete al chileno a la ley chilena respecto de la capacidad para celebrar actos que van a tener efecto en Chile. La capacidad de Juan Carlos para otorgar el poder a Guillermo se rige por la ley chilena en cuanto supone la administración de bienes en Chile.
 - b. ¿Qué ley rige la validez formal y sustancial de ese poder? Es la ley de Nueva York la que rige la validez formal del poder, mientras que será la ley chilena la que regule la validez sustancial (Art. 16 CC).
 - c. ¿Qué requisitos debe reunir ese poder para hacerlo valer en Chile? Para darle validez de un instrumento internacional son la legalización y la apostilla.

- d. ¿Dónde deberá demandar Juan a Guillermo por el incumplimiento de su obligación de rendirle cuenta de su gestión? En Chile por el domicilio del demandado.

(2.) Jean Bernaux y Brigitte Mercier, franceses, se casan en París en el año 2000 y el año 2010 se trasladan a vivir a Mendoza, Argentina. El año 2015 compran en Mendoza a un argentino, domiciliado en Mendoza, un departamento de veraneo ubicado en el balneario chileno de Las Tacas.

1. ¿Qué elementos internacionales pueden influir en la regulación de este acto?
 - a. Nacionalidad de las partes (franceses y argentinos).
 - b. Matrimonio en Francia.
 - c. Cambio de domicilio a Argentina.
 - d. Compra-venta en Argentina.
 - e. Departamento ubicado en Chile.
2. ¿Qué problemas se presentan?
 - a. ¿Qué ley rige la validez del matrimonio de Jean y Brigitte? Conforme a la Ley de Matrimonio Civil (Art. 80), la ley que rige la validez de forma y fondo del matrimonio es la ley del lugar de celebración.
 - b. ¿Qué ley rige el régimen patrimonial matrimonial de este matrimonio? Conforme al Art. 135 CC, los que se hayan casado en el extranjero, se miran en Chile como separados de bienes, salvo que inscriban ese matrimonio. Así, Jean no necesitaría autorización de su mujer para celebrar el contrato.
 - c. ¿Qué ley rige el contrato de compra-venta del departamento de veraneo? Las formalidades de ese contrato quedan gobernadas por la ley argentina (Art. 17 CC). Además, conforme al Art. 18 CC y Art. 1702 CC, en Chile no se puede probar la compra-venta de un bien raíz por instrumento privado, aun cuando en el país en que se otorgó se permita.
 - d. ¿Cómo se probará o acreditará en Chile la compra-venta del departamento celebrada en Argentina? Se tienen que realizar los trámites de legalización o apostilla de la escritura.
 - e. ¿Qué ley rige la adquisición de la propiedad de ese departamento? La ley chilena por la ubicación del bien (Art. 16 CC). La tradición se efectúa por la inscripción de la escritura en el Conservador de Bienes Raíces.
 - f. ¿Dónde debe demandar Jean al vendedor para exigirle la tradición del departamento? Se debe demandar en Argentina.
 - g. ¿Dónde debe demandar el argentino vendedor a Jean para exigirle el pago del precio del departamento? Se debe demandar en Argentina.
3. A la muerte de Jean ¿qué ley regirá los derechos sucesorios sobre el departamento? Se aplica el Art. 955 CC, la ley del último domicilio del causante.

(3.) La empresa agrícola chilena Los Molles S.A es demandada por Supermarché Carrefour, empresa francesa, en un juicio arbitral con sede en París por el incumplimiento de un contrato de compra-venta de 5.000 toneladas de manzanas y arándanos. El tribunal arbitral condena a Los Molles S.A. al pago de una indemnización a Carrefour de 80.000 dólares.

1. ¿Qué elementos internacionales pueden influir en la regulación de este acto?
 - a. Nacionalidad de las empresas.

- b. Juicio arbitral con sede en París.
 - c. Incumplimiento contractual.
 - d. Sentencia arbitral condenatoria.
2. ¿Qué problemas se presentan?
- a. ¿Qué validez tiene en Chile esta sentencia arbitral pronunciada en París? Hay que someterla al trámite del *exequátur*.
 - b. ¿Qué ley rige la capacidad del Gerente de Carrefour-Francia para representar a la empresa en el juicio de *exequátur* en Chile? La ley francesa es la que rige la capacidad para representar a una persona jurídica francesa.

(4.) Juan Barreda, gerente de la empresa distribuidora de insumos tecnológicos CHILETEC Ltda., compra en una feria tecnológica efectuada en Silicon Valley (California, EE.UU) a la empresa China Shangai Computers Inc., 2.000 unidades de Tarjetas Gráficas NVIDIA, manufacturadas en China Continental y a entregarse en el puerto de Valparaíso (Chile) por la cantidad de 20.000 dólares FOB a pagarse mediante una Carta de Crédito. CHILETEC abre esa carta de crédito en el Banco Santander (Santiago) para pagarse por la sucursal en Shangai del Banco HSBC a Shangai Computers Inc. una vez recibidas conforme las mercaderías en Valparaíso. Las mercaderías sufren un daño importante al ser descargadas en Valparaíso.

1. ¿Qué elementos internacionales pueden influir en la regulación de este acto?
 - a. Feria internacional en Estados Unidos entre comprador chileno y vendedor chino.
 - b. Se paga por carta de crédito.
 - c. Existe el INCOTERM FOB (Free On Board) donde la responsabilidad se traspa al momento de cargar la mercadería en el transporte.
 - d. Las mercaderías sufren daño al ser descargadas en el puerto de destino.
2. ¿Qué problemas se presentan?
 - a. ¿Qué ley rige el contrato de compraventa de las tarjetas? La ley de California.
 - b. ¿Qué ley rige la apertura y el pago de la carta de Crédito? La apertura en Chile y el pago en China.
 - c. ¿Qué ley rige el daño que sufren las mercaderías en el puerto de Valparaíso? La ley chilena (Art. 14 CC).
 - d. ¿Qué ley rige la personería de Juan Barreda para representar a CHILETEC? ¿Cómo se acredita esa personería? La ley chilena.
 - e. ¿Ante qué tribunales puede demandarse el incumplimiento del contrato de compraventa? Ante los tribunales de Shangai o en los tribunales chilenos.

II. Las normas de conflicto y sus fuentes.

A. Nombre de las Normas de Derecho Internacional Privado:

1. Normas de derecho internacional privado o normas de conflicto.
2. Reglas de conflicto o *conflict rules*.
3. Normas de colisión.
4. Reglas o factores de conexión.

B. Tipos de Normas de Derecho Internacional Privado: hay diversos de tipos de normas de conflicto:

1. Indirectas o atributivas v/s materiales o sustantivas.
2. Universales v/s territoriales.
3. Unilaterales v/s multilaterales.
4. Dispositivas v/s de policía o aplicación necesaria.

B.1. Normas de Conflicto Indirectas o Atributivas: son normas jurídicas que no resuelven materialmente el caso multinacional sino que establecen criterios para determinar la ley aplicable a su solución. Le atribuyen competencia a una cierta ley para resolver ciertos problemas específicos.

1. Ejemplos:

- a. **Art. 955 CC:** la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio; salvos los casos expresamente exceptuados. / La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvo las excepciones legales.
 - b. **Art. 16 inc. 1 CC:** los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile.
 - c. **Art. 17 inc. 1 CC:** la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento.
- 2. Estructura:** todas las normas de conflicto indirectas o atributivas tienen una misma estructura.

Supuesto de Hecho	Criterio o Factor de Conexión	Consecuencia Jurídica (Ley Aplicable)
Sucesión (Art. 955 CC).	Último domicilio del causante.	Se rige por la ley del Estado del último domicilio del causante.
Propiedad de los Bienes (Art. 16 CC).	Lugar de ubicación del bien.	Se rige por la ley del Estado en el que esté ubicado el bien.
Forma de un Instrumento Público (Art. 17 CC).	Lugar de otorgamiento.	Se rige por la ley del Estado donde se otorga.

- 3. Criterios o Factores de Conexión:** hay ciertos criterios o factores de conexión utilizados habitualmente en las normas de conflicto para conectar una situación jurídica con un hecho o situación jurídica:
- a. *Lex fori* (ley del Estado juzgador). Habitualmente las normas procesales tienden a ser normas de *lex fori*.
 - b. *Lex rei sitae* (ley del lugar de ubicación del bien). Habitualmente las normas que regulan los actos sobre los inmuebles son normas de *lex rei sitae*.
 - c. *Lex locus regit actum* (ley del lugar de celebración del acto). Habitualmente se utiliza para determinar la ley que rige un determinado acto (Art. 17 CC o el Art. 80 LMC).
 - d. Ley de la nacionalidad de las partes. El Art. 15 CC somete la capacidad de un chileno a la ley chilena para celebrar un acto cuyos efectos se produzcan en Chile.
 - e. Ley o tribunal elegido por las partes o autonomía de la voluntad. En un contrato internacional las partes pueden someterse a un tribunal en Nueva York.

- f. Ley del domicilio o residencia de una persona natural. Por ejemplo, el Art. 955 CC somete la sucesión al último domicilio del causante.
 - g. Ley del lugar de constitución gobierna a las personas jurídicas en algunos sistemas legales; en otros (principalmente europeos), ellas quedan gobernadas por la ley del Estado donde la persona jurídica tenga su establecimiento principal de los negocios. Por ejemplo, las sociedades suelen regularse por su lugar de constitución.
 - h. Ley del lugar de producción del daño gobierna la responsabilidad extracontractual surgida de un delito o cuasidelito civil en algunas legislaciones; otras prefieren la ley del lugar donde se realizó la acción que produjo el daño. Por ejemplo, si alguien viaja a Perú, arrienda un auto y tiene un accidente automovilístico (lugar donde se produce el daño). En el otro caso, podría ser que una empresa contamina aguas en Argentina y llueve lluvia ácida en Uruguay destruyendo bosques (lugar donde se produce la acción).
4. **Explicación:** las normas indirectas o atributivas son las normas clásicas del DIPRI de muchos Estados, pero existe hoy una tendencia a reemplazarlas, ya sea por normas materiales (en vez de indicar la ley aplicable, resuelvan directamente el problema en cuestión) o por normas indirectas internacionales uniformes para promover una unificación de las normas de DIPRI. Este movimiento de unificación y de armonización legislativa mundial pretende garantizar la certeza jurídica acerca de la ley estatal que rige los actos internacionales y ha cuajado en la celebración de tratados internacionales, en la proposición de Leyes Modelos en ciertas materias. El objetivo de este movimiento unificador y armonizador del DIPRI es que una situación jurídica determinada se resuelva igual y por la misma ley en cualquiera de los Estados vinculados con ella.
5. **Problemas:** las normas indirectas o atributivas suscitan ciertos problemas, tales como: (i) incerteza jurídica¹ y reenvío²; (ii) pueden no dar soluciones justas en ciertos casos³; (iii) pueden conducir a la aplicación de un derecho extranjero de difícil conocimiento y aplicación para el juez y las partes⁴; (iv) su aplicación puede verse limitada por el orden público del foro. Todas estas razones explican los motivos por los que, en ciertas materias, el legislador prefiere dictar normas materiales para resolver situaciones de DIPRI.

¹ Esto porque no se determina con precisión cuál es la regla aplicable.

² El reenvío consiste en una norma que manda a aplicar normas de un ordenamiento diverso. Por ejemplo, la aplicación del Art. 955 CC en una sucesión cuyo causante fallece en España y de nacionalidad estadounidense (procedente del Estado de Maryland). La norma chilena remite a la ley del último domicilio del causante (España), ésta dispone que la sucesión se regula por la ley de la última nacionalidad del causante (Estados Unidos / Maryland) y resulta que la ley de Maryland dispone que los bienes se regulan por el lugar donde se ubican (por ejemplo, asúmase que se ubican en Alemania). En este caso hay diversos factores de conexión: último domicilio (Chile); última nacionalidad (España); y ubicación de los bienes (Maryland). Podría incluso darse el caso de que la ley alemana reenvíe a la ley de la sucesión (chilena), en lo que se llama un reenvío circular. Hay casos en que se prohíbe al juez aceptar el reenvío (Perú); otros en que se prohíbe aceptar el reenvío, salvo que se reenvíe a una norma propia (España); y otros casos en que no se dice nada y, en consecuencia, el juez tiene libertad (Chile).

³ En alguna época hubo países que reconocían la adopción y otros que no la reconocían. En consecuencia, podría darse el caso de una sucesión que se regule por la ley de un país en que no se reconoce la adopción y, la voluntad del causante, era que sí fuese reconocido como heredero.

⁴ Por ejemplo, el caso de que un juez chileno deba aplicar las normas del derecho cherokee en Estados Unidos.

B.2. Normas Directas o Materiales o Sustantivas: son normas que otorgan una solución material o sustantiva al problema jurídico de DIPRI. Son lo contrario a las normas indirectas. Por ejemplo, el Art. 135 inc. 2 CC dispone que los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago, y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción.

Este tipo de normas genera mayor certeza jurídica que las normas indirectas, pero, pueden otorgar una solución que no sea justa en el ámbito internacional y/o que puede ser muy distinta a la que otorgan las normas de otros Estados.

En el Derecho Internacional Privado contemporáneo se ha dado una tendencia a dictar mayores normas sustantivas (especialmente iguales, para que las soluciones en todos los países sean semejantes). Esta uniformización se ha dado por los Tratados Internacionales (por ejemplo, la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías), Leyes Internacionales (por ejemplo, todas las leyes internacionales o reglamentos de la Unión Europea) y Leyes Modelos (por ejemplo, la Ley de Arbitraje Comercial Internacional) han comenzado a incluir también estas normas materiales para asegurar una solución uniforme a nivel internacional o regional, en ciertas materias específicas. Por ejemplo, Convención de Varsovia sobre transporte aéreo de 1929, con sus Protocolos adicionales suscritos en Montreal en 1975, de los que Chile es parte ratificante.

Además de normas materiales de origen nacional y convencional, han surgido otras normas materiales como producto de los usos y costumbres del comercio internacional (*lex mercatoria*).

B.3. Otros Tipos de Normas:

1. Normas **universales y otras territoriales**, según sea el ámbito de aplicación espacial que les fije el legislador.
 - a. Las normas universales se aplican a todas las situaciones jurídicas que gobiernan, sin perjuicio del lugar o territorio donde ocurran. Por ejemplo, el Art. 955 CC hace aplicable la ley del último domicilio del causante a toda sucesión, salvo algunas pocas excepciones legales y el Art. 15 CC somete el estado civil del Chileno, donde quiera que esté a la ley chilena.
 - b. Las normas de conflicto territoriales sólo rigen en un espacio territorial determinado. Por ejemplo, el Art. 18 inc. 1 CC que sólo se aplica en Chile, dispone que en los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas (también el caso del Art. 16 CC).
2. Normas **unilaterales o multilaterales**, dependiendo de si la norma se aplica sólo a situaciones gobernadas por la ley del foro o también a otras situaciones en el extranjero. Las normas unilaterales sólo regulan las situaciones en que debe aplicarse la ley del foro y no indican nada para los casos en que esa ley del foro no deba aplicarse (es un solo ángulo). Las normas de conflicto multilaterales establecen la ley aplicable para la situación jurídica en general, aunque ésta quede gobernada por una ley extranjera (son dos ángulos).

- a. Así, por ejemplo, conforme al Art. 16 inc. 1 CC, los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Este Art. 16 CC es una norma unilateral porque sólo determina la ley que rige a los bienes situados en Chile y no dispone acerca de la ley que gobierna los bienes ubicados en el extranjero (también está el caso del Art. 135 inc. 2 CC).
 - b. A su vez, el Art. 17 CC dispone que la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados; su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento. El Art. 17 CC es una norma multilateral porque somete a todos los instrumentos públicos, cualquiera sea el lugar donde se otorguen, a la ley del país en que hayan sido otorgados.
- 3. Existen **normas de conflicto de aplicación inmediata o normas de policía y normas dispositivas**.
 - a. Las normas de policía son normas imperativas en el ámbito internacional y no reemplazables por la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, que el juez nacional aplicará siempre con preeminencia a las normas del derecho extranjero designado por las normas de conflicto nacionales. Por ejemplo, el Art. 18 CC, dispone que en los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas.
 - b. Las normas de conflicto dispositivas son normas que las partes pueden desplazar y dejar sin efecto al elegir otra ley que gobierne su relación jurídica. Por ejemplo, el Art. 113 del Código de Comercio:
 - i. Todos los actos concernientes a la ejecución de los contratos celebrados en país extranjero y cumplidos en Chile, son regidos por la ley chilena, en conformidad a lo que se prescribe en el inciso final del artículo 16 del Código Civil.
 - ii. Así la entrega y pago, la moneda en que éste deba hacerse, las medidas de toda especie, los recibos y su forma, las responsabilidades que imponen la falta de cumplimiento o el cumplimiento imperfecto o tardío, y cualquiera otro acto relativo a la mera ejecución del contrato, deberán arreglarse a las disposiciones de las leyes de la República, a menos que los contratantes hubieren acordado otra cosa.

C. Algunos Ejercicios:

1. El Art. 135 inc. 2 CC dispone que los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago, y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción. Se trata de una norma directa o material, territorial, multilateral y de policía.
2. El Art. 80 de la LMC dispone que los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. Así, el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad con las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno, siempre que se trate de la unión entre

un hombre y una mujer. Se trata de una norma indirecta, universal, multilateral y de policía.
/ Sin embargo, podrá ser declarado nulo de conformidad a la ley chilena, el matrimonio celebrado en país extranjero que se haya contraído en contravención a lo dispuesto en los artículos 5º, 6º y 7º de esta ley. Se trata de una norma directa o material, territorial, unilateral y de policía (hay duda, ya que vale el acto mientras nadie se alegue o se constata de oficio).
/ Tampoco valdrá en Chile el matrimonio que se haya contraído en el extranjero sin el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes. Se trata de una norma directa o material, territorial, multilateral y de policía.

3. El Art. 18 CC dispone que en los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas. Se trata de una norma directa o material, territorial, multilateral y de policía.
4. El Art. 12 de la Ley 20.830 dispone que los acuerdos de unión civil o contratos equivalentes, no constitutivos de matrimonio, que regulen la vida afectiva en común de dos personas del mismo o de distinto sexo, sujetos a registro y celebrados válidamente en el extranjero, serán reconocidos en Chile, en conformidad con las siguientes reglas: Se trata de una norma material o directa, territorial, unilateral.
 - a. (1) Los requisitos de forma y fondo del acuerdo se regirán por la ley del país en que haya sido celebrado. Es una norma indirecta y universal.
 - b. (2) Sin embargo, podrá ser declarado nulo de conformidad a la ley chilena, el acuerdo celebrado en territorio extranjero que se haya contraído en contravención a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º y 9º de esta ley. Es una norma sustantiva, unilateral y territorial.
 - c. (3) Para que el acuerdo otorgado en país extranjero produzca efectos en Chile, deberá inscribirse en el Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil que establece el artículo 6º. Los efectos de este acuerdo, una vez inscrito conforme a lo señalado precedentemente, se arreglarán a las leyes chilenas, aunque los contrayentes sean extranjeros y no residan en el territorio nacional.
 - d. (4) La terminación del acuerdo y los efectos de la misma se someterán a la ley aplicable a su celebración.

D. Fuentes del Derecho Internacional Privado: las fuentes del derecho internacional privado tienen relevancia porque en él existen normas nacionales y normas internacionales.

1. Fuentes Directas:

a. Fuentes Directas Nacionales o Internas:

- i. **Leyes Nacionales:** en Chile, las normas de conflictos son escasas y generalmente unilaterales, por ello, dejan muchos vacíos legales. Hay normas de DIPRI en el Código Civil (Art. 14 al Art. 18), Código de Procedimiento Civil (normas de prueba y executur), Código de Comercio (contratos internacionales), Código Orgánico de Tribunales (legalización y apostilla), Ley de Matrimonio Civil, Ley que establece el Acuerdo de Unión Civil, Ley de Arbitraje Comercial Internacional, entre otros.
- ii. **Jurisprudencia Nacional:** es especialmente relevante en los países anglosajones. En Chile, es más importante que en otras áreas del derecho

porque la jurisprudencia ha resuelto muchas lagunas legales. En los países del *Common Law* hay recolecciones importantes de jurisprudencia, que sirven de base a los jueces para resolver asuntos de DIPRI. Por ejemplo, en EE.UU. (*Restatement Second o Conflict of Laws*) o en Reino Unido (*Dicey and Morris*). Así, el juez norteamericano usualmente aplica esa recopilación y, en caso de apartarse de ella, debe justificar.

iii. Costumbre Nacional.

Estas fuentes nacionales pueden ordenar o aplicar un derecho extranjero nacional o un derecho internacional, por ejemplo, la ley chilena puede ordenar aplicar la ley española a ciertas situaciones, o bien, ordenar aplicar un tratado internacional vigente en la materia.

b. Fuentes Directas Internacionales:

- i. Tratados Internacionales.
- ii. Leyes Internacionales (por ejemplo, en la Unión Europea).
- iii. Costumbre Internacional o *Lex Mercatoria*.
- iv. Jurisprudencia Internacional (emanada de tribunales internacionales de arbitraje y otros tribunales internacionales).
- v. Autonomía de la Voluntad de las Partes.
- vi. Principios de Derecho Internacional Privado (generalmente reconocidos).

2. Fuentes Indirectas:

- a. Doctrina de los autores nacionales y extranjeros.
- b. Leyes Modelos, enunciados de Principios de DIPRI, proyectos de Codificaciones y otros instrumentos redactados por académicos y organismos internacionales especializados, como el Instituto UNIDROIT o UNCITRAL o la CCI.

La conclusión es que para resolver los casos de derecho internacional privado hay que identificar el derecho aplicable aplicando las normas de conflicto internacional. Esta norma de conflicto nacional puede ordenar aplicar una ley interna extranjera o un tratado internacional o una ley internacional. Dentro de estas fuentes internacionales se desarrollan brevemente dos: la *lex mercatoria*, por su novedad y singularidad, y los tratados internacionales, por su importancia práctica.

D.1. Lex Mercatoria: son las costumbres y usos internacionales de carácter obligatorio y vinculante para las partes, que elaboran los operadores del comercio internacional y otros organismos internacionales no gubernamentales.

Son normas de derecho espontáneo que surgen preferentemente en el comercio internacional. Por eso se discute si son normas jurídicas, propiamente tales, ya que no son dictadas por ningún Parlamento Estatal y sólo resultan aplicables cuando son incorporadas por las partes en un contrato y/o cuando los jueces o árbitros estiman pertinente, por ser costumbres establecidas en un determinado ámbito del derecho.

Estas costumbres y usos internacionales han sido recopiladas en instrumentos elaborados por organismos privados y son de amplia aplicación en la contratación internacional. Este es el caso de los Incoterms y del *Brochure 600*.

La *lex mercatoria* se ha reconocido principalmente en el arbitraje internacional. Es de aplicación frecuente en los tribunales arbitrales de la Cámara de Comercio Internacional de París (CCIP), del Tribunal Londinense de Arbitraje, del Centro de Arbitraje del Banco Mundial, de la *American Association of Arbitration* (AAA) y del Instituto de Árbitros de G. Bretaña, entre otros. Su reconocimiento se ha visto facilitado en la práctica, por las Convenciones Internacionales que regulan el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.

Estos usos de *lex mercatoria* se aplican conjuntamente con ordenamientos estatales y, a veces, en lugar de ellos. Por ejemplo, el Art. 13 del Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional de París (Cámara de Comercio, que es la principal en el mundo) establece que el arbitraje se rige por las leyes elegidas por las partes. En ausencia de elección, el árbitro está facultado para elegir la ley aplicable al fondo y forma del arbitraje debiendo tomar en cuenta “los usos del comercio internacional.

Finalmente, algunos contenidos normativos de la *lex mercatoria*:

1. **Incoterms:** los *International Commercial Terms*, son un conjunto de siglas elaboradas por la CCIP que establecen reglas acerca de la entrega de bienes vendidos, de quien soporta los riesgos relativos a la mercadería, y quien está obligado al pago de los gastos de embalaje transporte, tasas de exportación, internación, desaduanamiento, y de las primas de seguros de esos bienes. Hay varias versiones de Incoterms: 1936 (con revisiones y actualizaciones en 1945, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010, y 2020). Actualmente están en vigor los incoterms 2020 (desde el 1 de enero de 2020), sin que ello signifique que los anteriores hayan dejado de poder usarse. Los Incoterms emanan de la ICC (International Chamber of Commerce). De ahí la necesidad de señalar en los contratos en los que se incorporen tanto el Incoterm como el año de la versión a que se refiere.

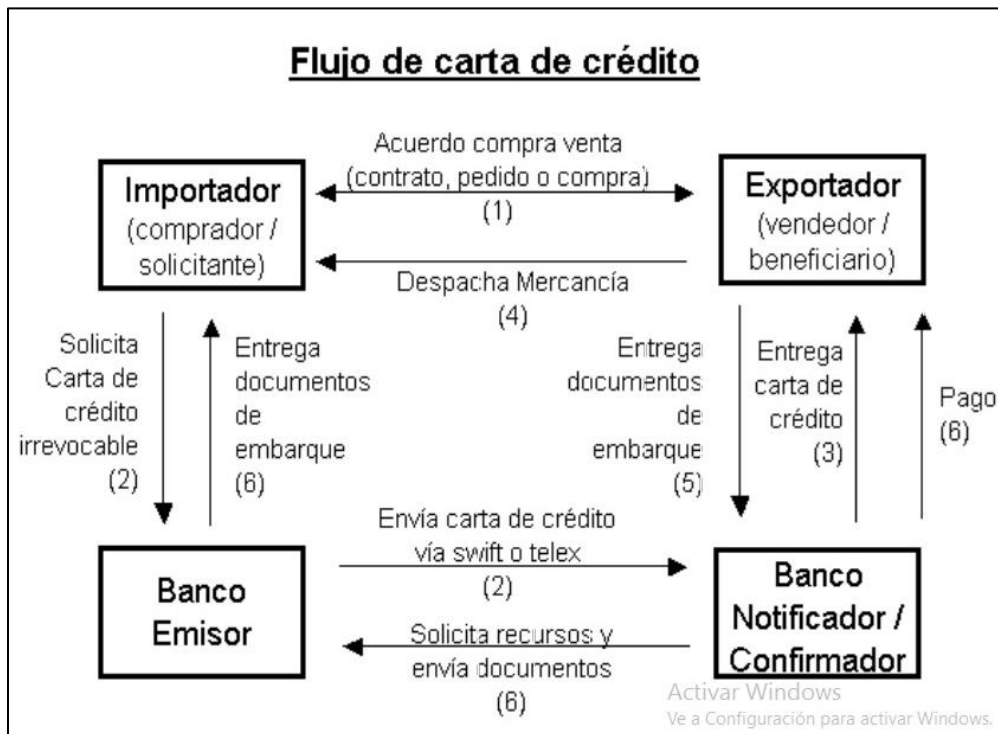
Algunos ejemplos de Incoterms:

- a. *Ex –Works* (franco fábrica).
- b. *FAS* (*free alongside ship*).
- c. *FOB* (*free on board*).
- d. *CFR* (*cost and freight*).
- e. *CIF* (*cost, insurance and freight*).
- f. *CPT* (*carriage paid to*).
- g. *DES* (*delivered ex-ship*).
- h. *DAF* (*delivered at frontier*).
- i. *DDP* (*delivered duty paid*).
- j. *CIP* (*carriage, insurance, freight paid to*).
- k. *DDU* (*delivered duty unpaid*).

Al contratar, las partes deben señalar la versión del Incoterms y el lugar de destino de las mercaderías. Ellas pueden también acordar variar los Incoterms parcialmente. Por ejemplo, en un contrato de compraventa internacional puede pactarse el precio de \$ 100 FOB Valparaíso, Incoterms 2010, o 100\$ DDP Valparaíso, Incoterms 2020. En el primer caso, el

vendedor está obligado a entregar las mercaderías a bordo del buque en Valparaíso y responde legalmente por su transporte, riesgos y pérdidas hasta esa entrega; él no debe pagar los gastos de descarga ni de desaduanamiento de la mercadería. En el segundo caso, el incoterms DDP le obliga a entregar la mercadería en Valparaíso asumiendo los costos de desaduanamiento y los riesgos de su daño o pérdida hasta la entrega. Aunque los Incoterms no están contenidos en las legislaciones nacionales, los jueces de todos los países del mundo los aplican y consideran vinculantes para las partes, por ello pueden considerarse *lex mercatoria* y fuente de normas de DIPRI.

2. **Cartas de Crédito Bancarias, Acreditivos Documentarios o *Letters of Credits*:** están regulados por los usos internacionales codificados por la Comisión Bancaria de la CCI Paris que ha elaborado “Las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios - UCP 600 de la ICC (International Chamber of Commerce, Paris), que en la industria son popularmente conocidas en conjunto como “el Brochure 600”. Estas Cartas son actualmente el medio de pago más usado en el Comercio Internacional porque dan seguridad al comprador de que recibirá la mercadería en buenas condiciones y al vendedor de que recibirá oportunamente su pago. Sin embargo, la regulación de estas Cartas de Crédito y de los derechos y obligaciones de todos los que intervienen en ellas (comprador, vendedor, banco otorgante, banco intermediario) no está regulada en las leyes o códigos nacionales sino en este Brochure 600.



3. **Principios Internacionales:** la CCI Paris también ha fijado ciertos principios internacionales que deben ser cumplidos en los contratos internacionales y que los jueces árbitros aplican habitualmente en el mundo. Estos principios pueden considerarse también parte de la *lex mercatoria*:

- a. Principio de obligación de colaboración de las partes para la ejecución de un contrato.
- b. Presunción de competencia internacional (las partes no pueden invocar desconocimiento de los compromisos contraídos en una operación comercial).
- c. Principio de interpretación útil de las cláusulas contractuales.
- d. Principio de actividad ante el incumplimiento, es decir, de minimización de las pérdidas para ambas partes.
- e. Obligación de secreto de las partes.
- f. Principio de legitimidad de la conducta de las partes apreciable de oficio.

D.2. Tratados Internacionales: los Tratados Internacionales son la fuente de mayor jerarquía en el DIPRI de muchos países. En consecuencia, sus disposiciones priman habitualmente, por sobre las de las normas nacionales de DIPRI. Los tratados internacionales de DIPRI se aplican a las relaciones jurídicas o actos celebrados entre los nacionales de los Estados partes o entre los domiciliados o residentes en esos Estados, como ley vigente en las materias que regulan. También excepcionalmente se pueden aplicar entre nacionales de o domiciliados en países signatarios no ratificantes, no como tratado vigente, sino como fuente de principios de Derecho Internacional Privado. Por ejemplo, la Corte Suprema ha declarado que el Código de Bustamante contiene verdaderos principios de DIPRI y puede aplicarse, en calidad de tal a situaciones de DIPRI entre partes de Estados no ratificantes del Código cuando no existe otra norma de DIPRI que regule el caso. En Chile y en la mayor parte de los países del mundo, los tratados internacionales se rigen por las normas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23-V-1969, ratificada por Chile el 9-IV-1981.

1. **Definición (Art. 2 N°1 A):** *“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.* Así, un tratado es un acuerdo internacional escrito celebrado entre Estados y gobernado por el derecho internacional, ya sea contenido en uno o más instrumentos y cualquiera sea su denominación. Esto significa que los tratados tienen que ser escritos, entre dos o más Estados o entre un Estado y un organismo internacional, quedan regidos por el derecho internacional y cualquiera que sea su denominación.
2. **Vigencia (Art. 24 / el Art 25 sobre vigencia provisoria en caso de acuerdo entre Estados):** en general, el Tratado entra en vigor, en la manera y fecha en que se haya acordado por las partes signatarias, o cuando haya sido ratificado por los Estados signatarios, o en la fecha en que un nuevo Estado ha accedido a él, respecto de ese nuevo Estado. Habitualmente, las condiciones de vigencia de un tratado se consignan en una cláusula de vigencia que suele incluirse entre las cláusulas finales del mismo. Por ejemplo, esta cláusula puede estipular una fecha concreta de entrada en vigencia, o puede disponer que entrará en vigor cuando un número mínimo de signatarios la hayan ratificado, o que regirá hechos ocurridos a partir de cierta fecha, entre otros. El Art. 24 dispone (*entry into force*):
 - a. *A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating States may agree.*
 - b. *Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be bound by the treaty has been established for all the negotiating States.*

- c. *When the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has come into force, the treaty enters into force for that State on that date, unless the treaty otherwise provides.*
 - d. *The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of the consent of States to be bound by the treaty, the manner or date of its entry into force, reservations, the functions of the depositary and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty apply from the time of the adoption of its text.*
- 3. **Reservas (Art. 2 N°1 D):** *“reservation” means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State.* Entonces, se entiende por “reserva” una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a un tratado, por la que se propone excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a dicho Estado. Es decir, las reservas son declaraciones unilaterales hechas por los Estados para excluir o modificar el efecto legal de ciertas cláusulas del Tratado a su respecto. Esas cláusulas entonces, no se aplican o se aplican modificadas a ese Estado. Entre el Art. 20 y el Art. 23 se regula el procedimiento y el alcance de una reserva, la que debe ser autorizada por el tratado o por las partes contratantes. Produce efectos respecto de la parte que la ha formulado y no respecto de otras partes al tratado. Las reservas pueden interponerse en los momentos que el Tratado establezca, si no dice nada, el Estado la puede interponer al momento de firmar o de ratificar o de aprobar o de acceder a ella. El Art. 54 CPR dispone que “el Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle. El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional”. Por ejemplo, Chile suscribió la Convención de Viena sobre compraventa de mercadería con una reserva relativa a que el contrato tiene que ser escrito (Argentina tiene la misma reserva). Para Chile un contrato oral no se rige por la Convención de Viena sobre contratación internacional de mercaderías.
- 4. **Incorporación de un Tratado al Derecho Interno Chileno:** de acuerdo con la CPR, todo Tratado debe ser aprobado por el Congreso después de su suscripción por el Presidente de la República o de su representante para adquirir vigor en Chile.
 - a. **Negociación, conclusión y firma a cargo del Presidente de la República o su representante:** el Art. 32 N°15 CPR dispone que son atribuciones especiales del Presidente de la República el conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el Art. 54 N°1 CPR.
 - b. **Aprobación por el Congreso de la República:** el Art. 54 N°1 CPR dispone que son atribuciones del Congreso aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de

un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda, en conformidad al artículo 66, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley. El Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle. El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional. Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el Presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria. Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional. Corresponde al Presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas Cámaras del Congreso, en el caso de tratados que hayan sido aprobados por éste. Una vez que la denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el tratado internacional, éste dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno. En el caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el Presidente de la República deberá informar de ello a éste dentro de los quince días de efectuada la denuncia o el retiro. El retiro de una reserva que haya formulado el Presidente de la República y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar un tratado, requerirá previo acuerdo de éste, de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva. El Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare dentro de este término, se tendrá por aprobado el retiro de la reserva. De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el tratado internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá el Congreso autorizar al Presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de aquél, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 64.

Una vez dictada y vigente la ley aprobatoria del Tratado, el Presidente de la República está facultado para ratificar el Tratado y enviar el instrumento de Ratificación, para su depósito, al Organismo encargado de custodiar el Tratado.

5. **Jerarquía Normativa de los Tratados:** en algunos países los tratados tienen igual jerarquía normativa que la ley interna (Brasil o EE.UU.), es decir tienen un valor legal. En otros, tienen una jerarquía mayor a la ley, es decir, tienen un valor supra-legal (Perú, México, Venezuela,

o Argentina). Algunos países tienen normas legales expresas para referirse a la jerarquía normativa de los Tratados y otros, como Chile, guardan silencio al respecto.

Por ejemplo, el Art. 2047 del Código Civil Peruano expresa claramente la jerarquía de las normas de DIPRI en ese país: “Normas aplicables: el derecho aplicable para regular relaciones jurídicas vinculadas con ordenamientos jurídicos extranjeros se determina de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Perú que sean pertinentes y, si estos no lo fueran, conforme a las normas del presente Libro. / Además son aplicables, supletoriamente, los principios y criterios consagrados por la doctrina del Derecho Internacional Privado”. Así, en Perú prevalecería las normas del tratado, luego las normas internas y, en su defecto, los principios generales.

Se ha discutido la jerarquía normativa de los tratados en Chile. En Chile, el tema se ha discutido porque no existen normas jurídicas que lo determinen expresamente. La Corte Suprema dictaminó en el pasado que, de acuerdo a la Constitución, eran verdaderas leyes y que, por tanto, están sometidos a las normas del Código Civil sobre derogación (Art. 52 y ss. CC), interpretación (Art. 19 y ss. CC) y su vulneración podía corregirse por medio del recurso de casación en el fondo. Esta opinión fue aceptada por parte de la doctrina nacional (F. Duncker, F. Albónico, S. Benadava, entre otros) y por la jurisprudencia de la Corte Suprema anterior a la ratificación chilena de la Convención de Viena (se discute que la ley interna, por ejemplo, pueda derogar un tratado internacional que, de hecho, se rige por el derecho internacional). Esta postura o solución se discute en la actualidad:

- a. Muchos autores sostienen que no tienen igual jerarquía que las leyes sino que son superiores a ellas. La opinión de la cátedra es que los tratados son infra-constitucionales y supra-legales (los tratados de derechos internacional privado, ya que, por ejemplo, aquellos que versan sobre Derechos Humanos son supra-constitucionales). Los fundamentos que se esgrimen para defender el valor suprallegal de los Tratados son:
 - i. El Art. 27 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados impide alegar la existencia de una norma interna para dejar incumplido un Tratado (Art. 27: el derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46).
 - ii. Hay que considerar que los tratados tienen una naturaleza normativa especial distinta de la de las leyes nacionales. Por ejemplo, tienen un origen supranacional; no son derogables pero sí denunciabiles por el Ejecutivo; no se les aplican las normas de nacionales de derogación e interpretación del CC, sino las especiales para los tratados, contenidas en el Tratado mismo o en las normas generales de la Convención de Viena, entre otros.
 - iii. La historia fidedigna de redacción de la Constitución (la tesis de suprallegalidad inspiró la Constitución de 1980).
 - iv. El incumplimiento de un tratado vulnera el Derecho Internacional y puede reclamarse frente a la Justicia Internacional.

- v. Además, hay normativas internas que le dan valor supralegal a los tratados (por ejemplo, el Art. 242 CPC en materia de execuátur).
- b. Otros autores sostienen que el tratado tiene igual valor que la ley porque la Constitución los somete al mismo trámite de una ley y refutan los argumentos anteriores sosteniendo que las disposiciones de la Convención de Viena son ley interna en Chile y que, por tanto, no pueden tener un valor supralegal, ni reconocer ese valor a los Tratados, en general.
- c. Existe consenso legal, doctrinal y jurisprudencial de que el tratado tiene una jerarquía inferior a la de la Constitución, excepto si se refiere a la protección de Derechos Humanos Fundamentales. Esto queda consagrado en nuestra Constitución Política, que señala expresamente que corresponde al Tribunal Constitucional controlar la constitucionalidad de los tratados y declararlos inaplicables. El Art. 93 de la CPR dispone que son atribuciones del Tribunal Constitucional:
 - i. (1) Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación.
 - ii. (3) Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso; de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación;
 - iii. (6) Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”.
- 6. **Vigencia de un Tratado:** para determinar la vigencia de un Tratado debe estudiarse la Cláusula de Vigencia incluida en el Tratado mismo para determinar cuándo y en qué condiciones o casos éste entra en vigor. Si el Tratado no incluye una cláusula de vigencia, se aplican las normas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para determinarla.

Para determinara su aplicabilidad a un caso concreto, también deben tenerse en cuentas las cláusulas de compatibilidad o incompatibilidad del Tratado con otros posteriores sobre el mismo asunto o materia.

La terminación anticipada de un tratado requiere de denuncia del Presidente de la República, previa la petición de opinión al Congreso. No cabe la derogación tácita de un Tratado por desuso o falta aplicación del mismo; sí por la entrada en vigor de otro Tratado sobre la misma materia en ciertos casos bajo el principio de *lex posterior derogat priori*.

- 7. **Conflicto entre Tratados y Ley Interna:** aquí hay dos criterios. Por una parte, en un conflicto entre la ley interna y un tratado nuevo, prevalece el tratado (por su carácter supralegal). Por otra parte, entre un tratado antiguo y una ley nueva, prevalece el tratado aunque la nueva ley contenga disposiciones contrarias (por su valor superior). Estas reglas no se aplican, como se verá, a la aplicación en Chile del Código de Bustamante ya que, por

excepción y debido a las reservas con las que Chile lo suscribió y ratificó, siempre prevalece la legislación interna chilena ante las normas de ese Código.

8. **Conflicto entre Tratados:** cuando hay multiplicidad de tratados aplicables, puede producirse un conflicto entre Tratados; para resolverlo y determinar qué Tratado prima, hay que estudiar la cláusula de vigencia de esos tratados y su cláusula de compatibilidad. Si el tratado nuevo tiene una cláusula de compatibilidad con tratados antiguos de la misma materia, prevalece el tratado antiguo; si no tiene esta cláusula, prevalece el tratado más nuevo, por aplicación del principio *lex posterior derogat priori*. Además, para determinar la aplicación de cláusulas concretas de un Tratado deben estudiarse las reservas con las que los Estados partes los han suscrito porque ellas pueden limitar esa aplicación.

En resumen, en cualquier situación de DIPRI siempre hay que estudiar si existe algún Tratado Internacional que rija la materia, porque esa es la primera norma que aplicar. Si no existen Tratados, se aplican las demás normas de conflicto internas. Para saber si un tratado es aplicable a una situación de DIPRI determinada hay que estudiar si los sujetos privados o la situación jurídica tienen vínculos con un Estado parte de un Tratado que regula la materia, si este Tratado está vigente entre esos Estados o ha sido modificado por otro posterior, si el Tratado estaba en vigor en todos los Estados involucrados al momento de producirse los hechos que originan el problema jurídico discutido, y si alguno de los Estados relacionados con la situación jurídica ha suscrito o ratificado el Tratado con Reservas y esas reservas modifican la aplicación del Tratado a su respecto. Así, para cada caso de análisis de DIPRI, hay que determinar que los países en conflicto hayan suscrito o no un tratado; que ese tratado se encuentre vigente para los países en cuestión; que haya o no reservas; que el acto jurídico se haya celebrado antes del tratado y éste tenga una norma específica.

D.3. Ejercicio Práctico: se trata de un ejercicio o caso sobre la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York del 10 de Junio de 1958), cuyo articulado fue reproducido en clases y que entró en vigor el 07 de Junio de 1959.

1. ¿Por qué entro en vigor el 07 de Junio de 1959?

Alemania	10/06/1958 (firma).	30/06/1961 (ratifica).	28/09/1961 (entra en vigor).
Brasil		07/06/2002 (adhesión).	05/09/2002 (entra en vigor).
Canadá ⁵		12/05/1986 (adhesión).	10/08/1986 (entra en vigor).
Chile		04/09/1975.	03/12/1975 (entra en vigor).

2. ¿Se aplica esta Convención al reconocimiento en Chile de una sentencia arbitral brasilera de fecha 17-08-2002? Los Estados miembros de la OEA suscribieron la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional el 30/01/1995 que regula la misma materia respecto a laudos comerciales (esta convención no tiene ninguna cláusula que se refiera a otros tratados sobre la misma materia). Esta Convención está vigente en Chile desde el año 1976 y en Brasil desde el año 1995. Sin embargo, la Convención de Nueva York no

⁵ El Canadá declaró que aplicaría la Convención únicamente a las controversias derivadas de relaciones jurídicas, fueran o no contractuales, consideradas como mercantiles por el derecho interno del Canadá, excepto en el caso de la Provincia de Quebec, donde la ley no preveía esa limitación (reserva).

aplica al caso de una sentencia arbitral brasilera del 17/08/2002 en cuanto no había entrado en vigencia en dicho país.

3. ¿Cuál prima para determinar el reconocimiento en Chile de una sentencia arbitral comercial brasilera del año 2020? La Convención de Nueva York tiene cláusula de compatibilidad, mientras que la de 1995 no dice nada; por lo que se aplica la de 1995.

D.4. El Código de Bustamante: el Código de Bustamante se aprobó como un Anexo a la Convención de Derecho Internacional Privado de 20-II-1928, en la Sexta Conferencia Internacional Americana que se celebró en la Habana el año 1928 (D. Of. 25-IV-1934 y 14-V-1934). El Código de Bustamante es el tratado de derecho internacional privado más completo que existe hasta hoy en el mundo. Fue redactado por el profesor y experto cubano Don Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén. Es un código omnicompreensivo, que contiene:

1. Un título preliminar que regula los problemas generales del DIPRI: condición jurídica del extranjero, clasificación de las leyes, normas de orden público, calificación, respeto a los derechos adquiridos.
2. Libro I sobre las personas, bienes y modos de adquirir, obligaciones y contratos.
3. Libro II sobre derecho comercial internacional.
4. Libro III sobre derecho penal internacional.
5. Libro IV sobre derecho procesal internacional: extradición, exhortos, exequátur.

Este Código fue firmado por 20 países latinoamericanos y ratificado por 16 países por lo que tiene un ámbito de vigencia importante. En general, lo ratificaron la mayoría de los países latinoamericanos con excepción de los países de la Cuenca del Plata (Argentina, Paraguay y Uruguay) y Colombia, países que son parte de un conjunto de tratados que se llaman los tratados de Montevideo de 1889 y de 1940.

La Tabla de Estados Signatarios y Partes del Código de Bustamante:

Países Signatarios	Firma (mm/dd/yy)	RA/AC/AD	Depósito (mm/dd/yy)
Argentina	02/20/28	--/--/--	--/--/--
Bahamas (Commonwealth de las)	--/--/--	01/23/2017	01/23/2017 AD
Bolivia	02/20/28	01/20/32	03/09/32 RA
Brasil	02/20/28	06/25/29	08/03/29 RA
Chile	02/20/28	07/14/33	09/06/33 RA
Colombia	02/20/28	--/--/--	--/--/--
Costa Rica	02/20/28	02/04/30	02/27/30 RA
Cuba	02/20/28	03/28/28	04/20/28 RA
Ecuador	02/20/28	04/15/33	05/31/33 RA
El Salvador	02/20/28	09/25/31	11/16/31 RA
Guatemala	02/20/28	09/09/29	11/09/29 RA
Haití	02/20/28	01/07/30	02/06/30 RA
Honduras	02/20/28	04/04/30	05/20/30 RA
México	02/20/28	--/--/--	--/--/--
Nicaragua	02/20/28	12/17/29	02/28/30 RA

Panamá	02/20/28	09/26/28	10/26/28 RA
Paraguay	02/20/28	--/--/--	--/--/--
Perú	02/20/28	01/08/29	08/19/29 RA
República Dominicana	02/20/28	02/04/29	03/12/29 RA
Uruguay	02/20/28	--/--/--	--/--/--
Venezuela (República Bolivariana de)	02/20/28	12/23/31	03/12/32 RA
D = Declaración / RA = Ratificación / AC = Aceptación / AD = Adhesión / R = Reserva			

Entre los países que lo han ratificado se encuentran Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y Bahamas.

Respecto a la vigencia en Chile del Código de Bustamante, el Código se aplica principalmente entre los Estados ratificantes. Además, la Corte Suprema y el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno han declarado, en su jurisprudencia, que el Código da cuenta de principios generales de derecho internacional privado, que deben aplicarse también respecto de otros Estados no ratificantes, en el caso de vacío legal. La Corte Suprema ha expresado que el Código contiene “verdaderos y definitivos principios de derecho internacional”.

Ahora bien, Chile formuló dos reservas al Código de Bustamante; la primera, la formuló la Delegación Chilena al momento de suscribirlo y la segunda, la formuló el Congreso, al momento de ratificarlo. Ambas reservas son indeterminadas y amplias y declaran inaplicables las normas del Código si contradicen la legislación nacional. Estas reservas generales han sido criticadas por la doctrina por ser contrarias al Art. 3 de del mismo Código de Bustamante y por dar primacía a la legislación interna chilena, por sobre las normas del Código.

1. Reserva de la delegación chilena formulada al momento de suscribir el Tratado: aprueba “salvando su voto en las materias que estime convenientes, en especial, en los puntos referentes a su política tradicional y a la legislación nacional”.
2. Reserva del Congreso chileno formulada el 10 de Mayo de 1932 al momento de discutir la aprobación del Tratado: aprueba la convención “con la reserva de formulada por los Delegados de Chile y además de que, ante el Derecho Chileno y con relación a los conflictos que se produzcan en la legislación chilena y ante alguna extranjera los preceptos de la legislación actual y futura de Chile prevalecerán sobre dicho Código en caso de desacuerdo entre unos y otros”. Es una reserva súper amplia y está diciendo que el Código de Bustamante se aplicará en Chile mientras no contravenga la legislación interna actual o futura.

En cuanto a la aplicación práctica del Código de Bustamante en Chile, producto de estas dos reservas, las normas del código tienen no tienen un valor suprallegal, como el resto de los Tratados, y por ello son de aplicación supletoria en Chile; específicamente, puede distinguirse entre su aplicación respecto de países ratificantes y no ratificantes.

Respecto de países ratificantes:

1. El Código se aplica primero cuando la ley chilena remite a la aplicación de tratados internacionales, por ejemplo, este es el caso del Art. 242 CPC que dice que las resoluciones

judiciales dictadas en un país extranjero tendrán la fuerza que le concedan los tratados respectivos. Así si la resolución judicial viene de Venezuela se aplica el Código de Bustamante, que es el único tratado internacional vigente con Venezuela respecto a la eficacia de resoluciones judiciales emanadas de tribunales extranjeros.

2. También cuando la legislación remite al derecho internacional como, por ejemplo, hace en el caso del domicilio político. El Art. 60 inc. 2 CC dice que “la constitución y efectos del domicilio político pertenecen al derecho internacional”.
3. También se aplica el Código de Bustamante cuando la legislación chilena remite a la aplicación de los principios del derecho internacional, esto sucede en el caso de la extradición (Art. 637 CPP).
4. También cuando regule una materia no contemplada en la legislación chilena actual o futura. Estos casos de aplicación supletoria ante el vacío legal son frecuentes en la legislación chilena de derecho internacional privado, por ejemplo:
 - a. El Art. 16 del CC dice que los bienes situados en Chile se rigen por la ley chilena pero no existe norma que regule los bienes que no están situados en Chile. Se aplicará entonces la norma del Código de Bustamante acerca de la ley que rige el derecho de propiedad de un bien.
 - b. Para resolver un conflicto de nacionalidad. En Chile, la Constitución establece quiénes tienen la nacionalidad chilena, pero no dispone nada -ni debe hacerlo- respecto de qué nacionalidad tienen los que no son chilenos. Tampoco existe en nuestra legislación interna ninguna norma que lo haga, por eso, se deben aplicar el Art. 9 al Art. 21 del Código de Bustamante para resolver un conflicto de nacionalidad.

Respecto de países no ratificantes, según las normas generales, no corresponde aplicar un tratado a un país que no lo ha ratificado; sin embargo, la Corte Suprema y el Ministerio de RR.EE. han sostenido uniformemente que el Código de Bustamante contiene verdaderos y definidos principios de derecho internacional. Por eso cuando nuestra legislación interna manda aplicar tratados internacionales y no hay tratados con ese país, o cuando manda aplicar el derecho internacional, o los principios de Derecho internacional; la Corte Suprema ha determinado que debe aplicarse el Código de Bustamante, aunque no como tratado vigente, sino como fuente de principios de derecho internacional privado.

III. Los factores de conexión en la legislación chilena.

Esto se relaciona con las normas atributivas o indirectas. Las legislaciones de derecho internacional privado suelen utilizar ciertos elementos o criterios para conectar una situación jurídica con una determinada legislación. A estos conectores se les llama factores de conexión, como, por ejemplo, los principios de *lex rei sitae* o *lex locus regit actum*. Es común que las legislaciones usen variados factores de conexión para resolver cuestiones determinadas pero, es también común, que opten por un factor principal que inspire su legislación de DIPRI (por ejemplo, la legislación italiana da preponderancia al factor nacionalidad por razones históricas).

1. **La Territorialidad:** el factor de conexión principal en la legislación chilena es el factor territorial. El criterio de territorialidad es el fundamental para resolver los conflictos de leyes en nuestra legislación, e inspira numerosas disposiciones del Código Civil. Este criterio está

consignado como un principio general de nuestra legislación en el Art. 14 CC (la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros).

Conforme a esta norma, la ley chilena rige todo lo que sucede en la República. Pero este principio tan general se puede interpretar *a contrario sensu*, esto es, que la ley chilena, en general, no se aplica fuera de los límites de la República o a los hechos que ocurran fuera de ella. Cuando, por excepción, la ley chilena persigue imponer sus normas más allá de los límites territoriales, sólo las limita a los efectos que los actos produzcan en Chile y a los nacionales que en ellos intervengan (Art. 15 CC.)

En cuanto al alcance de la norma del Art. 14 CC:

- a. Se aplica a todos los habitantes de la República. El término habitante incluye a toda persona que vive permanente o transitoriamente en el país, es decir a domiciliados, residentes o transeúntes.
 - b. Por República se entiende todo el territorio de Chile, es decir, legalmente se extiende al territorio físico de la República y a todo espacio sobre el cual Chile ejerce jurisdicción exclusiva, como el mar territorial, espacio aéreo exclusivo, naves y aeronaves de guerra y naves o aeronaves chilenas en alta mar o cielos internacionales. Todos los barcos y aeronaves están registrados en algún país y se rigen, cuando están en aguas o cielos de ese país o internacionales, por la ley del pabellón o del lugar de registro.
2. **La Nacionalidad:** el Art. 15 CC fija un estatuto personal restringido basado en la nacionalidad, que sigue al chileno aunque tenga residencia o domicilio en el extranjero en determinadas materias o cuando el efecto del acto se va a producir en Chile o cuando existe un cónyuge o pariente chileno. Este artículo dispone que la ley chilena se aplica al chileno fuera de Chile simplemente por ser chileno, es decir, si éste pierde la nacionalidad chilena deja de aplicarse. En el caso de quien tiene doble nacionalidad chilena y extranjera, para nuestra legislación, esa persona es exclusivamente chilena.
 - a. **Art. 15 CC:** a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. (1º) En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile; (2) En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos.
 - b. **Art. 998 CC:** en la sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio de la República, tendrán los chilenos a título de herencia o de alimentos, los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada de un chileno. / Los chilenos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero. / Esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un chileno que deja bienes en país extranjero.
3. **El Domicilio:** el domicilio es la base para resolver conflictos de leyes en materia sucesoria. El Art. 955 CC dispone que la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio; salvos los casos expresamente exceptuados (inc. 1). La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvas las excepciones legales (inc.

- 2). Las normas procesales consideran también al domicilio como elemento determinante de la competencia jurisdiccional de un tribunal.
4. **La Residencia:** de acuerdo a la legislación chilena, la residencia suple la falta del domicilio en muchos aspectos legales (cuando falta el *animus manendi* hay sólo residencia).
5. **La Situación de los Bienes:** el Art. 16 CC consagra un principio clásico del Derecho comparado, el principio *lex rei sitae*, que somete a los bienes -muebles e inmuebles- a la ley del lugar de su ubicación. El Art. 16 CC dispone que:
- a. Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile.
 - b. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño.
 - c. Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas.
6. **La Lugar de Celebración del Acto:** la legislación chilena recoge en diversas normas el principio *lex locus regit actum*, que es un principio generalmente aceptado en el Derecho Comparado.
- a. El Art. 17 CC lo consagra respecto de la forma de los instrumentos públicos. Esta norma dispone:
 - i. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento.
 - ii. La forma se refiere a las solemnidades externas, y la autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos se exprese.
 - b. El Art. 1027 CC lo consagra respecto del testamento escrito otorgado en país extranjero. La norma dispone que valdrá en Chile el testamento escrito, otorgado en país extranjero, si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria.
 - c. El Art. 80 LMC lo consagra respecto de los requisitos de forma y fondo del matrimonio celebrado en Chile y en el extranjero. La norma dispone que:
 - i. Los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. Así, el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad con las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno, siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer.
 - ii. Sin embargo, podrá ser declarado nulo de conformidad a la ley chilena, el matrimonio celebrado en país extranjero que se haya contraído en contravención a lo dispuesto en los artículos 5º, 6º y 7º de esta ley.
 - iii. Tampoco valdrá en Chile el matrimonio que se haya contraído en el extranjero sin el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes.
7. **Autonomía de la Voluntad:** el Art. 113 CCom autoriza a las partes de un contrato internacional para elegir la ley que regirá sus efectos. Lo mismo hace el Art. 1 del D.L. 2.349 de 1978 respecto de los contratos financieros celebrados por el Estado de Chile o sus

organismos y empresas y empresas internacionales que tengan el centro principal de sus negocios en el extranjero. Algunos agregan que esta misma autorización la daría el Art 16 inc. 2 del CC respecto de contratos civiles internacionales.

- a. **Art. 113 CCom:** todos los actos concernientes a la ejecución de los contratos celebrados en país extranjero y cumplidos en Chile, son regidos por la ley chilena, en conformidad a lo que se prescribe en el inciso final del artículo 16 del Código Civil. / Así la entrega y pago, la moneda en que éste deba hacerse, las medidas de toda especie, los recibos y su forma, las responsabilidades que imponen la falta de cumplimiento o el cumplimiento imperfecto o tardío, y cualquiera otro acto relativo a la mera ejecución del contrato, deberán arreglarse a las disposiciones de las leyes de la República, a menos que los contratantes hubieren acordado otra cosa.
- b. **Art. 1 DL 2.349:** declárense válidos los pactos destinados a sujetar al derecho extranjero los contratos internacionales, cuyo objeto principal diga relación con negocios u operaciones de carácter económico o financiero, celebrados o que se celebren por organismos, instituciones o empresas internacionales o extranjeras que tengan el centro principal de sus negocios en el extranjero, con el Estado de Chile o sus organismos, instituciones o empresas. / Son igualmente válidas las estipulaciones por las cuales se haya sometido o se sometan diferendos derivados de tales contratos a la jurisdicción de tribunales extranjeros, incluyendo tribunales arbitrales previstos en mecanismos de arbitraje preestablecidos o en el respectivo contrato, como también las estipulaciones por las que se haya fijado o se fije domicilio especial y se haya designado o se designe mandatario en el extranjero para los efectos del contrato. / Lo dispuesto en los incisos anteriores igualmente es aplicable a los actos y contratos por los cuales el Estado de Chile o sus organismos, instituciones y empresas, hayan otorgado u otorguen, en cualquier forma, su garantía a terceros en los contratos a que se refiere el inciso primero. / En virtud del sometimiento a la jurisdicción de un tribunal extranjero, cesará el derecho a invocar la inmunidad de jurisdicción, a menos de estipulación expresa en contrario.

A continuación algunos ejercicios sobre factores de conexión en la ley chilena:

(1.) En Arabia Saudita, donde rige la “Sharia” o ley Islámica se prohíbe el matrimonio de 2 personas amamantadas por la misma nodriza. Omar y Ranah se casan en Riad y posteriormente se trasladan a vivir a Chile. En Chile, Omar demanda la nulidad de su matrimonio argumentando que él y Ranah eran hermanos de leche. Ranah se defiende argumentando que este hecho no constituye un impedimento matrimonial en Chile. ¿Qué ley aplicarán los tribunales chilenos para decidir acerca de esta acción de nulidad matrimonial? Fundamente su respuesta legalmente.

1. Hechos:

- a. Matrimonio en Riad.
- b. Impedimento dirimente (hermanos de leche).
- c. En Chile se demanda nulidad.
- d. No es impedimento en Chile.

2. Problema Jurídico: ley aplicable a validez.

3. Norma Aplicable: Art. 80 LMC, rige la ley del lugar de celebración, esto es, la Sharia, por lo que hay impedimento dirimente.

(2.) Carlos Pérez es un chileno, pródigo interdicto, domiciliado en Santiago. Durante un viaje a Nueva York, vende su casa ubicada en Pucón a James McCain por un 50% de su valor comercial. Recibe el pago por medio de una transferencia bancaria hecha a una cuenta corriente en Nueva York. Los curadores de los bienes de Carlos Pérez solicitan, ante los tribunales chilenos, que la venta se declare nula y que se impida la inscripción de la propiedad a nombre de McCain. James McCain se defiende alegando la validez del contrato de compraventa, haber adquirido la casa de buena fe y haber pagado la totalidad del precio. ¿Qué ley o leyes aplicarán los tribunales chilenos para decidir este asunto? Fundamente su respuesta legalmente.

1. Hechos:

- a. Chileno domiciliado en Santiago y pródigo interdicto.
- b. Venta en Nueva York de casa en Pucón a norteamericano.
- c. Pago recibido en Nueva York.
- d. Comprador de buena fe.
- e. Demanda de nulidad por curadores en Chile.

2. Problema Jurídico: validez de la compraventa por incapacidad.

3. Norma Aplicable: Art. 15 N°1 CC, por lo que se aplica la regla de capacidad chilena respecto de actos que vayan a tener efectos en Chile, siendo nula la venta.

(3.) Carlos Pérez, chileno residente en Thiruvananthapuram (Kerala-India), otorga testamento escrito en idioma malabar en esa ciudad en el 2002. En el testamento lega sus bienes situados en Chile a su mujer india. Carlos muere en Thiruvananthapuram el año 2018.

1. Hechos:

- a. Chileno residente en India.
- b. Testamento otorgado por escrito en India.
- c. Lega bienes situados en Chile a su mujer india
- d. Muere en India.

2. ¿Conforme a la ley chilena qué ley determinará la validez formal del testamento de Carlos Pérez? Aplica el Art. 1027 CC, por lo que se siguen las solemnidades del país en que se otorgó (ley de Kerala).

3. Si se discute en Chile si su mujer es o no heredera ¿Qué ley regirá esta cuestión debatida? Fundamente su respuesta legalmente. Aplica el Art. 955 CC, esto es, la ley del último domicilio (ley de Kerala).

(4.) El arqueólogo submarino norteamericano Mark Schlessinger planea recuperar ciertos galeones españoles hundidos en el Siglo XVI en las inmediaciones de la Isla de Juan Fernández. Señale cuál será la ley aplicable para decidir la propiedad de los galeones encontrados. Fundamente su respuesta legalmente.

1. Hechos:

- a. Norteamericano.
- b. Recuperar galeones españoles.
- c. Ubicados en Juan Fernández.

2. Problema Jurídico: determinar quien será propietario de los galeones.

3. **Norma Aplicable:** aplica el Art. 16 CC en la medida de que los galeones se encuentren en mar territorial chileno, extendiéndose las normas del tesoro en el CC. Si los galeones estuvieran fuera del mar territorial chileno, no habría respuesta clara.

IV. Los problemas que suscita la aplicación de la norma de conflicto.

A. Aspectos Generales: las normas atributivas utilizaban un elemento para conectar la situación jurídica con la norma relevante (último domicilio para conectar la sucesión con la ley aplicable). En un caso internacional, el juez tiene que resolver varios problemas: (i) si tiene jurisdicción para conocerlo; (ii) determinar la naturaleza jurídica del problema en cuestión para poder determinar la norma de conflicto a aplicar; y (iii) seleccionar la legislación aplicable al asunto conforme a las normas de conflicto pertinentes y aplicarla.

B. Calificación: calificar es definir, determinar la naturaleza o categoría jurídica de un hecho. Todos los sistemas legales clasifican los problemas jurídicos en grandes categorías; tales como cuestiones de estado y capacidad, cuestiones sucesorias, cuestiones de procedimiento, cuestiones contractuales, cuestiones extra-contractuales, cuestiones de familia, cuestiones de propiedad, entre otros, y someten esas cuestiones a distintas normas de conflicto que designan diferentes leyes aplicables para ellas. Algunos casos son:

1. Por ejemplo, las minas en Chile son inmuebles por adherencia y, por tanto, se les aplica la ley relativa a los inmuebles; pero en Rusia se entiende que son muebles y, por tanto, se rigen por las normas establecidas para los muebles. De ahí que el juez deba calificar qué naturaleza jurídica asigna la ley aplicable al hecho en cuestión para poder determinar quién es, por ejemplo, el dueño de la mina.
2. La copropiedad o el tiempo compartido. De acuerdo a la legislación de varios Estados de Estados Unidos, el tiempo compartido tiene naturaleza contractual, pero en la legislación española se lo califica como un tipo de propiedad y, por lo tanto, se le aplican las normas referidas al derecho real de propiedad. Entonces, el juez tiene que calificar la naturaleza jurídica del asunto para, según eso, ver cuál es el factor de conexión que se aplica porque los bienes se rigen por la ley del lugar de ubicación y, en cambio, el derecho contractual se rige por la ley elegida por las partes.
3. La aceptación de la donación es considerada por algunas legislaciones como requisito formal y sometida a la ley del lugar de celebración del acto y, por otras, como requisito de validez de la misma, y sometido a la ley del domicilio del donante o a otra.

La calificación de un mismo hecho puede variar desde un país a otro, lo que influye en la ley que lo puede regir. En DIPRI no es fácil calificar, porque pueden haber dos calificaciones distintas de una misma cosa. El juez para poder determinar cuál es la ley aplicable deberá calificar (es decir, determinar “esta es materia sucesoria”, “esto es materia contractual”, “o “esto es materia de derechos reales”).

Existen algunas normas de conflicto que dan ellas mismas una calificación (calificaciones autónomas), pero son pocas; habitualmente utilizan conceptos indeterminados que el juez deberá calificar para resolver el caso de DIPRI. Todo tribunal debe calificar, a veces, hacerlo es fácil, pero en ocasiones, la calificación se dificulta porque se trata de una situación no clara o porque la

legislación extranjera califica de modo distinto un asunto (conflicto de calificación), por ejemplo, cuando un asunto es considerado sucesorio por una legislación y matrimonial por otra.

Existen diversas razones por las que se hace necesario calificar:

1. La institución jurídica podría no estar regulada en el derecho del juez (caso del *trust* anglosajón); el juez debe a veces buscar una institución similar para aplicarle sus normas.
2. Puede ser necesario definir el mismo factor de conexión. Por ejemplo, Jean Der Meer, holandés, pasa cada año sus vacaciones en España y tiene ahí su casa de veraneo. Durante el verano de 1988, ejercita ante los tribunales españoles una acción de divorcio en contra de su mujer Claire, belga. Según la legislación española, el divorcio se rige por la ley nacional común de los cónyuges al tiempo de la presentación de la demanda y, en defecto de esta circunstancia, por la ley de la residencia habitual de los cónyuges (Art. 107.1 CC Español). Estos mismos criterios determinan la competencia jurisdiccional del juez. ¿Tienen los cónyuges residencia habitual en España? Si la tienen, se aplica al divorcio. El juez determinó que tener casa de veraneo no le daba competencia para resolver, sino que debía ser resuelto donde realmente tenían residencia. Para aplicar esta norma, debe determinar qué entiende esta ley por domicilio y verificar si éste existe o no.
3. Puede ser necesario definir el mismo derecho extranjero a aplicar en base a sus propias calificaciones. Este caso puede darse cuando es necesario aplicar la ley de un Estado Federal en que cada Estado miembro tiene su propia ley, entonces el juez debe aplicar las normas de conflicto internas del Estado Federal en cuestión para determinar qué ley estatal debe aplicar (las normas de conflicto interestatales están normalmente en las Constituciones y Códigos Federales, por ejemplo, en la Constitución norteamericana o el Código Civil Federal de México).
4. Las partes pueden haber elaborado su propia calificación en un contrato internacional, la cual debe ser aplicada por el juez. Por ejemplo, pueden pactar que para los efectos de este contrato se entiende por lugar de ejecución el lugar donde debe efectuarse el pago (por ejemplo, mora anticipada, es una mora distinta a la que plantea el CC).

Es posible referir a un caso clásico; el caso maltés *Anton vs. Bartholo* resuelto por la Corte de Apelaciones de Algeria (24/12/1889, JDI, 1891 p. 1171). François Bartholo y Marie Aquilina se casan en la isla de Malta el 9 de Mayo de 1839 y luego se trasladan a vivir a Algeria donde el marido compra tierras (en Blida). Después de algunos años el marido fallece y llega el momento de abrir su sucesión y la viuda reclama el usufructo de la “cuarta del cónyuge pobre”. Las normas de conflicto de Algeria, donde regía la ley francesa, y de Malta, donde regía la ley inglesa, eran iguales: (i) los derechos sucesorios sobre inmuebles eran gobernados por la ley del lugar de su ubicación; y (ii) los derechos matrimoniales por la ley del domicilio de los contrayentes al momento de contraer matrimonio (Malta, donde estaba vigente el Código de Rohan).

De acuerdo al Art. 17 del Código de Rohan, vigente en Malta, a la muerte del esposo la viuda sin hijos heredaba la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio y, en el caso que fuere pobre, le correspondía además el usufructo de la cuarta parte de los bienes del marido (cuarta del cónyuge pobre). Por ello la viuda reclamó ante los tribunales de Algeria esta cuarta del cónyuge pobre. Este

Art. 17 estaba ubicado en el Libro II, capítulo 1° dentro del título del Matrimonio y de la Sociedad Conyugal.

La institución de la cuarta del cónyuge pobre no existía en el derecho francés, de ahí que la Corte debió determinar si el asunto debatido era de naturaleza sucesoria (porque si lo era debía aplicarse la ley de Francia en cuyo caso no habría derecho) o pertenecía al régimen patrimonial matrimonial (porque si lo era debiera aplicarse la ley maltesa y sí habría derecho). Tenía dos alternativas, aplicar la calificación de la *lex fori* -ley francesa- o la de la *lex causae* o ley que originó el asunto -ley maltesa-. La Corte aplicó la segunda y decidió que era una institución del régimen matrimonial puesto que así la consideraba el Código de Rohan. Así determinó que se regía por la ley maltesa y que, en consecuencia, debía reconocerse a la viuda su derecho de usufructo sobre esa cuarta.

Habían dos normas sucesorias iguales, había que determinar si la cuarta del cónyuge pobre se podía calificar como institución sucesoria o se debía calificar como una institución perteneciente al régimen matrimonial patrimonial. Si se aplicaba la ley de Algeria, sucesorio, no dando la cuarta; pero si se rige por la ley que reguló el asunto, estaba incluida dentro del matrimonio, siendo una institución matrimonial, debiendo aplicarla porque la ley francesa sometía la ley del matrimonio al lugar donde se celebró. Habían dos leyes: la del foro o la que suscitó la situación. Dependiendo de cual aplicaba, reconocía el usufructo o no.

Luego, hay que referir a los diversos criterios para calificar:

1. **Aplicar *Lex Fori*:** en principio, una primera posibilidad que tiene el juez es calificar según los criterios de la *lex fori* (*ley del Estado juzgador*). Por lo tanto, si el Estado juzgador es Chile y se presenta el asunto en Chile, el juez chileno va a calificar de acuerdo con la calificación que la ley chilena le dé al asunto. A veces no es adecuado para calificar una situación contenida en la ley extranjera. Hay situaciones en que la aplicación de este criterio no es adecuada para calificar un concepto contenido en una legislación extranjera y puede llevar a una solución injusta. Por ejemplo, al determinar si el consentimiento paterno exigido para el matrimonio de menores es un requisito formal o de validez de un acto que acarrea su nulidad. La doctrina establece como excepciones a la aplicación de la *lex fori* que la clasificación de los bienes debiera sujetarse a la ley del lugar de su ubicación, que la forma del testamento otorgado en el extranjero debiera someterse a la ley del lugar de otorgamiento y la calificación de situaciones y hechos hecha por las partes, que debiera someterse a su autonomía de la voluntad.
2. **Aplicar *Lex Causae*:** también puede calificarse de acuerdo a la *lex causae*, es decir, de acuerdo a la ley de fondo que originó el hecho en cuestión y lo gobierna.
3. **Aplicar la Doctrina Rabel:** otra posibilidad es calificar conforme a la doctrina de Rabel. Ernst Rabel propuso estudiar cada calificación caso a caso y aplicarle las soluciones que, en general, le da el derecho comparado. Por ejemplo, si en general el derecho comparado considera este asunto contractual, el asunto se califica como contractual. Esta doctrina tiene la ventaja de ser flexible pero la desventaja de mayor dificultad en su aplicación para el juez, exige un conocimiento de derecho comparado profundo.

Finalmente, en cuanto a la legislación chilena:

1. No hay una norma en Chile que determine el criterio para calificar.
2. En la jurisprudencia anterior al Código de Bustamante, la Corte Suprema determinó que había que aplicar como criterio de calificación el criterio de la *lex fori*.
3. El Art. 6 del Código de Bustamante establece que en todos los casos no previstos por este Código cada uno de los Estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o relaciones jurídicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados en el Art. 3, o sea, el Código se inclina por el criterio *lex fori*.
 - a. Respecto a los países ratificantes hay obligación de aplicar para la calificación el criterio de la *lex fori* a menos que haya que aplicar algún criterio especial previsto en el mismo Código.
 - b. En el caso de los países no ratificantes el juez chileno puede calificar conforme a *lex fori* al considerar el Código como fuente de un principio de Derecho internacional.

La doctrina más moderna hoy está dejando el concepto de calificación y comienza a hablar de la interpretación de los conceptos empleados por la norma de conflicto; vale decir, de que el juez debe intentar entender el alcance que el legislador dio a esos conceptos. En todo caso, igualmente persiste el problema de determinar la ley que servirá al juez para interpretar esos conceptos.

Por último, se incorpora una columna de Hernán Corral sobre “Ley que rige la sucesión: sobre la muerte en Miami de una figura de la TV chilena” (reenvío).

C. La Resolución de la Cuestión Previa o Incidental: al resolver una cuestión de DIPRI, el juez puede enfrentarse a una cuestión principal que debe resolver y, además a una cuestión preliminar, incidental o previa que debe resolver con anterioridad a fin de poder resolver la cuestión principal que se somete a su conocimiento. En este caso, se plantea la disyuntiva de aplicar a ambas cuestiones las normas de conflicto de la *lex fori*, o bien, separarlas y aplicar a la cuestión preliminar la norma de conflicto de la *lex causae*.

Los elementos que configuran la cuestión principal o preliminar son:

1. Que la cuestión principal, según la norma de DIPRI del juez, quede gobernada por una ley extranjera.
2. Que surja una cuestión previa o incidental y tenga también elementos internacionales.
3. Que la cuestión previa o incidental sea susceptible de planteamiento por separado en otro contexto y que esté regulada por normas de conflicto propias, distintas a las aplicables a la cuestión principal.
4. Que la norma de DIPRI de la *lex fori* para la cuestión previa y la norma de DIPRI de la ley aplicable a la cuestión principal, lleven a resolver la cuestión previa de modo distinto.

Por ejemplo, se discutió en Italia si la actriz sueca Ingrid Bergman tenía capacidad legal para casarse con el director de cine italiano Roberto Rosellini. Ingrid se había casado antes en Suecia con un director de cine sueco y divorciado en México, por poder, unos años después. Para poder resolver la cuestión principal, el juez italiano debía determinar antes si la legislación italiana reconocía la validez del divorcio mexicano. En el ejemplo anterior relativo a Ingrid Roberto, están los siguientes elementos:

1. La cuestión principal es la capacidad de Ingrid para casarse, la que, según la norma de DIPRI italiana, quedaba gobernada por la ley de su nacionalidad, la sueca.
2. La cuestión previa era determinar la validez del divorcio decretado en México, gobernada también, según la norma de DIPRI italiana, por la ley de su nacionalidad.
3. La determinación de la capacidad para casarse es una cuestión jurídica independiente y puede plantarse separadamente del problema de la validez del divorcio.
4. La norma de DIPRI italiana para determinar la capacidad para casarse mandaba aplicar la ley sueca, conforme a la ley sueca los divorciados tienen capacidad para casarse.

La norma de DIPRI italiana para determinar la validez del divorcio mandaba aplicar también la ley de la nacionalidad, es decir, la ley sueca, conforme a la cual ese divorcio express, realizado en México, era nulo. Es decir, los resultados de la aplicación de ambas leyes eran distintos. El juez italiano separó ambas cuestiones y aplicó a la cuestión previa su norma de DIPRI (*lex fori*) y declaró que no se podía reconocer en Italia el divorcio mexicano.

Los criterios de solución de la cuestión previa son:

1. **Aplicar la norma de conflicto de la *lex fori* para resolverla (ley del Estado juzgador).** Muchos autores consideran que la cuestión previa se puede resolver separadamente de la cuestión principal, aplicando la norma de conflicto de la *lex fori* que regula la materia, para mantener la coherencia de la misma ley.
2. **Aplicar la norma de conflicto de la *lex causae* (ley que rige el fondo del asunto).** Se argumenta que aplicar esta ley conduce a resultados más lógicos.
3. **Resolver cada caso en particular.** Se argumenta que deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso y los factores de hecho y de derecho envueltos en cada situación.

En Chile no existe norma que regule el criterio para resolver la cuestión previa, de modo que el juez queda en libertad de aplicar el criterio que le parezca más adecuado.

Es posible referir a un caso clásico; caso Schwebel con Ungar resuelto por la Corte de Suprema de Canadá el 21/12/1964). Un matrimonio judío -casado en Budapest en 1945- domiciliado en Hungría emigra a Israel. Durante el viaje en 1948, se divorcian extrajudicialmente (Gett) en Italia. Después de algunos años de vivir en Israel, la mujer viaja a Canadá a visitar a una prima y conoce a un canadiense, se casa con él y se queda a vivir en Canadá. El segundo marido demanda después en Canadá la nulidad de su matrimonio por bigamia de su cónyuge argumentando que el divorcio extrajudicial celebrado en Italia no era válido.

La cuestión principal aquí es determinar la capacidad de la mujer para contraer el segundo matrimonio y la cuestión previa, que debe decidirse como requisito para resolver la principal, es la determinación de la validez del divorcio extrajudicial. La ley húngara e italiana desconocían la validez de los divorcios extrajudiciales, mientras que la ley de Israel aceptaba su validez.

Según la norma de DIPRI canadiense, la capacidad para casarse quedaba regulada por la ley del domicilio de la mujer al momento del matrimonio, es decir, por la ley israelí ya que la mujer estaba domiciliada ahí cuando contrajo el segundo matrimonio. La ley de Israel la consideraba capaz para

casarse. La norma de DIPRI canadiense determinaba que la validez del divorcio quedaba regulada por la ley del domicilio del marido al momento de decretarse, es decir, por la ley húngara que lo declaraba nulo (aunque esto era discutible porque el marido, que había vivido en Israel, en un viaje a Hungría fue obligado a quedarse allí y a trabajar en campos de trabajo forzado). Según la norma de DIPRI israelí, la validez del divorcio se regía por la ley de la nacionalidad de la mujer al momento de decretarse, es decir, por la ley de Israel.

El juez debió decidir si para resolver la cuestión previa, acerca de la validez del divorcio, debía aplicar la norma de DIPRI canadiense relativa a la validez del divorcio, o la norma de DIPRI de Israel, país donde estaba domiciliada y del que era nacional la mujer al momento de casarse. Si aplicaba la norma de la *lex fori* (canadiense), debía aplicar la ley húngara y declarar el divorcio y el segundo matrimonio nulos; si aplicaba la norma de la *lex causae*, debía aplicar la ley israelí y declarar la validez del divorcio y del subsecuente matrimonio. La Corte de Apelaciones de Ontario y la Corte Suprema canadienses aplicaron la norma de DIPRI de la *lex causae* para decidir la cuestión previa, es decir, la ley israelita según la cual ese divorcio era válido y consecuentemente, también el segundo matrimonio.

Otro ejemplo consiste en que en 1943 murió en Argentina Miguel Grimaldi, italiano, con último domicilio en Italia. Él había adoptado en 1937 a Concepción Di Paola Grimaldi, domiciliada en Italia e italiana. A su muerte dejó un inmueble y una cuenta corriente en Argentina. Se planteó la controversia entre el Consejo Nacional de Educación argentino y la hija respecto a quién debía heredar esos bienes ya que conforme al derecho argentino la herencia de quien fallece sin herederos se considera mostrenca y pasa a la propiedad del Ministerio de Educación.

Según el Art. 3283 del CC Argentino, vigente entonces, la sucesión se regía por la ley del último domicilio del causante, en este caso, la ley italiana. En ese momento en Argentina no existía norma que autorizara o regulara la adopción. El derecho italiano somete la sucesión a la ley nacional del causante, es decir, a la ley italiana y la adopción a la ley nacional del adoptado.

Habían dos cuestiones a resolver: (i) la principal era la sucesoria; y (ii) la previa era la validez y consecuencias jurídicas de la adopción. La Corte de Apelaciones Argentina decidió aplicar la norma de DIPRI de la *lex causae* a la validez de la adopción (ley italiana) y reconoció el derecho de herencia de la hija adoptiva. Si la Corte hubiese aplicado a la adopción la norma de DIPRI de la *lex fori* (ley argentina) habría declarado que esa adopción no producía efectos jurídicos en Argentina y que la herencia era vacante o mostrenca y debía pasar a manos del Ministerio de Educación Argentino.

D. Dépeçage: el dépeçage, splitting o desmembramiento se produce cuando un asunto de derecho internacional privado está regulado por varias leyes distintas que regulan, cada una, un aspecto específico del acto (por ejemplo, capacidad, formalidades, fondo de un mismo contrato gobernado por distintas leyes, entre otros). Por ejemplo, los aspectos formales pueden ser gobernados por la ley del lugar de celebración del acto, los efectos del acto pueden ser gobernados por la ley del lugar de ejecución y la adquisición de derechos reales que el acto genera por la ley del lugar de ubicación de los inmuebles sobre los que se ejercen. Entonces, el acto puede quedar gobernado por estas varias leyes distintas, cada una regulando aspectos jurídicos distintos de él. El dépeçage es común en el

Derecho Internacional Privado y, por ello, para resolver un caso de DIPRI es necesario identificar las leyes que se aplican sus distintos aspectos.

Por ejemplo, se celebra un contrato de compraventa de un bien raíz ubicado en Chile en Buenos Aires. El vendedor es un argentino domiciliado en Mendoza y el comprador un uruguayo domiciliado en Montevideo (formalidades - lugar de celebración; capacidad - nacionalidad; efectos del contrato - Chile). Este contrato y sus efectos pueden quedar gobernados por varias leyes distintas, cada una de las cuales gobierna aspectos concretos: (i) ley que rige las formalidades del contrato; (ii) ley que rige la capacidad de las partes para celebrarlo; (iii) ley que rige los efectos del contrato (obligación de entregar la cosa vendida); (iv) ley que rige la transferencia de la propiedad del bien raíz; y (v) ley que rige los requisitos para el reconocimiento en Chile de la escritura pública argentina en la que consta el contrato.

Este dépeçage o desmembramiento, en general, puede tener tres orígenes:

1. **Legal:** es legal cuando la ley misma es la que desmiembra las legislaciones aplicables al fijar el ámbito restrictivo en el que ellas se aplican. Por ejemplo, los requisitos de forma y fondo del matrimonio se rigen por la ley del lugar de celebración y los efectos por la ley del domicilio de los contrayentes. Por ejemplo, el Art. 1027 CC dispone que valdrá en Chile el testamento escrito, otorgado en país extranjero, si por lo tocante a las solemnidades se hiciera constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria.
2. **Convencional:** es convencional cuando las partes acuerdan que ciertos aspectos de un acto o contrato queden regidos por ciertas leyes. Por ejemplo, las partes pueden acordar que la evaluación de los daños por incumplimiento de un contrato se haga conforme a una ley específica, distinta de la que gobierna el contrato en general. Por ejemplo, las partes pueden incluir en un contrato internacional una cláusula contractual que diga: “este contrato se regirá por la ley francesa; sin embargo, la ejecución de las garantías de este contrato se regirá por la ley del lugar donde estén ubicadas esas garantías”.
3. **Judicial:** es judicial cuando el juez es quien realiza el desmembramiento de los distintos aspectos del caso y aplica diversas leyes para resolverlo.

E. Reenvío: es posible partir con un caso clásico, el caso resuelto por la Corte de Casación francesa en 1882 *Administration des Domaines con Heritier Javier Forgo* (Cass. Civ., 24-VI-1878, D. 1879, I, 56 et Req., 22-II-1882, D., 1882, I, 301). Javier Forgo fue un hijo natural de padres bávaros y de nacionalidad bávara que se trasladó a vivir a la ciudad de Pau en Francia. Murió allí intestado, sin hijos y dejando una cuantiosa fortuna mobiliaria.

Conforme al derecho francés, quien muere sin herederos es heredado por el Estado y el órgano estatal correspondiente, la *Administration des Domaines*, solicitó la posesión efectiva de la herencia de Forgo. Unos parientes colaterales bávaros por el lado materno, los Ditchi, reclamaron la herencia pero la *Administration des Domaines* se defendió diciendo que, de acuerdo al Derecho francés, los colaterales no tienen derecho a herencia y que, por tanto, le correspondía heredar a ella.

Los Ditchi alegaron que éste era un caso de derecho internacional privado, porque Javier Forgo tenía nacionalidad bávara. Argumentaron también que la norma de conflicto francesa mandaba aplicar a la sucesión mobiliaria de un causante el Derecho de su último domicilio. Sostuvieron que, aunque Javier Forgo vivió toda su vida en Francia, nunca obtuvo el decreto que le autorizara a fijar su domicilio ahí, y que, por tanto, su domicilio de derecho estaba en Baviera; por ello, debía ser el derecho bávaro el que rigiera la sucesión.

La ley bávara somete la sucesión mobiliaria también a la ley del domicilio pero reconoce el derecho a herencia de los colaterales. El juez de primera instancia francés dio la razón a los Ditchi. Sin embargo la *Administration des Domaines* recurrió de casación en el fondo alegando que el juez francés había aplicado mal la ley. Argumentó que, si bien la ley francesa somete la sucesión a la ley del último domicilio de derecho del causante, es decir, a la ley bávara; la ley bávara, a su vez, ordena aplicar a la sucesión la ley del último domicilio de hecho del causante, es decir, la ley francesa. Así la ley bávara reenvía a la ley francesa. Esta tesis fue acogida por la Corte quien declaró heredero al fisco francés.

Entonces, hay reenvío cuando la norma indirecta de una legislación ordena aplicar una ley para regular un asunto de DIPRI y, a su vez, la norma indirecta de esa ley, ordena aplicar otra ley para regular ese asunto (concepto).

Existen diversos tipos de reenvío:

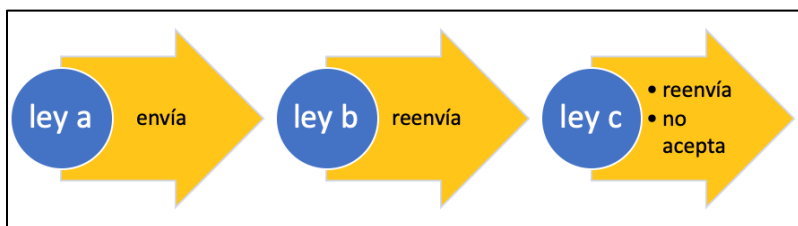
1. **Reenvío de Primer Grado o de Retorno:** se da cuando la legislación del país A ordena aplicar la legislación del país B y la legislación de B reenvía a la legislación de A quien acepta su competencia.



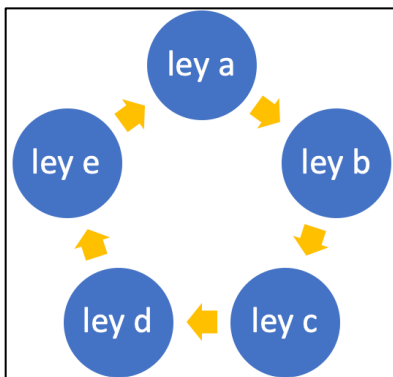
2. **Reenvío de Segundo Grado:** se da cuando la legislación de A ordena aplicar la legislación de B y B, a su vez, ordena aplicar la legislación del país C quien acepta su competencia porque su norma indirecta coincide con la del país B. Por ejemplo, la legislación española rechaza el reenvío a menos que éste reenvíe a la aplicación de la legislación española.



3. **Reenvíos Indefinidos o Perpetuos:** se da cuando una legislación manda aplicar una ley, la que, a su vez, manda a aplicar otra, la que, a su vez, manda a aplicar otra y así sucesivamente, sin que ninguna de ellas acepte su competencia porque sus normas indirectas son distintas.



4. **Reenvíos Circulares:** Se dan cuando la legislación enviada reenvía a la inicial que es la del foro.

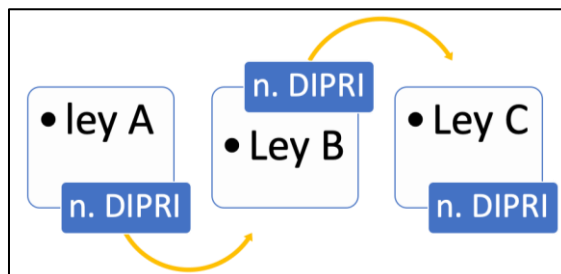


Los requisitos para que haya reenvío son:

1. Para que haya reenvío las legislaciones aplicables deben utilizar distintos factores de conexión para regir una misma situación. Por ejemplo, la legislación A rige la sucesión por la ley del último domicilio del causante y esta ley por la ley de ubicación de los bienes hereditarios.



2. Es necesario que la remisión se entienda hecha a la totalidad del derecho extranjero aplicable, es decir, tanto a sus normas sustantivas como a sus normas de conflicto. Si sólo se aplican las normas sustantivas de la ley enviada no hay reenvío. Por ejemplo, la ley A es chilena, tiene todo tipo de normas de fondo y dentro de la ley chilena hay normas de DIPRI. En el caso de la sucesión, la regla envíe a aplicar la ley del último domicilio (B). Si se considera que ese envío comprende la totalidad de la ley del último domicilio, inclusive sus normas de DIPRI, estas normas son las que generarán el reenvío a la ley C. Cuando se interpreta que la remisión que hace la norma de conflicto a otra ley, incluyendo las normas de DIPRI, estas últimas generarán el reenvío. Si se interpreta que la remisión se refiere sólo a las normas sustantivas de B, excluyendo sus normas de DIPRI, no habrá reenvío, porque esas normas de DIPRI producen el reenvío.



El reenvío produce ciertos problemas: (i) dificulta la identificación y aplicación del derecho extranjero; y (ii) genera incerteza jurídica.

Por lo mismo, la doctrina y las legislaciones difieren en cuanto a aceptarlo o no. Hoy existe un creciente consenso de que no debe aceptarse el reenvío en materia de ley aplicable a los contratos, porque es importante garantizar la certeza jurídica a las partes contratantes.

1. **Corrientes que aceptan el reenvío:** se dan muchos argumentos para aceptar el reenvío, de entre ellos pueden mencionarse dos.
 - a. El que expone que cuando la legislación nacional manda aplicar la ley extranjera, debe respetarse la integridad de esa legislación y aplicarla en su totalidad ya que si el legislador nacional quisiera que se aplicara sólo en parte, es decir, excluyendo sus normas de conflicto, lo diría expresamente; por ello debe acogerse el reenvío.
 - b. Por otra parte, se argumenta que si la legislación nacional envía a aplicar una ley extranjera y esta ley extranjera reenvía a aplicar otra ley no se debe ser más exigente

que la ley extranjera misma e insistir en aplicar sus normas sustantivas, en circunstancias que ella misma ordena aplicar las de otra legislación.

2. **Corrientes que rechazan el reenvío:** se dan también variados argumentos para rechazar el reenvío, entre ellos los siguientes cuatro.
 - a. La aceptación del reenvío genera incerteza jurídica y dificulta la determinación de la legislación aplicable a un problema de Derecho Internacional Privado.
 - b. No procede aplicar la norma indirecta de otra legislación para resolver un conflicto de ley que ya está resuelto por las normas de conflicto del foro, esto podría considerarse un menoscabo de la soberanía del Estado del foro.
 - c. Es perfectamente razonable distinguir entre las normas sustantivas y las de conflicto de la ley enviada y excluir estas últimas por tratarse de normas de diversa naturaleza jurídica.
 - d. El argumento de la “raqueta internacional” o “del gabinete de los espejos”: si no se impidiera al juez excluir las normas de conflicto de la legislación enviada, el juez jamás podría detenerse, ni siquiera en el reenvío de primer grado y no podría determinarse la solución jurídica al asunto.

En general, la tendencia actual en el derecho comparado es que las legislaciones internas se refieran al problema del reenvío rechazándolo o aceptándolo. También lo hacen ciertas convenciones internacionales. Por ejemplo:

1. Código Civil de Perú (Art. 2048): los jueces aplicaran únicamente el Derecho interno del Estado declarado competente por la norma peruana de Derecho Internacional Privado.
2. Código Civil de España (Art. 12.2): la remisión al Derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española.
3. El Art. 20 del Reglamento (CE) N°593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) establece (exclusión del reenvío): cuando el presente Reglamento establezca la aplicación de la ley de un país, se entenderá por tal las normas jurídicas materiales en vigor en ese país, con exclusión de las normas de Derecho internacional privado, salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa.

Por último, en cuanto a la legislación chilena y el reenvío, no existe norma en la legislación chilena que trate del reenvío. La jurisprudencia chilena aceptó el reenvío en un caso en virtud de una norma derogada que es el antiguo Art. 135 inc. 2 CC que ordenaba: “los que se hayan casado en país extranjero y pasaren a domiciliarse en Chile, se mirarán como separados de bienes, siempre que en conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron no haya habido entre ellos sociedad de bienes”.

Eso lleva al Caso Tschumi (C. Sup. 30-VI-1944, RDJ t. 42, sec. 1ª, p. 325). La Corte Suprema, para determinar el régimen matrimonial patrimonial de un matrimonio que se había casado en Alemania, aceptó el reenvío. La ley chilena en ese entonces (antiguo Art. 135 inc. 2 del CC) remitía la determinación del régimen matrimonial a la ley del lugar de celebración del matrimonio (Alemania) y el Art. 15 de la Ley de Introducción al Código Civil alemán sometía el régimen matrimonial a la ley de la nacionalidad del marido que, en este caso, era la suiza y, específicamente, la del Cantón de

Berna. Entonces, la Corte Suprema aceptó el reenvío de la ley alemana y aplicó la ley del Cantón de Berna para determinar el régimen matrimonial del matrimonio Tschumi.

Este caso es excepcional y aplicó una norma, hoy derogada. Por ello, de él no puede deducirse que exista un criterio jurisprudencial firme respecto a la aceptación del reenvío. En principio, los jueces chilenos son libres de aceptar el reenvío o no, puesto que no existe norma legal que lo autorice o prohíba. El Código de Bustamante tampoco contiene norma acerca del reenvío.

F. Ordenamientos Plurilegislativos: en algunos países el ordenamiento jurídico es plurilegislativo, es decir, comprende múltiples y distintos sistemas legales. Esto sucede, por ejemplo, en los Estados Federales y en otros Estados donde, por razones históricas, coexisten varios ordenamientos jurídicos, como en Gran Bretaña, Canadá o en los países de la Commonwealth. En estos países, la determinación de la ley aplicable requiere estudiar las normas de conflicto “interregionales o interestatales” que determinan la competencia de los distintos ordenamientos que subsisten en ese Estado. Esas normas de conflicto pueden estar contenidas en la legislación interna o en Convenios internacionales sobre materias específicas. Por eso, cada vez que sea necesario aplicar la ley de uno de estos Estados plurilegislativos habrá que resolver el conflicto de ley “interregional” para determinar cuál de todas las leyes de ese Estado corresponde aplicar.

G. Problemas Temporales en la Aplicación de la Norma de Conflicto:

1. Derogación de una norma de conflicto en reemplazo por una nueva: puede suceder que la norma de conflicto aplicable a una situación jurídica sea derogada y reemplazada por una nueva norma de conflicto que contenga un factor de conexión distinto a la norma primitiva. En este caso, es necesario determinar el ámbito de aplicación en el tiempo de ambas normas para determinar cuál debe aplicarse a la situación jurídica concreta. Los criterios para determinar la norma aplicable deberán buscarse en las normas transitorias dictadas por el legislador para la nueva ley. En esas normas transitorias, generalmente, se determina qué situaciones deben regirse por la ley nueva y cuáles por la antigua. En ausencia de normas transitorias, deberá recurrirse a la aplicación de las normas generales acerca de la aplicación de normas en el tiempo contenidas en la legislación del Estado de donde proceda la norma. Por ejemplo, si se trata de una norma de conflicto chilena debe aplicarse la “Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes” contenida en el apéndice del Código Civil.
2. Conflicto móvil: se produce el conflicto móvil cuando hay un cambio del hecho o circunstancia empleada por la norma de conflicto como factor de conexión (de tal modo que cambia la ley que rige una situación determinada). Por ejemplo, si el factor de conexión es nacionalidad y la persona cambia de nacionalidad, o el factor de conexión es el domicilio y la persona cambia de domicilio. Este conflicto se da cuando las normas usan factores de conexión mutables o, excepcionalmente, cuando se produce un cambio de soberanía territorial. Otro ejemplo, el Art. 998 CC garantiza a los herederos chilenos las asignaciones forzosas en la sucesión intestada; un causante fallece en Francia con último domicilio ahí el año 2000 y un hijo que se nacionaliza chileno el 2001, de manera que no podrá hacer prevalecer el Art. 998 CC en su favor, ya que no era chileno cuando se defirió la herencia. La legislación chilena no contiene normas para resolver estos conflictos. En general, se pueden señalar algunos criterios utilizados en el derecho comparado:

- a. Si el factor de conexión de la norma de conflicto es mutable pero determinado en el tiempo, se aplica la ley vigente en el momento establecido por el legislador. En esta situación, la norma de conflicto queda “congelada” en el tiempo. Por ejemplo, el Art. 9.8 CC español dispone que “la sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento.
- b. Si el factor de conexión mutable no está fijado en el tiempo por el legislador, se está en presencia de un conflicto móvil “stricto sensu” que debe resolverse. La legislación chilena no tiene criterios para ello y el juez tiene libertad para buscar una solución.
 - i. En este caso, alguna doctrina extranjera sostiene que igualmente puede interpretarse que la norma de conflicto fija la norma aplicable en un momento concreto, el de inicio de la situación jurídica; por ejemplo, la norma que rige la capacidad para celebrar un acto o su validez debe ser la vigente al momento de celebrar el contrato, al momento de celebrarse el matrimonio, al momento de testar o de interponerse la acción, la nacionalidad chilena debe tenerse al momento de celebrar el acto, entre otros.
 - ii. En el caso de los efectos jurídicos de un acto alguna doctrina sugiere que debieran diferenciarse los efectos inmediatos de los sucesivos en el tiempo. Los inmediatos o instantáneos, se regirían por la norma vigente al momento de celebrarse y los sucesivos por la nueva norma.
 - iii. Otra doctrina propone resolver el conflicto móvil usando las normas para la vigencia de la ley en el tiempo, aunque, muchas veces estas normas no dan criterios de solución para estos casos.

Existe un ejemplo jurisprudencial. En 1875 don Juan Zanelli adquirió unos terrenos en Mejillones cuando ese territorio formaba parte de Bolivia. En 1915, cuando éste formaba parte de Chile, se discutió ante los tribunales chilenos si don Juan Zanelli era o no propietario de esos terrenos. En teoría, el juez chileno debió aplicar el Art. 16 CC para resolver el caso (los bienes situados en Chile se rigen por las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile). Sin embargo, la Corte Suprema optó por no aplicar la ley chilena para resolver el caso, sino que aplicó la ley boliviana porque era la ley vigente al momento de adquisición del derecho real de dominio de los terrenos que, en ese entonces, estaban ubicados en Bolivia.

H. Algunos Ejercicios:

(1.) En 1985, un matrimonio brasileiro, sin hijos, legitima adoptivamente a un chileno de 15 años de edad domiciliado en Chile. En 1990 la familia traslada su domicilio a Francia. Poco después, el matrimonio fallece allí en un accidente automovilístico dejando bienes en Brasil y Argentina.

El hijo reclama ante los tribunales argentinos sus derechos sucesorios respecto de dos inmuebles situados en Buenos Aires, en su calidad de único heredero del matrimonio. Los hermanos del padre se hacen parte en la causa desconociendo los derechos sucesorios del hijo. Ellos alegan que el derecho brasileiro no aceptaba antes de 1991 la adopción plena o legitimación adoptiva de niños mayores de 7 años. Argumentan que la legitimación adoptiva debe regirse por la ley de la nacionalidad de los adoptantes (brasileira) porque así lo dispone el derecho francés que es el aplicable a la sucesión y que, por tanto esa legitimación es nula.

El hijo se defiende afirmando la validez de la adopción. Argumenta que si bien la sucesión se rige por la ley francesa, la legitimación adoptiva debe, conforme a la ley argentina (Ley 19.134), someterse a la ley del domicilio del adoptado al momento de la adopción, es decir, a la ley chilena, que la considera plenamente válida.

¿Cuál es el problema de Derecho Internacional Privado que el juez debe resolver en este caso y las posibles alternativas de solución? Aquí existe una cuestión previa, ya que hay dos problemas (determinar la validez de la adopción y, luego, la regulación sucesoria). Las posibilidades de resolución son dos: (i) aplicar la norma del foro, en este caso, la norma argentina que remite a la ley chilena, siendo válida la adopción; o (ii) aplicar la norma de conflicto de la ley que rige la cuestión principal, esto es, la norma francesa. La profesora aplicaría la norma del foro, es decir, la ley argentina, ya que ello permitiría al hijo ejercer sus derechos hereditarios, conforme a la intención de los padres.

(2.) Un norteamericano, ciudadano del Estado de Maryland, Mr. J.A. Lowenthal, muere en España donde tuvo su último domicilio. Buena parte de sus bienes inmuebles se hallan en Chile donde también residen sus descendientes que se han nacionalizado chilenos. Según el Art. 9.8 del Código Civil Español la sucesión por causa de muerte se rige por la ley nacional del causante al momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. La norma de conflicto del Estado de Maryland que rige la sucesión por causa de muerte, establece que las sucesiones relativas a inmuebles quedan sujetas a la ley donde tales inmuebles se encuentren. Los descendientes chilenos desean hacer valer sus derechos hereditarios sobre los bienes situados en Chile.

¿Dónde debe abrirse la sucesión? ¿Qué ley será la reguladora de esta sucesión? Fundamente su respuesta. Conforme al Art. 955 CC, la sucesión se abre en España y ella regirá tal sucesión, donde el causante tuvo su último domicilio. La ley española, a su vez, reenvía a la ley de Maryland (ley de la última nacionalidad), la que, a su vez, reenvía a la ley del lugar donde se ubican los inmuebles, esto es, en Chile. El juez chileno tiene dos opciones (ya que el reenvío es facultativo): (i) si acepta el reenvío, se aplica la ley chilena; o (ii) si no acepta el reenvío, se aplica la ley española.

(3.) En Septiembre de 1931, Dimitris Caraslanis y Marie Richarde se casaron en París ante un oficial de registro civil. Dimitris era griego y de religión ortodoxa. Su mujer francesa, demandó el divorcio en Francia. Dimitris alegó que el matrimonio era nulo por falta de la ceremonia religiosa ortodoxa requerida por la ley griega. Según Dimitris la ley francesa establecía que la validez sustancial del matrimonio quedaba gobernada por la ley de la nacionalidad de los contrayentes y, por ello, era aplicable la ley griega. La Corte de Apelaciones de París sostuvo que éste era un problema de validez formal y que de acuerdo a la ley francesa debía quedar gobernado por la ley del lugar de celebración del matrimonio. La Corte de Casación estableció que debía aplicarse la *lex fori* para determinar si la exigencia de matrimonio religioso se trataba de un requisito de forma o de fondo. ¿Qué problema se suscitó en este caso? ¿Qué otra alternativa de solución podría haber tenido el juez? Se discute la validez del matrimonio, para determinar la nulidad del matrimonio o la procedencia del divorcio. Esto tiene relevancia para eventuales obligaciones del marido (por ejemplo, pensión alimenticia en caso

de divorcio), además de posibilitar una eventual segunda nupcia (religión ortodoxa). Aquí existe un problema de calificación, ya que el juez puede calificar conforme: (i) la ley del foro, es decir, ley francesa, el matrimonio sería válido, ya que se trata de un requisito de forma; o (ii) la ley griega, siendo un requisito de fondo, apuntando a la nulidad. La Corte de Casación lo consideró válido porque calificó conforme a la ley francesa.

(4.) Juan Vásquez compra una grúa a la filial de Caterpillar en Curitiba, Brasil y la traslada a Lima para usarla en la construcción de una carretera. En Perú, los acreedores de uno de sus socios embargan la Grúa para cobrar sus créditos y se discute quién es su dueño. Indique qué ley aplicará el tribunal peruano para resolver el asunto. Aquí hay un conflicto móvil en virtud del cambio de ubicación de la grúa. Conforme al Art. 105 del Código de Bustamante, los bienes se rigen por la ley del lugar de situación. Así, el juez peruano, para resolver la tercería de dominio, no tiene que aplicar la ley peruana, sino la ley brasilera, ya que el bien se adquirió en Brasil, determinando si la grúa se compró por la sociedad (se puede embargar) o se compró individualmente por Juan Vásquez (debiendo aceptarse la tercería de dominio).

V. La naturaleza jurídica, aplicación y prueba del derecho extranjero.

A. Aspectos Generales: en doctrina, se ha discutido acerca de la naturaleza jurídica del derecho extranjero que la norma de conflicto del foro manda aplicar. Algunos autores piensan que el derecho extranjero tiene la calidad de verdadero derecho y otros que debe considerarse simplemente como un hecho del juicio porque no emana del legislador nacional. Estas dos posturas acarrearán consecuencias prácticas distintas: si el derecho extranjero se considera derecho, éste no debe probarse por las partes porque se presume conocido y puede ser aplicado por los jueces de oficio, además, su errónea aplicación puede corregirse por la vía de la casación en el fondo; si este derecho se considera meramente como un hecho, en cambio, éste debe ser probado por las partes en el juicio y el juez no puede aplicarlo de oficio ni corregir su errónea aplicación por medio de la casación en el fondo.

A.1. Teorías que consideran al derecho extranjero como un hecho (países anglosajones, en su mayoría): parte de la doctrina y de la jurisprudencia consideran que el derecho extranjero debe aplicarse como un hecho del juicio puesto que emana de un legislador extranjero sin soberanía en el país del foro.

- 1. Teoría de los *vested rights* (derechos adquiridos):** sus autores son *Joseph Beale* (Estadounidense-Harvard) y *Albert V. Dicey* (Inglés-Oxford y London School of Economics) y sostiene que cuando la legislación nacional manda aplicar el Derecho extranjero lo que manda aplicar no es el derecho extranjero propiamente tal, sino los derechos adquiridos conforme a esa legislación extranjera. Entonces, lo que está mandando la norma indirecta es a reconocer uno o varios hechos, y concretamente, los derechos adquiridos bajo el amparo de la legislación extranjera. Por lo tanto, de acuerdo a esta teoría el juez no aplica el derecho extranjero en sí y en cuanto tal, sino que se limita a reconocer la existencia de un derecho extranjero que ha generado ciertos derechos adquiridos. Por ello se sostiene que el juez del foro aplica sólo su propia ley y los hechos o derechos adquiridos bajo otra ley.
- 2. Teoría del uso jurídico:** es una teoría de *Werner Goldschmidt* (Argentino). Sostiene que, en realidad, cuando la norma indirecta manda aplicar Derecho extranjero lo que está mandando aplicar son los usos jurídicos vigentes en el país extranjero. Agrega que el juez nacional tiene

que aplicar la norma extranjera tal como se aplica en el país de origen, es decir, conforme a los usos jurídicos vigentes en ese país, ya que la norma de conflicto indirecta remite al estado real jurídico del país extranjero (que incluye sus usos, jurisprudencia, etc), estado que puede ser considerado un hecho internacional.

En cualquiera de las teorías de hecho que se acepte, se entiende que para que el juez pueda aplicar los derechos adquiridos o los usos jurídicos las partes tienen que alegarlos y probarlos. Y si no lo hacen, el juez no puede ni debe aplicarlos o reconocerlos.

A.2. Teorías que consideran al derecho extranjero como derecho (países codificados, en su mayoría): otra parte de la doctrina y jurisprudencia considera que el derecho extranjero es un verdadero derecho el cual puede entenderse o no incorporado a la legislación del foro.

1. Teorías de la incorporación: hay autores que sostienen que el derecho extranjero es un Derecho que se incorpora a la legislación nacional y que debe tratarse como una verdadera ley nacional. La teoría de la incorporación tiene dos variantes:

a. Incorporación sustantiva del Derecho extranjero en el Derecho nacional: quienes hablan de una incorporación sustantiva sostienen que el contenido de la norma extranjera se incorpora a la ley del foro (se “nacionaliza”) y pierde su carácter extranjero. En consecuencia debe interpretarse como cualquier otra norma de la ley del foro. Por ejemplo, si consideramos que la ley francesa se incorpora a la ley nacional, todas las normas francesas sobre sucesión van a pasar a formar parte del Derecho chileno y el juez las tendrá que aplicar igual que las normas chilenas.

b. Incorporación simplemente formal: sostiene que el Derecho extranjero es derecho, y conserva el sentido y el valor que le atribuye el sistema jurídico extranjero de origen. Por lo tanto, sigue siendo Derecho francés y debe ser interpretado de acuerdo a las normas francesas. El juez chileno tiene que aplicar el derecho extranjero, pero lo tiene que aplicar conforme a las normas de interpretación del Derecho al que pertenece, por lo tanto, no hay una “nacionalización” de la norma sino que se incorpora formalmente al derecho chileno aunque sigue siendo un Derecho extranjero.

2. Teoría del derecho extranjero: hay otros que dicen que es derecho, pero que hay que aplicarlo como un derecho extranjero porque no se incorpora al derecho nacional. Sostiene que el derecho extranjero es siempre derecho extranjero y se debe aplicar como lo señala el derecho extranjero en el que se origina. Esta postura se parece, en términos prácticos, a la teoría de la incorporación simplemente formal.

Otros autores, sin entrar en la discusión acerca de la naturaleza jurídica del derecho extranjero, consideran que el derecho extranjero es un **Hecho fuera de la Causa**, vale decir, es una norma que no tiene el mismo valor que el derecho nacional, pero que tampoco puede asimilarse a los hechos que se alegan en una causa. Sostienen así que el juez puede aplicar de oficio el derecho extranjero y que las partes pueden probarlo. Además, siempre el juez debe aplicarlo del mismo modo que lo aplicarían los jueces del país al que pertenece ese derecho.

A.3. Situación Chilena: no existe norma que determine la naturaleza jurídica del derecho extranjero y los autores están divididos acerca de este tema.

1. Hay autores que consideran que, como el Código Civil de Chile está inspirado en Savigny, el Derecho extranjero efectivamente es Derecho en Chile (Savigny considera que el Derecho extranjero es Derecho). Además, argumentan que el juez chileno, en ciertos casos, está obligado a aplicar de oficio el Derecho extranjero. Estos autores discuten si es Derecho incorporado o no incorporado al derecho nacional: (i) el profesor Duncker sostiene que el Derecho extranjero es Derecho y se incorpora al Derecho nacional; o (ii) el profesor Guzmán dice que no hay incorporación.
2. Sin embargo, hay otros autores que sostienen que en Chile el Derecho extranjero es un hecho y un hecho fuera de la causa. Los profesores Carlos y Gabriel Villarroel sostienen que la situación está clarificada por un tratado bilateral con Uruguay relativo a la aplicación e información del Derecho Extranjero, suscrito en Montevideo el 28/06/1984 (D. Oficial 21/10/1985), ya que este tratado sigue la teoría del uso jurídico de Goldschmidt. Según estos autores, este tratado zanjaría la discusión acerca de la naturaleza jurídica del Derecho extranjero en Chile no sólo respecto al Uruguay sino respecto a todo derecho extranjero estableciendo que en Chile el Derecho extranjero es un hecho que requiere de prueba.

La cátedra considera que este argumento no soluciona el debate porque el mismo texto de la convención no deja claro si el Derecho extranjero es un hecho o un derecho. La Convención simplemente dispone que los jueces estarán obligados a aplicar el Derecho extranjero tal como lo harán los organismos a cuyo ordenamiento pertenece. Este enunciado es aplicable tanto a la teoría de Goldschmidt como a la teoría de la incorporación simplemente formal del Derecho extranjero.

En Chile, el tema parece no estar decidido y la jurisprudencia ha sido vacilante hasta hoy (algunas veces lo ha considerado hecho y algunas veces lo ha considerado derecho), en ocasiones ha exigido la prueba del derecho extranjero y, en otras, lo ha aplicado de oficio.

Es indudable, en todo caso, que en Chile las partes siempre tienen la posibilidad de probar el contenido y alcance del Derecho extranjero con los medios de prueba que le permiten los Tratados y leyes vigentes. También es indudable que el juez lo puede aplicar de oficio. Por esto mismo, es importante que los abogados que tramitan causas de DIPRI siempre indiquen al juez el derecho extranjero aplicable y le faciliten su conocimiento y prueba. El Art. 408 del Código de Bustamante dispone expresamente que los jueces y tribunales de cada Estado contratante aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes de los demás sin perjuicio de los medios probatorios a que este capítulo se refiere.

B. Medios de Conocimiento y Prueba del Derecho Extranjero: existen diversos medios para probar la existencia, el contenido y el alcance del Derecho extranjero. Algunos pueden calificarse de gubernamentales, porque en ellos, interviene un ente gubernamental, y otros judiciales, porque ellos se ejercen en juicio.

1. Medios Gubernamentales:

- a. **Consulta Diplomática.** Existe la posibilidad que un Estado por vía diplomática consulte a otro acerca del contenido, sentido y alcance de su legislación y el que ese Estado responda por vía diplomática también.
- b. **Intercambio de Copias Autorizadas.** Los Estados intercambian o pueden solicitar el intercambio de copias auténticas de tratados y de legislación nacional entre sí.
- c. **Informes de Institutos Especializados.** Algunos Estados cuentan organismos nacionales dedicados a investigar acerca del Derecho extranjero. Por ejemplo, el instituto Max Planck de Derecho Privado con sede en Hamburgo, tiene el encargo del gobierno alemán de recopilar las publicaciones de Derecho Privado más relevantes en el mundo y tiene investigadores especializados en Sudamérica, Asia, etc. Por eso, cuando un tribunal alemán tiene que aplicar Derecho extranjero pide un informe al Max Planck respecto al contenido, sentido y alcance de ese derecho.

2. Medidas Judiciales:

- a. **Exhorto del Tribunal Nacional al Extranjero.** Las partes pueden solicitar al Tribunal chileno que envíe un exhorto a un país extranjero para que éste informe acerca del contenido, sentido y alcance de su derecho.
- b. **Informe de Peritos.** Solicitar informe de peritos a especialistas en ese derecho extranjero.
- c. **Copias Certificadas o Auténticas del Derecho Extranjero.** Es posible que las partes presenten copia certificada, apostillada o legalizada de las leyes extranjeras. Por ejemplo, si se quiere probar el contenido de la legislación francesa sucesoria se pueden presentar copias del Código Civil francés certificadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores francés o bien apostilladas.

C. Medios de Prueba del Derecho Extranjero en Chile: además de las medidas gubernamentales, las partes pueden usar las medidas judiciales que están a su alcance y que, en la práctica son las que se usan más comúnmente en Chile.

1. **Prueba de Peritos:** el Art. 411 N°2 CPC dispone que podrá también oírse el informe de peritos (2) sobre puntos de derecho referentes a alguna legislación extranjera. Es decir, el Código de Procedimiento Civil permite presentar un informe de peritos sobre puntos de derecho referentes a una legislación extranjera que deban acreditarse en un juicio en Chile. El perito puede ser cualquier persona que conozca en profundidad ese derecho. El Código de Bustamante en el Art. 409 dispone que la parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier Estado contratante en uno de los otros, o disienta de ella, podrá justificar su texto, vigencia y sentido, mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, que deberá presentarse debidamente legalizada. O sea, que un perito puede ser un abogado en ejercicio en Francia o un profesor de Derecho civil francés que explice cuál es el derecho francés y cómo la jurisprudencia interpreta esas normas.
2. **Prueba de Documentos:** esto no excluye la prueba documental como una copia certificada o legalizada, libros de autores o una sentencia dictada conforme a esa norma extranjera. Entonces esa sentencia prueba que la jurisprudencia aplica tal artículo de tal manera.

Por lo tanto, la legislación chilena permite el uso de cualquier medio de prueba. Además, Chile es parte de ciertos tratados internacionales que regulan la materia: el Código de Bustamante y la Convención Interamericana sobre Prueba e Información del Derecho Extranjero.

1. Código de Bustamante: regula la materia de la prueba del Derecho extranjero en entre el Art. 408 y el Art. 411 y dice, en resumen, lo siguiente:

- a. **Peritos (Art. 409):** la parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier Estado contratante en uno de los otros, o disienta de ella, podrá justificar su texto, vigencia y sentido, mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, que deberá presentarse debidamente legalizada.
- b. **Exhorto por Vía Diplomática (Art. 410):** a falta de prueba o si el juez o el tribunal por cualquier razón la estimaren insuficiente, podrán solicitar de oficio, antes de resolver, por la vía diplomática, que el Estado de cuya legislación se trate proporcione un informe sobre el texto, vigencia y sentido del derecho aplicable.

2. Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero⁶: esta convención señala medios de prueba idóneos para probar el Derecho extranjero.

a. **Normas Basales:**

- i. **Art. 2:** con arreglo a las disposiciones de esta Convención, las autoridades de cada uno de los Estados parte proporcionarán a las autoridades de los demás que lo solicitaren, los elementos probatorios o informes sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho.
- ii. **Art. 3:** la cooperación internacional en la materia de que trata esta Convención se prestará por cualquiera de los medios de prueba idóneos previstos, tanto por la ley del Estado requirente como por la del Estado requerido. / Serán considerados medios idóneos a los efectos de esta Convención, entre otros, los siguientes:
 - 1. La prueba documental, consistente en copias certificadas de textos legales con indicación de su vigencia, o precedentes judiciales.
 - 2. La prueba pericial, consistente en dictámenes de abogados o expertos en la materia.
 - 3. Los informes del Estado requerido sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos.

b. **En resumen:**

- i. **Prueba documental,** consistente en copias certificadas de textos legales con indicación de su vigencia, o precedentes judiciales.
 - ii. **Prueba pericial,** consistente en dictámenes de abogados o expertos en la materia.
 - iii. **Informes del Estado** requerido sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su Derecho sobre determinados aspectos.
- c. **Conclusión:** por lo tanto, en Chile es claro que a las partes pueden probar el contenido, alcance y vigencia del Derecho extranjero y que el juez puede también consultarlo, de oficio. Los autores han discutido qué pasa si no se llega a conocer el

⁶ Suscrita en Montevideo el 8 de mayo de 1979 y publicada en el Diario Oficial el 6-VI-1997.

Derecho extranjero por ser de difícil conocimiento o por otra causa. Algunos sostienen que: (i) el juez para resolver el problema podría aplicar el Derecho más semejante; o (ii) otros autores dicen que el juez estaría obligado a aplicar el Derecho del foro (*lex fori*).

D. Otros Problemas en relación con el Derecho Aplicable:

1. **Qué Derecho extranjero se debe aplicar.** Cuando la norma chilena remite a aplicar la ley extranjera, por ejemplo, la del último domicilio del causante (Art. 955 CC), ¿qué normas de esa ley deben aplicarse? ¿se aplica sólo la ley o se aplican las normas inferiores que pudieran estar vigentes en el país extranjero? En principio, cuando nuestra norma remite al Derecho extranjero está remitiendo a la totalidad del Derecho extranjero y, por lo tanto, incluye también las normas menores en jerarquía vigentes en el Derecho extranjero, por ejemplo, incluiría una ordenanza que sea vinculante en ese país extranjero.
2. **Qué pasa cuando se manda aplicar la ley de un país cuyo gobierno no ha sido reconocido por Chile.** Hay que distinguir entre un gobierno no reconocido y Estado no reconocido. En la gran mayoría de los casos en que este problema de gobierno no reconocido se ha presentado, los jueces han decidido aplicar el Derecho de ese Estado porque es un Derecho vigente en él, independientemente, de que haya sido dictado por un gobierno no reconocido. Distinto ha sido el caso de los Estados no reconocidos (por ejemplo, un país que no ha reconocido el Estado de Israel y que tiene que aplicar el Derecho de Israel). En principio, alguna parte de la jurisprudencia ha dicho que el Derecho de un Estado no reconocido no debe aplicarse; sin embargo, si es un Derecho vigente en un territorio determinado por un largo tiempo, debiera aplicarse, según la doctrina. Por ejemplo, por mucho tiempo los países occidentales no aplicaron el Derecho soviético porque no reconocieron la existencia de la Unión Soviética pero terminaron aplicándolo.
3. **Qué pasa cuando la ley extranjera es inconstitucional.**
 - a. **Inconstitucional conforme a la Constitución extranjera:** el juez tiene que ver a cargo de quién está el control constitucional en ese país. La respuesta depende del Sistema de control constitucional que exista en el país extranjero: tribunal superior o juez. Si está a cargo de un Tribunal especial, distinto de los jueces ordinarios, el juez chileno debe aplicar la norma porque también lo haría el juez ordinario del país de donde procede. Si está a cargo del juez ordinario del país de procedencia, le corresponde al juez chileno determinar si la aplica o no tal como lo puede hacer el juez extranjero.
 - b. **Inconstitucional conforme a la Constitución chilena:** el juez chileno no tiene el control de la constitucionalidad de las normas en Chile. Podría deducir un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional pero, en principio, el juez chileno aplicaría esa norma como aplica cualquier otra ley chilena contraria a la Constitución chilena.

E. Qué pasa con el Derecho Extranjero y el Recurso de Casación: ¿cabe presentar recurso de casación en el fondo por la errónea aplicación de la legislación extranjera? El Art. 767 CPC dispone que el recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen término al juicio o hacen imposible su

continuación, dictadas por Cortes de Apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas Cortes, siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia.

Si se considera que la norma extranjera tiene la naturaleza jurídica de un hecho; obviamente, no cabe interponer el recurso de casación en el fondo por su errónea aplicación porque el Art. 767 CPC exige que se haya pronunciado con infracción de ley. Si se considera, en cambio, que el derecho extranjero tiene la naturaleza jurídica de verdadero Derecho puede estudiarse la admisibilidad de este recurso. Es decir, hay quienes consideran inadmisible este recurso porque nunca puede interponerse por la errónea aplicación o evaluación de un hecho del juicio.

Sin embargo, hay autores que sostienen que sí es admisible el recurso de casación en el fondo por infracción del Derecho extranjero. Dentro de ellos hay dos corrientes de opinión:

1. Los que sostienen una admisibilidad amplia o directa. Sostienen que el Art. 767 CPC no distingue entre ley nacional y extranjera porque se aplica a sentencias que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo del fallo. Por lo tanto, como ese Art. 767 no distingue entre ley nacional y extranjera, sería admisible directamente el recurso de casación en el caso de que se aplique erróneamente la ley extranjera al dictar el fallo.
2. Los que sostienen una admisibilidad indirecta. Sostienen que no es admisible el recurso de casación por infracción de ley extranjera, porque el recurso de casación está establecido para proteger la correcta aplicación de la ley chilena. Entonces, directamente, no correspondería casar una sentencia que aplicó mal la ley extranjera. Sin embargo, este recurso puede ser admitido indirectamente, porque al aplicarse mal la ley extranjera se ha aplicado también erróneamente la norma de conflicto chilena que ordenaba su aplicación. Vale decir que, si la norma de conflicto chilena manda aplicar la ley del lugar de celebración del acto y el juez chileno aplicó mal esa ley -por ejemplo, porque aplicó normas derogadas- cabría casar la sentencia alegando que se aplicó mal la norma de conflicto chilena, que mandaba aplicar la ley extranjera. Entonces, el abogado que está redactando este escrito va a tener que argumentar, por ejemplo, que el Art. 955 CC fue mal aplicado porque ese artículo manda aplicar la ley del último domicilio del causante y esa ley del último domicilio dice no se aplicó o se aplicó erróneamente. Entonces deberá recalcarse que lo que se aplicó mal fue la norma chilena y por eso debe casarse la sentencia. Esto supone una admisibilidad indirecta del recurso de casación en el fondo por infracción de la ley extranjera. La Corte Suprema ha dado curso en ciertos casos al recurso de casación interpuesto por infracción de ley extranjera. Además, éste está especialmente previsto en el Código de Bustamante para los países partes. El Art. 412 CB dispone que en todo Estado contratante donde exista recurso de casación puede interponer respecto del Derecho extranjero en las mismas condiciones a cuando se puede respecto al Derecho nacional.

Respecto a la posible infracción de ley de la sentencia recurrida cabe preguntarse también:

1. ¿Procede el recurso si la sentencia recurrida dejó de aplicar las normas de un tratado ratificado por Chile? Sí cabe la casación respecto a la infracción de un tratado internacional vigente

sobre la materia, porque es indudable que los tratados ratificados por Chile son ley vigente en Chile respecto a los demás países partes en los que el tratado esté vigente.

2. ¿Procede el recurso si se infringe, no las normas de un tratado, sino que principios de derecho internacional privado? La jurisprudencia chilena ha denegado esta causal de casación por considerar que la infracción de Principios de DIPRI no constituye una infracción de ley.
3. ¿Procede el recurso si la sentencia recurrida dejó de aplicar una costumbre internacional? La jurisprudencia ha aceptado la procedencia del recurso de casación, si la sentencia se ha dictado con infracción de una costumbre mercantil internacional, cuando se cumplen los requisitos del Art. 4 CCom (las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad, y reiterados por un largo espacio de tiempo, que se apreciará prudencialmente por los juzgados de comercio). Podría darse el caso, de que la sentencia aplicara erróneamente un INCOTERM, por ejemplo.
4. ¿Procede el recurso si se infringe una cláusula del contrato internacional? En Chile, siempre se ha aceptado la casación en el fondo por infracción de la ley del contrato, esta es la opinión de Claro Solar, basada en el tenor del Art. 1545 del Código Civil, que dispone que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Esta opinión es refrendada por la historia fidedigna del Art. 767 CPC. Su redactor, José Bernardo Lira, inicialmente, sugirió que en el artículo se incluyera la frase “por infracción de ley expresa”, con la intención de excluir las cláusulas contractuales, pero esa mención se eliminó en el texto aprobado de la versión final del Código para aceptar que el recurso procediera por infracción de una cláusula contractual.

VI. Los límites a la aplicación del derecho extranjero.

A. Introducción: en todas las legislaciones del mundo existen límites a la aplicación del derecho extranjero, los que eximen al juez de la obligación de aplicarlo, a pesar de que la norma de conflicto nacional le ordene hacerlo. Estos límites son excepcionales y, por ello, el juez debe aplicarlos restrictivamente. Los límites a la aplicación del derecho extranjero reconocidos por la legislación chilena son: (i) la infracción del orden público nacional; (ii) el fraude a la ley nacional; y (iii) el cumplimiento de las normas de policía nacionales.

B. El Orden Público: esta limitación se aplica en todos los Estados cada vez que al aplicar el derecho extranjero en el foro, el juez compruebe que se vulneraría el orden público nacional. En este caso, el juez no está obligado a aplicar ese derecho y deberá declarar que no lo aplica por esta causal; además, en subsidio, deberá fallar el asunto conforme a su *lex fori*.

El problema que produce la aplicación del límite del orden público es definir qué es lo que es el orden público. Este concepto de orden público no es fácil de definir porque consiste, en general, en el conjunto de principios esenciales que inspiran el orden jurídico nacional. Estos principios fundamentales pueden ser cambiantes y localistas, porque dependen de cada país y situación histórica. Una formulación amplia del orden público, permite decir que él está constituido por el conjunto de valores, derechos, ideas morales, políticas, sociales y económicas que se consideran fundamentales para la conservación y desarrollo de un determinado Estado.

Por ejemplo, la ley chilena considera ciertos principios esenciales en su ordenamiento jurídico como: la diferenciación sexual para la existencia del matrimonio, el derecho del acreedor a cobrar sus créditos mientras no estén prescritos, el derecho del comprador a que se le entregue la cosa mientras ésta no se ha extinguido, el derecho de quien ha sufrido un daño para ser resarcido por quien lo ha dañado, la obligación de buena fe en la ejecución de un contrato, el derecho de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos, el derecho a adquirir, usar y gozar la propiedad privada, el derecho al debido proceso, el derecho a una nacionalidad, el derecho a ejercer jurisdicción sobre los habitantes de Chile, entre otros. Estos principios, que constituyen el orden público, a veces están contenidos en normas legales específicas; pero, otras veces, se encuentran inspirando nuestra legislación en ciertas materias, a pesar de no estar consagrados en normas específicas.

Resulta posible dar un caso hipotético. Podría ser el caso en que se discutiera el reconocimiento en Chile de una sentencia extranjera que ordena a la arrendataria de útero, domiciliada en Chile, abortar el niño que lleva en su vientre para cumplir una cláusula del contrato de arrendamiento que disponía que cualquiera de los dos progenitores biológicos podría, en cualquier momento, exigir el aborto del niño concebido. Imagínese que el padre biológico ha terminado su relación con la madre biológica y ha decidido hacer efectiva la cláusula con oposición de la arrendataria de útero, lo que lo ha llevado a solicitar al tribunal extranjero del lugar donde se celebró el contrato que se obligue a la mujer a cumplir su compromiso contractual, petición que ha sido aceptada por ese Tribunal extranjero. Si esa sentencia se trae a Chile para hacerse efectiva, la Corte Suprema podría rechazar su exequátur por oponerse al orden público nacional ya que, en Chile, nadie puede ser obligado a abortar el niño que lleva en su vientre.

Entonces el orden público es un límite a la aplicación del derecho extranjero que el juez puede esgrimir para dejar de aplicar una norma del derecho extranjero cada vez que esa norma atente contra principios esenciales de la organización moral, económica o social del propio Estado. En principio es el juez quien tiene que determinar si la norma es contraria al orden público nacional o no. Si el caso es muy claro el juez simplemente declarará en su sentencia que la norma extranjera no se aplica porque vulnera el orden público nacional, en otras situaciones menos claras, tendrá que argumentar más para aplicar este límite. En el caso de aplicar el límite, el juez deberá fallar conforme a la ley nacional.

En la legislación chilena solo hay referencias genéricas al orden público y al deber de respetarlo. No existe ninguna norma específica que prohíba aplicar el derecho extranjero en Chile por infringir el orden público nacional. Sin embargo, la jurisprudencia ha sido constante en aceptar al orden público como una limitación a la aplicación del derecho extranjero. Por ejemplo, en una sentencia al referirse al orden público, la Corte lo definió como el conjunto de disposiciones esenciales, establecidas por el legislador, en resguardo de los intereses de la colectividad. Otras legislaciones, como la peruana, la argentina, la francesa, etc. tienen normas específicas que disponen que las normas contrarias al orden público nacional, no se deben aplicar. El Código de Bustamante incluye la excepción de orden público en muchas disposiciones específicas, pero sin llegar a definirlo, reconociéndolo ampliamente.

Hay otros ejemplos de la aplicación de este límite:

1. El año 1964 la Corte Suprema chilena denegó la solicitud de exequátur de una sentencia alemana que quitaba la tuición de niños menores a su madre para dársela al padre porque en el juicio alemán no se había probado la conducta depravada de la madre, requisito legal que la legislación chilena exigía para despojarla de la tuición. La Corte declaró que esa sentencia alemana no era ejecutable en Chile porque era contraria al orden público chileno. En Chile está establecido legalmente que la madre tiene la tuición de los hijos menores de edad y también se establece que la madre tenía la tuición de los hijos menores de edad salvo que se le haya imputado conductas depravadas.
2. Un tribunal alemán denegó el exequátur a una sentencia suiza que ordenaba el pago de un crédito que estaba impago por más de 30 años porque la sentencia suiza consideró esos créditos imprescriptibles. El tribunal alemán argumentó que la prescripción de los créditos era un elemento esencial del ordenamiento jurídico alemán y de su orden público y, en el caso, en cuestión, se habían vencido todos los plazos dentro de los cuales esa obligación podría haberse hecho exigible en Alemania. Por lo tanto, si la ley suiza declaraba la imprescriptibilidad de los créditos esa imprescriptibilidad no era aplicable en Alemania porque vulneraba el orden público alemán.

Además, en casos específicos, la Corte Suprema ha declarado: (i) que todas las normas que rigen al Conservador de Bienes Raíces son de orden público, por lo tanto, no pueden obviarse por normas del derecho extranjero; y (ii) que las normas procesales que establecen garantías en resguardo del acreedor o del deudor son de orden público (por ejemplo, la posibilidad de embargar bienes, las tercerías, entre otros). La excepción de orden público es una excepción nacional, es decir, que el juez chileno está obligado a tutelar el orden público chileno y no el orden público de otro país extranjero.

C. El Fraude a la Ley: es posible comenzar con una caso histórico clásico, el *arrêt Bauffremont*, Corte de Casación Francesa, 18 de Marzo de 1878. Una princesa de nacionalidad Belga se casó con el príncipe francés Bauffremont y adquirió nacionalidad francesa por matrimonio. En 1874, la princesa Bauffremont obtuvo la sentencia de separación de cuerpos y de bienes de la Corte de París argumentando hábitos perversos del marido. Ella se trasladó a Sajonia en Alemania y se naturalizó allí el año 1875, luego, aprovechando que la legislación de Sajonia permitía convertir las sentencias de separación de sus nacionales obtenidas en países que no permitían el divorcio, en sentencia de divorcio Sajonas, obtuvo esa conversión y se casó con príncipe rumano Bibesko. Ambos volvieron inmediatamente a París y ahí el príncipe Bauffremont demanda ante los tribunales franceses para que se declare nulo el segundo matrimonio. La Corte de Casación declaró inválido este segundo matrimonio porque el cambio de domicilio y nacionalización de la Princesa se había realizado con el sólo objetivo de evadir la ley francesa. Cabe agregar, que la ley francesa regía la capacidad matrimonial por la ley de la nacionalidad del contrayente.

Así, los elementos del fraude a la ley son:

1. Generalmente hay un cambio de factor de conexión mutable (se puede cambiar la nacionalidad, el domicilio o la ubicación del bien mueble, por ejemplo).
2. Pero tiene que ser un cambio fraudulento, esto es, que se realice con intención de evadir la *lex fori* o la ley nacional que hubiera regido el asunto.
3. El fraude tiene que afectar la aplicación de la *lex fori*, es decir, dejarla incumplida.

4. Y, finalmente, no tiene que existir otro remedio para corregir o impedir los efectos del fraude. Por ejemplo, otro remedio es que exista una norma nacional que lo sancione o prohíba o que ese fraude pueda ser impedido por la vía del control del orden público.

En cuanto al tratamiento del fraude a la ley en la legislación chilena, ésta no tiene ninguna norma general que corrija o sancione el fraude a la ley, como tienen otras legislaciones. Tampoco el Código de Bustamante tiene alguna norma que lo haga. Sin embargo, la jurisprudencia chilena ha aplicado la excepción de fraude a la ley cuando se han cumplido sus requisitos de procedencia, en ciertos casos.

La única norma especial que sanciona el fraude a la ley en Chile es el Art. 83 inc. 4 LMC que declara inválidos en Chile los divorcios obtenidos en el extranjero que debieron ser decretados por los tribunales chilenos. La norma especifica cuándo se entiende que existe este fraude: tampoco se reconocerá valor a las sentencias obtenidas en fraude a la ley. Se entenderá que se ha actuado en fraude a la ley cuando el divorcio ha sido declarado bajo una jurisdicción distinta a la chilena, a pesar de que los cónyuges hubieren tenido domicilio en Chile durante cualquiera de los tres años anteriores a la sentencia que se pretende ejecutar, si ambos cónyuges aceptan que su convivencia ha cesado a lo menos ese lapso, o durante cualquiera de los cinco años anteriores a la sentencia, si discrepan acerca del plazo de cese de la convivencia. El acuerdo o la discrepancia entre los cónyuges podrá constar en la propia sentencia o ser alegado durante la tramitación del exequátur.

Existe otro ejemplo; hace años atrás hubo un estudiante chileno Licenciado en Derecho que fue a condenado a pena aflictiva, lo que le impedía poder jurar como abogado en Chile. Él se trasladó a Ecuador e hizo valer un Convenio bilateral entre Chile y Ecuador acerca del reconocimiento de títulos y grados universitarios. En base al Convenio él hizo reconocer su título de licenciado en Derecho en Ecuador y obtuvo ahí el título de abogado. Después volvió a Chile y pretendió hacer valer el mismo tratado bilateral para reconocer en Chile su título de abogado ecuatoriano. Todo lo que él hizo era legal pero, la Corte Suprema, estimó que no podía hacer uso de ese Convenio para obtener el reconocimiento de su título en Chile porque él había actuado con fraude a la ley chilena (su intención no fue ejercer como abogado en Ecuador sino, que evadir la exigencia de la ley chilena de no haber sido condenado a pena aflictiva). En este caso: (i) hubo un cambio de factor de conexión que fue el cambio de domicilio; (ii) lo hizo con intención de evadir la exigencia de la ley chilena (fraude); (iii) fraude que afectaba la *lex fori*; y (iv) no había otro remedio legal para dejar sin efecto los efectos de la actuación fraudulenta.

Finalmente, en cuanto a los efectos del fraude a la ley, el juez, en principio, cuando constata que se ha actuado con fraude a la ley, dejará sin aplicar la ley extranjera y desconocerá el valor de los actos o derechos que se han adquirido bajo su amparo, los cuales no habrían podido ejecutarse u adquirirse bajo su propia ley.

D. Las Normas de Policía: son normas concretas imperativas, es decir, inderogables por el juez y las partes, que remiten exclusiva e inflexiblemente al derecho nacional. En Estados Unidos se habla de *peremptory norms*. Estas normas deben aplicarse siempre. Por tanto, ellas excluyen, en el ámbito que regulan, la aplicación del derecho extranjero y también la autonomía de las partes. Cuando hay una norma de policía que regula un asunto, el juez tiene obligación de aplicarla y de dejar sin aplicar

la norma de conflicto que manda aplicar el derecho extranjero a esa cuestión. En principio, estas normas son excepcionales por lo que el juez las tiene que aplicar restrictivamente.

Por ejemplo, el Art. 955 CC somete la sucesión a la ley del último domicilio del causante; si éste tuvo su último domicilio en el Estado de California, el juez chileno deberá aplicar a su sucesión la ley sucesoria de California. Esta ley permite la total libertad testamentaria y no concede asignaciones forzosas a los descendientes o parientes del difunto. Sin embargo, la legislación chilena tiene una norma de policía que protege a los herederos chilenos del causante, garantizándoles las asignaciones forzosas que hubieran recibido si la sucesión se hubiera regido por la ley chilena, el Art. 998 CC⁷. El juez chileno tiene la obligación de aplicar el Art. 998 CC. Este artículo es una norma de policía porque es una norma imperativa que obliga al juez a aplicar el derecho nacional a la sucesión en lo que respecta al cálculo y protección de las asignaciones forzosas, las que además podrán pagarse con preferencia con los bienes situados en Chile. Hay ciertas áreas del derecho en que cada día se incluyen más normas de policía.

Además, existen ciertas áreas del Derecho en las que el legislador tiende a incluir normas de policía, para proteger ciertos derechos de una manera eficaz e impedir que se vean vulnerados en casos gobernados por la ley extranjera. Por ejemplo, podemos mencionar:

1. El área del derecho de protección al consumidor internacional. Las normas de este Derecho podrían verse vulneradas si se aplica al contrato una ley extranjera menos protectora del consumidor, por ello, el legislador tiende a incluir normas de policía para regular estos contratos internacionales. En esa área hay muchas normas de policía. Obviamente estas normas de policía pretenden proteger a la parte débil del contrato.
2. En el área del derecho laboral internacional. La ley protege con normas de policía las condiciones de trabajo y los derechos del trabajador individual, aunque el trabajador preste trabajos en el extranjero o haya aceptado que su contrato laboral quedara gobernado por derecho extranjero.
3. En el área del derecho de familia y sucesorio internacional. Para proteger a ciertos herederos y miembros de la familia que necesitan de protección.
4. En el área del derecho económico internacional. Por ejemplo, en materia de importaciones y exportaciones de ciertos bienes.
5. En el área del derecho procesal internacional. Por ejemplo, en las normas que establecen las condiciones para el reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras en el país o de instrumentos públicos.

Algunos ejemplos son:

1. **Art. 18 CC:** en los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas.

⁷ En la sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio de la República, tendrán los chilenos a título de herencia o de alimentos, los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada de un chileno. / Los chilenos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero. / Esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un chileno que deja bienes en país extranjero.

2. **Art. 135 CC:** por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, y toma el marido la administración de los de la mujer, según las reglas que se expondrán en el título De la sociedad conyugal. / Los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago, y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción.
3. **Art. 245 CPC:** en los casos en que no pueda aplicarse ninguno de los tres artículos precedentes, las resoluciones de tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubieran dictado por tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes:
 - a. Que no contengan nada contrario a las leyes de la República. Pero no se tomarán en consideración las leyes de procedimiento a que haya debido sujetarse en Chile la substanciación del juicio.
 - b. Que tampoco se opongan a la jurisdicción nacional.
 - c. Que la parte en contra de la cual se invoca la sentencia haya sido debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que, por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa.
 - d. Que estén ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas.

En cuanto al reconocimiento de una norma de policía, en principio, se reconoce siempre por su carácter imperativo e irrenunciable. Además, respecto a las normas de policía que el juez chileno debe, en primer lugar, respetar las normas de policía chilena. Sin embargo, cuando la norma de conflicto chilena manda a aplicar la ley extranjera, el juez deberá también respetar las normas de policía de esa legislación extranjera, salvo que ellas entren en conflicto con normas de policía de la ley chilena, las que primarían sobre las extranjeras.

E. Ejercicios Prácticos de Límites a la Aplicación del Derecho Extranjero:

(1.) Carlo Grimaldi, italiano, vive en Verona (Italia) con su esposa y tres hijos. Afectado de una enfermedad incurable y en estado de gravedad, se traslada a Austria y se nacionaliza austriaco. Allí otorga testamento por el que instituye a su esposa heredera en el 70% de sus bienes y a sus hijos en el 30% restante. Permanece en Austria 6 meses y regresa a Verona donde al poco tiempo fallece. La esposa solicita la apertura de la sucesión en Italia.

El derecho austriaco rige la sucesión por la ley de la última nacionalidad del causante y permite testar sin prohibiciones legales. El derecho italiano rige la sucesión también por la última nacionalidad del causante, pero establece asignaciones forzosas para los legitimarios.

Los hijos cuestionan el derecho austriaco como aplicable a la sucesión y, en consecuencia, la eficacia de las asignaciones del testamento. ¿Qué argumentos esgrimiría en defensa de sus derechos hereditarios? Fundamente su respuesta. Se podría alegar, por las circunstancias del caso, fraude a la ley (enfermedad incurable combinado con breve estadía en Austria), de manera que el testamento fuera inoponible y también la nacionalización, debiendo aplicarse la ley italiana.

(2.) Carlos Anguita y Edward Fawcett celebran en las Islas Caimán un contrato de mutuo de dinero por el cual Fawcett presta a Anguita la cantidad de 100.000 dólares americanos a devolverse en una única cuota a un año plazo, a pagarse en Islas Caimán, con un interés del 75% anual que se aumentaría a 85% anual en caso de mora. En el contrato se pacta una cláusula arbitral y se designa árbitro arbitrador a un abogado que debe actuar en Islas Caimán. Anguita no paga el crédito a su vencimiento y Fawcett inicia un procedimiento arbitral en Islas Caimán en el cual se condena a Anguita al pago de la deuda con sus intereses. El laudo pretende ejecutarse en Chile donde Anguita está domiciliado y tiene bienes. El abogado de Anguita, ¿qué argumento podría hacer valer en su defensa? Se podría entender que hay un principio esencial en el ordenamiento jurídico chileno de que no pueden cobrarse intereses usureros (condena a la usura), siendo contrario al orden público chileno y, por tanto, no reconocerse por la Corte ese laudo en Chile.

(3.) Anwar Abud de 25 años y Karima Awad de 15 años, se casan en Catar el año 2012 conforme a la ley vigente en ese lugar, y se trasladan a vivir a Chile el año 2015. Ellos inscriben su matrimonio en Chile en la Primera Circunscripción de la comuna de Santiago, según lo indica la ley chilena para los matrimonios contraídos en el extranjero. Los padres de Karima solicitan en Chile que el matrimonio sea declarado nulo argumentando que, si bien ese matrimonio es válido según la ley catari, no puede ser válido en Chile. Señale qué fundamento legal pueden esgrimir para su negativa y qué tipo de norma de conflicto la justifica. Aquí hay una norma de policía chilena (Art. 80 LMC) de que no se pueden infringir los impedimentos dirimentes establecidos por la ley chilena (en este caso, el Art. 5 LMC (menores de 16 años).

II. PARTE ESPECIAL.

I. Aspectos Generales.

Ahora se apunta al estudio de las normas de conflicto específicas que gobiernan ciertas materias en el DIPRI chileno y, concretamente, las normas propias de: (i) resolución de conflictos de leyes; (ii) resolución de conflictos de jurisdicción; y (iii) reconocimiento de instrumentos y sentencias extranjeras. Ese es el orden pedagógico que prefiere la profesora, pero realmente se debe comenzar por los conflictos de jurisdicción, luego, las leyes y, finalmente, el reconocimiento.

II. Normas para la Resolución de Conflictos de Leyes.

A. Normas Reguladoras del Estatuto Personal:

A.1. Normas reguladoras del estatuto personal de la persona natural: cuando se habla del estatuto personal de la persona natural, se refiere al conjunto de normas que rige a la persona en cuanto a su estado civil, capacidad, derechos y obligaciones que nacen de sus relaciones de familia y otros atributos personales como su nombre o nacionalidad. En muchas legislaciones, el estatuto personal sigue a la persona donde ella esté o actúe.

En las legislaciones de derecho comparado, normalmente se usan dos factores de conexión para gobernar el estatuto personal: la nacionalidad y/o el domicilio.

1. Las legislaciones que usan el factor de conexión de la nacionalidad someten la capacidad y el estado civil de la persona a la ley de su nacionalidad. Es el caso de Italia y de España, en

ciertos aspectos. En Chile, la legislación chilena usa este factor para los casos específicos contemplados en el Art. 15 CC⁸.

2. Hay otras legislaciones que usan el factor de conexión domicilio, es decir, someten el estatuto personal a la ley del domicilio o, en subsidio, al de la residencia de la persona. La legislación chilena usa este factor domicilio para todos los habitantes de Chile en el Art. 14 CC (la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros).

Así, en Chile se usa una combinación de estos dos factores: (i) domicilio para todos los domiciliados o habitantes en Chile; y (ii) nacionalidad sólo para los chilenos residentes o que actúan en el extranjero en aspectos específicos. Por eso, los autores sostienen que en Chile existe un “estatuto personal restringido”, sólo se reconoce para el chileno en las materias del Art. 15 CC y no se reconoce otro estatuto personal para los extranjeros actuando o habitando en Chile.

Las legislaciones europeas tienden a regir la capacidad por la ley nacional de la persona (por ejemplo, ley española e Italiana). Los países latinoamericanos rigen habitualmente la capacidad por la ley del domicilio. Esto por una razón histórica ya que los países latinoamericanos inicialmente se poblaron por personas de europeas que traían su propio estatuto personal a Latinoamérica y los países latinoamericanos deseaban hacer cumplir su derecho nacional propio legislado después de su Independencia.

Ahora bien, adoptar el factor de conexión nacionalidad para determinar el estatuto personal puede producir problemas, en ciertos casos:

1. Doble nacionalidad. Cuando la persona tiene dos o más nacionalidades debe determinarse cuál prima para efectos de determinar el estatuto personal; esto requiere resolver un conflicto de nacionalidad.
2. Cambio de nacionalidad. Este cambio produce un conflicto de ley en el tiempo que debe resolverse para determinar qué actos quedaron gobernados por la ley de la antigua nacionalidad y qué actos por la ley de la nueva nacionalidad.
3. Personas apátridas. En el caso de personas sin nacionalidad debe buscarse otro factor de conexión para determinar su estatuto personal.

Por eso, algunas legislaciones prefieren utilizar el factor de conexión domicilio o residencia habitual para determinar el estatuto personal, ya que ambos son más fáciles de conocer, aunque presentan también el problema de ser variables.

Hay que revisar el estatuto personal en la legislación chilena, para lo cual hay que distinguir:

1. Estatuto personal del habitante de Chile (Art. 14 CC): en Chile no existe una norma específica que disponga que el estatuto personal de un habitante de Chile se rige por la ley chilena, pero sí existe la norma general del Art. 14 CC que somete a todos los habitantes de la República a las leyes chilenas, sometimiento que puede extenderse también a su estado civil, capacidad y

⁸ Art. 15 CC: a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. (1º) En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile; (2º) En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos.

derechos y obligaciones de familia. El término habitante debe entenderse a toda persona que está físicamente presente en el territorio de Chile y los espacios donde Chile ejerce jurisdicción exclusiva. Por ello, no importa dónde un acto va a producir efectos jurídicos, si se realiza en Chile, la capacidad de la persona natural para realizarlo se rige necesariamente por la ley chilena, lo mismo sucede con su estado civil. Además, las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia del habitante de Chile se rigen por la ley chilena, aunque éste y sus parientes sean extranjeros.

2. Estatuto personal del no habitante de Chile: en virtud del Art. 15 CC hay que sub-distinguir.
 - a. Estatuto personal del extranjero en el extranjero: en principio, la legislación chilena no tiene una norma general para establecer el estatuto personal del extranjero no habitante de Chile, actuando en el extranjero. Por ejemplo, nuestra legislación no tiene una norma para determinar la ley que rige la capacidad de un extranjero contratando en el extranjero. El Código de Bustamante tampoco proporciona una norma ya que deja en libertad a los Estados partes para optar por cualquier ley para regir el estatuto personal. En su Art. 7 dispone que cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior. La doctrina nacional ha propuesto diversas soluciones:
 - i. Algunos autores sostienen que la ley que rige el estatuto personal de este extranjero será la ley del lugar de otorgamiento o celebración del acto, o de constitución del estado civil, porque esa es la norma general para los actos otorgados o celebrados en Chile, establecida en el Art. 14 CC que, bilateralizada, para llenar este vacío legal, podría aplicarse también a los actos ejecutados u otorgados en el extranjero y al Estado civil. Esta solución ha sido adoptada por la jurisprudencia chilena en varias ocasiones.
 - ii. Hay otros autores que dicen que debe aplicarse al estatuto personal la ley nacional del extranjero argumentando que si el Art. 15 CC determina la capacidad del chileno en base a su ley nacional, lo mismo debiera aplicarse al extranjero, bilateralizando este Art. 15 CC. Sin embargo, esta postura es refutada por los autores que defienden la primera postura, diciendo que el Art. 15 es un artículo especial, excepcional y de aplicación restringida al chileno, que no puede ser bilateralizado para aplicarse al extranjero.
 - b. Estatuto personal del chileno en el extranjero: en este caso debe distinguirse si el chileno actúa en el extranjero dentro de la esfera del Art. 15 CC o no.
 - i. Estatuto personal del chileno en las situaciones señaladas en el Art. 15 CC. Si su actuación se refiere a las situaciones del Art. 15 CC, se rige por la legislación chilena. El Art. 15 CC dispone que a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero: (1º) en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile; (2º) en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos.

Hay que analizar en detalle la disposición. Ella se aplica a los chilenos no habitantes de Chile aunque estén domiciliados en el extranjero. Es decir, se aplica al chileno que está transeúnte en el extranjero y al residente o domiciliado en el extranjero, mientras mantengan su calidad de chilenos, en las materias específicamente señaladas en el Art. 15 CC.

(1.) En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile.

1. El chileno que está en el extranjero queda sometido siempre a la ley chilena en cuanto a la determinación de su estado civil. Es decir, el estado civil del chileno en el extranjero siempre quedará gobernado por la ley chilena y en Chile, no se le reconocerá un estado civil que no le reconozca la ley chilena.

El concepto de estado civil, que puede definirse como la situación jurídica permanente de una persona en cuanto a sus relaciones de familia, debe interpretarse en sentido amplio incluyendo el nombre, su filiación, su domicilio, nacionalidad, entre otros.

Por ejemplo, no se le reconocerá la calidad de divorciado si la sentencia de divorcio extranjera no ha sido reconocida en Chile por medio del trámite del exequátur. Tampoco se le reconocerá la calidad de casado a un chileno que se haya casado en el extranjero con una persona de su mismo sexo, ya que la ley chilena no reconoce esa unión como matrimonio sino sólo como Acuerdo de Unión Civil y siempre que se haya inscrito en Chile como tal. No se le reconocerá la calidad de conviviente civil, si no ha inscrito el AUC en Chile. No se le reconocerá en Chile el nombre que haya adquirido en el extranjero por matrimonio, etc.

2. Capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile. Este artículo somete a la ley chilena la capacidad de ejercicio del chileno sólo cuando el acto que celebra o ejecuta haya de tener efecto en Chile. Si el acto que realiza no tiene efectos en Chile, su capacidad no queda determinada por la ley chilena. El artículo excluye expresamente la capacidad de goce, al hablar de capacidad para ejecutar.

Se ha discutido qué significa “que hayan de tener efecto en Chile”: es evidente que si un chileno ejecuta un acto en el extranjero y los derechos y obligaciones que surgen de ese acto pueden ser exigibles en Chile, su capacidad va a estar regida por la ley chilena. Si Juan, chileno, vende en Nueva York su departamento ubicado en La Serena a un norteamericano su capacidad va a estar regida por la ley chilena. Pero si Juan, chileno domiciliado en EE.UU., vende su

departamento en Manhattan a un norteamericano y recibe el pago ahí, su capacidad no quedará gobernada por la ley chilena. Incluso podría pasar que el vendedor fuera menor de edad en Chile e incapaz, pero plenamente capaz conforme a la ley del país donde contrata, si el acto no produce efectos en Chile, es válido si se ajusta a la ley del lugar de su celebración.

Se discute en doctrina si:

- a. Es necesario que el acto produzca efectivamente efectos en Chile para que se aplique la ley chilena o, basta que haya sido la intención de las partes que el acto vaya a producir efectos en Chile.
- b. O más aún, si el acto accidentalmente produce efectos en Chile, aunque las partes no pretendieron nunca que los produjera en Chile. Por ejemplo, se vende un caballo de carrera en Nueva York que va a correr en el Hipódromo de Palermo en Buenos Aires y se acuerda entregarlo al comprador ahí pero, por efectos de la Pandemia de Covid 19, se suspende la Carrera en Palermo; el caballo se traslada a Chile y hay que entregarlo aquí al comprador.

La respuesta y posición más segura es que basta con que el acto produzca algún efecto en Chile para que se le aplique la ley chilena a la capacidad del chileno que lo celebra, aunque esos efectos en Chile no hayan sido previstos por las partes.

(2.) En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos. Todas las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia de un chileno en el extranjero respecto de su cónyuge o parientes chilenos quedan necesariamente regidas por la ley chilena; *a contrario sensu*, las obligaciones y derechos de familia de este chileno respecto de su cónyuge y parientes extranjeros, no quedan regidas por la ley chilena. Este es el caso de las obligaciones que nacen del matrimonio, la filiación, la sucesión, entre otros.

- ii. Estatuto personal del chileno fuera de las situaciones del Art. 15 CC. El chileno y sus actuaciones quedarían fuera del ámbito del Art. 15 CC cuando:
 - (i) el acto que celebra en el extranjero no va a producir efectos en Chile; y
 - (ii) sus obligaciones y derechos de familia en el extranjero, se refieren a parientes extranjeros y cónyuge extranjero.

Para estas situaciones, la legislación chilena no tiene una norma que determine el estatuto personal del chileno actuando en el extranjero. Sí es

claro que no se puede aplicar la ley chilena a determinar su estatuto personal, ya que el legislador limitó su aplicación a sólo los casos del Art. 15 CC.

Frente al vacío legal de nuestra legislación, cabe buscar una solución bilateralizando la norma del Art. 14 CC, como se hizo para el caso de los extranjeros, actuando en el extranjero. Es decir, aplicar la ley del lugar de celebración o otorgamiento del acto o del domicilio del chileno en el extranjero para determinar su estatuto personal (capacidad de ejercicio y derechos y obligaciones de familia).

Entonces, recapitulando, en Chile existe lo que se ha denominado un estatuto personal restringido respecto del chileno porque la ley chilena sólo sigue al chileno en los casos concretos y específicos señalados en el Art. 15 CC y, en el resto de los casos, la legislación chilena aplica, como principio general, el principio de la territorialidad de la ley chilena, es decir, que la ley chilena sólo se aplica para determinar el estatuto personal de quien está en Chile.

A.2. Normas reguladoras del estatuto personal de la persona jurídica o de su *lex societatis*: la persona jurídica es un ente ficticio o moral con capacidad jurídica para adquirir derechos y exigir obligaciones. Generalmente, las personas jurídicas son creadas por ley (es la ley la que permite a un contrato la creación de la persona jurídica). Cuando una determinada ley lo permite, algunas personas jurídicas puedan ser creadas contractualmente. Es esa ley la que gobierna o regula la persona jurídica.

En el contexto internacional y del Derecho Internacional Privado, es importante identificar la ley que regula a la persona jurídica, es decir, la ley estatal bajo cuyo amparo la sociedad o persona jurídica nace, actúa y se extingue. Esta ley estatal suele llamarse, en doctrina, *lex societatis*. Esta *lex societatis* constituye el estatuto personal de la persona jurídica, vale decir, la ley que la rige en cuanto a su constitución, facultades y poderes, representación legal, responsabilidad con la que actúa y en todo lo referente al gobierno interno y a la administración de la persona jurídica y a su transformación, disolución o extinción.

Algunas legislaciones, asimilan el concepto de *lex societatis* al de nacionalidad de la sociedad, de este modo sostienen que cada persona jurídica tiene una nacionalidad y que esta nacionalidad determina su estatuto personal, por ejemplo, el Art 9.11 CC español dispone que: la ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad, y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción. / En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las respectivas leyes personales. El sistema legal chileno no tiene una norma como la anterior, pero sí distingue entre sociedades nacionales y extranjeras y exige a estas últimas algunos requisitos legales adicionales para constituir agencia en el país, como se verá (por ejemplo, Art. 447 al Art. 449 CCom y el Art. 121 al Art. 122 LSA).

En el Derecho comparado existen dos modelos principales de determinación de la *lex societatis* o de la nacionalidad de la persona jurídica:

1. **Modelo de constitución o incorporación.** Este modelo postula que la ley que rige la sociedad es la ley del Estado conforme a la cual la sociedad se constituye. En este modelo la *lex societatis* es determinada por la voluntad de quienes fundan o constituyen la sociedad, quienes, al fijar su domicilio estatutario, optan por constituir la en un determinado Estado y someterla a su legislación. De ahí que la localización de los bienes sociales, el lugar de la administración central o establecimiento principal de la persona jurídica sean irrelevantes para determinar la ley que gobierna la sociedad.

En este modelo son personas jurídicas o sociedades nacionales, regidas por el Derecho nacional, aquellas cuyo domicilio estatutario esté ubicado dentro del Estado. Son sociedades extranjeras, en cambio, aquellas cuyo domicilio estatutario está en otro Estado, bajo cuya legislación se constituyeron.

Es decir, según este modelo, son personas jurídicas chilenas aquellas constituidas con domicilio en Chile y regidas por la ley chilena. Son sociedades extranjeras, aquellas con domicilio en el extranjero y regidas por el derecho del Estado en el cual tienen su domicilio estatutario.

Se argumenta que este modelo facilita la actividad internacional de las sociedades porque da certeza jurídica acerca de cuál es la ley que las gobierna. De este modo, responde mejor al interés de los socios o miembros fundadores y no perjudica a terceros, en la medida que ellos sepan que están contratando con una sociedad extranjera.

2. **El modelo de la sede real o social.** El modelo del “*seat or principal place of business*” o “*siege*” sostiene que la *lex societatis* es determinada por la localización real del establecimiento principal o de la administración central de la sociedad o persona jurídica. Por esto, la *lex societatis* de la persona jurídica es la ley del Estado en cuyo territorio la persona jurídica tiene su domicilio real y su sede principal de sus negocios; esta ley determinará las condiciones para su constitución y funcionamiento.

Según este modelo, sólo se podrá constituir una persona jurídica o sociedad en un Estado, si tiene ahí su sede real. Una sociedad será nacional si tiene en ese Estado su asiento principal de los negocios y extranjera si lo tiene en otro Estado. Por ello, si una sociedad se constituye en el Estado A (Inglaterra) pero tiene su sede principal en el Estado B (Francia), desde el punto de vista de B (Francia), será una sociedad sometida a la ley de B (francesa), pero irregular o en formación porque no se ha constituido correctamente.

Se argumenta que este modelo de sede real es adecuado porque previene el fraude, así una sociedad que actúa principalmente en un Estado, debe necesariamente someterse a las leyes de ese Estado y sus socios no pueden someterla a leyes de otros Estados que puedan ser más favorables para ellos.

Corresponde analizar un ejemplo, puesto por el profesor Garcimartín. Durante mucho tiempo, el derecho alemán se ha considerado como el paradigma de los modelos de sede real y el derecho británico como el paradigma de los modelos de constitución. Imagínese una sociedad constituida en

Bahamas con domicilio social allí, pero cuya administración central se encuentra en Berlín. Desde el punto de vista del derecho británico, dicha sociedad sería reconocida como sociedad de Bahamas, sujeta al régimen de este último país y que como tal podría actuar en el mercado británico. En cambio, desde el punto de vista del derecho alemán, dicha sociedad estaría sujeta al derecho alemán y debería haberse constituido bajo esta última ley. Al no estar debidamente constituida, su estatuto sería el de una sociedad nula, inexistente o irregular, según cómo la califique el derecho alemán.

Finalmente, hay que referirse a la *lex societatis* en la legislación chilena. La legislación chilena parece acogerse al modelo de constitución o incorporación, de modo que se consideran chilenas a las sociedades y fundaciones constituidas o registradas en Chile y extranjeras a las sociedades constituidas o registradas en el extranjero. Así, la *lex societatis* de las sociedades constituidas en Chile es la ley chilena, por aplicación de la norma general del Art. 14 CC y la *lex societatis* de las sociedades constituidas o registradas en el extranjero es la ley del lugar de su constitución. Por ejemplo, si actúa en Chile una sociedad constituida en Delaware (EE.UU), su *lex societatis* será la del Estado de Delaware; esa ley será la que le dé la calidad de persona jurídica, la que determine quién la representa legalmente, cuáles son sus bienes, cómo funciona, quién la administra, entre otros.

Lo anterior se desprende de las disposiciones relativas a agencias de sociedades extranjeras del Código de Comercio y de la Ley 18.056 sobre Sociedades Anónimas.

1. **Art. 447 CCom:** para que una sociedad u otra persona jurídica con fines de lucro extranjera pueda constituir agencia en Chile, su agente o representante deberá protocolizar en una notaría del domicilio que ésta tendrá en Chile, en el idioma oficial del país de origen, traducidos al español si no estuvieren en ese idioma, los siguientes documentos emanados del país en que se haya constituido, debidamente legalizados:
 - a. Los antecedentes que acrediten que se encuentra legalmente constituida de acuerdo a la ley del país de origen y un certificado de vigencia de la entidad.
 - b. Copia auténtica de los estatutos vigentes.
 - c. Un poder general otorgado por la entidad al agente que ha de representarla en el país, en el que consten la personería del mandante y se exprese en forma clara y precisa que el agente obra en Chile bajo la responsabilidad directa de la entidad, con amplias facultades para ejecutar operaciones en su nombre y en que se le otorguen expresamente las facultades a que se refiere el inciso segundo del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil.
2. **Art. 448 CCom:** por escritura pública de la misma fecha y ante el mismo notario ante el cual se efectúe la protocolización a que se refiere el artículo anterior, el agente deberá declarar a nombre de la entidad y con poder suficiente para ello:
 - a. El nombre con que la entidad funcionará en Chile y el objeto u objetos de ella.
 - b. Que la entidad conoce la legislación chilena y los reglamentos por los cuales habrán de regirse en el país, sus agencias, actos, contratos y obligaciones.
 - c. Que los bienes de la entidad quedan afectos a las leyes chilenas, especialmente para responder de las obligaciones que ella haya de cumplir en Chile.
 - d. Que la entidad se obliga a mantener en Chile bienes de fácil realización para atender a las obligaciones que hayan de cumplirse en el país.

- e.Cuál es el capital efectivo que va a tener en el país para el giro de sus operaciones y la fecha y forma en que éste ha de ingresar en la caja de la agencia en Chile.
- f.Cuál es el domicilio de la agencia principal.

Estas mismas exigencias se repiten para la constitución de agencias de sociedades anónimas extranjeras en Chile (Art. 121 y Art. 122 LSA). A su vez, el Código de Bustamante permite a cada Estado parte adoptar el modelo que desee para sus personas jurídicas, es decir, elegir el de constitución o de sede real (Art. 31 a Art. 35 CB). La nacionalidad de una sociedad puede tener importancia para efectos diplomáticos y la aplicación de tratados internacionales, por ejemplo, los de Libre Comercio. El Gobierno de Chile además de proteger y exigir la protección de sociedades constituidas en Chile ha provisto también protección diplomática a sociedades extranjeras con mayoría de accionistas chilenos.

Asimismo, Chile suscribió (pero aún no ha ratificado) la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídica en el Derecho Internacional Privado (La Paz, Bolivia, 1984), la que **opta por el modelo de constitución. Sus normas principales son:**

1. **Art. 1:** la presente Convención se aplicará a las personas jurídicas constituidas en cualquiera de los Estados Partes, entendiéndose por persona jurídica toda entidad que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a las de sus miembros o fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del lugar de su constitución. / Se aplicará esta Convención sin perjuicio de convenciones específicas que tengan por objeto categorías especiales de personas jurídicas.
2. **Art. 2:** la existencia, la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, el funcionamiento, la disolución y la fusión de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por la ley del lugar de su constitución. / Por “la ley del lugar de su constitución” se entiende la del Estado Parte donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas.
3. **Art. 3:** las personas jurídicas privadas, debidamente constituidas en un Estado Parte, serán reconocidas de pleno derecho en los demás Estados Partes. El reconocimiento de pleno derecho no excluye la facultad del Estado Parte para exigir la comprobación de que la persona jurídica existe conforme a la ley del lugar de su constitución. / En ningún caso, la capacidad reconocida a las personas jurídicas privadas, constituidas en un Estado Parte, podrá exceder de la capacidad que la ley del Estado Parte de reconocimiento otorgue a las personas jurídicas constituidas en este último.
4. **Art. 4:** para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto social de las personas jurídicas privadas, regirá la ley del Estado Parte donde se realicen tales actos.
5. **Art. 5:** las personas jurídicas privadas constituidas en un Estado Parte que pretendan establecer la sede efectiva de su administración en otro Estado Parte, podrán ser obligadas a cumplir con los requisitos establecidos en la legislación de este último.

Luego, hay que referirse al ámbito de aplicación de la *lex societatis* o del estatuto personal de la persona jurídica. En general, la *lex societatis* gobierna la constitución y todos los aspectos internos y externos de la persona jurídica. De este modo gobierna:

1. La constitución de la persona jurídica y las formalidades de constitución. Esta ley determina: (i) los trámites y requisitos para que ella se constituya; (ii) la necesidad de otorgar escritura pública para su constitución; (iii) el contenido de los estatutos; (iv) la eficacia y necesidad de los trámites de registro y de publicidad, o de autorizaciones gubernamentales; entre otros. La excepción es que no regula la capacidad para asociarse de las personas naturales o jurídicas, porque ella queda regulada por el estatuto personal de esas personas. Tampoco regula las restricciones para asociarse entre los cónyuges, porque ella queda regulada por su ley matrimonial.
2. Las relaciones internas de la sociedad o persona jurídica. Esta ley determina: (i) la estructura social o corporativa; (ii) el valor normativo de los estatutos; (iii) quiénes son los administradores de la sociedad; (iv) las relaciones entre socios y administradores; y (v) los requisitos para aumentar o disminuir el capital social. En el caso de sociedades accionarias: (i) la forma cómo se emitirán las acciones; (ii) cómo se ejercerán los derechos accionarios; (iii) cómo se traspasarán las acciones no emitidas como títulos al portador; (iv) el valor de los pactos de accionistas; (v) la condición de socio de los herederos del socio difunto; entre otros. La excepción es que las acciones emitidas como títulos al portador se rigen por el principio *lex carta sitae*, es decir, por la ley del lugar de su ubicación para efectos de su transferencia y constitución de derechos reales sobre ellas.
3. Las relaciones externas de la sociedad o persona jurídica. Esta ley determina: (i) bajo qué condiciones y con qué contenido la persona jurídica adquiere personalidad jurídica y capacidad jurídica; (ii) determina el régimen de representación de la sociedad y su alcance; (iii) la capacidad de la sociedad para emitir determinados títulos o participaciones sociales; (iv) el régimen de disolución, liquidación y extinción de la sociedad, la posibilidad de fusión; entre otros. Además, determina el régimen de responsabilidad de la entidad frente a terceros, concretamente: (i) de qué responde la sociedad y si su patrimonio es separado del de sus socios; y (ii) de qué responde el directorio y los socios.

A veces pueden superponerse otras leyes a la *lex societatis*, como la Ley de Mercado de Valores de otro Estado o la ley que permite el “levantamiento del velo” de la sociedad o la que sanciona la responsabilidad extracontractual, entre otros.

Finalmente, hay que referirse a dos elementos. Por una parte, al cambio de la *lex societatis*. La *lex societatis* puede cambiar cuando se cambia el domicilio estatutario a otro Estado, conservando la personalidad jurídica de origen. Las sociedades pueden “emigrar” e “inmigrar”. El simple traslado de la sede real a otro Estado no afecta la *lex societatis* en nuestro sistema jurídico (sí en los que aceptan la teoría de la sede social). El cambio de domicilio social o de nacionalidad exige tener en cuenta dos leyes, la ley del Estado de domicilio inicial y la ley del Estado del domicilio de destino, habrá que hacer una aplicación distributiva de ambas para determinar la procedencia del cambio, sus requisitos y sus efectos. El cambio sólo es posible si ambas leyes lo permiten. Por otra parte, el asunto de la fusión de sociedades y su efecto en la *lex societatis*. En las fusiones internacionales participan dos sociedades sometidas a leyes de Estados distintos y una de ellas es absorbida por la otra o ambas se extinguen por la constitución de una nueva sociedad. En ellas al menos una de las sociedades, cambia de *lex societatis*: sus socios y terceros dejan de estar sometidos a la *lex societatis* anterior para quedar sometidos a una nueva *lex societatis*. En estos casos se aplican ambas leyes societarias distributivamente: la ley de cada sociedad determina si procede y las condiciones de procedencia y

efectos de la fusión con una sociedad extranjera. Es necesario, en todo caso, que ambas leyes permitan la fusión.

A.3. Ejercicios sobre Estatuto Personal:

(1.) Juan Sepúlveda, chileno, compra en Las Vegas (EE.UU.) una grúa Caterpillar por el precio de 20.000 dólares FOB Valparaíso para usarla en una construcción de una carretera en Chile. Luego, se discute en Chile si el contrato era válido ya que Juan estaba sujeto a interdicción en Chile al momento de la compra. ¿Qué ley aplicará el juez chileno para resolver este asunto?

- a. Elementos jurídicamente relevantes:
 - a. Chileno.
 - b. Compra en Las Vegas.
 - c. Para usar el bien en una construcción de carretera en Chile.
 - d. Estaba sujeto a interdicción la momento de la compra.
- b. Problema jurídico debatido: validez del contrato en vista de la capacidad.
- c. Normas de derecho aplicables: Art. 15 N°1 CC.
- d. Posibles soluciones jurídicas: el contrato es nulo por incapacidad, conforme a la ley chilena.

(2.) Juan Sepúlveda, chileno domiciliado en Kansas y gerente de la sociedad Kansas Technology Inc., también domiciliada en Kansas, quiere comprar un inmueble en Valparaíso para la sociedad, con el objeto de abrir una agencia de esa sociedad en Chile. ¿Qué ley determinará su capacidad para hacerlo?

- a. Elementos jurídicamente relevantes:
 - a. Chileno domiciliado en Kansas.
 - b. Gerente de una sociedad en Kansas.
 - c. Comprar inmueble en Valparaíso.
- b. Problema jurídico debatido: determinar si Juan tiene capacidad para comprar.
- c. Normas de derecho aplicables: ¿qué ley rige? Ley de Kansas. Si esta ley permite al gerente de una sociedad para comprar, entonces será capaz.
- d. Posibles soluciones jurídicas: como compra a nombre de la sociedad, rige la *lex societatis*, esto es, la ley de Kansas.

(3.) Juan Sepúlveda, chileno, domiciliado en Kampala contrae matrimonio allí con Jane Smith el año 2000 y se divorcia extrajudicialmente de ella el año 2016. Juan vuelve a Chile y quiere casarse ahora con Elena Manríquez, venezolana.

- a. Elementos jurídicamente relevantes:
 - a. Chileno domiciliado en Kampala.
 - b. Se casa allí.
 - c. Se divorcia extrajudicialmente.
 - d. Vuelve a Chile y quiere casarse nuevamente.
- b. Problema jurídico debatido: capacidad para contraer matrimonio y validez del divorcio en Kampala.
- c. Normas de derecho aplicables: Art. 15 N°1 CC (estado civil y ley chilena) y Art. 83 LMC (invalidez de los divorcios extrajudiciales).

- d.** Posibles soluciones jurídicas: Juan no tiene capacidad para contraer matrimonio en Chile, porque está sujeto a un impedimento dirimente del vínculo matrimonial no disuelto (bigamia).

(4.) Juan Sepúlveda, chileno, asigna en su testamento otorgado en Kansas todos sus bienes a su hija Irene, conforme a la ley de Kansas. A su muerte deja bienes en Kansas y en Chile. Juan tiene además dos hijos: Paul y Michael quienes disputan la validez de la asignación testamentaria.

- a.** Elementos jurídicamente relevantes:
 - a.** Chileno.
 - b.** Testamento otorgado en Kansas conforme a esa ley.
 - c.** Deja todos sus bienes a su hija.
 - d.** Muere y deja bienes en Kansas y en Chile.
 - e.** Dos hijos adicionales.
- b.** Problema jurídico debatido: la eficacia de la asignación del testamento
- c.** Normas de derecho aplicables: Art. 15 N°2 CC (se somete a la ley chilena, en la medida de que los hijos sean chilenos).
- d.** Posibles soluciones jurídicas: los hijos, de ser chilenos, podrían ejercer una acción de reforma de testamento o una acción de petición de herencia.

(5.) Juan Sepúlveda es accionista de la sociedad anónima argentina “Carnes Bariloche S.A” y consulta si puede celebrar, en Santiago de Chile con su amigo Pedro Segovia, un pacto de accionistas para obtener el control de la administración de esa sociedad. ¿Qué ley gobierna este asunto?

- a.** Elementos jurídicamente relevantes:
 - a.** Accionista en sociedad anónima extranjera.
 - b.** Celebrar en Santiago con un amigo un pacto de accionista para obtener el control de la administración.
- b.** Problema jurídico debatido: posibilidad de celebrar el pacto y su licitud.
- c.** Normas de derecho aplicables: se aplica la ley societaria argentina, conforme al modelo de constitución.
- d.** Posibles soluciones jurídicas: solicitar un informe a un abogado argentina para evaluar la posibilidad del pacto.

(6.) Juan Sepúlveda tiene un crédito ascendente a 100.000 dólares en contra de la sociedad boliviana “Rio Silala Ltda.”, cuyos socios son Pablo y Guillermo Choitán. La sociedad cayó en insolvencia y Juan consulta a si puede pedir el embargo de unos inmuebles de propiedad de los hermanos Choitán, ubicados en Santa Cruz (Bolivia), para asegurar el pago de esa deuda. Señale ¿qué ley regirá el asunto?

- a.** Elementos jurídicamente relevantes:
 - a.** Crédito por 100.000 USD
 - b.** .Contra sociedad boliviana.
 - c.** Con dos socios, hermanos.
 - d.** La sociedad cae en insolvencia.
 - e.** Se solicita embargo de bienes ubicados en Santa Cruz.

- b. Problema jurídico debatido: qué ley rige la responsabilidad de los socios, será la *lex societatis*, esto es, la ley boliviana determinará si se pueden embargar bienes propios de los socios.
- c. Normas de derecho aplicables: *lex societatis*.
- d. Posibles soluciones jurídicas: determinar la posibilidad.

B. Normas Regulatoras del Matrimonio: hay que revisar las formalidades y requisitos internos, disolución, nulidad y efectos del matrimonio.

B.1. Calificación del matrimonio: para determinar si una unión tiene la calidad jurídica de matrimonio, el juez chileno va a aplicar la calificación que da la *lex fori* en el Art. 102 del Código Civil, esto es, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente.

Es decir, para nuestro ordenamiento jurídico el matrimonio es un contrato cuyo perfeccionamiento exige la concurrencia de ciertas formalidades o solemnidades y que sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer y tiene un contenido y fines definidos. Por ello en Chile, no se reconoce el matrimonio poligámico en ninguna de sus formas, poliandria y poliginia, ni tampoco el matrimonio homosexual ni el matrimonio consensual, ni se asimila la cohabitación de una pareja a matrimonio.

B.2. Normas reguladoras de las formalidades del matrimonio: para determinar estas normas se debe distinguir si el matrimonio se celebra en Chile o no, aunque en ambos casos se aplica el principio *lex locus regit actum*.

1. **Matrimonio celebrado en Chile:** se rigen por la ley chilena por la disposición general del Art. 14 CC que remite a la aplicación del Art. 80 LMC, el que dispone:
 - a. Los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. Así, el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad con las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno, siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer.
 - b. Sin embargo, podrá ser declarado nulo de conformidad a la ley chilena, el matrimonio celebrado en país extranjero que se haya contraído en contravención a lo dispuesto en los artículos 5º, 6º y 7º de esta ley.
 - c. Tampoco valdrá en Chile el matrimonio que se haya contraído en el extranjero sin el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes.

Por lo tanto, si el matrimonio se celebra en Chile tiene que regirse por las formalidades exigidas por la Ley de Matrimonio Civil chilena. La legislación sólo permite casar al oficial del Registro Civil chileno y al ministro de culto autorizado de una entidad religiosa de derecho público si cumple con los demás requisitos exigidos por la ley (Art. 20 LMC). Los diplomáticos extranjeros acreditados en Chile no pueden casar en Chile, aunque la legislación del Estado al que representan les otorgue esa facultad.

2. **Matrimonio celebrado en el extranjero:** conforme al Art. 80 LMC, los matrimonios celebrados en el extranjero deben someterse a las solemnidades establecidas por la ley del lugar de celebración de ese matrimonio, cualesquiera que sean esas formalidades. Esta norma dispone que los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley

del lugar de su celebración. Se han discutido tres problemas en relación con las formalidades del matrimonio:

- a. **Validez en Chile del matrimonio celebrado en el extranjero con la sola forma religiosa:** este matrimonio sólo religioso o eclesiástico celebrado en el extranjero produce efectos civiles en Chile si cumple con todas las formalidades de la ley del lugar de celebración y en ese país los produce. En muchos países se reconoce efectos civiles a los matrimonios religiosos (por ejemplo, Grecia, Reino Unido, España, Bélgica, Chile, EE.UU, entre otros) Si el matrimonio celebrado en ellos cumple con los requisitos formales establecidos por el culto religioso y aceptados por la ley del lugar de celebración, esos matrimonios son válidos en Chile, según el Art. 80 LMC.
- b. **Validez en Chile del matrimonio consensual extranjero:** apunta a un matrimonio que produce efectos civiles de matrimonio, a pesar de no haberse prestado ningún consentimiento solemne, sino sólo por el hecho de las partes haber cohabitado juntas por un determinado período de tiempo. Por ejemplo, en el canadiense de Nova Scotia la cohabitación de un hombre y una mujer por 2 o más años seguidos se considera matrimonio, en el de New Brunswick la cohabitación por tres años o el haber tenido o adoptado un hijo juntos produce los efectos de matrimonio, *common law marriage*. Algo similar ocurre en varios Estados americanos (Colorado, Iowa, Kansas, Rhode Island, Texas, Utah, Distrito de Columbia).

Para determinar si este matrimonio es válido en Chile o no se debe recurrir a la definición de matrimonio del Art. 102 CC que establece que el matrimonio es un contrato solemne. Esta norma recoge un principio fundante y esencial de la ley matrimonial chilena, que puede ser considerado parte de su orden público, e incluso como una norma de policía, y que exige que el consentimiento matrimonial se exprese precisa y solemnemente. Por ello, un matrimonio meramente consensual en Chile no produciría efectos civiles porque atentaría contra un principio fundamental del ordenamiento jurídico chileno. La jurisprudencia chilena ha negado reconocimiento a estos matrimonios.

- c. **Validez del matrimonio celebrado en el extranjero ante agentes diplomáticos extranjeros:** algunos países otorgan a sus agentes diplomáticos la capacidad de casar a dos nacionales o a un nacional con un extranjero conforme a su ley nacional. Para que este matrimonio sea válido se requiere:
 - i. Que la ley del lugar de celebración autorice a agentes diplomáticos extranjeros a casar (en Chile la ley chilena no los autoriza).
 - ii. Que la ley del Estado a la cual pertenece el agente diplomático, lo autorice a casar. En este caso, el matrimonio se somete a las solemnidades de la ley del agente diplomático.

En cuanto a la prueba del matrimonio, en Chile, la existencia del matrimonio celebrado en el extranjero se prueba de la misma forma como se prueba en el lugar de celebración, vale decir, presentando un certificado de matrimonio o instrumento equivalente emitido por el Estado donde se celebró el matrimonio, debidamente legalizado o apostillado y traducido, si es necesario.

B.3. Normas reguladoras de los requisitos de validez sustanciales o de fondo del matrimonio: para determinar la ley que rige estos requisitos debemos distinguir si el matrimonio se celebra en Chile o en el extranjero; en ambos casos se aplica el principio *lex locus regit actum*, como regla general, aunque sujeto a algunos requisitos adicionales. Cabe hacer presente que la ley chilena dispone que todos los matrimonios válidos, celebrados en Chile o el extranjero, producen los mismos efectos que si se hubieran celebrado en Chile (Art. 80 LMC).

- 1. Requisitos de validez sustancial del matrimonio celebrado en Chile:** los rige la ley chilena por aplicación general del Art. 14 CC, que remite al Art. 80 LMC, que somete la validez de fondo del matrimonio a la ley del lugar de celebración del mismo (los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración). Todos los matrimonios celebrados en Chile, incluso el de dos extranjeros transeúntes, se rigen por la ley chilena y, concretamente por todos los requisitos de validez e impedimentos establecidos en la LMC.
- 2. Requisitos de validez sustancial del matrimonio celebrado en el extranjero:** al tenor de lo dispuesto en el Art. 80 LMC⁹, hay que concluir que la ley que rige estos requisitos de fondo es:
 - a.** En primer lugar, la ley del lugar de celebración del matrimonio. Los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. Un matrimonio que nace nulo en el extranjero, en conformidad a la ley de su lugar de celebración, siempre será o podrá ser declarado nulo en Chile.
 - b.** En segundo lugar, la ley chilena que impone otros requisitos de validez sustancial al matrimonio celebrado en el extranjero:
 - i.** Que se trate de un matrimonio heterosexual, siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer.
 - ii.** Que no se infrinjan los impedimentos dirimentes de la ley chilena contenidos en los artículos 5º, 6º y 7º de la ley de matrimonio civil: sin embargo, podrá ser declarado nulo de conformidad a la ley chilena, el matrimonio celebrado en país extranjero que se haya contraído en contravención a lo dispuesto en los artículos 5º, 6º y 7º de esta ley:
 - 1.** Art. 5 LMC: no podrán contraer matrimonio:
 - a.** Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto.
 - b.** Los que se hallaren ligados por un acuerdo de unión civil vigente, a menos que el matrimonio lo celebre con su conviviente civil.
 - c.** Los menores de dieciséis años.
 - d.** Los que se hallaren privados del uso de razón; y los que por un trastorno o anomalía psíquica, fehacientemente

⁹ Art. 80 LMC: los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. Así, el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad con las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno, siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer. / Sin embargo, podrá ser declarado nulo de conformidad a la ley chilena, el matrimonio celebrado en país extranjero que se haya contraído en contravención a lo dispuesto en los artículos 5º, 6º y 7º de esta ley. / Tampoco valdrá en Chile el matrimonio que se haya contraído en el extranjero sin el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes.

diagnosticada, sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio.

- e. Los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio.
 - f. Los que no pudieren expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea en forma oral, escrita o por medio de lenguaje de señas.
- 2. Art. 6 LMC: no podrán contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. / Los impedimentos para contraerlo derivados de la adopción se establecen por las leyes especiales que la regulan.
 - 3. Art. 7: el cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el imputado contra quien se hubiere formalizado investigación por el homicidio de su marido o mujer, o con quien hubiere sido condenado como autor, cómplice o encubridor de ese delito.

Si se infringe uno de estos impedimentos, el matrimonio, aunque sea válido en conformidad a la ley del lugar de celebración puede ser declarado nulo en Chile. Mientras no lo sea produce plenos efectos jurídicos.

- iii. Que los contrayentes hayan prestado su consentimiento libre y espontáneamente (tampoco valdrá en Chile el matrimonio que se haya contraído en el extranjero sin el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes). Hay dos ejemplos:

- 1. Un matrimonio paquistaní se traslada a vivir a Chile y la mujer demanda la nulidad del matrimonio alegando que tenía 12 años al momento de casarse o que el cónyuge es su medio-hermano por el lado paterno. Ese matrimonio, que puede ser válido en Paquistán, puede declararse nulo en Chile por infracción del impedimento dirimente del Art. 5 N°2 LMC o Art. 6 LMC.
- 2. Otro caso, imagínese que se trató del matrimonio de una mujer que fue raptada y obligada a casarse en la India, país donde ese matrimonio es perfectamente válido, si los esposos vienen a vivir a Chile se puede decretar aquí la nulidad de ese matrimonio, por falta de consentimiento libre y espontáneo de la mujer.

- 3. **Requisitos adicionales para el matrimonio en el extranjero de dos contrayentes chilenos o de un chileno/a con un extranjero/a:** en el caso de casarse en el extranjero dos chilenos o un contrayente chileno con uno extranjero, por producir el matrimonio un cambio de estado civil en el o los chilenos; él o los contrayentes chilenos quedan sujetos a los requisitos adicionales que exige la ley chilena para los que se casan en Chile, en virtud del Art. 15 N°1 CC (a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero; en lo relativo al estado de las personas). Esto significa, en la práctica, que estos chilenos quedan sujetos a los impedimentos impeditivos de la ley chilena. Estos impedimentos impeditivos no producen

la nulidad del matrimonio, pero su contravención trae aparejada sanciones específicas de índole patrimonial (posibilidad de desheredamiento, pérdida del derecho de remuneración del tutor, pérdida del derecho a suceder como legitimario del o heredero abintestato del hijo cuyo patrimonio se administró). Ellos son: (i) minoría de edad (Art. 105, Art. 107, Art. 111 y ss. CC); (ii) guarda (Art. 116 CC); y (iii) segundas nupcias (Art. 124 al Art. 127 CC¹⁰). Estos impedimentos se aplican siempre al contrayente chileno.

B.4. Inscripción en Chile del matrimonio celebrado en el extranjero: por disposición del Art. 80 LMC el matrimonio celebrado en el extranjero, en conformidad a los requisitos de esa norma es válido y produce efectos en Chile. Esto significa que no necesita inscribirse en Chile para producir efectos legales en el país. Sin embargo, los chilenos que se casan en el extranjero están obligados a inscribir su matrimonio en Chile en el Registro Civil de la Primera Sección de la Comuna de Santiago (Recoleta). Pueden hacer este trámite personalmente o por vía consular. La falta de inscripción produce como efecto que no pueden hacer valer en juicio en Chile ese matrimonio.

El Art. 4 de la Ley sobre Registro Civil (Nº4.808) dispone que en el libro de los matrimonios se inscribirán:

1. Los matrimonios que se celebren en el territorio de cada comuna.
2. Los matrimonios celebrados en artículo de muerte dentro del territorio de la República en la comuna correspondiente al lugar en que este acto se verifique.
3. Los matrimonios celebrados fuera del país por un chileno con un extranjero o entre dos chilenos, se inscribirán en el Registro de la Primera Sección de la comuna de Santiago. Para efectuar esta inscripción, cualquiera de los contrayentes remitirá, debidamente legalizados, los antecedentes que correspondan, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este Departamento verificará la autenticidad de los documentos y los enviará al Conservador del Registro Civil, quien dispondrá la inscripción en el Registro correspondiente.
4. Las sentencias ejecutoriadas en que se declare la nulidad del matrimonio o se decrete el divorcio perpetuo o temporal; la simple separación de bienes de los cónyuges; los instrumentos en que se estipulen capitulaciones matrimoniales y las sentencias ejecutoriadas que concedan a la mujer o a un curador, la administración extraordinaria de la sociedad conyugal y las que declaren la interdicción del marido. Estas subinscripciones podrán solicitarse también del Conservador del Registro Civil, quien ordenará que se haga la subinscripción en el libro de la comuna que corresponda.

A su vez, el Art. 8 dispone que las sentencias judiciales y los instrumentos que, en conformidad a esta ley, deben ser inscritos o sub-inscritos en los registros, no podrán hacerse valer en juicio sin que haya precedido la inscripción o subinscripción que corresponda. / Los nacimientos, los matrimonios y defunciones ocurridos en el extranjero y cuya inscripción no esté autorizada por los artículos anteriores, serán inscritos en los respectivos libros del Registro Civil Nacional cuando ello sea necesario para efectuar alguna inscripción o anotación prescrita por la ley. Estas inscripciones se efectuarán en el Registro de la Primera Circunscripción de la comuna de Santiago, para lo cual se exhibirá al Oficial del Registro Civil que corresponda el certificado de nacimiento, matrimonio o defunción legalizado.

¹⁰ Art. 128, Art. 129 y Art. 130 inc. 2 CC derogados por la Ley 21.264 (D.O. 11/09/2020).

B.5. Ejercicios sobre requisitos matrimoniales de forma y fondo:

(1.) Carlos Medwinsky y Esther Goldschmidt, chilenos-israelíes, se casan en Chile y luego, el año 2000, trasladan su domicilio a Israel. El año 2006 se divorcian extrajudicialmente en Israel y Carlos se casa nuevamente allí el año 2008, volviendo a Chile en el 2009 y falleciendo aquí a comienzos del 2010 intestado. Esther, que ha regresado a Chile el año 2006, demanda en Chile la nulidad del segundo matrimonio de Carlos alegando el impedimento de vínculo matrimonial no disuelto y, consecuentemente, solicita que se le reconozcan sus derechos hereditarios sobre la sucesión de Carlos. Si Ud. es el abogado de Esther, ¿qué argumentos legales esgrimiría en apoyo de su demanda?

1. Hechos jurídicamente relevantes:
 - a. Chilenos-israelíes se casan en Chile.
 - b. Se divorcian extrajudicialmente en Israel.
 - c. El marido se casa en Israel, volviendo a Chile y falleciendo allí.
 - d. Se demanda nulidad del segundo matrimonio y reconocimiento de derechos hereditarios.
2. Problema jurídico: hay una cuestión previa (validez del divorcio y validez del segundo matrimonio como cuestión previa y los derechos hereditarios de Esther como cuestión principal).
3. Argumentos: se aplica el Art. 15 N°1 CC, rigiendo la ley chilena, en concreto, el Art. 83 LMC, de manera que es inválido el divorcio extrajudicial, siendo nulo el segundo matrimonio.

(2.) Un griego Stavros Kyprios domiciliado en Londres fallece intestado, dejando bienes muebles en Inglaterra y Chile. La norma de conflicto inglesa somete la sucesión mortis causa de los muebles a la ley del último domicilio del causante. La viuda, también griega, reclama una parte de su herencia ante los tribunales chilenos; sin embargo, los hermanos de Kyprios se oponen a su petición alegando que su matrimonio con Kyprios es nulo por haberse contraído en Inglaterra ante un notario, sin ceremonia religiosa, forma válida de hacerlo en Inglaterra pero no conforme a la ley Griega que exige a los griegos ortodoxos casarse en matrimonio religioso ya sea en Grecia o en el extranjero. Señale cómo debe resolver este problema el juez chileno y que ley o leyes aplicaría para hacerlo.

1. Hechos jurídicamente relevantes:
 - a. Griego domiciliado en Londres fallece intestado.
 - b. Bienes muebles en Inglaterra y Chile.
 - c. La norma inglesa somete la regla sucesoria sobre bienes muebles al último domicilio del causante.
 - d. Viuda griega y reclama parte de la herencia ante tribunales chilenos.
 - e. Hermanos del causante alegan que el matrimonio es nulo por no haberse ajustado a las formalidades griegas.
2. Problema jurídico: validez del matrimonio.
3. Normas aplicables: Art. 80 LMC, requisitos según lugar de celebración, esto es, ley inglesa, siendo válido el matrimonio.

(3.) Carlos Pérez, chileno y Marie Villenot, francesa, se casan en Londres ante el cónsul francés el año 2015 y se trasladan a vivir a Chile el año 2016. El año 2019, Marie solicita la nulidad de su

matrimonio ante un Juzgado de Valparaíso. ¿Qué causales de nulidad puede invocar para fundamentar su petición?

1. Hechos jurídicamente relevantes:
 - a. Chileno y francesa se casan en Londres ante cónsul francés.
 - b. Se trasladan a vivir en Chile.
 - c. Solicitud de nulidad en Valparaíso.
2. Problema jurídico: causales de nulidad invocables.
3. Norma aplicable: Art. 80 LMC, requisitos de la ley del lugar de celebración (ley inglesa), pero hay que ver si ésta autoriza a diplomáticos extranjeros a casar en su territorio y determinar si la ley francesa lo autoriza a casar. Se podría alegar, además, inexistencia de consentimiento o algún otro impedimento dirimente Art. 5, Art. 6 y Art. 7 LMC.

B.6. Disolución del matrimonio: el Art. 42 LMC establece las causales de disolución del matrimonio que se reconocen en la ley chilena. Dispone la norma que el matrimonio termina: (i) por la muerte de uno de los cónyuges; (ii) por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados en el artículo siguiente; (iii) por sentencia firme de nulidad; y (iv) por sentencia firme de divorcio.

1. **Muerte Natural:** la muerte es un hecho que hay que acreditar o certificar. Para efectos del DIPRI, interesa determinar el modo de hacer constatar en Chile que un matrimonio se disolvió por la muerte de una persona.
 - a. Si la muerte natural ocurre en Chile, basta acreditarla presentando un certificado de defunción que se subinscribe al margen de la partida de matrimonio.
 - b. Si la muerte natural ocurre en el extranjero, debe probarse por los certificaciones e instrumentos públicos establecidos por la ley del lugar donde acaeció. En este caso, deberá presentarse al Registro Civil en Chile un instrumento extranjero debidamente apostillado o legalizado y, si es necesario, traducido que certifique la muerte del cónyuge. El Registro Civil procederá a inscribir en Chile la defunción y a subinscribirla al margen de la inscripción del matrimonio en Chile.
 - c. En el caso de la muerte de cualquier chileno en el extranjero, su defunción debe ser inscrita en el Registro Civil chileno (Art. 5 Ley Registro Civil¹¹), si se omite esta inscripción, su muerte no podrá ser probada en juicio (Art. 8 Ley Registro Civil).
 - d. En el caso de la muerte de un extranjero en el extranjero puede hacerse la inscripción de su defunción en el Registro Civil chileno para los efectos de subinscribirla al margen de la inscripción matrimonial (Art 8 inc. 2 Ley Registro Civil). Para eso hay que presentar el certificado de defunción extranjero debidamente legalizado o apostillado.
2. **Muerte Presunta:** la muerte presunta, o declaración de fallecimiento, es una situación jurídica constituida por la declaración judicial que presume el fallecimiento de una persona y fija la fecha presuntiva de su muerte pese a no haberse podido encontrar su cadáver para determinarla médicamente. Esta declaración la realiza el juez tras el correspondiente

¹¹ Art. 5 LRC: en el libro de las defunciones se inscribirán (3) las defunciones de chilenos ocurridas en el extranjero. Para efectuar esta inscripción se remitirán los documentos debidamente legalizados al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este Departamento verificará la autenticidad de los documentos y los enviará al Conservador del Registro Civil, a fin de que disponga la inscripción en el Registro de la comuna correspondiente. / Las defunciones de los hijos de chilenos ocurridas en el extranjero, podrán, asimismo, ser inscritas en la forma dispuesta precedentemente.

procedimiento judicial respecto de personas de quienes no se ha tenido noticias por un determinado tiempo establecido legalmente; o respecto de personas que por haber desaparecido en circunstancias tales es posible presumirlas fallecidas.

La muerte presunta debe distinguirse de la declaración de ausencia, que simplemente permite la administración de los bienes del ausente. La declaración de muerte presunta permite declarar a la persona que ha desaparecido como fallecida, a fin de que sus familiares puedan disponer de sus bienes y acceder a las prestaciones que, en su caso, puedan derivarse de su muerte, además disuelve el matrimonio de la persona declarada muerta presuntivamente.

Hay que distinguir:

- a. **Muerte presunta declarada en Chile:** por aplicación del Art. 14 CC ella se registrará por las leyes chilenas. La muerte presunta aparece reglamentada en el Art. 80 al Art. 94 CC, con plazos y causales específicas. Le compete declararla, según dice el Art. 81 N°1 del CC, al juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile y la sentencia debe inscribirse en el Registro de Defunciones del Registro Civil de la comuna que corresponda al tribunal que hizo la declaración (Art. 5 N°5 Ley Registro Civil).

El Art. 81 N°1 CC dispone que la presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile, justificándose previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia, han transcurrido a lo menos cinco años.

Además, el legislador ha regulado la terminación del matrimonio por muerte presunta, en el caso de que la muerte presunta sea declarada en Chile. El Art. 43 LMC dispone que:

- i. El matrimonio termina por la muerte presunta de uno de los cónyuges, cuando hayan transcurrido diez años desde la fecha de las últimas noticias, fijada en la sentencia que declara la presunción de muerte.
- ii. El matrimonio también se termina si, cumplidos cinco años desde la fecha de las últimas noticias, se probare que han transcurrido setenta años desde el nacimiento del desaparecido. El mismo plazo de cinco años desde la fecha de las últimas noticias se aplicará cuando la presunción de muerte se haya declarado en virtud del número 7 del artículo 81 del Código Civil ((herida de guerra o grave peligro)).
- iii. En el caso de los números 8 y 9 del artículo 81 del Código Civil, el matrimonio se termina transcurrido un año desde el día presuntivo de la muerte.
- iv. El posterior matrimonio que haya contraído el cónyuge del desaparecido con un tercero, conservará su validez aun cuando llegare a probarse que el desaparecido murió realmente después de la fecha en que dicho matrimonio se contrajo.

Entonces, cuando la muerte presunta es declarada en Chile:

- i. La ley aplicable es la ley chilena (Art. 14 CC).
- ii. El juez competente es el del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile (Art. 81 N°1 CC).
- iii. Esta sentencia de declaración de muerte presunta deberá inscribirse en el Registro de Defunciones del Registro Civil y al margen de la inscripción matrimonial para producir la extinción del matrimonio. Con la siguiente excepción: en el caso de las causales señaladas en el Art 81 N°8 (desaparición en pérdida de nave o aeronave) y N°9 (desaparición en sismo o catástrofe) el matrimonio se termina después de 1 año del día presuntivo de la muerte.

Finalmente, está el caso de la muerte cierta. En los casos en que la muerte puede ser tenida como cierta, se puede solicitar que el juez declare la muerte sin esperar el plazo largo de desaparición propio de la muerte presunta. En este caso, el juez competente también será el del último domicilio que haya tenido el difunto en Chile.

El Art. 95 CC dispone que toda vez que la desaparición de una persona se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte pueda ser tenida como cierta, aun cuando su cadáver no fuere hallado, el juez del último domicilio que el difunto haya tenido en Chile, a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello, podrá tener por comprobada su muerte para efectos civiles y disponer la inscripción de la resolución correspondiente en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuere posible la identificación del cadáver.

¿Cuándo es el juez chileno competente para declarar la muerte presunta? Si el desaparecido no ha tenido domicilio en Chile, al juez chileno no le compete declarar su muerte presunta según lo dispone el Art 81 N°1 CC y ésta no se registrará por las leyes chilenas. El profesor Hernán Corral extiende la competencia del juez chileno a declarar la muerte presunta de chilenos domiciliados en el extranjero. Se basa en una interpretación amplia del Art. 15 N°1 CC. El argumenta que la muerte es una extinción de personalidad y supone un cambio de estado civil de la persona, que quedaría sometida a la ley chilena. Por ello, el juez chileno podría declarar la muerte presunta de un chileno, aunque éste no haya tenido último domicilio en Chile. Esta postura ha sido acogida en la jurisprudencia nacional. En este sentido, los tribunales chilenos han declarado la muerte presunta de chilenos con último domicilio en el extranjero, aunque hayan desaparecido en el extranjero haciéndoles extensiva la jurisdicción chilena.

- b. **Muerte presunta declarada en el extranjero:** aquí el problema de DIPRI radica en identificar la ley aplicable para determinar la muerte presunta en el extranjero y el juez competente. Nuestra legislación no tiene una norma de conflicto que resuelva este problema. En este aspecto, el Art. 82 CB, dice que todo lo que se refiera a la presunción de muerte del ausente y a sus derechos eventuales, se regula por su ley personal. Entonces, el Art. 82 CB remite a la ley personal del ausente. La ley personal del ausente podría ser, según el Art. 7 CB: (i) la ley de su domicilio; o (ii)

la ley de su nacionalidad u otra adoptada por la legislación. Es decir, el CB no llena el vacío legal. El juez podría bilateralizar el Art. 81 N°1 CC y aplicar a la muerte presunta declarada en el extranjero la ley del último domicilio del desaparecido y sostener que el juez competente para declararla es el de ese domicilio.

Además, está la necesidad del exequátur de la sentencia de muerte presunta extranjera. Toda sentencia de declaración de muerte presunta extranjera debe obtener el exequátur para hacerse valer en Chile, conforme a las normas generales de reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras en Chile contenidas en el Art. 242 y ss. CPC. Una vez otorgado el exequátur la sentencia debe inscribirse en el Registro de Defunciones del Registro Civil para poder hacerse valer como medio de prueba en juicio. Los autores discuten acerca de si se reconocería en Chile una declaración de muerte presunta extranjera puramente administrativa, no judicial.

3. Nulidad Matrimonial: al respecto cabe distinguir entre la nulidad del matrimonio declarada en Chile y la declarada en el extranjero.

a. Nulidad del matrimonio declarada en Chile: si se declara en Chile, se aplican las leyes chilenas, Art. 14 CC. Se aplicará específicamente, el Art. 80 LMC y para ello se debe distinguir entre el matrimonio celebrado en Chile y el matrimonio celebrado en el extranjero.

i. Nulidad declarada en Chile del matrimonio celebrado en Chile: se aplica la ley chilena y, en consecuencia, procede aplicar sólo las causales de nulidad de la LMC chilena (Art. 14 y Art. 80 LMC) que remite a las causales de nulidad de la ley del lugar de celebración, que en este caso, es Chile.

ii. Nulidad declarada en Chile del matrimonio celebrado en el extranjero: conforme al Art. 80 LMC, los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. De acuerdo al Art. 80 LMC se podrían alegar como causales de nulidad:

1. Las causales de nulidad del lugar de celebración del matrimonio.
2. La infracción de los impedimentos dirimentes de la LMC chilena, vale decir, de los contenidos en el Art. 5, Art. 6 y Art. 7 LMC.
3. La ausencia de consentimiento libre y espontáneo.

Además, la falta de heterosexualidad puede alegarse como causal de inexistencia del matrimonio (Art. 80 LMC).

b. Nulidad del matrimonio declarada en el extranjero: la sentencia de nulidad extranjera deberá someterse en Chile al trámite del exequátur y cumplir con todos sus requisitos de procedencia, para después subinscribirse al margen de la inscripción de matrimonio.

4. Divorcio (Art. 83 LMC¹²):

¹² Art. 83 LMC: el divorcio estará sujeto a la ley aplicable a la relación matrimonial al momento de interponerse la acción. / Las sentencias de divorcio y nulidad de matrimonio dictadas por tribunales extranjeros serán reconocidas en Chile conforme a las reglas generales que establece el Código de Procedimiento Civil. / En ningún caso tendrá valor en Chile el divorcio que no haya sido declarado por resolución judicial o que de otra manera se oponga al orden público chileno. / Tampoco se reconocerá valor a las sentencias obtenidas en fraude a la ley. Se entenderá que se ha actuado en fraude a la ley cuando el divorcio ha sido declarado bajo una jurisdicción distinta a la chilena, a pesar de que los cónyuges hubieren tenido domicilio en Chile durante

- a. **Divorcio declarado en Chile:** si el divorcio es declarado en Chile porque el juez chileno es competente, obviamente, las causales de divorcio que él va a aplicar serán las de la ley chilena porque toda relación matrimonial de los habitantes de Chile queda regida por la ley chilena (Art. 14 CC, Art. 80 y Art. 83 LMC). El juez chileno es competente para declarar el divorcio de los matrimonios en que, al menos, uno de los cónyuges esté domiciliado en Chile al momento de interponerse la acción. Además, el Art. 83 LMC le da jurisdicción exclusiva al juez chileno cuando ambos cónyuges están domiciliados en Chile o hayan estado domiciliados en Chile durante los tres o cinco años anteriores a la acción de divorcio, dependiendo si hay acuerdo en la fecha de cese de convivencia de las partes o no.
- b. **Divorcio declarado en el extranjero:** las sentencias de divorcio extranjero deberán ser sometidas al trámite del exequátur para hacerse valer en Chile. El matrimonio se entenderá disuelto en Chile desde la fecha de inscripción de esa sentencia de divorcio al margen de la inscripción de matrimonio en el registro Civil Chileno. El Art. 83 LMC obliga a distinguir entre:
 - i. **Divorcio entre dos chilenos o un chileno y un extranjero:** el divorcio del matrimonio de un chileno o de dos chilenos en el extranjero, queda regido por el Art. 15 N°1 CC ya que produce un cambio de estado civil, es decir, queda sometido a la ley chilena. Esto es confirmado por el Art. 83 LMC que somete el divorcio a la ley aplicable a la relación matrimonial al momento de interponerse la acción, esta ley para los chilenos es la ley chilena. Esto significa que para que ese divorcio decretado en el extranjero sea válido en Chile, tiene que ser:
 - 1. Un divorcio judicial.
 - 2. No puede ser contrario al orden público chileno ni otorgado con fraude a la ley chilena.
 - 3. Además las causales por las cuales se dicte tienen que ser autorizadas por la ley chilena, porque se trata de chilenos cambiando de estado civil. Por ejemplo, la Corte Suprema ha denegado el exequátur a sentencias de divorcio extranjeras pronunciadas sin causal.
 - ii. **Divorcio entre dos extranjeros en el extranjero:** aquí el Art. 83 LMC dice que este divorcio se rige por la ley que rige la relación matrimonial al momento de interponerse la acción. Por lo tanto, habrá que ver cuál era la ley que regía la relación matrimonial según la ley del lugar donde se dictó el divorcio; por ejemplo, si el divorcio se dictó en Francia se tendrá que ver cuál era la ley que regía la relación matrimonial de esas personas en Francia al momento de interponerse la acción de divorcio, y esa ley será la ley que aportará las causales y requisitos para la procedencia del divorcio. Además, este divorcio para que tenga validez en Chile debe ser otorgado por

cualquiera de los tres años anteriores a la sentencia que se pretende ejecutar, si ambos cónyuges aceptan que su convivencia ha cesado a lo menos ese lapso, o durante cualquiera de los cinco años anteriores a la sentencia, si discrepan acerca del plazo de cese de la convivencia. El acuerdo o la discrepancia entre los cónyuges podrá constar en la propia sentencia o ser alegado durante la tramitación del exequátur.

resolución judicial y no puede ser contrario al orden público nacional ni obtenido con fraude a la ley chilena.

El Art. 83 inc. 4 LMC dispone que se entenderá que se ha actuado en fraude a la ley cuando el divorcio ha sido declarado bajo una jurisdicción distinta a la chilena, a pesar de que los cónyuges hubieren tenido domicilio en Chile durante cualquiera de los tres años anteriores a la sentencia que se pretende ejecutar, si ambos cónyuges aceptan que su convivencia ha cesado a lo menos ese lapso, o durante cualquiera de los cinco años anteriores a la sentencia, si discrepan acerca del plazo de cese de la convivencia. El acuerdo o la discrepancia entre los cónyuges podrá constar en la propia sentencia o ser alegado durante la tramitación del exequátur.

c. Efectos del divorcio: el Art. 84 LMC dice la ley que rija el divorcio y la nulidad del matrimonio se aplicará también a sus efectos.

- i. Efectos del divorcio decretado en Chile:** el divorcio decretado en Chile se rige por la ley chilena y, por lo tanto, produce los efectos que la ley chilena le otorga, Art. 14 CC.
- ii. Efectos del divorcio decretado en el extranjero:** para producir efectos en Chile, la sentencia de divorcio extranjero requiere de exequátur, si el matrimonio estaba inscrito en Chile o debiera haber estado inscrito en Chile. Ese divorcio produciría efectos en Chile desde la fecha de la subinscripción de la sentencia en el Registro Civil chileno.

Si el matrimonio no estaba inscrito en Chile ni debía estarlo, bastaría acreditar el divorcio conforme se acredita en el lugar donde se pronunció. Por ejemplo, presentando un instrumento público que indique que esa persona tiene la calidad de divorciado, debidamente legalizado o apostillado en Chile.

En todo caso, ese divorcio que se ha regido por una ley extranjera produce en Chile los mismos efectos que la ley extranjera le otorga; con la excepción del divorcio de uno o dos chilenos que, por disposición del Art. 15 N°1 CC produce los efectos que le otorga la ley chilena ya que supone un cambio de estado civil.

5. Separación Judicial: no es una causal de disolución del matrimonio. El legislador la reguló como un trámite previo al divorcio, que termina el régimen matrimonial, hace cesar el deber de fidelidad y la presunción de paternidad y otorga un estado civil nuevo: el de separado judicialmente.

- a. Separación judicial solicitada en Chile:** se rige por la ley chilena según lo dispone la norma general del Art. 14 CC, que remite al Art. 21 al Art. 41 LMC.
- b. Separación judicial solicitada en el extranjero:** la sentencia judicial de separación judicial dictada en el extranjero requiere de exequátur para hacer valer sus efectos en Chile. En relación con la ley aplicable a esta separación judicial, hay que distinguir si alguno de los cónyuges es chileno o no:

- i. **Si la separación judicial solicitada en el extranjero se refiere al matrimonio de un chileno con un extranjero o de dos chilenos:** como la separación comporta en Chile un cambio de estado civil, se aplica el Art. 15 N°1 CC al cónyuge chileno y, por lo tanto, se le aplica la ley chilena, es decir, las normas de la LMC chilena y produce los efectos que esta ley le otorga. En consecuencia, se le otorgará el exequátur a la sentencia de separación si ha sido dictada por un tribunal competente por causales análogas a las de la LMC chilena.
- ii. **Si la separación judicial extranjera se refiere al matrimonio de dos extranjeros:** no existe norma en la legislación chilena para determinar la ley aplicable a esta separación, por lo tanto, para determinar sus efectos, el juez chileno deberá decidir qué ley aplicar; una posibilidad, que parece razonable, es aplicar por analogía la solución del Art. 84 LMC respecto al divorcio y nulidad, en cuyo caso aplicaría a la separación los efectos señalados en la ley que la rigió en el extranjero, que pueden ser distintos a los establecidos en la ley chilena. La otra opción es aplicar a esos efectos la ley chilena por aplicación de Art. 14 CC pero, cabría la posibilidad que ella le otorgara efectos distintos o más amplios que los que le otorga la ley que la dictó.

Finalmente, hay que referir a la inscripción del certificado de defunción, de la sentencia de muerte presunta, nulidad, divorcio y separación judicial. Estos instrumentos deben ser inscritos en el Registro Civil chileno y subinscritos al margen de la inscripción del matrimonio para producir efectos jurídicos en Chile. La falta de inscripción produce como efecto que no pueden probarse en juicio en Chile la disolución o separación judicial de ese matrimonio.

El Art. 4 de la Ley sobre Registro Civil dispone que en el libro de los matrimonios se inscribirán:

1. Los matrimonios que se celebren en el territorio de cada comuna.
2. Los matrimonios celebrados en artículo de muerte dentro del territorio de la República en la comuna correspondiente al lugar en que este acto se verifique.
3. Los matrimonios celebrados fuera del país por un chileno con un extranjero o entre dos chilenos, se inscribirán en el Registro de la Primera Sección de la comuna de Santiago. Para efectuar esta inscripción, cualquiera de los contrayentes remitirá, debidamente legalizados, los antecedentes que correspondan, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este Departamento verificará la autenticidad de los documentos y los enviará al Conservador del Registro Civil, quien dispondrá la inscripción en el Registro correspondiente.
4. Las sentencias ejecutoriadas en que se declare la nulidad del matrimonio o se decrete el divorcio perpetuo o temporal; la simple separación de bienes de los cónyuges; los instrumentos en que se estipulen capitulaciones matrimoniales y las sentencias ejecutoriadas que concedan a la mujer o a un curador, la administración extraordinaria de la sociedad conyugal y las que declaren la interdicción del marido. Estas subinscripciones podrán solicitarse también del Conservador del Registro Civil, quien ordenará que se haga la subinscripción en el libro de la comuna que corresponda.

El Art. 8 LRC dispone que las sentencias judiciales y los instrumentos que, en conformidad a esta ley, deben ser inscritos o subinscritos en los registros, no podrán hacerse valer en juicio sin que haya precedido la inscripción o subinscripción que corresponda. / Los nacimientos, los matrimonios y defunciones ocurridos en el extranjero y cuya inscripción no esté autorizada por los artículos anteriores, serán inscritos en los respectivos libros del Registro Civil Nacional cuando ello sea necesario para efectuar alguna inscripción o anotación prescrita por la ley. Estas inscripciones se efectuarán en el Registro de la Primera Circunscripción de la comuna de Santiago, para lo cual se exhibirá al Oficial del Registro Civil que corresponda el certificado de nacimiento, matrimonio o defunción legalizado.

B.7. Ejercicios Prácticos de Disolución de Matrimonio:

(1.) Abud Salamah, turco, se casa en Ankara (Turquía) con Ranuh Ashmir, también turca, el año 2010 bajo el rito musulmán. El año 2016, Abud otorga en Ankara un divorcio repudio a Ranuh frente a dos testigos, conforme a la Sharia y válido en Turquía. El año 2018 Abud se viene a vivir a Chile y quiere casarse con Zafir, una pariente lejana nacida en Chile. Analice su situación legal.

1. Hechos jurídicos relevantes:
 - a. Dos turcos se casan en Turquía bajo rito musulmán.
 - b. Se otorga divorcio repudio en Turquía y válido ahí.
 - c. Marido se traslada a Chile y se quiere casar ahí con una pariente lejana.
2. Problema jurídico: capacidad para casarse, para lo cual se debe averiguar su estado civil de Abud y, para ello, determinar la validez del divorcio.
3. Normas aplicables: Art. 83 LMC.
4. Solución o soluciones: requisitos del divorcio en el extranjero (por resolución judicial, respeto por el orden público, no haya fraude a la ley chilena y que se rija por la ley que rige la relación matrimonial al momento de interponerse la acción). La relación matrimonial se regía por la ley musulmana (Sharia), siendo válido, conforme a ella, el divorcio ante dos testigos. Entonces, el divorcio es válido en Turquía, pero no será válido en Chile porque no se otorgó por resolución judicial. Entonces, no puede casarse Abud porque hay un impedimento dirimente por vínculo matrimonial no disuelto (Art. 5 LMC).

(2.) Ana María Pérez, chilena, es casada con Jean Filliol, francés, ambos están domiciliados en París, el matrimonio tiene dos predios agrícolas en Chile que son propiedad de la sociedad conyugal. En noviembre del año 2018, Jean desaparece en una expedición de alpinismo al Mont Blanc sin que se encuentren sus rastros o su cadáver. Ana María le consulta acerca de cuál es en Chile la situación legal de Jean, de la posibilidad de tramitar su sucesión y de cómo y dónde tramitarla.

1. Hechos jurídicos relevantes:
 - a. Chilena se casa con francés, domiciliados en París, con sociedad conyugal y dos predios agrícolas en Chile.
 - b. Jean desaparece en expedición, sin que se encuentren sus rastros o cadáver.
 - c. Ana María tiene inquietudes jurídicas.
2. Problema jurídico: determinar la muerte para, eventualmente, determinar la apertura de la sucesión y la disolución del matrimonio con la consecuente disolución de la sociedad conyugal. Por otra parte, declarada la muerte, determinar dónde tramitar la sucesión.

3. Normas aplicables: Art. 955 CC (apertura y ley que rige la sucesión), Art. 42 LMC (muerte natural o presenta determina disolución del matrimonio), Art. 43 LMC (plazos de disolución por muerte presunta), Art. 81 N°1 CC (muerte presunta se solicita ante juez del último domicilio del desaparecido) y Art. 8 RC (inscripción).
4. Solución o soluciones:
 - a. Lo primero será solicitar la muerte presunta en Francia.
 - b. Con la sentencia de muerte presunta, tramitar exequátur de la sentencia en Chile.
 - c. Subinscripción de la sentencia en el registro matrimonial.
 - d. Cómputo del plazo para determinar disolución del matrimonio y la fecha de muerte produce la delación de la herencia.
 - e. La sucesión se abrirá en Francia (Art. 955 CC). Sobre los dos inmuebles, habrá que solicitar la posesión efectiva.

(3.) Omar Acnur y Anisa Bashir, ambos pakistaníes, se casan en Chile el año 2010 y se trasladan a vivir a Pakistán el año 2011. Allí anulan judicialmente su matrimonio argumentando haber sido amamantados por la misma nodriza cuando niños, impedimento dirimente contenido en la Sharia, ley vigente en Pakistán. Omar regresa a Chile y solicita aquí el exequátur de la sentencia de nulidad matrimonial. Analice el caso.

1. Hechos jurídicos relevantes:
 - a. Matrimonio pakistaní en Chile.
 - b. Se trasladan a Pakistán y anulan judicialmente el matrimonio, arguyendo impedimento dirimente de hermanos de leche.
 - c. Solicitud de exequátur en Chile de la sentencia pakistaní de nulidad matrimonial.
2. Problema jurídico: determinar la validez de la sentencia de nulidad pakistaní en Chile.
3. Normas aplicables: Art. 80 LMC (requisitos de validez del matrimonio: ley de lugar de celebración del matrimonio, en este caso, ley chilena).
4. Solución o soluciones: no se puede invalidar en Chile el matrimonio, ya que el impedimento dirimente de hermanos de leche no es tal bajo la legislación chilena. La Corte no debe conceder el exequátur.

(4.) Carlos Céspedes y Anita Cerda, chilenos, se casan en Chile el año 2000 y se trasladan a vivir a Australia el año 2004. En Australia Anita solicita la nulidad de su matrimonio por reiteradas infidelidades de su marido antes y después de su matrimonio, la sentencia de nulidad se dicta el año 2010. Anita regresa ese mismo año y solicita el exequátur de la sentencia ante la Corte Suprema para que se reconozca en Chile. Analice su situación legal.

1. Hechos jurídicos relevantes:
 - a. Dos chilenos se casan en Chile.
 - b. Se solicita en Australia nulidad del matrimonio por reiteradas infidelidades.
 - c. Se dicta sentencia y se solicita exequátur en Chile.
2. Problema jurídico: validez de la nulidad de matrimonio decretada en Australia.
3. Normas aplicables: Art. 15 N°1 CC y Art. 80 LMC. La nulidad de este matrimonio queda sometido a la ley chilena, solamente pudiendo invocarse las causales de nulidad chilena. Bajo la ley chilena, la reiterada infidelidad no es causal de nulidad, siendo válido ese matrimonio en Chile.

4. Solución o soluciones: la Corte no debe otorgar el executur a la sentencia de nulidad extranjera.

B.8. Efectos del Matrimonio: el matrimonio produce efectos jurídicos entre los cónyuges, es decir crea derechos y obligaciones mutuas para ellos. Estos efectos pueden clasificarse en: (i) efectos personales; y (ii) efectos patrimoniales.

1. **Efectos personales del matrimonio:** son las obligaciones personales que surgen a raíz del matrimonio para ambos cónyuges, como el deber de ayuda mutua, de cohabitación en el hogar común, de fidelidad, entre otros (Art. 131 CC a Art. 134 CC). Los casados en Chile, los cónyuges que habiten en Chile y los cónyuges transeúntes, se rigen en cuanto a los efectos personales del matrimonio, íntegramente por la Ley Chilena (por aplicación del Art. 14 CC y del Art. 80 y Art. 81 LMC), aunque sean extranjeros, casados en el extranjero y domiciliados en el extranjero.

El Art. 81 LMC dispone que los efectos de los matrimonios celebrados en Chile se registrarán por la ley chilena, aunque los contrayentes sean extranjeros y no residan en Chile. A su vez, el Art. 80 inc. 1 LMC dispone que los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. Así, el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad con las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno, siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer.

En el caso de dos chilenos casados en el extranjero, por aplicación del Art. 15 N°2 CC que somete los derechos y obligaciones del chileno respecto de su cónyuge chileno a la ley chilena, su matrimonio SIEMPRE se registrará por la Ley Chilena en nuestra legislación, aunque NO vivan en Chile. En definitiva, para nuestra legislación, los efectos personales de los matrimonios celebrados tanto en Chile como en el extranjero están regidos por la ley chilena.

2. **Efectos patrimoniales del matrimonio:** existen sistemas jurídicos en los que el matrimonio produce un efecto jurídico en el patrimonio de los cónyuges y otros en que no lo produce, por ejemplo, en las jurisdicciones del *common law*. En aquellos en que sí lo produce se habla de la constitución de un régimen patrimonial matrimonial especial con normas que regulan el patrimonio de los cónyuges, su administración y reparto para garantizar una solución justa y previsible a sus problemas patrimoniales.

En las normas de DIPRI de los distintos Estados que regulan los regímenes matrimoniales hay diferencias en relación a: (i) unicidad¹³ o multiplicidad¹⁴ del régimen matrimonial; (ii) permanencia en el tiempo y espacio del régimen matrimonial; y (iii) factor de conexión¹⁵ para determinar la ley aplicable al régimen matrimonial y la posibilidad de elección de la ley

¹³ Un único régimen permanente.

¹⁴ Establecen cambio de régimen o varios regímenes según territorio donde estén los bienes o los cónyuges.

¹⁵ Por ejemplo, Suiza establece que la ley que rige la relación es la del primer domicilio del matrimonio (se casan en Suiza, pero se establecen en Bélgica, rige la ley belga), otros por la ley de nacionalidad común de los cónyuges (se casan en Inglaterra, pero son franceses, aplica la ley francesa), otros establecen que las partes pueden elegir, otros establecen una regla imperativa (como en Chile).

aplicable por las partes (autonomía de la voluntad) y determinación de ley supletoria en ausencia de elección.

En las normas internas que rigen los regímenes legales patrimoniales hay un rasgo común. En general, se deja en libertad a los contrayentes para elegir entre los diversos regímenes legales contemplados en la ley interna y, en el caso de que no elijan, se determina un régimen legal supletorio. En los distintos sistemas jurídicos nacionales hay diversidad de regímenes legales supletorios: comunidad de bienes, participación en los gananciales, separación de bienes.

La globalización mundial ha producido un aumento de conflictos de ley en relación al patrimonio conyugal porque ha causado: (i) un aumento de la diferencia de nacionalidad entre los cónyuges; (ii) su mayor migración de un país a otro; y (iii) una adquisición creciente de bienes en distintos países durante la vigencia del matrimonio.

En cuanto a la definición o noción de régimen matrimonial patrimonial, por régimen matrimonial se entiende el conjunto de normas legales que regulan las consecuencias que el matrimonio produce en la propiedad, uso, goce y administración de los bienes de los cónyuges durante su vigencia y después de su disolución, incluyendo los eventuales derechos de terceros o acreedores sobre estos bienes.

En cuanto a las normas chilenas reguladoras de los regímenes matrimoniales, la legislación distingue entre matrimonios celebrados en Chile y matrimonios celebrados en el extranjero.

- a. **Matrimonios celebrados en Chile:** el régimen patrimonial de los casados en Chile se rige por la ley chilena por disposición del Art. 14 CC que remite al Art. 135 inc. 1 CC que dice que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, y toma el marido la administración de los de la mujer, según las reglas que se expondrán en el título de la sociedad conyugal. Es lo que se denomina el régimen legal supletorio o default, esto es, la sociedad conyugal de bienes y que se aplica a todos los casados en Chile. Es decir, la ley chilena para los casados en Chile: (i) establece la existencia de un régimen matrimonial; (ii) les permite la elección de régimen en convenciones matrimoniales y el cambio sucesivo del régimen en ciertos casos; y (iii) les determina como régimen legal supletorio el de comunidad de bienes.
- b. **Matrimonios celebrados en el extranjero:** por disposición del Art. 14 CC que remite a la aplicación del Art. 135 inc. 2 CC, el régimen matrimonial de los casados en el extranjero queda regido en Chile por la ley chilena que (actualmente): (i) dispone en el Art. 135 inc. 2 CC un régimen territorial imperativo para todos los casados en el extranjero; (ii) no reconoce efectos a los regímenes matrimoniales adquiridos en el extranjero por esos cónyuges; y (iii) establecen un sistema de multiplicidad de regímenes matrimoniales para migrantes o quienes tienen bienes ubicados en diversos países. Estos regímenes quedan regulados por el Art. 135 inc. 2 CC en su redacción original y en su redacción modificada por la Ley 18.802 de 1989 y la Ley 19.335 de 1994. Esto es importante porque, actualmente, existen

situaciones regidas por alguna de las dos normas. Cualquiera de ellas establece un régimen legal imperativo.

Corresponde efectuar un análisis del Art. 135 inc. 2 CC. A la mayoría de los casados en el extranjero se les aplica el Art. 135 inc. 2 CC en su redacción actual que establece que los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago, y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción. Así, el régimen legal supletorio es la separación de bienes, salvo que pacten sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales. Esta norma se aplica a los que se hayan casado en país extranjero y no se exige que vivan o estén domiciliado en Chile.

Sin embargo, a otros matrimonios se les aplica todavía la redacción original de Andrés Bello que señala que los que se hayan casado en país extranjero y pasaren a domiciliarse en Chile, se mirarán como separados de bienes, siempre que en conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido entre ellos sociedad de bienes. A la profesora le gusta más la redacción original.

Entonces: ¿cuál es la diferencia entre las normas? ¿qué matrimonios son regidos por cada una? ¿cuál es el régimen patrimonial anterior de dichos matrimonios? Por una parte, la redacción original permite una continuidad de la sociedad de bienes contraída bajo ley extranjera (permitía unidad y continuidad del régimen matrimonial patrimonial), mientras que la redacción actual mira a los extranjeros como separados de bienes (cualquiera que sea el régimen bajo el cual se casaron), salvo que inscriban el matrimonio y ahí pacten comunidad de bienes o régimen de participación en los gananciales. Ahora bien, el problema está en que el periodo previo a la inscripción del matrimonio y el pacto de régimen, se mirarán separados de bienes bajo la ley chilena. Por otra parte, la redacción original rige a los que se hayan casado en país extranjero y pasaren a domiciliarse en Chile (antes del 9 de septiembre de 1989, fecha de entrada en vigencia de la ley). En cambio, la redacción actual rige a los que se hayan casado en país extranjero sin exigir la domiciliación en Chile.

Redacción Original Art. 135 inc. 2 CC	Redacción Actual Art. 135 inc. 2 CC
Se aplica a los casados en el extranjero que pasen a domiciliarse en Chile antes del 9 de septiembre de 1989. La jurisprudencia estableció que no se aplicaba al matrimonio de dos chilenos casados en el extranjero porque ellos, por disposición del Art. 15 N°2, quedan regidos por la ley chilena y, consecuentemente,	Se aplica a todos los casados en el extranjero, excepto aquellos regidos por la redacción original. Se discute si se aplica o no al matrimonio de dos chilenos en el extranjero: (i) algunos sostienen que no por aplicación del Art. 15 N°2 CC (norma especialísima) ¹⁶ ; (ii) otros sostienen que sí

¹⁶ Postura de Hernán Corral y de la cátedra.

por el Art. 135 inc. 1 CC, Art. 1718 CC, Art. 1720 CC.	porque el Art. 135 CC no distingue y es norma general.
Reputa a los cónyuges casados en comunidad de bienes o separación de bienes. Permite a los cónyuges después cambiar según las normas generales del CC; vale decir, si hay sociedad conyugal, pueden pactar separación o participación en los gananciales. Si se reputaban separados de bienes no, aunque hoy sí por participación en gananciales.	Reputa a los cónyuges casados en separación de bienes. Se permite el pacto expreso de otro régimen matrimonial al momento de inscribir el matrimonio en el registro civil chileno. Ese régimen pactado rige siempre hacia el futuro. Antes se los reputa siempre separados de bienes.
Establece un régimen supletorio de separación de bienes si los cónyuges no estaban casados en un régimen de sociedad conyugal. Si lo estaban, se les reconoce dicho régimen en Chile, pero debían probarlo en Chile.	Siempre el régimen supletorio es separación de bienes a menos que, en Chile, pacten otra cosa.
Hay continuidad del régimen de comunidad de bienes adquirido en el extranjero quedando regulado por las normas de la sociedad conyugal chilena.	No se reconoce el régimen matrimonial adquirido en el extranjero por los cónyuges aunque sea igual a uno de los reconocidos por la ley chilena.
Problema. Deja un vacío legal. No regula el régimen de los casados en el extranjero que no se domicilian en Chile o sean transeúntes. Doctrina y jurisprudencia aportaron soluciones dispares.	Mérito. Elimina este vacío legal, regula el régimen de todos los casados en el extranjero, incluso transeúntes.
Mérito. Compatibiliza un sistema territorialista con un régimen unitario que permite la continuidad del régimen matrimonial	Problema. Impide continuidad del régimen extranjero de los cónyuges. Puede ocasionar pluralidad de regímenes matrimoniales simultáneos para los cónyuges que tienen bienes en distintos Estados. Aunque pacten el mismo régimen, éste rige hacia el futuro.

Entonces, bajo la redacción actual del Art. 135 inc. 2 CC, los contrayentes quedan separados de bienes en dos casos: (i) si no han inscrito su matrimonio en Chile; (ii) si al inscribirlo no han pactado otro régimen.

Es posible referir a un ejemplo. El Caso Tshumi (1944) es el único caso donde se aceptó el reenvío en Chile y se resolvió aplicando la antigua redacción del Art. 135 inc. 2 CC. Un matrimonio se casó en Alemania y se vinieron a vivir a Chile, el marido era suizo del Cantón de Berna. A su muerte, se debió determinar cuál era el régimen matrimonial del matrimonio para estudiar si procedía o no liquidar la sociedad conyugal y determinar la masa hereditaria. Para ello, había que determinar si se habían casado o no en sociedad de bienes. De manera que el juez tuvo que mirar el derecho alemán, que era la ley bajo cuyo imperio se casaron, que dictaminaba que el régimen patrimonial se regía por la ley de la nacionalidad del marido al momento de contraer matrimonio. El juez acogió este reenvío

y aplicó la ley suiza del Cantón de Berna, de acuerdo a la cuál sí se había formado sociedad conyugal entre los cónyuges. Si hubiera aplicado derecho interno alemán, no habría habido sociedad conyugal porque el régimen legal supletorio en Alemania es participación en los gananciales. Si se aplica la redacción actual del Art. 135 inc. 2 CC ese matrimonio tendría el régimen de separación de bienes en Chile si no pactó otro régimen al momento de inscribir el matrimonio en Chile.

Otro ejemplo es el de dos ingleses que se casan en Inglaterra en 1980 y se vienen a Chile el año 2000, su régimen matrimonial queda gobernado por la redacción actual del Art. 135 CC. En este caso, su régimen matrimonial sería separación de bienes, a menos que hubieren pactado otro régimen al momento de la inscripción de su matrimonio en Chile. Si hubieren pactado sociedad conyugal o participación en los gananciales, estos regímenes habrían comenzado a regir desde la fecha del pacto, y antes del pacto, la legislación chilena los considera separados de bienes.

A su vez, es posible referir al pacto de régimen matrimonial conforme al Art. 135 inc. 2 CC. Para que los casados en el extranjero puedan pactar un régimen matrimonial deben concurrir ambos cónyuges al momento de solicitar la inscripción en Chile (no puede pactarse si se inscribe por vía diplomática). Además, debe dejarse constancia del pacto al margen de la inscripción matrimonial (requisito de existencia por lo cual no tendrá valor alguno si se omite esta subinscripción, Art. 1716 CC).

Por su parte, respecto a la sustitución del régimen matrimonial supletorio o pactado durante la vigencia del matrimonio, el Art. 1723 CC permite sustituir el régimen supletorio o el pactado una vez durante la vigencia del matrimonio. El Art. 1723 CC dispone que:

1. Durante el matrimonio los cónyuges podrán sustituir el régimen de sociedad de bienes por el de participación en los gananciales o por el de separación total. También podrán sustituir la separación total por el régimen de participación en los gananciales.
2. El pacto que los cónyuges celebren en conformidad a este artículo deberá otorgarse por escritura pública y no surtirá efectos entre las partes ni respecto de terceros, sino desde que esa escritura se sub-inscriba al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Esta sub-inscripción sólo podrá practicarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la escritura en que se pacte la separación. El pacto que en ella conste no perjudicará, en caso alguno, los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido o de la mujer y, una vez celebrado, no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges.
3. En la escritura pública de separación total de bienes, o en la que se pacte participación en los gananciales, según sea el caso, podrán los cónyuges liquidar la sociedad conyugal o proceder a determinar el crédito de participación o celebrar otros pactos lícitos, o una y otra cosa; pero todo ello no producirá efecto alguno entre las partes ni respecto de terceros, sino desde la sub-inscripción a que se refiere el inciso anterior.
4. Tratándose de matrimonios celebrados en país extranjero y que no se hallen inscritos en Chile, será menester proceder previamente a su inscripción en el Registro de la Primera Sección de la comuna de Santiago, para lo cual se exhibirá al oficial civil que corresponda el certificado de matrimonio debidamente legalizado.
5. Los pactos a que se refiere este artículo y el y el inciso 2° del artículo 1715, no son susceptibles de condición, plazo o modo alguno.

Asimismo, hay que referirse a las capitulaciones matrimoniales y pactos de sustitución de régimen matrimonial celebrados en el extranjero.

1. **Art. 1715 CC:** se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones de carácter patrimonial que celebren los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. / En las capitulaciones matrimoniales que se celebren en el acto del matrimonio, sólo podrá pactarse separación total de bienes o régimen de participación en los gananciales.
2. **Art. 1716 CC:**
 - a. Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán por escritura pública, y sólo valdrán entre las partes y respecto de terceros desde el día de la celebración del matrimonio, y siempre que se sub-inscriban al margen de la respectiva inscripción matrimonial al tiempo de efectuarse aquél o dentro de los treinta días siguientes. Pero en los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior, bastará que esos pactos consten en dicha inscripción. Sin este requisito no tendrán valor alguno.
 - b. Tratándose de matrimonios celebrados en país extranjero y que no se hallen inscritos en Chile, será menester proceder previamente a su inscripción en el Registro de la Primera Sección de la comuna de Santiago, para lo cual se exhibirá al oficial civil que corresponda el certificado de matrimonio debidamente legalizado. En estos casos, el plazo a que se refiere el inciso anterior se contará desde la fecha de la inscripción del matrimonio en Chile.
 - c. Celebrado el matrimonio, las capitulaciones no podrán alterarse, aun con el consentimiento de todas las personas que intervinieron en ellas, sino en el caso establecido en el inciso 1.º del artículo 1723.

El artículo deja en claro que es posible celebrar capitulaciones matrimoniales en el extranjero antes del matrimonio o durante su celebración. Estas capitulaciones pueden sub-inscribirse en Chile. La pregunta que surge es determinar ¿cómo es posible la sub-inscripción de capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero, si el Art. 135 CC no reconoce los regímenes pactados en el extranjero? Los profesores Corral y Zelaya han sostenido que el Art. 1716 CC sólo se aplicaría a las capitulaciones matrimoniales celebradas por dos chilenos casados en el extranjero, porque ellos quedan sometidos a la legislación chilena que sí permite estos pactos (Art. 15 N°2 CC). Lo mismo sucede con el pacto de sustitución del régimen matrimonial del Art. 1723 inc. 4 CC, es decir, lo pueden efectuar los chilenos en el extranjero para después sub-inscribirlo en Chile al margen de su inscripción matrimonial.

Por ejemplo, si dos chilenos se casaron en Miami y no pactaron nada están sujetos al régimen de sociedad conyugal. Si ellos quieren después separarse de bienes, pueden pactar separación de bienes pero deberán subinscribir ese pacto al margen de la inscripción matrimonial en Chile para que tenga efecto en Chile. Deberán presentar la escritura pública extranjera donde conste el pacto legalizada o apostillado para proceder a su inscripción. Si esos dos chilenos quieren casarse en régimen de participación en los gananciales o separación total de bienes, pueden pactar capitulaciones matrimoniales en Miami que deberán sub-inscribirse al margen de la inscripción de matrimonio en Chile.

Por último, sobre el estatuto primario de los bienes familiares, la Ley 19.335 de 1994 (Art. 141 y ss. CC) creó el estatuto primario de los bienes familiares que declara que ciertos bienes, considerados como familiares, no sean embargables. Este estatuto primario se aplica a cualquier régimen patrimonial matrimonial y se aplica sólo a los bienes situados en Chile.

B.9. Ejercicios Prácticos sobre Regímenes Matrimoniales:

(1.) Un matrimonio de holandeses se traslada a vivir a Chile en 1986 y adquiere bienes aquí. El año 2007, el marido hace cesión de bienes a sus acreedores debido al mal estado de sus negocios y los síndicos piden la entrega de un bien raíz a la que se opone en tercería la esposa alegando que la propiedad es suya. Señale qué antecedentes legales tendrá el juez en cuenta para fallar esta tercería y cuál podría ser su posible fallo.

1. Hechos jurídicos relevantes:

- a. Matrimonio de holandeses se traslada a vivir a Chile en 1986.
- b. Adquieren bienes en Chile.
- c. Marido hace cesión de bienes.
- d. Oposición de tercería de dominio.

2. Problema jurídico: tercería de dominio, ¿quién es dueño del bien raíz?

3. Normas aplicables: hay que determinar cuál es el régimen matrimonial de ese matrimonio, aplicándose el Art. 135 inc. 2 antiguo CC.

4. Solución o soluciones: ese matrimonio puede tener entonces comunidad o separación de bienes. Si estaban separados de bienes, la señora puede alegar el dominio si está inscrito a su nombre en el Registro del Conservador de Bienes Raíces. Si se casaron con comunidad de bienes, el bien puede ser social y en ese caso sí responde de las deudas del marido, o puede formar parte del patrimonio reservado de la mujer, en cuyo caso sí podría interponer una tercería de dominio.

(2.) Juan Marín y Elena González, ambos chilenos, se casan en Londres en 1996. Elena muere en Chile en 1999 y se suscita el problema de determinar en Chile el régimen patrimonial al que estaba sujeto el matrimonio. Señale las posibles soluciones que contempla nuestra legislación al respecto.

1. Hechos jurídicos relevantes:

- a. Dos chilenos casados en Londres.
- b. Mujer muere en Chile.

2. Problema jurídico: determinación del régimen matrimonial patrimonial.

3. Normas aplicables: Art. 135 inc. 2 nuevo CC y Art. 15 N°2 CC.

4. Solución o soluciones:

- a. Sociedad conyugal, aplicándose el estatuto personal de los chilenos (Art. 15 N°2 CC), correspondiendo el Art. 135 inc. 1 CC, no habiendo pactado ningún otro régimen.
- b. Separación de bienes, por aplicación expresa del Art. 135 inc. 2 CC.
- c. Sociedad conyugal pactada por Art. 135 inc. 2 CC.
- d. Régimen de participación en los gananciales por Art. 135 inc. 2 CC.
- e. Modificación de régimen.

(3.) Carlos Celedón, chileno se casa en Melbourne (Australia) con Rita Simpson, australiana el año 2000 en régimen de separación de bienes. Ambos se trasladan a vivir a Chile el año 2010 y Rita

fallece aquí el año 2014. A su muerte, se discute en Chile el régimen legal matrimonial al que ella estaba sujeta. Señale las posibles soluciones que contempla nuestra legislación al respecto.

1. Hechos jurídicos relevantes:

- a. Matrimonio en Australia entre chileno y australiana.
- b. Bajo régimen de separación de bienes.
- c. Se trasladan a vivir a Chile.
- d. Mujer fallece el 2014 en Chile.

2. Problema jurídico: determinar el régimen patrimonial.

3. Normas aplicables: Art. 135 inc. 2 nuevo CC.

4. Solución o soluciones:

- a. Separación de bienes.
- b. Pacto de régimen (comunidad de bienes o régimen de participación en los gananciales). Si pactaron, para la ley chilena tienen tanto el régimen anterior al que hubieran pactado (separado de bienes) y el régimen posterior (participación en los gananciales).
- c. No aplica el Art. 15 N°2 CC respecto a la cónyuge, ya que se exige que la cónyuge sea también chilena.

C. Normas Reguladoras del AUC: lo que interesa revisar es el reconocimiento del acuerdo de unión civil extranjeros y regímenes patrimoniales de los convivientes civiles. El Acuerdo de Unión Civil se creó en Chile mediante la Ley 20.830 publicada en el Diario Oficial del 21-04-2015 y en vigor desde el 22-10-2025.

C.1. Concepto y calificación legal del AUC: la calificación legal del AUC queda regida por la ley chilena. El Art. 1 de la Ley 20.830 determina qué se entiende en Chile por AUC. El juez chileno deberá aplicar esta calificación (de la *lex fori*) para determinar si un acuerdo equivalente, contraído en el extranjero, puede considerarse en Chile AUC. Sin embargo, además de ser un acuerdo con el propósito señalado en el art. 1, el acuerdo extranjero debe estar sujeto a Registro y efectivamente registrado en el país de celebración, para que pueda considerarse en Chile un AUC (Art. 12 Ley 20.830).

El Art. 1 dispone que el acuerdo de unión civil es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. Los contrayentes se denominarán convivientes civiles y serán considerados parientes para los efectos previstos en el artículo 42 del Código Civil. / Su celebración conferirá el estado civil de conviviente civil. El término de este acuerdo restituirá a los contrayentes el estado civil que tenían antes de celebrar este contrato, salvo en la situación prevista en la letra c) del artículo 26.

C.2. Ley que rige los requisitos de validez del AUC: para determinar la ley que rige la validez del AUC debe distinguirse entre el AUC celebrado en Chile y el celebrado en el extranjero.

- 1. Ley que rige los requisitos de Validez del AUC celebrado en Chile:** si el AUC se celebra en Chile, queda regulado por la ley chilena en base al Art. 14 CC que remite al Art. 5 al Art. 9 de la Ley 20.830, que dispone que el acuerdo debe celebrarse ante Oficial de Registro Civil competente, que su acta debe inscribirse en el Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil,

que debe ser celebrado por contrayentes mayores de edad que consientan libre y espontáneamente a su celebración y que no tengan impedimento de parentesco entre sí.

2. **Ley que rige los requisitos de validez del AUC celebrado en el extranjero (Art. 12 de la Ley 20.830):** los acuerdos de unión civil o contratos equivalentes, no constitutivos de matrimonio, que regulen la vida afectiva en común de dos personas del mismo o de distinto sexo, sujetos a registro y celebrados válidamente en el extranjero, serán reconocidos en Chile, en conformidad con las siguientes reglas:

- a. (1ª) Los requisitos de forma y fondo del acuerdo se regirán por la ley del país en que haya sido celebrado.
- b. (2ª) Sin embargo, podrá ser declarado nulo de conformidad a la ley chilena, el acuerdo celebrado en territorio extranjero que se haya contraído en contravención a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º y 9º de esta ley.
- c. (3ª) Para que el acuerdo otorgado en país extranjero produzca efectos en Chile, deberá inscribirse en el Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil que establece el artículo 6º. Los efectos de este acuerdo, una vez inscrito conforme a lo señalado precedentemente, se arreglarán a las leyes chilenas, aunque los contrayentes sean extranjeros y no residan en el territorio nacional.
- d. (4ª) La terminación del acuerdo y los efectos de la misma se someterán a la ley aplicable a su celebración.
- e. (5ª) Las sentencias que declaren la nulidad o la terminación del acuerdo, dictadas por tribunales extranjeros, serán reconocidas en Chile conforme a las reglas generales que establece el Código de Procedimiento Civil.
- f. (6ª) Los actos auténticos en que conste la terminación de uno de estos acuerdos serán reconocidos en Chile, en conformidad con la legislación chilena vigente en esta materia.

Los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo serán reconocidos en Chile como acuerdos de unión civil si cumplen con las reglas establecidas en esta ley, y sus efectos serán los mismos del referido acuerdo.

3. **Requisitos de validez exigidos por la ley chilena en el Art. 12 Ley 20.830:**

- a. El AUC o contrato equivalente no constitutivo de matrimonio que regule la vida afectiva de dos personas, debe estar sujeto a registro en el país extranjero donde se celebró. Esto significa que no se reconocerá en Chile, en ningún caso, un AUC que no esté registrado en un Registro Público del lugar de celebración. Por otra parte, para que este AUC extranjero produzca efectos legales en Chile, debe inscribirse en el Registro Especial de AUC del Registro Civil chileno y sólo producirá efectos en Chile a partir de la fecha de su inscripción (Art. 12 N°3 Ley 20.830). En este requisito el AUC se diferencia del matrimonio celebrado en el extranjero, el que produce efectos jurídicos sin necesidad de estar inscrito en el Registro Civil chileno (Art. 80 LMC).
- b. Debe cumplir con los requisitos de forma y fondo de la ley del país de celebración, es decir, debe haber sido válidamente celebrado en el país extranjero.
- c. Debe cumplir con los requisitos de fondo adicionales de la ley chilena, establecidos en el Art. 12 L. 20830. No infringir los requisitos establecidos en el Art. 7, Art. 8 y

Art. 9 de la Ley 20.830 (impedimentos dirimentes especiales: minoría de edad, falta de consentimiento libre, parentesco y vínculo matrimonial o AUC no disuelto).

i. **Art. 7:** para la validez de este contrato será necesario que los contrayentes sean mayores de edad y tengan la libre administración de sus bienes. No obstante lo anterior, el disipador que se halle en interdicción de administrar lo suyo podrá celebrar, por sí mismo, este acuerdo.

ii. **Art. 8:** será necesario, además, que los contrayentes hayan consentido libre y espontáneamente en celebrarlo. / Se entenderá que falta el consentimiento libre y espontáneo en los siguientes casos:

1. Si ha habido error en la identidad de la persona del otro contrayente.
2. Si ha habido fuerza, en los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil.

iii. **Art. 9:** no podrán celebrar este contrato entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. Tampoco podrán celebrarlo las personas que se encuentren ligadas por un vínculo matrimonial no disuelto o un acuerdo de unión civil vigente.

d. **El AUC deberá inscribirse en el Registro Especial de AUC chileno (Art 12 N°3 Ley 20.830).** Para que el acuerdo otorgado en país extranjero produzca efectos en Chile, deberá inscribirse en el Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil que establece el artículo 6°. Los efectos de este acuerdo, una vez inscrito conforme a lo señalado precedentemente, se arreglarán a las leyes chilenas, aunque los contrayentes sean extranjeros y no residan en el territorio nacional. Esto es importante porque un AUC celebrado en el extranjero no produce ningún efecto mientras no se haya inscrito en Chile y los produce a partir de la fecha de inscripción.

4. **Requisitos adicionales exigidos por la ley chilena para la celebración del AUC de dos chilenos en el extranjero o de un chileno con extranjero:** en el caso del AUC celebrado en el extranjero por un chileno o chilena o por dos chilenos deben cumplirse además con las otras exigencias de la Ley 20.830 para los AUC celebrados en Chile. Esto porque conforme al Art. 15 inc. 1 del CC, el chileno en el extranjero queda sometido en cuanto a su estado civil y a los cambios de su estado civil, a la ley chilena y el AUC produce un cambio de estado civil al de conviviente civil (Art 1 Ley 20.830). Por esto, el chileno o los chilenos deben cumplir con los requisitos adicionales del Art. 10 de la Ley 20.830 (similar al impedimento impediende de guarda). El Art. 10 dispone que la persona que, teniendo la patria potestad de un hijo o la guarda de otra, quiera celebrar un acuerdo de unión civil, deberá sujetarse a lo prescrito en el Art. 124 CC al Art. 127 CC . A su vez, el Art. 11 fue derogado por Ley 21.264 (D. OF. 11-SEPT 2020).

C.3. Ley que rige los efectos del AUC: los efectos del AUC celebrado en Chile y el extranjero quedan gobernados por la ley chilena y concretamente por la Ley 20.830, por disposición del Art 14 CC y Art. 2 y Art. 12 inc. 3 de la Ley 20.830.

1. **Art. 2:** el acuerdo generará para los convivientes civiles los derechos y obligaciones que establece la presente ley (AUC celebrados en Chile).

2. **Art. 12 N°3:** para que el acuerdo otorgado en país extranjero produzca efectos en Chile, deberá inscribirse en el Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil que establece el artículo 6°. Los efectos de este acuerdo, una vez inscrito conforme a lo señalado precedentemente, se arreglarán a las leyes chilenas, aunque los contrayentes sean extranjeros y no residan en el territorio nacional. Es decir, los AUC extranjeros, una vez inscritos en Chile, producen aquí los efectos que la Ley 20.830 concede a todo AUC.

C.4. Situación legal en Chile de los matrimonios homosexuales celebrados en el extranjero: el Art. 12 inc. fina de la Ley 20.830 establece que los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo serán reconocidos en Chile como acuerdos de unión civil si cumplen con las reglas establecidas en esta ley, y sus efectos serán los mismos del referido acuerdo. Es decir, esos matrimonios no se reconocen en Chile como matrimonio, por la expresa prohibición establecida en el Art. 80 LMC¹⁷ y el Art. 12 Ley 20.830, pero se los reconoce e inscribe en Chile como AUC.

C.5. Ley que rige el término del AUC: el Art. 12 N°4 de la Ley 20.830 dispone que la terminación del acuerdo y los efectos de la misma se someterán a la ley aplicable a su celebración. Conforme a este artículo para determinar la ley aplicable al AUC habrá que distinguir si el AUC se celebró en Chile o en el extranjero y, en este último caso, si se trata del término del AUC entre dos extranjeros o en el que uno o los dos contrayentes son chilenos.

1. **Ley que rige el término del AUC celebrado en Chile:** respecto del término del AUC celebrado en Chile, habrá que distinguir entre la ley que rige el término del AUC celebrado en Chile y aquella que rige el término del AUC celebrado en el extranjero. El término del AUC producirá efectos en Chile desde la fecha en que se subinscriba al margen de la inscripción del AUC respectivo en el Registro de AUC chileno.
 - a. **Ley que rige el término solicitado en Chile del AUC celebrado en Chile:** el término del AUC celebrado en Chile y solicitado en Chile queda íntegramente regido por la ley chilena porque ella es la ley aplicable a su celebración (Art. 12 N°4 Ley 20.830). Al respecto, el Art. 26 de la Ley 20.830 dispone que el acuerdo de unión civil terminará:
 - i. Por muerte natural de uno de los convivientes civiles.
 - ii. Por muerte presunta de uno de los convivientes civiles, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley N° 19.947, sobre matrimonio civil. Terminará también por la comprobación judicial de la muerte de uno de los convivientes civiles efectuada por el juez del último domicilio que el difunto haya tenido en Chile, en los términos prescritos en los artículos 95 y 96 del Código Civil.
 - iii. Por el matrimonio de los convivientes civiles entre sí, cuando proceda.
 - iv. Por mutuo acuerdo de los convivientes civiles, que deberá constar por escritura pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil.

¹⁷ Art. 80 LMC: los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. Así, el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad con las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno, siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer.

- v. Por voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles, que deberá constar por escritura pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil.
- vi. Por declaración judicial de nulidad del acuerdo. La sentencia ejecutoriada en que se declare la nulidad del acuerdo de unión civil deberá subinscribirse al margen de la inscripción a que se hace mención en el artículo 6º y no será oponible a terceros sino desde que esta subinscripción se verifique.

El término voluntario del AUC se realiza a través de una escritura pública o acta en el Registro Civil. Se debe inscribir en el Registro de Acuerdos de Unión Civil y se notifica al otro conviviente. No se exige plazo mínimo para el cese previo de la convivencia para poder poner término al AUC ya sea unilateral o de común acuerdo, como sí se exige en el caso del divorcio de los matrimonios.

- b. **Ley que rige el término solicitado en el extranjero del AUC celebrado en Chile:** este término del AUC queda regido por la ley chilena, que fue la ley aplicable a la celebración de ese AUC, por ello no se reconocería en Chile un término por una causal o instrumento no autorizado por la ley chilena. Para producir efectos en Chile deberá traerse el documento público de término legalizado o apostillado y, si es necesario traducido, y subinscribirse en el Registro de AUC en Chile. En el caso de término por sentencia judicial de nulidad o de término, esas sentencias deberán someterse al trámite del exequátur previo a su subinscripción en el registro de AUC. El Art. 12 de la Ley 20.830 dispone que los acuerdos de unión civil o contratos equivalentes, no constitutivos de matrimonio, que regulen la vida afectiva en común de dos personas del mismo o de distinto sexo, sujetos a registro y celebrados válidamente en el extranjero, serán reconocidos en Chile, en conformidad con las siguientes reglas:

- i. 4ª. La terminación del acuerdo y los efectos de la misma se someterán a la ley aplicable a su celebración.
- ii. 5ª. Las sentencias que declaren la nulidad o la terminación del acuerdo, dictadas por tribunales extranjeros, serán reconocidas en Chile conforme a las reglas generales que establece el Código de Procedimiento Civil.
- iii. 6ª. Los actos auténticos en que conste la terminación de uno de estos acuerdos serán reconocidos en Chile, en conformidad con la legislación chilena vigente en esta materia.

- 2. **Ley que rige el término del AUC celebrado en el extranjero:** el Art. 12 de la Ley 20.830 dispone que la terminación del acuerdo y los efectos de la misma se someterán a la ley aplicable a su celebración. Para determinar esta ley se debe distinguir si el término del AUC extranjero se solicita en el extranjero o en Chile.

- a. **Ley que rige el término solicitado en el extranjero del AUC celebrado en el extranjero:** este término, por regla general, se somete a la ley del país donde se celebró el AUC. Para que produzca efectos en Chile habrá que solicitar en Chile el exequátur de la sentencia de término o nulidad o presentar el documento público extranjero que lo acredite, legalizado o apostillado (Art. 12 N°4, N°5 y N°6 de la Ley 20.830). Los efectos del término serán los que establece la ley que lo rige.
- b. **Ley que rige el término solicitado en Chile del AUC celebrado en el extranjero:** el término del AUC celebrado en el extranjero se rige por la ley aplicable a su

celebración según lo dispone el Art. 12 de la Ley 20.830: la terminación del acuerdo y los efectos de la misma se someterán a la ley aplicable a su celebración. Entonces, el término del AUC celebrado en el extranjero y solicitado en Chile, se rige por la ley aplicable a su celebración, que será la de la ley del país donde se celebró. Por ejemplo:

- i. Si dos franceses celebraron un AUC en Paraguay y solicitan su término en Chile, ellos quedan sujetos en Chile a la ley Paraguaya para su término y los efectos de ese término.
- ii. Si dos franceses celebran un AUC en Paraguay y solicitan su término en Francia, según la ley chilena, quedan gobernados por la ley paraguaya para su término y los efectos de ese término.
- iii. Si dos chilenos o un chileno con paraguaya celebran un AUC en Paraguay, su término queda regido por la ley paraguaya porque el Art. 15 N°1 somete a los chilenos a lo que disponga la ley chilena en cuanto al estado civil y esa ley chilena, en el Art. 12 de la Ley 20.830, los somete a la ley del lugar de celebración del AUC.

C.6. Efectos patrimoniales del AUC: los efectos patrimoniales del AUC celebrado en Chile o en el extranjero quedan regidos por la ley chilena.

1. **Efectos patrimoniales del AUC celebrado en Chile:** la ley chilena dispone que el AUC celebrado en Chile no produce efectos jurídicos sobre el patrimonio de los convivientes civiles, a menos que ellos pacten el régimen patrimonial especial que establece el Art. 15 de la Ley 20.830. Es decir, el AUC tiene como régimen patrimonial supletorio el de separación de bienes.

El Art. 15 de la Ley dispone que los convivientes civiles conservarán la propiedad, goce y administración de los bienes adquiridos a cualquier título antes de la celebración del contrato y de los que adquieran durante la vigencia de éste, a menos que se sometan de manera expresa a las reglas que se establecen a continuación, las que deberán ser acordadas por los contrayentes al momento de celebrarse el acuerdo de unión civil. De este pacto se dejará constancia en el acta y registro que se indica en el artículo 6°.

La lógica de este régimen supletorio radica en que el AUC es por naturaleza temporal y fácilmente disoluble. De ahí que, el legislador chileno opte por imponerle un régimen supletorio de separación de bienes que facilite su disolución. Sin embargo, los convivientes civiles pueden pactar expresamente, al momento de contraer el AUC, someterse a las reglas del Art. 15 de la Ley 20.830 que establece una especie de comunidad de bienes entre los convivientes civiles. Esta comunidad de bienes es absolutamente distinta a la sociedad conyugal. El Art. 15 N°3 de la Ley 20.830 hace aplicable a esa comunidad de bienes las normas relativas al cuasi contrato de comunidad, que es esencialmente disoluble.

En cualquier momento, los convivientes civiles podrán sustituir este pacto de comunidad especial, por el régimen de separación de bienes (Art. 15 inc. 2 y 3). Este pacto de sustitución de régimen debe otorgarse por escritura pública y subinscribirse al margen de la inscripción

del AUC. Produce efectos entre los convivientes y respecto de terceros desde la fecha de la inscripción.

2. Normas que rigen el régimen patrimonial especial del Art. 15 de la Ley 20830: este régimen se rige siempre por la ley chilena, y concretamente, por el Art. 15 de la Ley 20.830 que dispone:

- a. 1ª. Los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia del acuerdo se considerarán indivisos por mitades entre los convivientes civiles, excepto los muebles de uso personal necesario del conviviente que los ha adquirido.
- b. 2ª. Para efectos de esta ley, se tendrá por fecha de adquisición de los bienes aquella en que el título haya sido otorgado.
- c. 3ª. Se aplicarán a la comunidad formada por los bienes a que se refiere este artículo las reglas del Párrafo 3º del Título XXXIV del Libro IV del Código Civil.

Si los convivientes civiles hubieren pactado el régimen de comunidad podrán sustituirlo por el de separación total de bienes.

El pacto que los convivientes civiles celebren para sustituir el régimen de comunidad deberá otorgarse por escritura pública y no surtirá efectos entre las partes ni respecto de terceros, sino desde que esa escritura se subinscriba al margen de la respectiva inscripción del acuerdo de unión civil. Esta subinscripción sólo podrá practicarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la escritura en que se pacte la separación. El pacto que en ella conste no perjudicará, en caso alguno, los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto de cada uno de los convivientes civiles.

En la escritura pública de separación total de bienes, los convivientes civiles podrán liquidar la comunidad, celebrar otros pactos lícitos o ambas cosas, pero todo ello no producirá efecto alguno entre las partes ni respecto de terceros, sino desde la subinscripción a que se refiere el inciso anterior.

3. Efectos patrimoniales del AUC celebrado en el extranjero: el Art. 13 y el Art. 15 inc. 5 de la Ley 20.830 regulan esta materia y disponen:

- a. **Art. 13:** los convivientes civiles que hayan celebrado el acuerdo o contrato de unión equivalente en territorio extranjero se considerarán separados de bienes, a menos que al momento de inscribirlo en Chile pacten someterse a la comunidad prevista en el artículo 15 de esta ley, dejándose constancia de ello en dicha inscripción.
- b. **Art. 15 inc. 5:** tratándose de uniones civiles o contratos equivalentes, que regulen la vida afectiva en común de dos personas del mismo o de distinto sexo, sujetos a registro y celebrados válidamente en el extranjero que no se encuentren inscritos en Chile, y que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley, será menester proceder previamente a su inscripción en el registro especial que establece el artículo 6º de esta ley. Mediante el reglamento señalado en el artículo 48 se determinará la forma en que se dará cumplimiento a lo establecido en este inciso.

Es decir, los convivientes civiles que hayan contraído un AUC en el extranjero se entenderán en Chile como separados de bienes, a menos que al inscribir su AUC en el Registro chileno pacten el régimen especial del Art. 15 de la Ley 20.830. Esta norma se aplica a todos los

convivientes civiles casados en el extranjero sean chilenos o no. El pacto celebrado produce efectos jurídicos hacia el futuro, a partir de la fecha de su inscripción, de modo que se consideran separados de bienes antes de celebrarlo e inscribirlo. Se permite a los convivientes que hayan pactado comunidad, sustituirlo después por el régimen de separación de bienes.

Cabe agregar que los convivientes civiles no son parientes en general, lo son sólo para los efectos del Art. 42 CC (Art. 1 de la Ley 20.830), que tiene un alcance muy restringido. Es decir, los convivientes chilenos no son parientes para los efectos del Art. 15 N°2 CC.

El Art. 42 CC dispone que en los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderán comprendidos en esa denominación el cónyuge de ésta y sus consanguíneos de uno y otro sexo, mayores de edad. A falta de consanguíneos en suficiente número serán oídos los afines. / Serán preferidos los descendientes y ascendientes a los colaterales, y entre éstos los de más cercano parentesco. / Los parientes serán citados, y comparecerán a ser oídos, verbalmente, en la forma prescrita por el Código de Enjuiciamiento.

4. **Estatuto primario de los bienes familiares:** los bienes de los convivientes civiles situados en Chile pueden acogerse a este estatuto, según lo dispone el Art. 15 inc. final de la Ley 20.830: cualquiera sea el régimen de bienes que exista entre los convivientes civiles, tendrá aplicación lo dispuesto en los artículos 141 a 149 del Código Civil.

C.7. Ejercicios Prácticos:

(1.) Juan Tinelli, argentino, y Pedro Safirio (chileno) se casan en Argentina el año 2017 y se trasladan a vivir a Chile el año 2018 y pretenden inscribir su matrimonio en Chile. Analice su situación jurídica.

- a. **Hechos jurídicos relevantes:** matrimonio homosexual celebrado en Argentina, contrayentes chileno y argentino, traslado a Chile e inscripción en Chile.
- b. **Problema jurídico:** reconocimiento del matrimonio homosexual extranjero en Chile.
- c. **Normas aplicables:** Art. 80 LMC, Art. 102 CC y Ley 20.830.
- d. **Solución o soluciones:** inscripción del matrimonio homosexual extranjero como AUC en Chile.

(2.) José Tiznado y Magdalena Soto, chilenos, contraen un Acuerdo de Unión Civil en Francia el año 2015 y se domicilian en Chile al año 2017. El 20 de enero de ese año inscriben su AUC en Chile. José pone término unilateral al AUC por escritura pública suscrita en Santiago el 25 de noviembre del año 2019 e inscrita en el Registro de AUC el 20 de diciembre del 2019. Magdalena reclama ser la dueña total de un inmueble comprado en el año 2016 en Toulouse y del 50% de un departamento comprado en Santiago por José el 30 de noviembre del año 2019. José se opone alegando que a la fecha de compra del inmueble en Toulouse ambos habían pactado un régimen de comunidad de bienes regulado por la ley francesa y que a la fecha de compra del departamento en Santiago su AUC estaba terminado. Al respecto señale:

- a. **Hechos jurídicos relevantes:** AUC heterosexual en Francia, contrayentes chilenos, inscripción AUC en Chile, término unilateral del AUC a través de EP, inscripción del término, Magdalena es dueña de un inmueble en Toulouse y 50% de un inmueble en Santiago, oposición de José por pacto de régimen de comunidad de bienes en Francia.
- b. **¿Desde cuándo se los considera en Chile convivientes civiles?:** desde la fecha de inscripción del AUC en Chile, 20 de enero del 2017.
- c. **¿A qué ley queda sometida la validez de su AUC?:** en primer lugar, a la ley francesa porque allí se celebró el AUC y, en segundo lugar, a la ley chilena respecto de los requisitos adicionales.
- d. **¿Es jurídicamente procedente el reclamo de Magdalena respecto de los inmuebles?:** respecto del departamento de Toulouse, el reclamo es procedente si el inmueble está a nombre de Magdalena en Francia, ya que la ley chilena los presume separado de bienes. Respecto al departamento de Santiago, el reclamo no procede, ya que no se ha inscrito el régimen especial de bienes al momento de inscribir el AUC en Chile, encontrándose casados en separación de bienes. Respecto al reclamo de José, no es procedente puesto que, la EP de término unilateral no se encontraba inscrita en el registro especial de AUC a la fecha de compraventa del departamento en Santiago.

D. El Estatuto de los Bienes y la Ejecución de Sentencias Extranjeras que Afectan Bienes Situados en Chile:

D.1. Concepto: el estatuto de los bienes es el conjunto de normas jurídicas que rigen los bienes en sí mismos y los derechos reales que pueden ejercerse directamente sobre ellos, y concretamente, ciertos aspectos, como:

1. La calificación y clasificación de los bienes.
2. Los modos de adquirir los bienes.
3. Los modos de adquirir la posesión y mera tenencia de los bienes.
4. Los tipos, contenidos y efectos jurídicos de los derechos y cauciones reales.
5. Los modos de constituir, transferir, extinguir y ejecutar los derechos y cauciones reales que se ejercen sobre bienes.
6. Las acciones reales o posesorias que se ejercen sobre bienes.

La excepción es que el derecho real de herencia, que queda regulado por el estatuto de la sucesión. Precisar qué aspectos de los bienes quedan gobernados por el estatuto de los bienes es importante para entender, interpretar y aplicar el Art. 16 inc. 1 CC que dice: los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Este Art. 16 CC, al afirmar que los bienes situados en Chile se rigen por la ley chilena, está prescribiendo que los modos de adquirir esos bienes, la posesión y mera tenencia que se puede ejercer sobre esos bienes y los derechos reales sobre esos bienes se rigen por la ley chilena por el hecho de estar situados en Chile. Es decir, este Art. 16 usa el factor de conexión *lex rei sitae* para establecer la ley que rige a estos bienes.

D.2. *Ius in re* y *ius ad rem*: precisando aún más qué materias relacionadas con los bienes, quedan comprendidas en el estatuto de los bienes, podemos afirmar que aquellas calificadas como *ius in re*, vale decir, que se refieren a derechos ejercidos directamente sobre la cosa. En consecuencia, quedan excluidas del estatuto de los bienes aquellas materias relativas al *ius ad rem* que otorgan derechos hacia la cosa, como son, por ejemplo, los derechos personales a que se me entregue la cosa o se me pague su valor porque estos derechos personales quedan gobernados por otro estatuto (el de los actos y contratos).

D.3. La determinación de la ley reguladora del estatuto real o de los bienes en el derecho comparado: en el DIPRI comparado hay distintas soluciones jurídicas para determinar la ley que rige el estatuto personal. Hay sistemas jurídicos que asimilan muebles e inmuebles, y someten los derechos reales que se ejercen sobre ellos al principio *lex rei sitae* o a la ley del lugar de ubicación de la cosa. Este es el sistema adoptado en nuestro país. Hay otros sistemas jurídicos que distinguen entre bienes muebles e inmuebles. Estos sistemas tienden a someter al principio *lex rei sitae* a los inmuebles y someten a los muebles a otras leyes como, por ejemplo, a la ley del domicilio del dueño o la ley de ubicación habitual de ese bien o a la ley del lugar de su registro. En todo caso, el principio *lex rei sitae* es adoptado en la mayoría de los países del mundo para los bienes inmuebles, los que quedan gobernados por su ley de situación.

D.4. Materias relativas a bienes que quedan excluidas del estatuto de los bienes y regidas por otras leyes o estatutos:

1. La capacidad para celebrar actos y contratos respecto de bienes porque la capacidad queda gobernada por el estatuto personal y no por el estatuto de los bienes.
2. Las formalidades o los requisitos externos de los actos o contratos que se refieren a bienes porque las formalidades quedan gobernadas por la ley del lugar de celebración del acto, es decir, por el estatuto de la forma de los actos.
3. Los actos y contratos relativos a bienes en cuanto a su validez de fondo porque forman parte del estatuto de los actos y contratos y pueden quedar gobernados por la ley del lugar de celebración del acto, o la del lugar de ejecución del contrato, o la ley elegida por las partes.

Por ejemplo, si se celebra en París un contrato de compraventa de un bien raíz ubicado en Chile:

1. Las formalidades del contrato quedan gobernadas por la ley del lugar de celebración.
2. Los derechos y obligaciones personales que surjan de él- obligación de entregar y de pagar el precio- por la ley del lugar de ejecución (ley francesa y chilena).
3. La adquisición del derecho real de propiedad, por la ley chilena porque el bien está ubicado en Chile.

D.5. Ley reguladora del estatuto real en Chile: tanto los bienes inmuebles como muebles quedan sujetos al principio *lex rei sitae*. Est significa que el estatuto real queda sometido a la *lex situs* o ley de situación del bien. Hay que analizar el Art. 16 CC, el que dispone que: los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. / Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño. / Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas.

El inciso primero se refiere específicamente al estatuto de los bienes. Los incisos 2° y 3° se refieren al estatuto de los contratos.

1. El Art. 16 CC habla, en general, de bienes sin distinguir ningún tipo en especial; por lo tanto, puede entenderse que incluye los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporeales. De ahí que, el sistema jurídico chileno somete tanto a los bienes muebles como inmuebles situados en Chile a la ley chilena.
2. El Art. 16 CC no considera la nacionalidad del propietario ni su domicilio para determinar la ley que rige a los bienes situados en Chile.
3. Todos los bienes situados en Chile quedan gobernados por la ley chilena. Esto se refiere a todo el territorio nacional, incluyendo también los espacios sobre los cuales Chile ejerce jurisdicción exclusiva como el espacio aéreo, terrestre y naves aeronaves mercantes con pabellón chileno en altamar y las de guerra que pertenecen a la armada chilena donde quiera que estén.
4. El Art. 16 es una norma unilateral que establece la ley que rige los bienes ubicados en Chile y guarda silencio acerca del estatuto real de los bienes ubicados en el extranjero. Este vacío legal puede llenarse bilateralizando esta norma y/o aplicando el Art. 105 CB (para países partes), que tiene un alcance multilateral y contempla la misma solución, cualquiera sea el país de ubicación del bien. El Art. 105 CB dispone que los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de la situación.

D.6. Criterios para determinar la ubicación de ciertos bienes de dudosa ubicación: hay bienes respecto de los cuales no es fácil determinar su ubicación. Para ello, podemos utilizar los criterios de ubicación que señala el Código de Bustamante en los Art. 105 y siguientes para los muebles y ciertos bienes incorporeales. Ellos sirven para identificar la ley que los regula y complementan al Art. 16 CC y Art. 105 CB.

1. Títulos representativos de crédito y bienes muebles corporales: el Art. 106 dispone que para los efectos del artículo anterior (determinar la ley de su situación) se tendrá en cuenta, respecto de los bienes muebles corporales y para los títulos representativos de créditos de cualquier clase, el lugar de su situación ordinaria o normal. Es decir, los muebles se encuentran ubicados en el lugar donde habitualmente se encuentran. Los títulos de crédito - un pagaré, letra de cambio, entre otros- se rigen por la *lex cartae sitae*, ley del lugar donde se encuentran.
2. La situación de los créditos: el Art. 107 dispone que la situación de los créditos se determina por el lugar en que deben hacerse efectivos, y, si no estuviere precisado, por el domicilio del deudor.
3. La propiedad intelectual: el Art. 108 dispone que la propiedad industrial, la intelectual y los demás derechos análogos de naturaleza económica que autorizan el ejercicio de ciertas actividades acordadas por la ley, se consideran situados donde se hayan registrado oficialmente.
4. Concesiones de cualquier clase (mineras, operación de autopistas, de radio o tv, entre otros): el Art. 109 dispone que las concesiones se reputan situadas donde se hayan obtenido legalmente.

5. Cosas dadas en prenda: el Art. 111 dispone que se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior las cosas dadas en prenda, que se consideran situadas en el domicilio de la persona en cuya posesión se hayan puesto. En el caso de la prenda especial sin desplazamiento, sería el domicilio del dueño o el lugar donde esté el bien dado en prenda si es posible establecerlo.
6. Norma subsidiaria: el Art. 110 dispone que a falta de toda otra regla y demás para los casos no previstos en este Código, se entenderá que los bienes muebles de toda clase están situados en el domicilio de su propietario, o, en su defecto, en el del tenedor.

D.7. Casos especiales de otros bienes:

1. **Naves y aeronaves**: el Código de Bustamante en el Art. 274 y ss. establece que las naves se rigen por la Ley del Pabellón, es decir, la ley del lugar de registro para la constitución y transmisión de derechos reales respecto de ellas. El Art. 282, hace aplicable esta misma ley a las aeronaves. Por lo tanto, las Naves/Aeronaves que tienen Pabellón Chileno se rigen por la Ley Chilena, independientemente, del lugar donde se encuentren. Sin embargo, algunos aspectos como la posibilidad de embargo y remate judicial de las naves y aeronaves se rigen por la ley del lugar de su situación (Art. 276 CB).
2. **Las universalidades**: las universalidades son un conjunto de bienes distintos entre sí, que comparten una misma destinación económica o jurídica por lo que la ley los reputa una unidad. Existen universalidades de hecho y de derecho. El problema de derecho internacional respecto a las universalidades es determinar cuál es la ley que rige la universalidad.

Las universalidades de hecho son un conjunto de bienes de igual o de diferente naturaleza que por tener una misma destinación, pueden reputarse una unidad, como una Biblioteca, una colección, una estación eléctrica, etc. Estas universalidades tienen normalmente una ubicación determinada y, por ello se rigen por la ley del lugar donde están situadas.

Las universalidades de derecho son un conjunto de bienes que la ley reputa como una unidad, como el patrimonio social de una empresa, la masa hereditaria, el patrimonio del fallido que ha caído en quiebra o los haberes de la sociedad conyugal.

El legislador establece un criterio o factor de conexión para determinar cuál es la ley que rige a las universalidades de derecho. Muchas veces utiliza adoptar el criterio domicilio y establece que la ley aplicable será la del último domicilio del causante, la del domicilio del fallido, la del domicilio común de los cónyuges, la del domicilio social, suponiéndose que los bienes que componen la universalidad están habitualmente ubicados ahí.

En el caso de las universalidades de derecho, no se aplica literalmente el principio *lex rei sitae* porque las universalidades quedan gobernadas por otra ley, que el legislador designa. Por ejemplo, la adquisición y cesión del derecho real de herencia sobre un fundo ubicado en Malleco queda gobernada por la ley del último domicilio del causante, según la ley chilena (Art. 955 CC) y no a la ley donde están ubicados los bienes.

D.8. El principio *lex rei sitae* y el conflicto móvil: el conflicto móvil surge cuando el HECHO que constituye factor de conexión cambia. En el caso de los bienes, cuando éstos cambian de ubicación.

Hay que recordar un caso: en 1875 don Juan Zanelli adquirió unos terrenos en Mejillones cuando ese territorio formaba parte de Bolivia. En 1915, cuando éste formaba parte de Chile, se discutió ante los tribunales chilenos si don Juan Zanelli era o no propietario de esos terrenos. Cuando se discute quién es su dueño en Chile, la Corte Suprema opta por no aplicar la ley chilena al asunto, según dispone el Art. 16 CC para los terrenos ubicados en Chile; sino que aplica la ley boliviana, que era la ley donde los terrenos estaban ubicados cuando Zanelli adquirió el derecho real de dominio. Entonces, para que se aplique el Art. 16 CC el bien debe estar ubicado en Chile al momento de adquisición del derecho real. Si al momento de la adquisición del derecho real estaba ubicado en otro país no se aplicará la ley chilena, sino la de ese país donde estaba situado.

D.9. Excepciones al principio *lex rei sitae*:

1. Conforme al Art. 955 CC la adquisición, cesión y pérdida del derecho real de herencia queda sujeto a la ley del último domicilio del causante y no a la ley de ubicación de los bienes hereditarios. La consecuencia de esto es que el derecho real de herencia de un bien ubicado en Chile puede quedar sometido a una ley extranjera si el causante tuvo su último domicilio en el extranjero.
2. Hay algunos autores (la profesora no se incluye) que hablan de otra excepción que es la de los inc. 2 y 3 del Art. 16 CC, que dicen: esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño; pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas. Sin embargo, esta no es una realmente una excepción, ya que ambos incisos se refieren a otro estatuto, el de los actos y contratos y determinan la ley que rige los derechos personales que surgen de esos actos o contratos, los que quedan gobernados por la ley chilena, si se van a ejercer en Chile.

Por ejemplo, si Pedro celebra un contrato de compraventa en París de una casa ubicada en Villarrica, Chile. El inc. 1 del Art. 16 CC dispone que el modo de adquirir el dominio va a quedar gobernado por la ley chilena. El inc. 2 valida ese contrato y declara que puede producir efectos en Chile y el inc. 3 señala que los derechos personales como, por ejemplo, la obligación de entregar la cosa, que deban producirse en Chile, quedan gobernados por la ley chilena, porque es la ley del lugar de cumplimiento del contrato.

D.10. Ejecución de sentencias extranjeras sobre bienes situados en Chile: para hacer efectiva en Chile una sentencia arbitral u ordinaria, dictada por un tribunal extranjero, que disponga sobre bienes situados en Chile, debe solicitarse en Chile su exequátur ante la Corte Suprema. Por ejemplo, cuando se quiere ejecutar una sentencia que ordena el remate de un bien situado en Chile o el pago de una cantidad de dinero a un deudor chileno.

La jurisprudencia de la Corte Suprema chilena, sostenidamente, ha considerado que las sentencias extranjeras que dispongan directamente sobre bienes situados en Chile vulneran el orden público nacional y la jurisdicción nacional (ver Art. 245 CPC requisitos para otorgar el exequátur). Su argumento ha sido que el Art. 16 CC al someter los bienes situados en Chile a la ley chilena, no sólo los somete a esa ley, sino que también a la jurisdicción exclusiva de los tribunales chilenos. Así, dándole un alcance jurisdiccional al Art. 16 CC ha declarado que los tribunales chilenos son los únicos

competentes para decidir acerca de los bienes situados en Chile. Por eso, la Corte Suprema ha denegado sostenidamente, el executur a estas sentencias.

Por esta misma razón la Corte ha declarado que los tribunales chilenos son los únicos competentes para ordenar medidas precautorias o de apremio sobre bienes situados en Chile. La Corte Suprema sólo otorga el executur a sentencias que NO disponen directamente sobre bienes situados en Chile; por ejemplo, a sentencias extranjeras que ordenan el pago de una suma de dinero a un deudor domiciliado en Chile.

D.11. Ejercicios Prácticos:

(1.) Juan Pérez, chileno, es inventor de un cilindro para la extracción de minerales e inscribió en el año 2005 sus derechos de propiedad industrial en Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, inscripciones que permanecen vigentes. En el año 2017, toma conocimiento de que ese modelo de cilindro ha sido imitado por un fabricante sin su autorización y se está comercializando en Perú y Bolivia. Juan Pérez le solicita un informe en derecho acerca de su situación jurídica y, concretamente, acerca de la ley que ampara su derecho de propiedad industrial sobre el cilindro y cómo hacerlos valer.

1. Hechos:

- a. Chileno inventor de un cilindro cuyos derechos de propiedad industrial están inscritos en Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, actualmente vigente.
- b. Imitación de fabricante no autorizado y comercializado en Perú y Bolivia.

2. Problema Jurídico: exigibilidad del derecho de propiedad.

3. Norma Aplicable: Art. 105 CB (se aplica la ley de situación de los bienes), combinado con el Art. 108 CB (la propiedad industrial se sitúa en el lugar de registro).

4. Solución: el derecho de propiedad industrial se encuentra ubicado, en este caso, en Perú y Bolivia, por lo que habrá que demandar en esos países y los jueces respectivos aplicarán sus respectivas leyes nacionales (peruana y boliviana).

(2.) La compañía naviera chilena Sudamericana de Vapores desea garantizar un crédito solicitado a un banco de Nueva York, constituyendo hipoteca naval sobre una de sus naves que navega bajo bandera liberiana. Indique dónde y bajo qué ley debe proceder a inscribir esa hipoteca.

1. Hechos:

- a. Compañía naviera chilena.
- b. Crédito bancario en Nueva York
- c. Hipoteca naval bajo bandera liberiana.

2. Problema Jurídico: determinar la ley que rige la hipoteca y dónde debe inscribirse.

3. Norma Aplicable: Art. 274 y ss. CB.

4. Solución: la nave se rige por la ley del lugar de inscripción o del pabellón, siendo gobernada por la ley liberiana.

(3.) Juan Carlos Swett compra en Brasil una grúa Caterpillar a un distribuidor de esa marca con oficinas en Sao Paulo el precio de la compra es 50.000 dólares CIF Valparaíso. Posteriormente, Juan Carlos constituye una prenda sin desplazamiento en favor del Banco BCI, sucursal Punta Arenas, para garantizar el pago de un crédito contraído con ese Banco. Al respecto señale:

1. ¿Qué ley regirá la adquisición del dominio de la grúa? Conforme al Art. 16 inc. 1 CC, se rige por la ley chilena (la tradición se hace en Valparaíso).
2. ¿Qué ley regirá la adquisición del derecho de prenda por parte de BCI? Conforme al Art. 16 inc. 1 CC y Art. 111 CB, la prenda se constituye en Chile y, por tanto, se rige por la ley chilena.
3. ¿Qué ley regirá la capacidad de Juan Carlos para celebrar el contrato de compraventa? Asumiendo que es chileno, se regirá por la ley chilena en virtud del Art. 15 N°1 CC en vista del Incoterm.

E. El Estatuto de la Sucesión por Causa de Muerte o Hereditaria:

E.1. Concepto y ámbito: el estatuto de las sucesiones es el conjunto de normas que regulan la ley aplicable a la sucesión hereditaria o *mortis causa*. Rige la mayoría de los aspectos de la sucesión como:

1. La capacidad para suceder, la determinación de los herederos y el orden de sucesión
2. El derecho de representación.
3. La apertura de la sucesión, la transmisión y posesión de la herencia, su administración y las facultades del albacea.
4. La determinación de la masa hereditaria y la separación de patrimonios hereditarios.
5. La existencia de legítimas y mejoras.
6. La partición de la herencia, los efectos de la herencia, la división de créditos y deudas hereditarias.
7. La eficacia e interpretación del testamento, de los pactos sucesorios y de las donaciones *mortis causa*.
8. La aceptación de la herencia.

Existe una excepción, ya que la validez formal del testamento que queda regida por la ley del lugar de otorgamiento (Art. 1027 CC). La capacidad para testar que queda regida por el estatuto personal.

E.2. La sucesión en el derecho internacional comparado: las distintas legislaciones del mundo adoptan diversas soluciones para determinar la ley que rige la sucesión.

1. Sistemas de unidad y sistemas de pluralidad de leyes sucesorias:

- a. Algunos sistemas jurídicos someten la sucesión a una única ley sucesoria, adoptando un único factor de conexión para determinarla. Por ejemplo, muchos países europeos optan por gobernar la sucesión por la ley de la última nacionalidad del causante y nuestro sistema jurídico por la ley del último domicilio del causante. Esto significa, en la práctica, que la sucesión de todos los bienes hereditarios queda sujetos a esta ley, sin importar dónde estén situados. Estos sistemas de unidad de la sucesión son sistemas personales, por estar basados en la persona del causante.
- b. Otros sistemas jurídicos optan por someter la sucesión a una pluralidad de leyes sucesorias al elegir el factor de conexión para determinar la ley que la rige. Por ejemplo, someten la sucesión a la ley del lugar donde están ubicados los bienes hereditarios, los que pueden estar situados en Estados distintos con leyes distintas. También, pueden adoptar dos factores de conexión y someter los bienes hereditarios inmuebles a la *lex situs* y los muebles a la ley del último domicilio o residencia

habitual del causante. Estos sistemas suelen llamarse sistemas reales, por estar basados en los bienes hereditarios mismos.

2. Sistemas reales y personales, según la naturaleza jurídica de la sucesión:

- a. Los sistemas reales consideran a la sucesión primordialmente como un conjunto de bienes y, por ello, someten esos bienes, si son inmuebles, siempre a la ley del lugar de situación y a los muebles también a esa ley o a la ley del último domicilio o residencia habitual del causante.
- b. Los sistemas personales consideran a la sucesión como una continuadora jurídica de la persona del causante y, en base a esto, adoptan diversos factores de conexión para determinar su ley reguladora:
 - i. Someten a la sucesión a la ley personal del causante que, en muchos casos, es la ley de su última nacionalidad. Por ejemplo, sistema español, italiano.
 - ii. Entienden que la sucesión está determinada por un hecho jurídico fundamental, que es la muerte del causante, hecho jurídico que suele ocurrir en el lugar del último domicilio del causante y por eso someten la sucesión a la ley de este último domicilio.

3. Sistemas de transmisión directa e indirecta de la herencia:

- a. Algunos sistemas jurídicos, mayormente los reales, establecen una transmisión indirecta de los bienes hereditarios a los herederos, nombrando administradores de la sucesión encargados de pagar las deudas hereditarias que gravan la herencia y de recolectar los bienes que la integran para luego, entregar el remanente a los herederos (*Estate Management, Probate case*). Este es el caso de los sistemas jurídicos del *Common Law*.
- b. Otros sistemas jurídicos, establecen una transmisión directa de los bienes hereditarios a los herederos, la herencia se les defiende por la muerte del causante, de tal manera, que los herederos se reputan legalmente como sus sucesores jurídicos y quedan obligados al pago de las deudas hereditarias, con algunas excepciones legales. Esta es la solución más general de los países de Derecho codificado.

E.3. Elementos que pueden internacionalizar la herencia:

- 1. Lugar de ubicación de los bienes.
- 2. Lugar de domicilio o residencia habitual del causante.
- 3. Nacionalidad del causante o de los herederos.

E.4. La regulación de la sucesión en el derecho internacional privado chileno: el sistema regulador chileno de la sucesión hereditaria es mayormente unitario, es decir, busca someter la sucesión a una única ley, salvo las excepciones legales establecidas en favor de los herederos chilenos. Es también un sistema personal, que concibe a la sucesión y a los herederos en su conjunto como los continuadores de la persona del causante, estableciendo un sistema de transmisión directa de la herencia. La principal norma reguladora del estatuto de la sucesión es la del Art. 955 CC, el que dispone que la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio (salvos los casos expresamente exceptuados); la sucesión se regula por la ley del domicilio en que se abre (salvas las excepciones legales).

E.4.1. Análisis del Art. 955 CC:

1. Se refiere a todo tipo de sucesión. Este artículo al referirse a la sucesión, en general; somete tanto la sucesión testada como la intestada a la ley del último domicilio del causante, salvo las excepciones legales.
2. Establece como regla general una única ley sucesoria para gobernar la sucesión sin considerar la ubicación de los bienes ni su naturaleza jurídica. Esta ley del último domicilio del causante gobierna, en general, todos los aspectos comprendidos dentro del estatuto de la sucesión y a todos los bienes sucesorios. Por ejemplo, la capacidad para suceder, la aceptación y la repudiación de la herencia, la posesión de la herencia, la separación de patrimonios hereditarios, la división de la herencia, los efectos de la herencia, la división de créditos y deudas hereditarias, el derecho de representación, las facultades del albacea, entre otros.
3. No se refiere a la validez formal del testamento y a la capacidad para testar, las que quedan sometidas a otra ley. La formalidad del testamento normalmente queda sometida a la ley del lugar de celebración y la capacidad para testar queda gobernada por la ley del estatuto personal.
4. Establece como factor de conexión la ley del lugar de apertura de la sucesión, es decir, la ley del último domicilio del causante.

E.4.2. Concepto de último domicilio: se refiere al domicilio jurídico, es decir, la residencia acompañada, real o presuntivamente, con ánimo de permanecer en ella. (Art. 59 CC). La doctrina discute si se trata del domicilio político (relativo al Estado en general, Art. 60 CC) o civil (relativo a una parte determinada del Estado, Art. 61 CC y Art. 62 CC). En el caso de no poder establecer el domicilio del causante, se puede aplicar la ley del lugar de mera residencia, que hace las veces de domicilio civil (Art. 68 CC). En todo caso, el juez chileno debiera calificar el domicilio conforme a la lex fori, es decir, a la definición del CC chileno y no conforme a la ley del lugar de apertura de la sucesión. Este último domicilio del causante no se identifica con el lugar de fallecimiento del causante, aunque a veces puede coincidir con él.

E.4.3. Excepciones legales a la regla general del Art. 955 CC¹⁸: la doctrina está conteste en que existen tres excepciones al principio general y algunos autores señalan otras dos. Las excepciones generalmente aceptadas son: (i) Art. 15 N°2 CC; (ii) Art. 998 inc. 1 CC; y (iii) Art. 998 inc. 3 CC. Las excepciones adicionales son: (i) Art. 81 N°1 CC; y (ii) Art. 27 de la Ley 16.271 sobre Impuesto de Herencia y Donaciones.

1. **Excepción del Art. 15 N°2 CC (causante chileno con herederos chilenos).** La norma dispone que a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero (2) en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos.

Esta norma somete al chileno residente en el extranjero a la ley chilena, respecto de sus obligaciones y derechos de familia hacia su cónyuge y parientes chilenos. Por lo tanto, el

¹⁸ Art. 955 CC: la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio; salvo los casos expresamente exceptuados. / La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvo las excepciones legales.

causante chileno está sometido a las obligaciones y derechos que surgen de las relaciones de familia establecidas por la ley chilena respecto de su cónyuge y parientes chilenos.

En la práctica, esto significa que aunque su sucesión quedará gobernada por la ley de su último domicilio; su cónyuge y parientes chilenos tendrán los derechos hereditarios que les concede la ley chilena, vale decir, tendrán siempre derecho a las asignaciones forzosas que les concede la ley sucesoria chilena.

Entonces, si la ley extranjera que rige la sucesión le otorga al cónyuge y/o parientes chilenos menos derechos hereditarios que los que les correspondería como asignaciones forzosas de la ley chilena; estos herederos chilenos, pueden reclamar estas asignaciones. Este reclamo se podrá hacer efectivo sobre los bienes del causante chileno situados en Chile. Para el cálculo de estas asignaciones forzosas deben colacionarse todos los bienes del causante, existentes en Chile y en el extranjero.

Esta excepción es una excepción parcial, porque no altera la regla general de la ley que rige la sucesión. Por tanto, la sucesión se va a seguir rigiendo por la regla general, pero respecto de los chilenos, el legislador chileno los protege y les va a garantizar siempre, al menos, sus asignaciones forzosas.

2. **Excepción del Art. 998 inc. 1 CC (causante extranjero con herederos chilenos).** La norma dispone en su inciso primero que en la sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio de la República, tendrán los chilenos a título de herencia o de alimentos, los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada de un chileno. El inciso segundo agrega que los chilenos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero.

Según el texto del Art. 998 CC, éste se aplica a la sucesión intestada de un extranjero y beneficia a los herederos chilenos de este extranjero, otorgándoles los mismos derechos que les correspondería en la sucesión intestada de un chileno. Estos derechos son las asignaciones forzosas establecidas por la ley sucesoria chilena. Esta excepción se aplica, cualquiera sea la ley general extranjera que regule la sucesión. Es una norma de policía.

En el inc. 2 se establece el mecanismo para hacer efectivas, en la práctica, estas asignaciones: pedir que se les adjudiquen esas asignaciones a los herederos chilenos en los bienes del causante existentes en Chile. Esto podrá hacerse efectivo por medio de una acción de petición de herencia o de reforma de testamento presentada ante los tribunales chilenos.

Si no hay bienes del causante en Chile quedará al arbitrio del tribunal extranjero que conoce de la sucesión y de la ley de ese foro reconocer o no estos derechos que otorga la ley chilena a los chilenos. Por eso, la efectividad práctica de esta norma depende de que existan bienes de la sucesión en Chile. Esta es también una excepción parcial, porque en todos los demás aspectos y derechos sucesorios, la sucesión se seguirá rigiendo por la ley del último domicilio del causante extranjero.

¿Se aplica la excepción del Art. 998 inc. 1 CC también a la sucesión testada del extranjero? Una aplicación e interpretación literal de este artículo nos obliga a restringir su aplicación sólo a la sucesión intestada de un extranjero. Sin embargo, parte de la doctrina nacional ha cuestionado esta aplicación restringida con buenos fundamentos legales y movidos por la intención de proteger el principio general de nuestra legislación sucesoria que otorga siempre asignaciones forzosas a los legitimarios sin distinguir si la sucesión es testada o no. Estos autores dan los siguientes argumentos:

- a. Sería injusto proteger las asignaciones forzosas de los herederos chilenos sólo para la sucesión intestada y no para la testada e incongruente con la norma general de nuestra legislación sucesoria.
- b. No existe una justificación para restringir el otorgamiento de estas asignaciones forzosas a los herederos chilenos sólo en la sucesión intestada.
- c. El Art. 998 inc. 1 debe interpretarse de manera armónica y teleológica con las demás normas sucesorias chilenas de modo de extenderse su aplicación también a la sucesión testada del extranjero.
- d. En nuestro Código Civil la sucesión legal se llama intestada o *abintestato*.

Una interpretación teleológica de esta norma lleva a buscar cuál es el fin que el legislador contempló al dictarla. Evidentemente, al hacerlo el legislador buscó proteger a los herederos chilenos del causante extranjero, ante la eventualidad que una ley extranjera les otorgara menores derechos sucesorios que la ley chilena. Además, el legislador, implementó un mecanismo práctico para que ellos pudieran hacer efectivo estos derechos en Chile.

Los profesores Domínguez abogan por una interpretación armónica de la norma. Ellos argumentan que en la legislación chilena no tiene sentido distinguir entre sucesión testada o sucesión intestada, porque en ambos tipos de sucesión se reconocen las asignaciones forzosas. Agregan, que cualquiera sea el tipo de sucesión, el origen de las asignaciones forzosas no está en el testamento, sino que siempre está en la ley. Por ello es correcto decir que esas asignaciones son asignaciones legales. El Código Civil en el Art. 952 CC indica expresamente que si sucede en virtud de la ley la asignación se llama “intestada o *abintestato*”. Por lo tanto, dicen los profesores Domínguez, cuando el legislador habla de la sucesión *abintestato* del extranjero se refiere a la sucesión legal de un extranjero y, por ello, es posible entender que el Art. 998 CC protege las asignaciones forzosas de los chilenos también en la sucesión testada porque estas asignaciones son siempre asignaciones legales. Esta interpretación, como decíamos antes, está en mayor armonía con toda la legislación sucesoria chilena.

Para calcular el monto de las asignaciones forzosas se colacionan a la masa hereditaria todos los bienes del causante, tanto los que están en Chile como los que están en el extranjero.

3. **Excepción del Art. 998 inc. 3 CC (causante chileno con herederos chilenos).** La norma dispone que esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un chileno que deja bienes en país extranjero. La norma dispone que los herederos chilenos de un chileno que deja bienes en país extranjero tienen garantizados, por la ley chilena, los mismos derechos

que les otorga la ley chilena en la sucesión intestada de un chileno, cualquiera sea la ley extranjera que rija la sucesión de ese chileno. Estos derechos podrán hacerse valer sobre los bienes del causante chileno ubicados en Chile (Art. 998 inc. 2 CC). Entonces este artículo:

- a. Se aplica a la sucesión de un causante chileno, gobernada por una ley extranjera.
- b. Si el causante chileno que dejó bienes sucesorios en el extranjero.
- c. Se aplica cualquiera sea el tipo de sucesión: testada o intestada.
- d. Garantiza a los herederos chilenos las asignaciones forzosas de la ley chilena, siempre que la ley general sucesoria les otorgue menos derechos que la ley chilena en sus asignaciones forzosas: “en caso necesario”.
- e. Esas asignaciones forzosas se pueden hacer valer sobre los bienes del causante ubicados en Chile (Art. 998 inc. 2 CC).
- f. Establece una excepción parcial a la ley determinada por el Art. 955 CC.

Esta excepción es similar, en la práctica, a la establecida en el Art. 15 N°2 CC. Sin embargo, se diferencia de ella en que, para que opere este inciso 3°, es necesario que el causante haya dejado bienes en el extranjero. Esto no se exige para que opere la excepción del Art. 15 N°2 CC. En los demás requisitos y efectos ambas normas son semejantes. Los beneficiarios son los mismos y las asignaciones hereditarias también. Las normas sólo difieren en que la norma del Art. 15 CC es general y la del Art. 998 CC es especial, referida sólo a la sucesión. Aunque el Art. 15 CC no contempla sistema específico para defender las asignaciones, es indudable que permite a los herederos chilenos también aplicar el beneficio que está establecido en el inciso segundo del Art. 998 CC, es decir, que se pueden pagar sus asignaciones forzosas sobre los bienes ubicados en Chile con preferencia respecto de las demás adjudicaciones de la herencia del causante.

4. **¿Excepción del Art. 81 N°1 CC?** La norma dispone que la presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile, justificándose previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia, han transcurrido a lo menos cinco años.

Algunos autores han considerado que esta norma establece una excepción a la norma del Art. 955 CC porque al establecer que la muerte presunta la debe declarar el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile, estaría indicando que la sucesión se regiría por la ley del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile y no por la ley del último domicilio efectivo del causante. Es decir, se regiría por la ley chilena aunque el causante haya tenido último domicilio en el extranjero.

Sin embargo, otra parte de la doctrina nacional, a la cual adhiere la cátedra, difiere de esta interpretación, porque considera que esa interpretación extensiva del Art. 81 CC es improcedente. El Art. 81 CC es una norma de competencia jurisdiccional que determina quién es el juez competente para decretar la muerte presunta; y no se refiere de ningún modo a la ley que debe gobernar la sucesión del desaparecido, que se determinará siempre conforme a la norma del Art. 955 CC ya que no se ve alterada por esta norma. Por ello, no sería realmente una excepción ni produciría un cambio de la ley reguladora de la sucesión.

Hay que recordar que, al estudiar antes la muerte presunta y este artículo 81, expusimos que el juez chileno sólo tiene competencia para decretar la muerte presunta cuando el desaparecido tuvo su último domicilio en Chile y que la jurisprudencia acompañada de la doctrina, ha extendido esa competencia a la declaración de la muerte presunta de los chilenos, aunque no hayan tenido su último domicilio en Chile, porque esa muerte extingue o produce un cambio su estado civil que, conforme al Art. 15 N°2 CC debe quedar regida por la ley y jurisdicción chilena.

Es decir, cuando un juez chileno declara la muerte presunta, lo hace porque el desaparecido tuvo su último domicilio en Chile y por ello su sucesión deberá abrirse en Chile y regirse por la ley chilena. En el caso excepcional de que el juez chileno declare la muerte presunta de un chileno con último domicilio en el extranjero, su sucesión deberá abrirse en el lugar de su último domicilio y quedará regida por la ley de ese lugar.

5. **¿Excepción del art. 27 Ley 16.271 sobre Impuesto a la Herencia y Donaciones?** La norma dispone que cuando la sucesión se abra en el extranjero, deberá pedirse en Chile, no obstante lo dispuesto en el artículo 955 del Código Civil, la posesión efectiva de la herencia respecto de los bienes situados dentro del territorio chileno, para los efectos del pago de los impuestos establecidos por esta ley. / La posesión efectiva, en este caso, deberá pedirse en el lugar en que tuvo el causante su último domicilio en Chile, o en el domicilio del que pida la posesión efectiva, si aquél no lo hubiere tenido.

Este artículo dispone que, cuando la sucesión se abre en el extranjero porque el último domicilio del causante estuvo en el extranjero, deberá pedirse en Chile la posesión efectiva de la herencia respecto de los bienes situados en Chile, para efectos del cálculo y pago del impuesto de herencia o donaciones, no obstante que la sucesión se tramite en el extranjero y conforme a una ley extranjera. En este caso, la posesión efectiva debe pedirse ante el juez competente del último domicilio que el causante haya tenido en Chile y, si no lo tuvo, ante el juez del domicilio de quien la solicite.

El objetivo de este artículo es garantizar el pago en Chile del impuesto de herencia que grava los bienes situados en Chile. El artículo no pretende alterar la ley sucesoria ni la jurisdicción del juez competente para realizar los demás trámites sucesorios, como por ejemplo, la partición y adjudicación de los bienes hereditarios. No es una excepción al Art. 955 CC.

Es decir, en este caso se solicita la posesión efectiva de los bienes ubicados en Chile ante el tribunal chileno, se confecciona su inventario, se evalúan los bienes y se manda a SII para que calcule el impuesto de herencia. Luego, se paga este impuesto y se envía al Conservador de Bienes Raíces del lugar para que practique la inscripción especial de la herencia a nombre de todos los herederos.

Esta norma está en consonancia con lo dispuesto en el Art. 149 COT, el que dispone que: cuando una sucesión se abra en el extranjero y comprenda bienes situados dentro del territorio

chileno, la posesión efectiva de la herencia deberá pedirse en el lugar en que tuvo el causante su último domicilio en Chile, o en el domicilio del que la pida si aquél no lo hubiere tenido.

E.5. El testamento en el derecho internacional chileno:

E.5.1. Concepto y calificación: el concepto o calificación del testamento queda determinado en Chile por la definición del Art. 999 de CC, el que dispone que el testamento es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva.

En relación al testamento, el DIPRI hace una distinción entre la ley que determina su validez formal y la que determina la eficacia de las disposiciones testamentarias, además de la ley que rige la capacidad para testar. La ley que rige la capacidad para testar es la que gobierna el estatuto personal del testador.

La eficacia de las disposiciones testamentarias queda determinada por la ley que rige la sucesión. Será esta ley la que determine si dará efecto o no a las disposiciones del testamento o las limitará cuando vulneran asignaciones legales forzosas que el causante debió respetar. Esta ley también determina la capacidad para suceder de los herederos o legatarios.

E.5.2. Validez formal del testamento en el derecho internacional privado comparado: los distintos sistemas jurídicos someten la validez formal del testamento a distintas leyes, dependiendo de la naturaleza jurídica que le asignan al testamento. Algunos sistemas jurídicos consideran que el testamento es un acto jurídico unilateral que debe someterse a la ley del lugar donde se otorga. Otros, en cambio, consideran que es un acto personalísimo, que debe someterse a la ley personal del testador. Y otros consideran que es un acto intrínsecamente ligado a o que forma parte de la sucesión, que debe regirse por la misma ley que rige la sucesión. La legislación chilena adopta la primera solución, someterlo a la ley del lugar de otorgamiento (*lex locus regit actum*).

E.5.3. Validez formal del testamento en la legislación chilena:

1. **Validez formal del testamento otorgado en Chile:** el testamento otorgado en Chile se rige por las normas de la ley chilena por disposición general del Art. 14 CC, que nos remite a la aplicación de las normas contenidas en los Art. 999 CC al Ar. 1055 CC. La legislación chilena permite testar en Chile ante agentes diplomáticos extranjeros en ciertos casos, en cuyo caso, estos testamentos quedarán gobernados, en cuanto a su forma, por la ley del Estado al que el agente representa.
2. **Validez formal del testamento otorgado en el extranjero:** la legislación chilena adopta el criterio general de someter la validez formal del testamento a ley del lugar de otorgamiento, pero incluye algunas excepciones.
 - a. **Primera forma: Art. 1027 CC, testamento otorgado en el extranjero con forma extranjera.** La norma dispone que valdrá en Chile el testamento escrito, otorgado en país extranjero, si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria. El testamento otorgado en el extranjero

que cumpla con los siguientes requisitos, será válido en Chile: (i) debe ser escrito; (ii) haberse otorgado conforme a las formalidades del país de otorgamiento; y (iii) debe probarse su autenticidad por medio de legalización o apostilla. Eventualmente, deberá traducirse si está escrito en otro idioma.

b. Segunda forma: Art. 1028 CC y Art. 1029 CC, testamento otorgado ante agente diplomático chileno en el extranjero, con forma chilena. El Art. 1028 CC dispone que valdrá asimismo en Chile el testamento otorgado en país extranjero, con tal que concurren los requisitos que van a expresarse:

- i. No podrá testar de este modo sino un chileno, o un extranjero que tenga domicilio en Chile.
- ii. No podrá autorizar este testamento sino un Ministro Plenipotenciario, un Encargado de Negocios, un Secretario de Legación que tenga título de tal, expedido por el Presidente de la República, o un Cónsul que tenga patente del mismo; pero no un Vicecónsul. Se hará mención expresa del cargo, y de los referidos título y patente.
- iii. Los testigos serán chilenos, o extranjeros domiciliados en la ciudad donde se otorgue el testamento.
- iv. Se observarán en lo demás las reglas del testamento solemne otorgado en Chile.
- v. El instrumento llevará el sello de la Legación o Consulado.

Entonces, para que este testamento otorgado ante diplomático chileno en el exterior sea válido en Chile, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que el testador sea chileno o bien, un extranjero que tenga domicilio en Chile; (ii) que el testamento sea autorizado por el funcionario competente del consulado y que se haga referencia en el testamento del cargo y título que tiene ese funcionario; (iii) que los testigos sean chilenos o extranjeros domiciliados en la ciudad donde se otorgue el testamento; (iv) que el testamento cumpla con las formalidades exigidas para el testamento solemne otorgado en Chile; (v) que lleve el sello de la legación o consulado. Este testamento no requiere de legalización o apostilla para hacerse valer en Chile porque se otorga ante un ministro de fe chileno.

A su vez, el Art. 1029 CC dispone que el testamento otorgado en la forma prescrita en el artículo precedente y que no lo haya sido ante un jefe de Legación, llevará el Visto Bueno de este jefe; si el testamento fuere abierto, al pie, y si fuere cerrado, sobre la carátula: el testamento abierto será siempre rubricado por el mismo jefe al principio y fin de cada página. / El jefe de Legación remitirá en seguida una copia del testamento abierto, o de la carátula del cerrado, al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile; el cual a su vez, abonando la firma del jefe de Legación, remitirá dicha copia al juez del último domicilio del difunto en Chile, para que la haga incorporar en los protocolos de un escribano del mismo domicilio. / No conociéndose al testador ningún domicilio en Chile, será remitido el testamento por el Ministro de Relaciones Exteriores a un juez de letras de Santiago, para su incorporación en los protocolos de la escribanía que el mismo juez designe.

Es decir, una copia de este testamento debe ser enviada a Chile por la legación y protocolizada ante el notario que el juez competente indique. El testamento otorgado de esta forma además puede ser abierto o cerrado, según lo dispone la legislación chilena. El Art.1029 CC especifica que el testamento abierto debe incluir al pie el visto bueno del jefe de legación, y el cerrado, ese visto bueno en la carátula. La ventaja práctica de testar con esta forma es que no necesita probarse en Chile que se han cumplido con las solemnidades establecidas por la ley extranjera del lugar de otorgamiento ni presentar el testamento autenticado o traducido. Este testamento queda regido por la ley chilena en cuanto a su forma.

3. **Testamento otorgado en el extranjero ante agentes diplomáticos extranjeros:** para que este testamento sea válido en Chile, debe cumplir con los requisitos del Art. 1027 CC. Sin embargo, además de estar autorizado testar ante agente diplomático extranjero por la legislación del país de otorgamiento, debe otorgarse ante un agente diplomático autorizado por la legislación del Estado al que representa. En este caso, el testamento deberá cumplir con las formalidades prescritas por esa ley ya que el agente diplomático actúa como ministro de fe de ese Estado y bajo la jurisdicción del estado al que representa.

E.5.4. Discusiones en torno a la validez de ciertas formas de testamentos extranjeros: se ha discutido acerca de la validez en Chile de ciertas formas de testamentos otorgados en el extranjero.

1. **Testamento ológrafo otorgado en el extranjero:** se ha discutido si un testamento ológrafo otorgado en el extranjero sería válido en Chile. Un testamento ológrafo es el testamento otorgado por escrito, sin ninguna otra formalidad. Este tipo de testamento es permitido y habitual en algunas legislaciones. Para saber si ese testamento es válido, es necesario verificar si cumple con los requisitos del Art. 1027 CC. Por ello, si la ley del lugar de otorgamiento reconoce su validez y se prueba su autenticidad en Chile, por medio de apostilla o legalización, éste valdrá en Chile.
2. **Testamento verbal otorgado en el extranjero:** el testamento verbal válido en el lugar de otorgamiento no sería válido en Chile, pues se vulnera una norma de policía que es el Art. 1027 CC que exige imperativamente que el testamento otorgado en el extranjero sea escrito para ser válido en Chile.

E.6. Ejercicios Prácticos:

(1.) Un chileno, estudiante de Diseño Gráfico en el DUOC (Sede Sn Carlos de Apoquindo) desaparece durante un viaje turístico a Bariloche (Argentina) sin que se tengan noticias de su paradero. Sus parientes deciden solicitar que se declare su muerte presunta. ¿Qué Tribunal será el competente para declarar su muerte presunta? ¿Qué ley será aplicable a su sucesión?

1. **Hechos jurídicamente relevantes:** chileno desaparecido en Bariloche y solicitud de muerte presunta.
2. **Problema jurídico:** declaración de la muerte presunta, juez competente y ley aplicable.
3. **Legislación aplicable:** Art. 15 N°1 y Art. 81 N°1 CC; Art. 955 CC.
4. **Posible solución o soluciones:** el juez competente para declarar la muerte presunta será el del ultimo domicilio del desaparecido, es decir, el juez chileno. El juez chileno deberá aplicar la ley chilena al ser esta la ley del ultimo domicilio del causante desaparecido.

(2.) Carlos Pérez, chileno, muere en Madrid teniendo allí su último domicilio. Pérez tenía bienes en España y Chile. Pérez otorga testamento en Madrid instituyendo a “La Fundación Las Rosas” (entidad chilena) heredera de sus bienes en Chile que ascienden al 50% de la masa hereditaria quedada a su fallecimiento. Su cónyuge es chilena y sus 5 hijos españoles-chilenos. Según las normas de conflicto chilenas, ¿qué ley rige esta sucesión?, ¿qué requisitos debe reunir su testamento para ser válido y eficaz en Chile?

1. **Hechos jurídicamente relevantes:** chileno muere con último domicilio en Madrid. Bienes en España y Chile. Testamento otorgado en Madrid. Entidad chilena heredera de los bienes chilenos que ascienden al 50% de la masa hereditaria. Cónyuge chileno e hijos chilenos y españoles.
2. **Problema jurídico:** ley sucesoria aplicable y requisitos de validez del testamento extranjero en Chile.
3. **Legislación aplicable:** Art. 955, Art. 998 inc. 3 y Art. 15 N°2, Art. 1027, Art. 1028 y Art. 1029 CC.
4. **Posible solución o soluciones:** en primer lugar, la sucesión debiera regirse por la ley española al ser España el último domicilio del causante. Sin embargo, debido a la vulneración a las asignaciones forzosas chilenas y a la existencia de cónyuges e hijos chilenos, éstos pueden hacer aplicable la ley sucesoria chilena a través de la acción de reforma de testamento, y en consecuencia, haciéndose exigible la asignación forzosa en los bienes chilenos y en todo lo restante se aplicará la ley española. En segundo lugar, el Art. 1027 CC exige que para que un testamento otorgado en el extranjero sea válido en Chile, se otorgue de acuerdo a las formalidades exigidas por la ley del país en que se otorgó (ley española). Sin embargo, Carlos pudo haber otorgado el testamento ante el cónsul chileno en España. En principio, la eficacia del testamento queda sometida a la ley sucesoria que sería la ley española, pero debido a la excepción del Art. 15 N°2 y Art. 998 inc. 3 CC la ley sucesoria será la ley chilena quedando la eficacia del testamento sometida a la ley chilena.

(3.) Carlos Fuentes, chileno, se casa en Francia con una francesa en 1988 y establece su domicilio ahí. El año 2000, Carlos otorga testamento en París instituyendo como heredera universal de sus bienes a su mujer Nicole. Carlos muere en París el año 2008 dejando bienes en Francia y Chile, le sobreviven su mujer y tres hijos nacidos en Francia. A su muerte se discute en Chile: (i) la validez del testamento y de sus disposiciones; (ii) los derechos sucesorios de los herederos de Carlos. Señale las normas legales que gobiernan estos asuntos y las soluciones que ellas determinan:

1. **Hechos jurídicamente relevantes:** chileno casado en Francia. Cónyuge francesa. Domicilio en Francia. Testamento otorgado en el extranjero. Heredera universal. Chileno muere en Francia. Bienes en Chile y Francia. Hijos franceses-chilenos.
2. **Problema jurídico:** validez del testamento y derechos sucesorios de los herederos.
3. **Legislación aplicable:** Art. 1027, Art. 1028 y Art. 1029 CC, Art. 955, Art. 998 inc. 3 y Art. 15 N°2 CC.
4. **Posible solución o soluciones:** misma solución del caso anterior.

(4.) Helmut Schmidt, alemán, domiciliado en Hamburgo, dueño de bienes en Alemania y Chile, le consulta a Ud. acerca de la forma en que debe testar para legar sus bienes ubicados en Chile a su hermana Gertrud, que vive en Frutillar-Chile.

1. **Hechos jurídicamente relevantes:** alemán domiciliado en Hamburgo. Bienes en Alemania y Chile.
2. **Problema jurídico:** forma de testar sobre bienes ubicados en Chile.
3. **Legislación aplicable:** Art. 1027 CC (no aplica el Art. 1028 y el Art. 1029 CC porque estos son solo aplicables a los chilenos o extranjeros domiciliados en Chile).
4. **Posible solución o soluciones:** el alemán deberá testar por escrito y con arreglo a las formalidades de la ley alemana (en específico, la de Hamburgo), debiéndose enviar el testamento a Chile de forma legalizada o apostillada y con la debida traducción al español.

F. El Estatuto de los Actos y Contratos:

E.1. Concepto: el estatuto de los actos y contratos es el conjunto de normas de conflicto que determinan la ley aplicable a los actos y contratos respecto de su validez formal, sustancial, interpretación y efectos. En DIPRI se distingue entre las normas que determinan la ley aplicable a: (i) la validez formal o solemnidades de los actos y contratos; y (ii) las normas que determinan la ley que rige su fondo.

E.2. Estatuto de la Forma de los Actos y Contratos: en cuanto al concepto, es el conjunto de normas de conflicto que determinan la ley aplicable a las formalidades de los actos y contratos. El Derecho Internacional Privado clásico estableció que las formalidades de los actos y contratos quedaban regidas por la ley de su lugar de celebración, aplicando el principio *lex locus regit actum*. Esta solución ha ido cambiando en el Derecho Internacional Privado contemporáneo porque:

1. A veces, no es fácil determinar el lugar de celebración de un contrato porque, por ejemplo, éste puede celebrarse por vía electrónica o porque, en otro contrato a distancia, hubo una larga negociación previa que no permite identificar exactamente quién envió la oferta finalmente aceptada y quién la aceptó.
2. Hay contratos internacionales que tienen múltiples lugares de otorgamiento, por ejemplo, los contratos que las partes firman simultáneamente, por vía electrónica en distintos lugares o “salas de cierre” ubicados en diversos países.
3. Hay contratos en los que el lugar de otorgamiento es accidental y tiene poca o nula vinculación jurídica con las partes o el contrato mismo; como, por ejemplo, una compraventa realizada en una feria industrial internacional entre un fabricante y un comprador extranjeros, ambos estando de paso en el lugar.

Por estas razones, las legislaciones más modernas de DIPRI han comenzado a aplicar el *principio favor negotii* para proteger la validez de los actos y contratos y evitar invalidarlos por defectos formales. Estas legislaciones, han optado por usar factores de conexión múltiples y subsidiarios para determinar la ley que rige las formalidades de los actos y contratos, sometiendo esas formalidades a varias leyes de aplicación alternativa o subsidiaria. Así, si el acto o contrato cumple las formalidades de cualquiera de esas leyes, el acto es válido.

En cuanto a la normativa de DIPRI chilena reguladora de la forma de los actos y contratos, en el derecho chileno no hay una norma general que establezca la ley que rige las formalidades de los actos y contratos. Sin embargo, hay algunas normas particulares o específicas que aplican el *principio lex locus regit actum* para determinar esa ley.

1. **Art. 17 CC:** este se refiere a la forma de los **instrumentos públicos**. En este artículo se consagra el principio *lex locus regit actum*, puesto que somete la forma de los instrumentos públicos a la ley del lugar en que hubieren sido otorgados.
2. **Art. 1027 CC:** este artículo se refiere al **testamento** escrito otorgado en país extranjero, el cual somete sus formalidades a la ley del lugar de otorgamiento.
3. **Art. 80 LMC:** Este artículo establece que los requisitos de fondo y forma del **matrimonio** serán los que establezca la ley del lugar de celebración.
4. **Art. 12 Ley Acuerdo Unión Civil (Ley 20.830):** respecto a las formalidades del AUC.

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha fallado, en base a la existencia de estos artículos, que en Chile la vigencia del *principio lex locus regit actum* es universal. Es decir, ha concluido que la ley chilena exige que los actos y contratos cumplan con las formalidades de la ley del lugar de celebración para que sean formalmente válidos. La ley chilena no utiliza otros factores de conexión subsidiarios para determinar la validez formal de los actos y contratos.

Asimismo, hay que referir a los tratados internacionales vigentes en Chile que disponen acerca de la ley que regula la forma de los actos. Los tratados internacionales vigentes en Chile carecen de una norma general que determine la ley reguladora de las formalidades de los actos y contratos, pero contienen normas específicas para ciertos tipos de instrumentos sometiendo sus formalidades a la ley del lugar de celebración o realización de los actos.

1. El Código de Bustamante incluye una norma específica para las letras de cambio. El Art. 263 CB dispone que la forma del giro, endoso, fianza, intervención, aceptación y protesto de una letra de cambio, se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice.
2. La Convención Interamericana sobre conflictos de ley en materia de cheques celebrada en Panamá en 1975, Diario Oficial del 8 de Julio 1986 y vigente en Chile desde 1976, regula la forma de los cheques. El Art. 2 dispone que la forma del giro, endoso, aval, protesta y demás actos jurídicos que puedan materializarse en el cheque, se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realizare.
3. La Convención Interamericana sobre conflictos de ley en materia de letras de cambio, pagarés y facturas (Panamá 1975), Diario Oficial del 14 de Julio 1986, regula la forma de las letras de cambio, pagarés y facturas en los mismos términos. El Art. 2 dispone que la forma del giro, endoso, aval, intervención, aceptación o protesto de una letra de cambio, se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice.

Luego, hay que referir al análisis del Art. 17 CC, Art. 18 CC y Art. 1701 CC y sus disposiciones en relación a la forma de los actos e instrumentos.

1. **Art. 17 CC:** la norma dispone que la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento. / La forma se refiere a las solemnidades

externas, y la autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos se exprese.

- a. Este artículo dispone expresamente que los instrumentos públicos se rigen, en cuanto a su forma, por la ley del lugar de otorgamiento.
- b. Esa misma ley del lugar de otorgamiento es la que les da su carácter de instrumento público. Es decir, la calificación de instrumento público debe hacerse conforma a la *lex causae*, la ley bajo la cual se otorgó ese instrumento. Esa ley es la que determinará si el instrumento es público y si quien lo otorga es un funcionario público con facultades para otorgarlo.
- c. Para que ese instrumento público puede hacerse valer en Chile deberá probarse además que es auténtico, es decir, que ha sido otorgado realmente por quien aparece otorgándolo y que ha sido autorizado realmente por quien aparece autorizándolo. Esto se hace por medio de la legalización o apostilla.

Este Art. 17 CC, debe aplicarse en conjunto con el Art. 18 CC y Art. 1701 CC.

- 2. **Art. 18 CC:** el que dispone que en los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas. Este Art. 18 CC restringe en Chile el valor probatorio de los instrumentos privados otorgados en el extranjero. Es decir, exige imperativamente que los actos que deban probarse en Chile por medio de instrumento público se prueben por medio de ese tipo de instrumento aunque, en el extranjero, puedan probarse por instrumento privado. Esta es una norma de policía y, como todas las normas probatorias, es territorial. Cada país es soberano para establecer sus propias normas probatorias, y para desechar las normas probatorias de otros países. Esta norma de policía debe entenderse en conjunto con el Art. 1701 CC.
- 3. **Art. 1701 CC:** el que dispone que la de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal: esta cláusula no tendrá efecto alguno. / Fuera de los casos indicados en este artículo, el instrumento defectuoso por incompetencia del funcionario o por otra falta en la forma, valdrá como instrumento privado si estuviere firmado por las partes.

Entonces, podemos concluir que, si la ley chilena exige que un acto se pruebe en Chile por instrumento público, NO se puede probar ese acto en Chile con otro tipo de instrumento. Esto, aunque en el país extranjero se permita probar el acto por instrumento privado. Entonces, el acto deberá probarse en Chile por medio de un instrumento público extranjero debidamente autenticado y, si es necesario, traducido.

La pregunta que surge es si el Art. 18 CC exige que ese instrumento público extranjero sea el mismo tipo de instrumento público que exige la ley chilena para probar el acto. La respuesta es que el Art. 18 CC no exige necesariamente probarlo por el mismo instrumento público que ordena el derecho chileno; el Art. 18 CC sólo resta valor a las escrituras privadas, es decir sólo exige que el instrumento extranjero sea público. De hecho, la Corte de

Apelaciones de Concepción ha aceptado un mandato otorgado en el extranjero por un instrumento público distinto a la escritura pública que exige la ley chilena.

En resumen, si la ley chilena exige que en Chile un acto se pruebe por instrumento público, y ese acto se realizó en el extranjero, sólo podrá probarse en Chile por medio de un instrumento público extranjero. Si en un país extranjero existe un tipo de instrumento público que no existe en Chile, este instrumento se reconoce como público también en Chile y tiene valor probatorio como tal. Finalmente, el Art. 1701 CC señala que a falta de instrumento público el acto se mira en Chile como no ejecutado o celebrado y, por ello no produce efecto jurídico alguno.

Luego, hay que referirse al análisis del Art. 420 N°5 COT, en cuanto a los efectos en Chile de la protocolización y apostilla del instrumento extranjero. La norma del Art. 420 N°5 COT dispone que una vez protocolizados, valdrán como instrumentos públicos: (5) Los instrumentos otorgados en el extranjero, las transcripciones y las traducciones efectuadas por el intérprete oficial o los peritos nombrados al efecto por el juez competente y debidamente legalizadas, que sirvan para otorgar escrituras en Chile. Así, protocolizar es incorporar un documento a un registro público, concretamente al repertorio y libro de un Notario. La protocolización de un instrumento público extranjero hace que éste adquiera el mismo valor que un instrumento público otorgado en Chile (Art. 420 COT y Art. 1700 CCC: plena fe en cuanto al hecho de haber sido otorgado y su fecha y plena fe respecto de las partes en cuanto a su contenido, Art. 1706 CC).

- 1. ¿Cuándo existe la obligación de hacer la protocolización del Art. 420 N°5 COT?** Cada vez que se va a usar un instrumento público extranjero para otorgar una escritura pública en Chile, ese instrumento debe protocolizarse en una notaría chilena. Ésta es una medida de publicidad. Si el instrumento público extranjero se va a usar para otros efectos no necesita ser protocolizado. Por ejemplo, si se quiere probar en un juicio que una persona es casada no es necesario protocolizar la partida de matrimonio, basta adjuntarla debidamente legalizada o apostillada y, si es necesario, traducida.
- 2. ¿Qué valor probatorio tiene un instrumento privado extranjero, protocolizado en Chile?** Si se protocoliza en Chile un instrumento privado extranjero ese instrumento no adquiere el valor de un instrumento público en Chile (esto, aunque en una primera lectura del Art. 420 COT pudiera entenderse así). Un instrumento privado otorgado en el extranjero sigue siendo siempre privado, porque la ley que le da la calificación de instrumento privado es la ley del lugar de otorgamiento. Los instrumentos públicos emanan siempre de funcionarios públicos realizando una función pública. Los instrumentos privados, emanan de personas privadas y por el hecho de ser protocolizados, no pueden convertirse en públicos ya que no han sido otorgados por ningún funcionario público dentro del ejercicio de sus funciones. La protocolización de un instrumento privado extranjero en Chile, produce el mismo efecto que produce la protocolización de un instrumento privado otorgado en Chile. Es decir, el instrumento adquiere fecha cierta en conformidad al Art. 1703 CC. Esta última norma dispone que la fecha de un instrumento privado no se cuenta respecto de terceros sino desde el fallecimiento de alguno de los que le han firmado, o desde el día en que ha sido copiado en un registro público, o en que conste haberse presentado en juicio, o en que haya tomado razón de él o le haya inventariado un funcionario competente, en el carácter de tal.

Ahora bien, hay que analizar el Art. 420 N°5 COT, párrafo 2. El Art. 420 N°5 COT fue modificado el año 2016 con la Ley 20.711 que implementó “El Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros”, vigente en Chile desde agosto del año 2016. Esta convención se llama “Convención de la Apostilla”. Esta ley agregó al Art. 420 N°5 un segundo párrafo que dice: “sin perjuicio de lo anterior, los documentos públicos que hayan sido indicados mediante el sistema de apostilla según lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de procedimiento Civil, no requerirán de protocolización para tener el valor de instrumento público. La apostilla no requerirá certificación de ninguna clase para ser considerada auténtica”. Esta norma exime de la obligación de protocolizar en Chile un instrumento público extranjero que haya sido apostillado en el país de origen, para adquirir el valor de instrumento público en Chile. Esto, porque el instrumento ya se incorporó a un Registro Público de Apostilla en su país de origen y ha adquirido fecha cierta desde la fecha de la Apostilla.

En cuanto a la prueba de la autenticidad de un instrumento público otorgado en el extranjero, para que pueda hacerse valer un instrumento público otorgado en el extranjero el Art. 17 CC exige probar su autenticidad en la forma prescrita por el CPC. La autenticidad se refiere al hecho de haber sido realmente otorgado y autorizado por las personas (funcionarios públicos) y de la manera que en tales instrumentos se exprese. En Chile existen dos sistemas para probar esta autenticidad: (i) la legalización; y (ii) la apostilla.

Por una parte, la legalización es un sistema que consiste en una cadena de certificación de firmas, que acredita que los distintos funcionarios que intervienen en la emisión de un documento tienen la potestad legal de otorgarlos. Esta legalización es necesaria cuando los documentos emitidos en un país necesitan ser utilizados en otro país. La legalización permite que estos documentos puedan ser reconocidos como auténticos y válidamente otorgados por un funcionario competente de ese país extranjero. El Art. 345 CPC ordena: los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas. / La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios se comprobará en Chile por alguno de los medios siguientes:

1. El atestado de un agente diplomático o consular chileno, acreditado en el país de donde el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
2. El atestado de un agente diplomático o consular de una nación amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionario chileno, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del país a que pertenezca el agente o del Ministro Diplomático de dicho país en Chile, y además por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos.
3. El atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en donde se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República.

Por otra parte, la apostilla pretende simplificar el reconocimiento de los instrumentos otorgados en el extranjero y reemplazar el trámite de legalización. Fue creada por la Convención de la Haya de 1961 y se utiliza entre los países partes de esta Convención. Estos países se comprometen a tener un registro público de instrumentos apostillados. La apostilla es un timbre que certifica que el documento público extranjero ha sido registrado en el Registro de Apostilla del país de origen, que en ese país se guarda una copia de ese instrumento, y que a éste se le ha asignado un número de registro específico. El Art. 345 bis del CPC dispone:

1. Los instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, no deberán ser sometidos al procedimiento de legalización, si respecto de éstos se ha otorgado apostillas por la autoridad designada por el Estado de que dimana dicho instrumento.
2. Las certificaciones oficiales que hayan sido asentadas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones para la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas, podrán presentarse legalizadas o con apostillas otorgadas, con arreglo al artículo precedente y a éste, respectivamente. Pero en estos casos la legalización o apostilla sólo acreditará la autenticidad de la certificación, sin otorgar al instrumento el carácter de público.
3. Según lo dispuesto por la Convención a que se refiere el inciso primero, no podrán otorgarse apostillas respecto de los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y los documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil o aduanera”.

La Apostilla se implementó en Chile mediante la Ley 20.711, del 20-12-2013, D. Of. 2-01-2014. Está regulada en el Decreto N°81 del año 2015 del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el Art. 2 se indica que para los efectos del presente Reglamento, la apostilla es un certificado, que emitido de conformidad con lo que se indica en lo sucesivo, produce respecto del documento público para el cual se otorga, los mismos efectos que el proceso de legalización. / Válidamente otorgada, la apostilla certificará respecto del documento público, en todos los Estados Parte en cuyo ordenamiento la Convención de la Apostilla se encuentre en vigor, la autenticidad de la firma en él contenida, la calidad en que ese signatario haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el instrumento esté revestido.

En la práctica, se presenta el documento al funcionario público del Registro de Apostilla del país de origen del documento y se le solicita apostillar el documento. El funcionario escanea el documento e incorpora esa copia al Registro de Apostilla asignándole un número de registro y estampándole un timbre especial. Este timbre y número permiten que el documento pueda ser llevado a cualquier país que sea suscriptor de la Convención de la Apostilla y que, eventualmente, se pueda solicitar su cotejo con la copia del instrumento que se mantiene en el Registro de Apostilla del país de origen.

La apostilla permite tener más certeza de que los documentos no han sido adulterados. Chile otorga una apostilla electrónica que puede solicitarse en diferentes reparticiones públicas de todo el país, dependiendo de la naturaleza del instrumento, por ejemplo, puede recurrirse al Ministerio o Seremi de Salud, de Educación, etc., para solicita una apostilla de un instrumento relacionado con esas reparticiones. El único Ministerio que tiene competencia total para apostillar cualquier tipo de documento es el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los instrumentos públicos deben apostillarse si se van a utilizar en el extranjero. También es posible apostillar un instrumento privado cuando en su otorgamiento haya intervenido un ministro de fe, por ejemplo, un título universitario o una licencia de Educación Media o un certificado médico. La apostilla le otorga a ese instrumento fecha cierta.

Finalmente, en cuanto a la forma de los instrumentos públicos otorgados ante agente diplomático extranjero en el extranjero, estos instrumentos quedan gobernados en cuanto a la forma por el Art. 17 CC, pero con la salvedad de que no se sujetan a las formalidades de la ley del Estado donde se emiten, sino a las formalidades exigidas por la ley del Estado al que representa ese agente diplomático.

E.3. Estatuto del Fondo de los Actos y Contratos Internacionales: el estatuto del fondo de los actos y contratos se refiere a las normas que determinan la ley que rige la validez esencial y los efectos -derechos y obligaciones- que nacen de los actos y contratos. La determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales es compleja debido a la diversidad de vínculos jurídicos que tienen los contratos internacionales, porque hay muchos tipos de contratos y porque hay contratos en que debe protegerse a la parte más débil.

E.3.1. Variedad de soluciones para determinar la ley que gobierna los contratos en el DIPRI. Esta complejidad ha dado lugar a variadas soluciones jurídicas a lo largo de la historia, que, en términos amplios, se mantienen hasta ahora y que pueden resumirse en: (i) la creación de un derecho material propio para los contratos internacionales; y (ii) la dictación de normas de conflicto específicas para determinar la ley que los gobierna.

E.3.1.A. Elaboración de un derecho material *ad hoc* para regir el fondo de los contratos internacionales. Los países suscriben tratados internacionales que regulan material y uniformemente ciertos contratos internacionales para garantizar que, en todas partes, queden gobernados por las mismas normas. Por ejemplo, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de Mercaderías o la de Varsovia sobre transporte aéreo de pasajeros, que establecen normas materiales uniformes para regular las obligaciones y derechos que surgen para las partes de estos contratos. En esta misma línea se ha avanzado en la confección de instrumentos de “*soft law*”, redactados como Principios o Guías, que promueven la adopción de normas materiales uniformes en ciertas áreas contractuales más complejas. Por ejemplo, los principios Unidroit sobre contratos comerciales internacionales o la Guía Unidroit sobre contratos agrícolas o el Protocolo sobre Garantías en Artefactos espaciales, entre otros.

E.3.1.B. La dictación de normas de conflicto para determinar la ley aplicable al fondo de los contratos internacionales. Esta solución presenta dificultades para las partes contratantes. La diversidad de las normas de conflicto adoptadas por los distintos países puede hacer que un mismo contrato pueda quedar gobernado por distintas leyes en distintos Estados, situación que genera incerteza jurídica para las partes. Además, provoca que la determinación definitiva de la ley reguladora del contrato sea hecha por el tribunal que resuelve los litigios relativos al contrato. Así, el funcionamiento práctico de las normas de conflicto puede tener resultados impredecibles y contrarios a las legítimas expectativas de las partes. El derecho comparado ha optado por privilegiar la intención

y la libertad de las partes contratantes, usando dos modalidades: (i) autorizando la autonomía de la voluntad, es decir, que permitiendo a las partes elegir la ley para gobernar su contrato; y (ii) dictando normas de conflicto que determinan la ley aplicable al contrato, en ausencia de la elección de las partes o cuando su elección ha sido declarada nula.

1. El reconocimiento de la autonomía de la voluntad en los contratos internacionales.

- a. El concepto de autonomía de la voluntad en el DIPRI.** La autonomía de la voluntad en el Derecho Internacional Privado se define como el derecho de las partes para elegir la ley que gobierna un contrato. Esto es, su facultad de determinar la ley que es *causa causans* del contrato; la ley que gobierna la existencia, validez sustancial y los efectos del contrato y que contiene aquellas normas de policía, que las partes no pueden desplazar convencionalmente; y finalmente, la ley que gobierna también la elección misma de ley estableciendo los requisitos para realizarla y regulando sus efectos.

Ahora bien, elegir ley aplicable es distinto a incorporar una ley extranjera a un contrato. Esta elección de ley para gobernar un contrato se distingue de la incorporación por referencia de una ley extranjera en un contrato. En *la autonomía*, *las partes someten el contrato a la ley elegida, y ella pasa a ser la ley que lo gobierna*. En la incorporación, las partes incorporan las normas de la ley extranjera como cláusulas del contrato, quedando la validez de estas cláusulas y el contrato mismo gobernados por la ley que gobierna al contrato, en general. Por ejemplo, es distinto decir en una cláusula: (i) las partes acuerdan que este contrato quede gobernado por la ley del Estado de Nueva York; (ii) las partes entienden incorporadas en este contrato las normas sobre indemnización de perjuicios por incumplimiento del Estado de Nueva York (aquí hay incorporación y no determinación de la ley aplicable).

La autonomía de la voluntad de las partes es distinta a la libertad contractual de derecho interno. Esta autonomía también se diferencia de la libertad contractual de derecho interno, la que permite a las partes desplazar algunas normas subsidiarias de la ley que gobierna el contrato o elaborar ciertas normas dispositivas que se aplicarán a él pero siempre, dentro de los límites y sujetas a los requisitos establecidos por la ley que gobierna al contrato. La autonomía de la voluntad, como principio del DIPRI se desarrolló principalmente a mediados del siglo 19 y 20; su aceptación es hoy tan universal que se la considera como perteneciente al “cuerpo común de los sistemas legales”.

Países: Brasil, Uruguay, Chile; **aceptación de autonomía de la voluntad. Prácticas aceptado en todos los países del mundo.**

- b. La justificación de la autonomía de la voluntad.** La autonomía de la voluntad se justifica con variadas razones:
- i.** Garantiza la libertad contractual de las partes. Principalmente se argumenta que las partes necesitan libertad para contratar en el ámbito internacional y que la autonomía reconoce y garantiza esta libertad.

- ii. Garantiza la aplicación de una ley adecuada al contrato. Se reconoce que las partes pueden usar la autonomía como una herramienta efectiva para excluir una ley inapropiada que, de otro modo, gobernaría el contrato; o excluir la ley nacional de una o ambas partes y elegir otra ley que consideran “neutra” o para elegir, de entre un vasto número de leyes, la que les parezca más conveniente para gobernar la totalidad o una parte específica de su contrato.
 - iii. Da certeza y predictibilidad acerca de la ley que gobierna el contrato. La autonomía se defiende también por aumentar la certeza y predictibilidad de la ley que gobierna a los contratos internacionales. Con esta elección las partes pueden fijar la ley reguladora del contrato de antemano, mientras éste se está negociando.
 - iv. Facilita el comercio internacional. Finalmente se argumenta que permite y facilita el comercio internacional y puede ser considerada como una base fundamental de una economía de mercado.
- c. **La autonomía de la voluntad y la elección de foro.** El derecho comparado considera las elecciones de ley y de foro como asuntos separados gobernados por distintas normas de conflicto, aunque ambas se contengan en una misma cláusula contractual. Sin embargo, las elecciones de ley y foro están estrechamente relacionadas entre sí puesto que la eficacia de una elección de ley depende fundamentalmente de la ley del foro en donde se entable la acción; de ahí que sea práctica frecuente que se incluyan ambas elecciones en los contratos internacionales.
- d. **Modelos de cláusulas de elección de ley o de derecho aplicable.**

Applicable law: <i>This contract shall be governed by the laws of...</i> Derecho Aplicable: Este contrato se regirá por las leyes de...
Applicable law: <i>This contract shall be governed by the laws of...excluding the conflict of law provisions of such country.</i> Derecho Aplicable: Este contrato se regirá por las leyes de...con exclusión de sus reglas de Derecho Internacional Privado.
Applicable law: <i>This contract and all claims, disputes, and lawsuits arising out of or relating in any way with this contract shall be governed by the laws of...excluding the conflict of law provisions of such country.</i> Derecho aplicable: Este contrato y todas las reclamaciones, controversias y litigios derivados de o relacionados de cualquier forma con este contrato se regirán por las leyes de...con exclusión de sus reglas de Derecho Internacional Privado.
Elección de varias leyes: Applicable law: <i>This contract shall be governed by the laws of..., except matters concerning Clause...(number) on...(issue) which shall be governed by the laws of...</i> Derecho aplicable: Este contrato se regirá por las leyes de...excepto en los aspectos relativos a la cláusula...(Nº) sobre...(materia) que se regirán por las leyes de...
Floating Clause: <i>The laws in the State in which the defending party maintains business shall govern the application and enforcement of this agreement, and all litigation pursuant to this agreement shall be conducted in the Country and the State of the defendant.</i>

Las leyes del Estado en el cual el defendido realice negocios gobernarán el cumplimiento y ejecución de este acuerdo, y todo litigio relativo a él se ventilará en el país y en el Estado del defendido.

Elección de ley incluyendo la responsabilidad extra-contractual:

- a) *Any and all matters in dispute between the parties to this agreement, whether arising from or relating to the agreement itself, or arising from alleged extra-contractual facts prior to, during, or subsequent to the agreement, including, without limitation, fraud, misrepresentation, negligence or any other alleged tort or violation of the contract, shall be governed by, construed, and enforced in accordance with the laws of..., regardless of the legal theory upon which such matter is asserted.*
- b) *This contract shall be governed and construed in accordance with the laws of..., excluding that State's choice of- law principles, and all claims relating to or arising out of this contract, or the breach thereof, whether sounding in contract, tort or otherwise, shall likewise be governed by the laws of..., excluding that State's choice-of-law principles.*

2. **Las normas de DIPRI chilenas relativas a contratos internacionales.** Las normas de conflicto chilenas relativas a contratos están inspiradas en dos principios de difícil reconciliación: el principio de territorialidad de la ley y el de libertad contractual. Las normas reguladoras de la ley aplicable a los contratos internacionales de mayor aplicación son: (i) el Art. 114 CCom para contratos comerciales; (ii) Art. 16 CC para contratos civiles; y (iii) el DL 2.349 para contratos celebrados por el Estado y empresas públicas.

a. **Autonomía de la voluntad en contratos mercantiles (Art. 113 CCom):** la norma establece que todos los actos concernientes a la ejecución de los contratos celebrados en país extranjero y cumplidos en Chile, son regidos por la ley chilena, en conformidad a lo que se prescribe en el inciso final del artículo 16 del Código Civil. El inciso segundo agrega que así la entrega y pago, la moneda en que éste deba hacerse, las medidas de toda especie, los recibos y su forma, las responsabilidades que imponen la falta de cumplimiento o el cumplimiento imperfecto o tardío, y cualquiera otro acto relativo a la mera ejecución del contrato, deberán arreglarse a las disposiciones de las leyes de la República, a menos que los contratantes hubieren acordado otra cosa. Entonces, el Art. 113 CCom autoriza a las partes para elegir una ley extranjera para regir los efectos de esos contratos en Chile. Es decir, el Art. 113 CCom literalmente se aplica y autoriza elegir ley aplicable a las partes de: (i) contratos comerciales celebrados en el extranjero; (ii) contratos extranjeros que deben cumplirse en Chile. La doctrina interpreta este artículo más ampliamente y considera que autoriza esta elección para cualquier contrato comercial internacional -celebrado en Chile o en el extranjero- y para cualquier efecto, ya sea producido en Chile o no. Sin embargo, la autorización legal de la autonomía para los contratos comerciales internacionales ha sido limitada por la tendencia judicial a aplicar a estos contratos la ley chilena por sobre aquella elegida por las partes.

b. **Autonomía de la voluntad en contratos civiles (Art. 16 CC y Art. 1545 CC):**

i. **Art. 16 inc. 2 y 3 CC:** esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extranjero. / Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas.

- ii. **Art. 1545 CC:** todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

No existe norma legal autorizando la autonomía para los contratos civiles internacionales. La doctrina considera que las cláusulas de elección de ley extranjera en estos contratos son válidas conforme al Art. 1545 CC que otorga amplia libertad contractual a las partes y, específicamente, conforme al Art. 16 CC que reconoce la validez de los contratos celebrados en el extranjero.

La aceptación de las cláusulas de elección de ley en el Art. 16 CC resulta, dudosa ya que su inciso final establece que *los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas* pareciendo rechazar cualquier otra ley elegida por las partes. La interpretación judicial de este Art. 16 ha sido inconsistente: algunos jueces la han interpretado como aceptando la autonomía en contratos para cumplirse en Chile y otros como ordenando imperativamente la aplicación de la ley chilena a estos contratos. Es decir, la ley y la jurisprudencia no dan certeza respecto a la aceptación de la autonomía en contratos civiles internacionales y evidencian el conflicto no resuelto entre territorialismo y libertad contractual en la legislación chilena.

- c. **Autonomía de la voluntad en contratos de financiamiento de empresas del Estado (Art. 1 DL 2.349 de 1978):** la norma dispone: (i) declárense válidos los pactos destinados a sujetar al derecho extranjero los contratos internacionales, cuyo objeto principal diga relación con negocios u operaciones de carácter económico o financiero, celebrados o que se celebren por organismos, instituciones o empresas internacionales o extranjeras que tengan el centro principal de sus negocios en el extranjero, con el Estado de Chile o sus organismos, instituciones o empresas; (ii) son igualmente válidas las estipulaciones por las cuales se haya sometido o se sometan diferendos derivados de tales contratos a la jurisdicción de tribunales extranjeros, incluyendo tribunales arbitrales previstos en mecanismos de arbitraje preestablecidos o en el respectivo contrato, como también las estipulaciones por las que se haya fijado o se fije domicilio especial y se haya designado o se designe mandatario en el extranjero para los efectos del contrato; (iii) lo dispuesto en los incisos anteriores igualmente es aplicable a los actos y contratos por los cuales el Estado de Chile o sus organismos, instituciones y empresas, hayan otorgado u otorguen, en cualquier forma, su garantía a terceros en los contratos a que se refiere el inciso primero; (iv) en virtud del sometimiento a la jurisdicción de un tribunal extranjero, cesará el derecho a invocar la inmunidad de jurisdicción, a menos de estipulación expresa en contrario. Entonces, el DL 2.349 acepta la elección de ley y foro extranjeros en: (i) contratos económicos o financieros celebrados por el Estado chileno o las empresas públicas; (ii) con empresas internacionales con asiento principal de sus negocios en el extranjero; o (iii) en aquellos celebrados por terceros con la garantía del Estado o una empresa pública chilena. Esta elección debe ser autorizada expresamente por el Presidente de la República para ser válida.

A modo de comentario final, es posible señalar que los abogados nacionales utilizan la autonomía con frecuencia en los contratos internacionales. Sin embargo, normalmente se precaven frente a un posible rechazo de la elección de ley extranjera, sometiendo los contratos que se refieren a bienes situados en Chile a la ley chilena para asegurar su ejecución judicial en el país. La aceptación de la autonomía de la voluntad ha sido discutida en los tribunales chilenos en pocas ocasiones y la jurisprudencia al respecto no es conteste.

3. Los problemas relativos al ejercicio la autonomía de la voluntad en los contratos internacionales: (i) los problemas específicos de la cláusula de elección de ley; (ii) el ámbito de aplicación de la ley elegida; y (iii) los límites al ejercicio de la autonomía de la voluntad.

a. Problemas específicos relativos a la cláusula de elección de ley:

- i. La posibilidad de una elección tácita de ley para el contrato:** las legislaciones, en su mayor parte, aceptan la elección tácita de ley hecha por las partes. Se exige, en general, que una elección tácita de ley se demuestre por medio de múltiples indicadores en el contrato y/o en la conducta de las partes. De este modo, estos indicadores deben permitir a los jueces deducir la existencia de una elección real de ley hecha por las partes y no de una presumida o hipotética. La ley chilena parece aceptar estas elecciones tácitas si se demuestran claramente. En efecto, ella no exige una elección de ley expresa en sus normas relativas a la autonomía (Art. 113 CCom, Art. 16 CC y DL 2.349) y además otorga valor a la expresión tácita de la voluntad de las partes en un contrato. (Art. 1560 CC y Art. 103 CCom); lo que permite deducir que las partes pueden elegir tácitamente la ley aplicable a un contrato.
- ii. Momento de la elección de ley y cambios subsecuentes de la misma:** se faculta a las partes para elegir ley aplicable en cualquier momento y cambiar esta elección si lo estiman conveniente, todo ello sujeto a algunos límites para proteger los derechos de terceros que pudieren verse afectados negativamente por estos cambios. La ley chilena autoriza que esta elección y sus cambios se hagan antes, durante o después de la celebración del contrato sin que afecte negativamente los derechos de terceros (Art. 12 CC y Art. 1683 CC).
- iii. Multiplicidad de elecciones de ley o división de la ley del contrato:** las partes pueden elegir múltiples leyes para gobernar distintas partes de un contrato o de que ellas dividan la ley que lo gobierna , pueden hacer elecciones parciales de ley. Corresponde a las partes determinar el ámbito en el que las diversas leyes deben ser aplicadas y reconciliadas. La ley chilena parece aceptar la división de ley para todo tipo de contratos puesto que sus normas no la prohíben.
- iv. Independencia de la cláusula de elección de ley del contrato:** actualmente, existe un creciente consenso en las legislaciones mundiales respecto a considerar que la cláusula de elección de ley incluida en un contrato tiene un carácter independiente del mismo. Esto cobra relevancia cuando la existencia o nulidad de un contrato está en disputa. En efecto, si la cláusula se considera independiente del contrato, la disputa se resuelve por la ley

elegida por las partes. Si la cláusula, en cambio, se considera como parte del contrato, la disputa se resuelve por la ley putativa del contrato determinada por las normas de conflicto del foro.

- b. El ámbito de aplicación de la ley elegida:** el derecho comparado está de acuerdo en considerar que la ley elegida debe regir los aspectos principales del contrato, es decir: (i) su existencia y su validez sustancial, no en Chile (ley de lugar de celebración); (ii) sus efectos (derechos y deberes que surgen del contrato); (iii) su interpretación; (iv) los modos de cumplimiento de las obligaciones que genera; (v) las consecuencias de su incumplimiento; y (vi) la evaluación de los daños y los efectos de la nulidad del contrato mismo. También está de acuerdo en considerar que la validez formal del contrato debe estar regida por la ley elegida, teniendo en cuenta también otras leyes (no en Chile, ley de lugar de celebración). Se excluye la capacidad para contratar del ámbito de la ley elegida por las partes. La capacidad de las personas naturales se somete comúnmente a su ley personal. La capacidad de las sociedades o corporaciones se rige normalmente por la ley del lugar de su constitución o sede social.
- c. Los límites en el ejercicio de la autonomía:** estos límites pretenden garantizar una relación contractual justa entre las partes, evitar el fraude o la evasión de ley y proteger valores fundamentales del foro. La ley del foro determina la permisibilidad de la autonomía y las condiciones para ejercerla. Entre los límites más comunes impuestos a la autonomía están: (i) autorizarla sólo para contratos internacionales; (ii) exigir una conexión entre la ley elegida y el contrato; (iii) restringir la elección a una ley estatal; (iv) exigir que la elección no sea contraria al orden público del foro o hecha con fraude a esa ley; (v) exigir el respeto de las normas imperativas del foro; y (vi) asegurar la protección de la parte contratante más débil del contrato.
 - i. Carácter internacional del contrato:** en Chile, la autonomía de la voluntad está restringida a los contratos internacionales y la elección de ley extranjera está prohibida para contratos puramente nacionales. Los contratos puramente nacionales están regidos necesariamente por la ley chilena. Además, la aceptación en el Código de Comercio de elecciones de ley para los contratos comerciales celebrados en el extranjero para cumplirse en Chile refuerza la conclusión de que la autonomía sólo puede ejercitarse en contratos internacionales. Este requisito está expresamente establecido para los contratos públicos gobernados por el DL 2.349 y para los contratos de compraventa internacional de mercaderías gobernados por la Convención de Viena de 1980. En cuanto a la calificación de un contrato internacional, en Chile no existe una definición amplia de contrato es internacional. Una interpretación literal de las normas del Art. 16 CC y Art. 113 CCom permite caracterizar un contrato como internacional cuando ha sido celebrado en el extranjero para cumplirse en Chile; una interpretación extensiva y analógica de estas mismas normas amplía esta caracterización a contratos celebrados en un Estado para ser cumplidos en otro. Ambas caracterizaciones son demasiado restringidas porque no es inusual que un contrato internacional sea celebrado y cumplido en un mismo Estado. Otro criterio: el hecho de que

las partes tengan el asiento de sus negocios en países diferentes, se establece en el DL 2.349 y en la Convención de Viena 1980.

- ii. **Conexión del contrato con la ley elegida:** la elección de una ley sin conexión con el contrato se acepta en la mayoría de los sistemas legales a menos que esta elección esté prohibida por una norma imperativa o el orden público del foro. En Chile, se sigue esta tendencia: la doctrina y los abogados nacionales entienden que la legislación acepta elecciones de leyes sin conexión con el contrato.
- iii. **Elección de un sistema legal estatal o de la costumbre internacional:** algunos sistemas legales restringen la autonomía a la posibilidad de elegir la ley de un Estado y excluyen la posibilidad de elegir otras normas a-nacionales como la *lex mercatoria* o los usos o principios comerciales internacionales. Sin embargo, la utilización de usos y principios comerciales internacionales y de la *lex mercatoria* está siendo progresivamente aceptada en el comercio internacional y ha obtenido reconocimiento en algunos sistemas legales. En la legislación chilena, la autonomía está restringida a la elección de una ley estatal vigente. Esta restricción puede inferirse de las normas de DIPRI sobre contratos que se refieren a una ley estatal y de las normas que establecen que las costumbres y usos comerciales sólo se aplican para suplir la ley estatal cuando la ley expresamente lo autoriza o cuando existe un vacío legal (Art. 2 CC y Art. 4 al Art. 6 CCom).
- iv. **Elección no contraria al orden público o fraudulenta:** la autonomía está también sujeta al requisito de que la elección de las partes no puede ser contraria al orden público del foro ni hecha con la intención fraudulenta de evadir sus normas. Esta restricción busca proteger normas o principios legales básicos del foro y asegurar el cumplimiento de sus normas imperativas cuando han sido fraudulentamente evadidas. En cualquier caso, los jueces deben aplicar las restricciones del orden público y del fraude a la a ley excepcionalmente ya que un celo excesivo en el uso de estas restricciones puede comprometer la libertad contractual y la autonomía de la voluntad en sí. Además, podría promover el *forum shopping* y poner en peligro la certeza y predictibilidad de las decisiones judiciales. En Chile, la protección del orden público chileno se ha deducido de las normas que declaran inexistente o nulo los contratos que contienen un objeto o causa contraria al orden público interno chileno o a la moralidad (Art. 1461 CC y Art. 1467 CC). Del mismo modo, la ley chilena no tiene norma que sancione el fraude a la ley, pero la doctrina y jurisprudencia están de acuerdo en que nadie puede tomar ventaja de su propio fraude para evadir el cumplimiento de la ley chilena.
- v. **Respeto de las normas de policía o imperativas del foro, de la *lex causae* o de un tercer Estado:** estas normas de policía son normas imperativas en el ámbito internacional que no pueden ser dejadas sin efecto ni reemplazadas por las normas de otro sistema legal. Ellas excluyen la ley elegida por las partes y proveen una solución sustancial para el problema que tratan.

Estas normas tienden a proteger grupos particulares de personas (por ejemplo, consumidores y empleados) o el sistema económico nacional (por ejemplo, normas antimonopolio, prohibiciones de importación o exportación, control de precios, restricciones al tipo de cambio) o valores morales (por ejemplo, matrimonio monógamo y heterosexual, la no discriminación por sexo, raza, condición social, etc.) o el interés público (por ejemplo, restricciones al dominio) y pueden ser especialmente relevantes en algunos tipos de contratos. Su efecto es desplazar la ley elegida parcialmente ya que ella sigue siendo aplicable respecto de las materias no regladas por estas normas.

Las normas imperativas del foro se aplican siempre a un contrato y dejan sin efecto las normas de la ley elegida que se les oponen. Lo mismo sucede con las normas imperativas de la ley elegida, que se aplican siempre, salvo que se opongan a las normas imperativas o al orden público del foro o hayan sido derogadas por las partes. Por el contrario, las normas imperativas de la ley de un tercer Estado conectado al contrato pueden eventualmente aplicarse, a discreción de los jueces, cuando la ley del foro o la ley elegida autoricen su aplicación. En todo caso, hay consenso de que las normas imperativas deben ser interpretadas restrictivamente y ser aplicadas excepcionalmente para no poner en peligro la certeza y predictibilidad jurídicas.

Además, existen normas chilenas imperativas especiales para ciertos contratos:

1. Los contratos nacionales deben ser gobernados por la ley chilena.
2. Los efectos de los contratos internacionales que se cumplen en Chile referentes a bienes inmuebles o muebles ubicados dentro del territorio deben también ser gobernados por la ley chilena (Art 16 CC), lo mismo sucede con los contratos de transporte marítimo si el puerto de destino está ubicado en Chile (Art. 979 y Art. 980 CCom).
3. Los contratos de trabajo individual y con consumidores celebrados o cumplidos en Chile están regidos imperativamente por las leyes chilenas de tal modo que las partes no pueden elegir gobernarlos por otras leyes que contengan normas menos favorables para el trabajador o consumidor (Ley 19.946 de 1997; Art. 1 y Art. 5 DFL N°1 del 2002).

E.3.2. Legislación chilena: ley aplicable al contrato cuando no hay elección de ley.

1. **Si hay un tratado internacional que regule el contrato: éste se aplicará.** Chile no tiene tratados que contengan normas de conflicto para determinar la ley que gobierna el contrato (excepción el CCB que tiene normas complejas que no se aplican habitualmente en Chile). Sí hay tratados que tienen normas sustantivas que rigen los efectos de los contratos – derechos y obligaciones que generan- y otros aspectos, como su formación: Convención de Viena sobre

Compraventa Internacional de Mercadería y la Convención de Varsovia sobre transporte aéreo de pasajeros. Estas convenciones se aplican pero no tienen normas para determinar la ley reguladora general del contrato.

2. **Si no hay tratado que establezca la ley aplicable al contrato, hay que distinguir.** La mayoría de la doctrina chilena sostiene que la ley chilena exige distinguir entre: (i) la ley aplicable a la validez esencial de un contrato internacional; y (ii) la ley aplicable a sus efectos.

a. **Validez esencial, sustancial o de fondo de un contrato:** (i) si el contrato se celebra en Chile. El contrato quedará gobernado por la ley chilena en base a la norma general del Art. 14 CC; o (ii) si el contrato se celebra en el extranjero, no hay norma específica en nuestra legislación. Es necesario llenar este vacío legal. Para ello, se ha propuesto bilateralizar el Art. 14 CC, entendiendo que éste dispone que la validez esencial de los contratos celebrados en Chile queda gobernada por la ley chilena, es decir, que usa como factor de conexión la ley del lugar de celebración. Entonces si se bilateraliza esta norma, podemos concluir que el contrato celebrado en el extranjero va a quedar gobernado por la ley del lugar de su celebración. Además, el Art. 16 inc. 2 CC dispone que esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño y puede interpretarse (no literalmente, pero extensivamente) como indicando que los contratos celebrados en el extranjero son válidos si se sujetan a la ley del lugar de celebración. Esta solución ha sido adoptada por la jurisprudencia. Existe una excepción: la capacidad para contratar que se rige por la ley que gobierna el estatuto personal de la persona natural o jurídica.

- b. **Efectos del contrato: derechos y obligaciones que emanan de él.** Nuestra legislación distingue, si estos efectos se producen en Chile o no.

i. **Efectos de los contratos internacionales que se producen en Chile:** conforme al Art. 16 inc. 3 CC, los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas. Es decir, esta norma somete expresamente los efectos de un contrato internacional que se van a producir en Chile a las leyes chilenas. Esta misma idea la repite el Art. 113 CCom: todos los actos concernientes a la ejecución de los contratos celebrados en país extranjero y cumplidos en Chile, son regidos por la ley chilena, en conformidad a lo que se prescribe en el inciso final del artículo 16 del Código Civil; así la entrega y pago, la moneda en que éste deba hacerse, las medidas de toda especie, los recibos y su forma, las responsabilidades que imponen la falta de cumplimiento o el cumplimiento imperfecto o tardío, y cualquiera otro acto relativo a la mera ejecución del contrato, deberán arreglarse a las disposiciones de las leyes de la República, a menos que los contratantes hubieren acordado otra cosa. La jurisprudencia ha adoptado siempre esta solución, por ejemplo, ha estimado que un contrato de mandato, celebrado en Argentina, surte en Chile, los mismos efectos que le otorga la ley chilena a un mandato otorgado en Chile.

ii. **Efectos de los contratos internacionales que se producen en el extranjero:** se trata de una situación de vacío legal, pues nuestra legislación carece de una norma que regule los efectos de los contratos internacionales

producidos en el extranjero. La doctrina ha propuesto bilateralizar el Art. 16 CC y el Art. 113 CCom, entendiendo que ellos aplican el factor de conexión de la ley del lugar de cumplimiento o de ejecución del contrato, en cuyo caso, debiera aplicarse esta ley para regir los efectos del contrato que se producen en el extranjero. La conclusión es que nuestra legislación opta por la ley del lugar de cumplimiento. Esta solución produce un desmembramiento de la ley aplicable, si el contrato produce efectos en dos o más países.

E.3.3. Ejercicios Prácticos:

(1.) La empresa INCHALAM Chile contrata a la empresa belga WIREINT para que le otorgue una asesoría técnica en la implementación de un nuevo sistema de producción de alambre en su planta de Talcahuano. El contrato se celebra en Bruselas y se acuerda que el pago de la asesoría se hará a la cuenta corriente de WIREINT en el banco Credit Suisse, de Ginebra. Las partes estipulan que el contrato se regirá por la ley francesa. La empresa belga demanda en Chile a INCHALAM y se discute: (i) la capacidad del representante de INCHALAM para contratar; (ii) las formalidades a que debió sujetarse ese contrato; (iii) el hecho de haber incurrido INCHALAM en un error esencial al contratar; (iv) el alcance de la obligación de WIREINT de mantener técnicos en la planta de INCHALAM durante toda la vigencia del contrato. Al respecto señale las leyes que gobiernan estos aspectos y su fundamento legal.

(2.) La constructora chilena DALSA celebra un contrato en Uruguay para la construcción de una planta manufacturera de zapatos, en las afueras de Montevideo. DALSA se compromete a entregar la obra en un año a cambio del pago de 13.000.000 de dólares americanos a efectuarse en Uruguay. Ante un retraso considerable en la entrega de la obra, la Compañía uruguaya demanda a DALSA en Chile argumentando incumplimiento de contrato y exigiendo indemnización por la mora. Señale la ley que el juez chileno aplicará para determinar la existencia de ese incumplimiento contractual y de la eventual indemnización.

(3.) Codelco Chile, celebra un contrato de crédito por 200.000 millones de dólares con la agencia chilena del Royal Bank of Scotland. El contrato se celebra en Santiago; las partes acuerdan someterlo a las leyes inglesas y que las divergencias que surjan respecto de él o su cumplimiento, se sometan a los tribunales ordinarios chilenos. El Banco deposita el dinero en una cuenta corriente de Codelco en Inglaterra y las partes pactan que el pago debe hacerse también en Londres.

1. En el caso de una divergencia entre las partes respecto del mecanismo de cálculo de los intereses del crédito, señale qué ley deberá aplicar el juez chileno para resolverla.
2. ¿Qué ley regulará las formalidades de este contrato?

E.4. El Estatuto de los Hechos Jurídicos y la Responsabilidad Extracontractual: este estatuto se define como el conjunto de normas que rigen a las obligaciones que nacen de los hechos jurídicos y la responsabilidad extracontractual que ellos generan. Los hechos jurídicos son hechos no convencionales generadores de obligaciones. Estas obligaciones generan responsabilidad extracontractual para las partes. Dentro de los hechos jurídicos generadores de responsabilidad extracontractual, se encuentran: los delitos civiles, los cuasi delitos civiles y los cuasi contratos. En lo que respecta a la legislación de DIPRI chilena reguladora de los hechos jurídicos internacionales,

para determinar la ley que gobierna un hecho jurídico internacional hay que distinguir si se produjo en Chile o no.

1. **Si el hecho jurídico se produce en Chile**, queda regulado por la legislación chilena en base a la norma general del Art. 14 CC.
2. **Si el hecho jurídico se produce fuera de Chile**, y se inicia un litigio en Chile para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual que genera (o el hecho jurídico se produce en Chile pero se reclama en el extranjero), es necesario determinar la ley aplicable.

La legislación chilena no tiene normas de conflicto nacionales para determinar la ley que rige los delitos, cuasidelitos y cuasicontratos, cuando éstos sean producidos fuera de Chile. Para resolver este vacío legal, el juez puede recurrir al Código de Bustamante y aplicarlo como norma vigente respecto de países ratificantes y como fuente de principios de Derecho Internacional Privado, respecto de países no ratificantes. El Código de Bustamante tiene las siguientes normas:

1. **Cuasidelitos civiles (Art. 168 CB):** las obligaciones que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, se regirán por el derecho del lugar en que se hubiere incurrido en la negligencia o la culpa que las origine. Entonces, los cuasidelitos civiles se rigen por el derecho del lugar en que se hubiera incurrido en la culpa o negligencia que los origine., es decir del lugar donde se realizó la actuación dañosa.
2. **Delito civil (Art. 167 CB):** las originadas por delitos o faltas se sujetan al mismo derecho que el delito o falta de que procedan. Es decir, se sujetan a la ley que tipifica el delito civil.
3. **Las obligaciones cuasicontractuales:** el cuasi contrato es un hecho no convencional que genera obligaciones. Los tipos de cuasicontratos en la legislación chilena son: (i) comunidad; (ii) gestión de negocios ajenos o agencia oficiosa; y (iii) pago de lo no debido.
 - a. **Gestión de negocios ajenos:** el Art. 220 CB dice que la gestión de negocios ajenos se regula por la ley del lugar donde se efectúa.
 - b. **Pago de lo no debido:** en el caso del pago de lo no debido, el Art. 221 CB establece que el cobro de lo indebido se somete a la ley personal común de las partes y, en su defecto, a la del lugar donde se hizo el pago. Entonces, si tienen la misma nacionalidad o domicilio se aplica la ley de su nacionalidad o domicilio y, en su defecto, la que corresponde al lugar donde se hizo el pago.
 - c. **Demás cuasicontratos:** el Art. 222 CB señala que los demás cuasi-contratos se sujetan a la ley que regule la institución jurídica que los origine.

Finalmente, hay ciertos ejercicios prácticos sobre hechos jurídicos.

(1.) Irineu Grandino, médico traumatólogo brasilero, opera a Juan Calvo de las caderas en una clínica de Sao Paulo e incurre en una negligencia médica que lleva a Juan a quedar imposibilitado de caminar. Grandino se traslada a vivir al Perú con posterioridad. Señale indicando el fundamento legal ¿qué ley regirá la negligencia y sus efectos?

1. **Hechos jurídicos relevantes:** médico brasilero, negligencia médica en Brasil, médico se traslada a Perú.
2. **Solución:** se deberá demandar ante tribunales peruanos por tener domicilio allí el autor del cuasidelito, debiendo tales tribunales aplicar la ley brasilera debido a que es en Brasil donde se realizó la acción negligente.

(2.) Francisco Seguel chileno paga, por error, los gastos de hotel de su amigo Jaime Silva durante un viaje a Perú. Con posterioridad, y de vuelta en Santiago, Seguel descubre su error y decide exigir al Hotel peruano la devolución de lo pagado, pero su gerente se niega a devolvérselo por lo que Seguel debe iniciar un procedimiento de cobro en Perú. ¿Qué ley aplicará el tribunal peruano para resolver este asunto?

1. **Hechos jurídicos relevantes:** pago de lo no debido en Perú, pagador chileno, en Chile se toma conocimiento del error, exigencia de la devolución de lo pagado, rechazo de la devolución, procedimiento de cobro en Perú.
2. **Solución:** Art. 221 CC. Debido a que las partes no tienen el mismo domicilio se deberá aplicar la ley del lugar donde se hizo el pago: ley peruana.

(3.) Juan Méndez, chileno domiciliado en Valparaíso, retira de un sastre en San José de Costa Rica, un traje a la medida de un conocido suyo, Carlos Sánchez, aprovechando que está ahí, sin que Carlos Sánchez se lo pida. Al llegar a Valparaíso, quiere cobrar a Sánchez 500 dólares por este trámite. Señale qué ley determinará si Sánchez debe hacer ese pago.

1. **Hechos jurídicos relevantes:** agencia oficiosa de chileno en Costa Rica, cobro de pago por el trámite en Chile.
2. **Solución:** Art. 220 CB. Debido a que la gestión objeto de la agencia oficiosa se realiza en Costa Rica, se aplicará la ley de Costa Rica por ser ella la ley del lugar donde se efectúa la agencia oficiosa.

III. Normas para la Resolución de Conflictos de Jurisdicción.

A. La Jurisdicción y Competencia Internacional de los Tribunales Chilenos. El conflicto de jurisdicción se produce cuando dos o más tribunales de Estados distintos se irrogan competencia, o pueden ser competentes, para resolver un asunto litigioso. En este caso, las normas de Derecho Internacional Privado deben determinar cuál de los posibles foros será el competente para conocer del litigio. Estas normas de conflicto reguladoras de la competencia internacional indican al juez los criterios para resolver y determinar si su jurisdicción es competente para conocer de un asunto o si éste debe ser resuelto por otra jurisdicción de un Estado distinto.

En Chile no existen normas generales que establezcan la competencia internacional de los tribunales Chilenos. Las normas del Código Orgánico de los Tribunales sólo establecen reglas para determinar la competencia nacional de los tribunales chilenos y, en general, no determinan su competencia en asuntos internacionales. Aunque el Art. 5 COT dispone que “a los tribunales corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promueven dentro del territorio de la República, esta norma dispone que los jueces chilenos están obligados a fallar todas las causas que se sometan a su conocimiento. Sin embargo, no le atribuye a los jueces chilenos competencia jurisdiccional para resolver todo tipo de conflicto litigioso, por ejemplo, los que no tienen ninguna conexión jurídica con Chile. De hecho, los tribunales chilenos podrían declararse incompetentes para resolver los conflictos jurídicos no relacionados con Chile en ningún aspecto.

El vacío legal existente acerca de la competencia internacional de los tribunales chilenos ha debido ser resuelto por vía jurisprudencial. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido los criterios para resolver los conflictos de jurisdicción internacional en un fallo emblemático “*Holzman con*

Gainsborg” (CS. 21-XI-1950, RDJ, t. XLVIII, sec. 1, p. 513), diciendo que “para resolver cualquier conflicto de competencia internacional, es preciso averiguar: en primer término, si existen o no tratados con el país a que pertenece o estuviere domiciliado el litigante; en seguida, qué preceptúa la legislación interna, y si ésta nada dispone deberá acudir a los principios generales del Derecho Internacional, en armonía naturalmente, con el criterio de la legislación nacional”.

Este fallo estableció los siguientes criterios para resolver conflictos de jurisdicción internacional en Chile: (i) estudiar la existencia de tratados con el país al que pertenece o estuviera domiciliado el litigante, en dicho caso, habrá que regirse por lo que dicen los tratados; (ii) a falta de tratados, deben aplicarse las normas de la legislación interna que dispongan acerca de competencia internacional; y (iii) si no existen normas dentro de la legislación interna que resuelvan el conflicto de jurisdicción, se deben aplicar los principios generales de derecho internacional que estén en consonancia con las normas de la legislación nacional. A continuación, se analizan esos criterios.

B. Primer Criterio de la Corte Suprema: existencia de tratados. Los tratados suscritos por Chile relativos a esta materia son el Código de Bustamante y algunos Tratados de Libre Comercio. Estos TLC tienen normas de alcance muy restringido, que establecen que ante conflictos relativos a la ejecución o cumplimiento del TLC se debe recurrir a los tribunales especiales señalados en el mismo TLC, como, por ejemplo, el CIADI.

El Código de Bustamante tiene normas específicas de competencia internacional en el Art. 318 al Art. 332, las que son aplicables para resolver conflictos de jurisdicción entre Estados parte y también, como veremos, pueden usarse como fuentes de principios generales de Derecho Internacional cuando están en consonancia con la legislación nacional.

C. Segundo Criterio de la Corte Suprema: a falta de tratado se aplican supletoriamente las normas de la legislación interna chilena. La legislación interna chilena tiene pocas normas que resuelven conflictos de jurisdicción y lo hacen en casos específicos. Esto sucede en las siguientes normas: (i) Art. 148 COT sobre juicios sucesorios; (ii) Art. 87 LMC sobre acción de separación, nulidad y divorcio; (iii) Art. 81 N°1 CC sobre declaración de muerte presunta; (iv) Art. 16 inc. 1 CC respecto a las acciones y derechos reales sobrevienes situados en Chile; (v) Art. 47 CM sobre concesiones mineras; (vi) Art. 28 DFL 259 sobre contratos de seguros; y (vii) DL 2349 de 1978 sobre contratos de financiamiento del Estado, sus organismos y las Empresas del Estado o con Aval del Estado.

1. **Art. 148 COT: juicios sucesorios.** La norma dispone en su inciso primero que será juez competente para conocer del juicio de petición de herencia, del de desheredamiento y del de validez o nulidad de disposiciones testamentarias, el del lugar donde se hubiere abierto la sucesión del difunto con arreglo a lo dispuesto por el artículo 955 del Código Civil. El inciso segundo agrega que el mismo juez será también competente para conocer de todas las diligencias judiciales relativas a la apertura de la sucesión, formación de inventarios, tasación y partición de los bienes que el difunto hubiere dejad. Por tanto, el juez competente relativo a la sucesión es aquel del lugar donde se abrió la sucesión y la sucesión se abre en el de último domicilio del causante y se rige por la ley de ese último domicilio, salvo las excepciones legales. El Art. 149 COT agrega que cuando una sucesión se abra en el extranjero y

comprenda bienes situados dentro del territorio chileno, la posesión efectiva de la herencia deberá pedirse en el lugar en que tuvo el causante su último domicilio en Chile, o en el domicilio del que la pida si aquél no lo hubiere tenido.

2. **Art. 87 LMC: acción de separación, nulidad y divorcio.** Este artículo señala que será competente para conocer de las acciones de separación, nulidad o divorcio, el juzgado con competencia en materias de familia, del domicilio del demandado. En consecuencia, si el demandado está domiciliado fuera de Chile, no le compete a los tribunales chilenos fallar esa acción a menos que se dé la excepción del Art. 83 inc. final LMC: que los cónyuges hayan tenido domicilio durante cualquiera de los 3 años anteriores a la acción si su convivencia ha cesado al menos ese tiempo y ambos están de acuerdo en este plazo o 5 años si hay desacuerdo acerca del plazo de cese de la convivencia.
3. **Art. 81 N°1 CC: declaración de muerte presunta.** Esta norma señala que la presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile, justificándose previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia, han transcurrido a lo menos cinco años. Esta disposición se refiere a la muerte presunta y establece que el juez competente para declararla es el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. Por tanto, si el desaparecido no tuvo su último domicilio en Chile, no le corresponde al juez chileno decretar su muerte presunta. Por excepción, un juez chileno podría decretar la muerte presunta de un chileno que haya tenido último domicilio en el extranjero, por el hecho de ser chileno, en conformidad a una interpretación amplia del Art. 15 N°1 CC, ya vista en clase.
4. **Artículo 16 inc. 1 CC: acciones y derechos reales sobre bienes situados en Chile.** La norma señala que los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño. Los tribunales chilenos han entendido que este artículo no sólo determina la ley aplicable a los bienes situados en Chile, sino que tiene un alcance jurisdiccional, por tanto, siempre que se discuta acerca de derechos reales que se ejerzan o se vayan a ejercer sobre bienes ubicados en Chile, el tribunal competente es el chileno. A *contrario sensu*, el tribunal chileno no es competente para decidir sobre estos derechos en el caso de que el bien esté situado fuera de Chile.
5. **Art. 37 CM: concesiones mineras.** Señala la disposición que será competente para intervenir en la gestión de constitución de las concesiones el juez de letras en lo civil que tenga jurisdicción sobre el lugar en que esté ubicado el punto medio señalado en el pedimento, o el punto de interés indicado en la manifestación. Las concesiones se constituyen y litigan ante el juez del lugar donde está ubicado el terreno sobre el que se solicita o ejerce la concesión minera.
6. **Art. 28 DFL 251: contratos de seguros.** La norma establece que las cuestiones litigiosas que se susciten con motivo de los contratos de seguros directos y reaseguros sujetos a esta Ley, serán sometidas a la jurisdicción chilena, siendo nulo todo pacto en contrario. Es decir, los litigios que se refieran a los contratos de seguro celebrados en Chile deben ser resueltos por los tribunales chilenos cuando el objeto asegurado está en Chile.

7. **DL 2349 de 1978: contratos de financiamiento del Estado, sus organismos y las Empresas del Estado o con Aval del Estado.** Esta norma señala, en su primer inciso, que declárense válidos los pactos destinados a sujetar al derecho extranjero los contratos internacionales, cuyo objeto principal diga relación con negocios u operaciones de carácter económico o financiero, celebrados o que se celebren por organismos, instituciones o empresas internacionales o extranjeras que tengan el centro principal de sus negocios en el extranjero, con el Estado de Chile o sus organismos, instituciones o empresas.

El inciso segundo agrega que son igualmente válidas las estipulaciones por las cuales se haya sometido o se sometan diferendos derivados de tales contratos a la jurisdicción de tribunales extranjeros, incluyendo tribunales arbitrales previstos en mecanismos de arbitraje preestablecidos o en el respectivo contrato, como también las estipulaciones por las que se haya fijado o se fije domicilio especial y se haya designado o se designe mandatario en el extranjero para los efectos del contrato.

El inciso tercero agrega que lo dispuesto en los incisos anteriores igualmente es aplicable a los actos y contratos por los cuales el Estado de Chile o sus organismos, instituciones y empresas, hayan otorgado u otorguen, en cualquier forma, su garantía a terceros en los contratos a que se refiere el inciso primero.

Finalmente, el inciso cuarto dispone que en virtud del sometimiento a la jurisdicción de un tribunal extranjero, cesará el derecho a invocar la inmunidad de jurisdicción, a menos de estipulación expresa en contrario.

Esta norma reconoce la validez de los pactos o cláusulas de elección de foro extranjero para los contratos de financiamiento del Estado, de sus organismos, de las empresas del Estado y demás contratos a los que se refiere. Por tanto, si en un contrato regido por este DL 2.349 se elige, por ejemplo, foro París, esa cláusula es válida en Chile y los tribunales chilenos carecerían de competencia para juzgar acerca de los litigios que surjan relativos a ese contrato.

C. Tercer Criterio de la Corte Suprema: se aplican los principios generales del derecho internacional, en consonancia con la legislación nacional. El Código de Bustamante (CB) ha sido considerado por la CS como verdadera fuente de principios de derecho internacional, aplicables para países no partes del CB. En su Art. 318 y siguientes establece dos principios esenciales para determinar la competencia civil y mercantil internacional: (i) la sumisión hecha por las partes a un determinado Tribunal; y (ii) en ausencia de sumisión, la determinación del tribunal dependiendo de la naturaleza de la acción deducida. Como se dijo, las normas del CB se aplicarán siempre a países partes como Tratado vigente y pueden también aplicarse como principios de derecho internacional respecto de países no contratantes, cuando sea necesario para determinar la jurisdicción competente.

Estas normas no son aplicables a la competencia penal que es estrictamente territorial. Es decir, el juez penal competente es siempre el juez del lugar donde se comete el delito. El único caso de competencia penal extraterritorial de los tribunales chilenos es el del artículo 6 del COT que se refiere

a los delitos cometidos por agentes diplomáticos chilenos en el extranjero, a la falsificación de la moneda nacional realizada en el extranjero y a los delitos cometidos por un chileno contra un chileno en el extranjero, si el acusado regresa a Chile. Excepcionalmente, hay competencia penal internacional establecida por tratados internacionales para los delitos de lesa humanidad.

1. **Principio de sumisión o prórroga de jurisdicción:** el Art. 318 CB dispone que será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el derecho local contrario. El inciso segundo agrega que la sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles, si la prohíbe la ley de situación.

Este criterio establece que, en primer término, será competente para conocer de un litigio civil o mercantil el tribunal elegido por las partes ya sea ordinario o arbitral. Por tanto, se validan las cláusulas de elección de foro en esta materia. Si las partes han elegido un foro para resolver estos litigios, debe demandarse ante ese foro ya que ese es el tribunal con competencia para resolverlo. El CB exige además de la sumisión, que haya un vínculo entre el tribunal elegido y la acción deducida, consistente en que al menos una de las partes sea nacional del juez al que se han sometido o tenga domicilio en el territorio jurisdiccional de ese juez.

Especifica también que la sumisión puede ser expresa o tácita:

- a. **Expresa:** el Art. 321 CB dispone que se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y designando con toda precisión el juez a quien se sometan. Es decir, es la sumisión que se ha expresado a través de una cláusula de elección de foro o de otra forma inequívoca.
 - b. **Tácita:** el Art. 322 CB dispone que entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante con el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda, y por el demandado con el hecho de practicar, después de personado en el juicio, cualquier gestión que no sea proponer en forma la declinatoria. No se entenderá que hay sumisión tácita si el procedimiento se siguiera en rebeldía. Es decir, se realiza cuando una parte demanda a otra ante un tribunal y la otra contesta la demanda sin alegar la incompetencia de ese tribunal.
2. **Establecer la competencia de acuerdo con la naturaleza de la acción:** en el caso de que no haya habido sumisión expresa o tácita a un tribunal, el CB contiene otras normas que determinan la competencia internacional en base a la naturaleza propia de la acción deducida: es decir, si es personal, real, sucesoria, de jurisdicción voluntaria, entre otros.
 - a. **Acciones personales:** son las que se ejercen respecto de determinada persona que ha contraído la obligación correlativa, pueden surgir, entre otros, de los contratos, actos y hechos jurídicos. El Art. 323 CB dispone que fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, y salvo el derecho local contrario, será juez competente para el ejercicio de acciones personales el del lugar del cumplimiento de la obligación, o el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia. En el caso de las acciones personales es posible la sumisión, pero si las partes no han elegido

ley, será competente el juez del lugar de cumplimiento de la obligación o del domicilio o residencia de los demandados.

- b. **Acciones reales:** son las que se ejercen sobre una cosa sin respecto de determinada persona. Por ejemplo, la acción reivindicatoria. El CB establece:
 - i. **Art. 324:** para el ejercicio de acciones reales sobre bienes muebles será competente el juez de la situación, y si no fuere conocida del demandante, el del domicilio, y en su defecto el de la residencia del demandado.
 - ii. **Art. 325:** para el ejercicio de acciones reales sobre bienes inmuebles y para el de las acciones mixtas de deslinde y división de la comunidad, será juez competente el de la situación de los bienes. En el caso de las acciones reales no puede haber sumisión. Estas acciones sólo pueden interponerse ante el juez del tribunal donde están ubicados los bienes. En el caso de los bienes muebles de ubicación desconocida, puede ser competente el juez del domicilio o residencia del demandado.
 - iii. **Art. 326:** si en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores hubiere bienes situados en más de un Estado contratante, podrá acudir a los jueces de cualquiera de ellos, salvo que lo prohíba para los inmuebles la ley de la situación.
- c. **Quiebras, concurso de acreedores o procedimientos de insolvencia:** supone el caso en que un deudor tiene deudas en diversos países, en cuyo caso debe determinarse ante qué tribunal puede ser declarado en quiebra.
 - i. Si la quiebra es voluntaria (solicitada por el propio deudor) será competente para conocerla el juez correspondiente a su domicilio. El Art. 328 CB indica que en los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere voluntaria la presentación del deudor en ese Estado, será juez competente el de su domicilio.
 - ii. Si la quiebra ha sido solicitada por sus acreedores, se aplica el Art. 329 CB: En los concursos o quiebras promovidos por los acreedores, será juez competente el de cualquiera de los lugares que esté conociendo de la reclamación que los motiva, prefiriéndose, caso de estar entre ellos, el del domicilio del deudor, si éste o la mayoría de los acreedores, lo reclamasen. Es decir, es competente para conocer de la quiebra cualquier tribunal ante el cual se esté litigando alguna deuda del deudor, prefiriéndose el de su domicilio si él o la mayoría de los acreedores lo pide.
- d. **Acciones sucesorias:** el Art. 327 CB indica que en los juicios de testamentaría o ab intestato será juez competente el del lugar en que tuvo el finado su último domicilio. Es el mismo criterio utilizado en el Art. 148 COT. En las acciones sucesorias no es posible la sumisión porque el legislador ha establecido expresamente que es el competente para conocerlas el juez del último domicilio del causante.
- e. **Actos de jurisdicción voluntaria o no contenciosos:** el Art. 330 CB indica que Para los actos de jurisdicción voluntaria y salvo también el caso de sumisión y el derecho local, será competente el juez del lugar en que tenga o haya tenido su domicilio, o en su defecto, la residencia, la persona que los motive. Esta norma es consistente con la norma del Art. 149 COT. Es competente el juez elegido por las partes, o, en su

defecto, el del lugar donde tenga o haya tenido su domicilio o residencia quien los motiva, por ejemplo, el causante en el caso de la posesión efectiva de la herencia. El Art. 331 indica que en los actos de jurisdicción voluntaria de materia de comercio es competente el juez elegido por las partes o, en su defecto, el del lugar en que la obligación deba cumplirse o el del lugar del hecho que los origine. El Art. 331 expresamente señala que respecto de los actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio y fuera del caso de sumisión y salvo el derecho local, será competente el juez del lugar en que la obligación deba cumplirse o, en su defecto, el del lugar del hecho que los origine.

D. Ejercicios Prácticos:

(1.) Juan Seguel, chileno, domiciliado en Suecia, desaparece en el año 2012 durante una expedición al Himalaya sin que se tengan noticias de su paradero. Su mujer sueca y dos hijos necesitan declarar su muerte presunta para poder tramitar su herencia. Juan dejó bienes muebles en Suecia y un inmueble que heredó de sus padres en Chile. Al respecto señale, indicando el fundamento legal:

1. **Hechos jurídicos relevantes:** chileno domiciliado en Suecia, desaparición de chileno en Himalaya, mujer sueca y dos hijos, bienes muebles en Suecia y bienes inmuebles en Chile.
2. **¿Qué tribunal es el competente para decretar su muerte presunta?:** Art. 15 N°1 CC (tribunal chileno) y Art. 81 N°1 CC bilateralizado (tribunal sueco)
3. **¿Dónde debe abrirse la sucesión de Juan y qué ley la regirá?:** Art. 955 CC establece que la sucesión se abre en el último domicilio del causante, es decir en Suecia. Sin embargo, es aplicable el Art. 15 N°2 CC y Art. 998 inc. 3 CC respecto de los hijos chilenos del causante, lo cual les asegurará las asignaciones forzosas sobre los bienes del causante ubicados en Chile.
4. **¿Ante qué tribunales debiera ventilarse una acción de petición de herencia deducida por uno de los hijos de Juan?:** Si se quieren hacer valer las asignaciones forzosas del Artículo 15 N°2 y 998 la acción de petición debería ejercerse en Chile. De lo contrario, se debe ejercer en Suecia por ser el último domicilio del causante.

(2.) Carlos Fuentes, propietario de una industria panificadora en Chillán, compra a una empresa alemana una máquina amasadora por la cantidad de 25.000 dólares, pagaderos en tres cuotas depositadas en la cuenta corriente de la empresa en un Banco de Frankfurt. En el contrato de compraventa se estipula que éste se regirá por la ley alemana y que cualquier litigio en relación con el contrato se ventilará exclusivamente ante los tribunales ordinarios de Frankfurt. Carlos Fuentes deja impaga la segunda y tercera cuota y usted es contactado por la empresa alemana para que persiga judicialmente este cobro, considerando que todos los activos de Fuentes están en Chile. Indique cómo debe resolver este asunto y, específicamente:

1. **Hechos jurídicos relevantes:** propietario de industria chilena, compraventa de empresa alemana, compraventa en Frankfurt, contrato se rige por ley alemana, juicios se ventilarán en Frankfurt, pago en Alemania, activos del deudor en Chile, incumplimiento de segunda y primera tercera.
2. **¿Ante qué tribunales debe demandarse el pago de la deuda?:** debido a que se estipula la sumisión de jurisdicción a los tribunales de Frankfurt, se debe demandar en Frankfurt y la sentencia de pago de dinero se debe enviar a Chile apostillada para obtener el exequatur. Con

el exequatur la sentencia será título ejecutivo, pudiendo en tal momento demandar en Chile. Por lo tanto, lo conveniente en este caso era establecer la jurisdicción de los tribunales chilenos.

3. ¿qué ley aplicará el tribunal para decidir sobre el asunto?: ley de Frankfurt.

(3.) Sergio Fuenzalida, chileno domiciliado en Santiago, compra en Brasil a una empresa brasilera una grúa por la cantidad de 50.000 dólares pagaderos en 10 cuotas a un año plazo y garantiza el pago del precio mediante una prenda sin desplazamiento en favor de la vendedora. El contrato contiene una cláusula de aceleramiento para el caso de la mora del deudor en una o más cuotas. La grúa se utiliza en la construcción de una carretera en Perú. Fuenzalida deja de pagar la deuda a partir de la quinta cuota adeudada. La empresa brasilera decide entonces realizar la prenda. ¿Dónde debe interponer la demanda para ello y qué ley aplicarán los tribunales para decidir al respecto?

- 1. Hechos jurídicamente relevantes:** chileno domiciliado en Santiago, compraventa en Brasil a empresa brasilera, garantía del pago con prenda sin desplazamiento, grúa utilizada en Perú, cláusula de aceleramiento, mora del deudor.
- 2. ¿Dónde debe interponer la demanda para ello y qué ley aplicarán los tribunales para decidir al respecto?:** Esta acción es una acción real, la cual debe interponerse donde se encuentran los bienes. Por lo tanto, se debe demandar ante tribunales peruanos. La ley aplicable será la brasilera porque ahí es donde se constituyó la prenda.

(4.) La compañía minera Andina, filial de Codelco Chile ha construido un tranque de relave cercano al límite entre Chile y Argentina. A raíz de una falla estructural, parte de los relaves se filtran contaminando las aguas de un río Argentino y produciendo la muerte de 500 reses de una compañía ganadera Argentina. ¿Dónde debe demandar esa compañía Argentina a la Cía. Minera Andina y qué ley debe aplicar el juez para resolver este asunto?

- 1. Hechos jurídicos:** filial de Codelco construye tranque en la frontera con Argentina y, por una falla estructural, se contaminan aguas y mueren reses.
- 2. Lugar de demanda:** acción personal, se demanda en domicilio del demandado, esto es, Chile.
- 3. Ley aplicable:** además, es un cuasidelito y, conforme al CB, se aplica la ley donde se produjo el cuasidelito, es decir, el lugar de la negligencia (Chile).

E. Excepciones Procesales Internacionales: es posible que un mismo juicio se ventile en dos países distintos. En estos casos, procede interponer excepciones de carácter internacional. Existen tres tipos de excepciones que se pueden interponer a nivel internacional. Ellas se encuentran reguladas en el Art. 394 y siguientes del CB: (i) litispendencia; (ii) cosa juzgada; y (iii) incompetencia del tribunal.

- 1. Litispendencia:** el Art. 394 CB dispone que la litis pendencia por pleito en otro de los Estados contratantes, podrá alegarse en materia civil cuando la sentencia que se dicte en uno de ellos haya de producir en el otro los efectos de cosa juzgada. Esta excepción procede cuando se discute un mismo asunto litigioso en tribunales de distintos Estados. En ese caso, se puede alegar Litis pendencia internacional ante el tribunal que empezó a conocer después del asunto litigioso. Procede alegarla cuando existe triple identidad (identidad legal de personas, de cosa pedida y de causa de pedir) entre ambos litigios, de modo que la sentencia dictada en uno de ellos produciría cosa juzgada en el otro. Puede interponer esta excepción

el doble demandado. Su objeto es suspender el juicio más reciente hasta que el tribunal que conoce del primer juicio dicte sentencia a su respecto.

2. **Cosa Juzgada:** el Art. 396 CB dispone que la excepción de cosa juzgada que se funde en la sentencia de otro Estado contratante, sólo podrá alegarse cuando se haya dictado la sentencia con la comparecencia de las partes o de sus representantes legítimos, sin que se haya suscitado cuestión de competencia del tribunal basado en disposiciones de este Código.
Procede alegar cosa juzgada cuando se da la triple identidad entre ambos asuntos litigiosos y el primer juicio ha sido llevado con comparecencia personal de ambas partes y ante un tribunal competente. Por tanto, no se puede alegar cosa juzgada en el caso de que la primera sentencia haya sido dictada en rebeldía de la parte contra la cual se alega o se haya suscitado una excepción de incompetencia del Tribunal en ese juicio.

Se discute en doctrina si para interponer la excepción de cosa juzgada es necesario solicitar el exequátur de la sentencia extranjera. Una parte de la doctrina opina que no es necesario porque no se está haciendo efectiva la fuerza ejecutiva de esa sentencia sino que, simplemente, su fuerza probatoria. Otros autores piensan que como la cosa juzgada enerva la acción ante el segundo tribunal, sí debiera solicitarse el exequátur de la sentencia extranjera ya que este efecto equivaldría a un efecto ejecutivo de esa sentencia y no meramente probatorio.

3. **Incompetencia del Tribunal:** esta excepción, de acuerdo con las normas procesales internas chilenas, se puede interponer por declinatoria o inhibitoria. Por vía inhibitoria, se interpone ante el tribunal superior para que ordene al inferior que se inhiba de seguir conociendo de un asunto litigioso. Por vía declinatoria, se interpone ante el mismo tribunal que está conociendo de un asunto para que deje de conocerlo. La excepción de incompetencia internacional sólo se puede interponer por declinatoria. El Art. 397 CB dispone que En todos los casos de relaciones jurídicas sometidas a este Código, podrán promoverse cuestiones de competencia por declinatoria fundada en sus preceptos. Puede interponerse cuando se considere que el tribunal es jurisdiccionalmente incompetente para conocer del asunto litigioso; por ejemplo, porque las partes eligieron otro foro. El Tribunal chileno puede aceptar la excepción de incompetencia cuando el litigio trate de un asunto o materia de competencia relativa de los tribunales chilenos y no la aceptará cuando el asunto sea de competencia absoluta o exclusiva de los tribunales chilenos.

F. Inmunidades Diplomáticas de Jurisdicción y Ejecución: el Derecho Internacional Público dispone que ciertas personas y entidades están investidas de un privilegio por el cual no pueden ser demandadas ni ejecutadas ante tribunales extranjeros, por ciertas actuaciones realizadas dentro del territorio jurisdiccional de esos tribunales extranjeros.

1. Hay ciertos **funcionarios públicos y organismos internacionales** investidos de inmunidad de jurisdicción y ejecución.
 - a. **Inmunidad de jurisdicción** significa que no pueden ser demandados en juicio en un país determinado.
 - b. **Inmunidad de ejecución** se refiere a que no pueden ser ejecutados en un país determinado.
2. En cuanto a los **sujetos que gozan de inmunidad diplomática:**

- a. **Estados extranjeros y jefes de Estados extranjeros (Art. 333 a, Art. 336 CB y Art. 9 DL 2.349 de 1978).** El Art. 9 dispone que cualquier Estado extranjero y sus organismos, instituciones y empresas podrán impetrar en Chile la inmunidad de jurisdicción y de ejecución, según el caso, en los mismos términos y con igual amplitud e idénticas excepciones como la reconociere su propia legislación en favor del Estado de Chile o de sus organismos, instituciones y empresas. Esta inmunidad se otorga en base a la reciprocidad internacional. Los Estados pueden renunciar a la inmunidad de jurisdicción, pero ello no comprende necesariamente la renuncia a la inmunidad de ejecución (Art. 5 y Art. 6 DL 2.349 de 1978; el Estado de Chile no puede renunciar a la inmunidad de ejecución sobre fondos y bienes del Banco Central en el extranjero y tampoco puede renunciar a la inmunidad de ejecución de bienes de la Embajada o Consulado, respectivamente).
- b. **Agentes diplomáticos de Estados extranjeros en el Estado en el que están acreditados.** Estas inmunidades están reguladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 1961, en vigor desde 1964 y en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 1963, en vigor desde 1967. Estas inmunidades protegen al personal diplomático oficial, a sus familias y empleados. En el caso del personal diplomático se les garantiza inmunidad de jurisdicción civil y penal absolutas y de ejecución absolutas (Art. 29 al Art. 41 Convención de Viena, 1961¹⁹²⁰). En el caso del personal consular, el alcance de estas inmunidades es más limitado;

¹⁹ Art. 31: (1.) El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata: a. de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión; b. de una acción sucesoria en la que el agente diplomático figure, a título privado y no en nombre del Estado acreditante, como executor testamentario, administrador, heredero o legatario; c. de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales. (2.) El agente diplomático no está obligado a testificar. (3.) El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos a, b y c del párrafo 1 de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia. (4.) La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante.

²⁰ Art. 32: (1.) El Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción de sus agentes diplomáticos y de las personas que gocen de inmunidad conforme al Artículo 37. (2.) La renuncia ha de ser siempre expresa. (3.) Si un agente diplomático o una persona que goce de inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 37 entabla una acción judicial, no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvención directamente ligada a la demanda principal. (4.) La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de las acciones civiles o administrativas no ha de entenderse que entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo cual será necesaria una nueva renuncia.

se les garantiza inmunidad penal relativa e inmunidad de ejecución sólo para actos oficiales y no personales (Art. 41 al Art. 53 Convención de Viena 1963^{21 22}).

- c. **Las organizaciones internacionales y sus funcionarios**, dependiendo del Tratado que las establece.
 - d. En Chile, gozan también de inmunidad **los Observatorios astronómicos y sus empleados extranjeros**, en conformidad con los acuerdos suscritos por ellos con el Estado Chileno.
3. En cuanto al **modo de hacer valer las inmunidades diplomáticas**, las inmunidades pueden ser alegadas por el Estado extranjero por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien la comunica a la Corte Suprema; puede también decretarla de oficio la Corte Suprema, o puede alegarse como una excepción de incompetencia en juicio.

G. Ejercicios Prácticos:

(1.) El Cónsul de España en Chile compra una casa de veraneo en Zapallar. Paga en el acto de la compraventa el 50% del precio al contado y contrata un crédito hipotecario con el Banco Santander por el 50% restante. Él cae en mora de la décima cuota. Indique si el Banco puede demandarlo y ejecutarlo en Chile.

- 1. **Hechos jurídicamente relevantes:** cónsul de España en Chile, compraventa de inmueble chileno de forma personal, contrato de crédito hipotecario en Chile de forma personal, mora del cónsul.
- 2. **Solución jurídica:** el Cónsul de España no goza de inmunidad porque ejecuta un acto privado.

(2.) El Primer Secretario de la Embajada de Nepal en Chile, arrienda un inmueble anexo a la Embajada, para el funcionamiento de las oficinas de la Embajada. Finalizado el arriendo, el arrendador constata que el inmueble ha sufrido un deterioro considerable y que el costo de su reparación no puede cubrirse con la cantidad que el arrendatario había pagado por concepto de garantía. Por ello, el arrendador exige al arrendatario que pague el saldo adeudado de las reparaciones,

²¹ Art. 41: INVOLABILIDAD PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS CONSULARES. (1.) Los funcionarios consulares no deberán estar expuestos a arresto o detención pendiente de juicio excepto en el caso de un delito grave y en el cumplimiento de una decisión de la autoridad judicial competente. (2.) Excepto en el caso especificado en el párrafo 1 de este Artículo, los funcionarios consulares no serán puestos en prisión ni estarán expuestos a ninguna otra forma de restricción de su libertad personal salvo en el cumplimiento de una decisión judicial de resultado final. (3.) Si se iniciaran procesos criminales contra un funcionario consular, éste tendría que comparecer ante las autoridades competentes. No obstante, los procesos se conducirán con el respeto que se le debe por razón de su posición oficial y, excepto en el caso especificado en el párrafo 1 de este Artículo, de una manera que obstaculice el ejercicio de las funciones consulares lo menos posible. Cuando, en las circunstancias mencionadas en el párrafo 1 de este Artículo, se ha hecho necesaria la detención de un funcionario consular, los procesos en su contra deberán iniciarse con el mínimo de demora.

²² Art. 43: INMUNIDAD DE JURISDICCION. (1.) Los funcionarios y empleados consulares no se someterán a la jurisdicción de las autoridades administrativas o judiciales del Estado receptor por actos llevados a cabo en el ejercicio de sus funciones consulares. (2.) Las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo no se aplicarán, sin embargo, respecto a una acción civil que ocurra: (a) como resultado de la conclusión de un contrato por parte de un funcionario o empleado consular en el cual no se contrató expresa o implícitamente como agente del Estado emisor; o (b) mediante una tercera parte por daños que surjan de un accidente en el Estado receptor causado por un vehículo, un barco, o un avión.

a lo que éste se niega. El arrendador se dirige a usted para pedirle que realice el cobro judicial de esta cantidad. Señale cómo proceder para ello.

1. **Hechos jurídicamente relevantes:** primer secretario de Embajada de Nepal, arriendo de inmueble en ejercicio de funciones diplomáticas, inmueble entregado tras arriendo con deterioro, costo no es cubierto por arriendo, cobro judicial de saldo adeudado de las reparaciones.
2. **Solución jurídica:** existe inmunidad de jurisdicción y de ejecución del funcionario de la embajada porque se arrendó el inmueble para el ejercicio de funciones oficiales de la Embajada de Nepal. Se debió haber solicitado la renuncia de inmunidad al momento de pactar el arriendo o exigir mayores garantías.

(3.) El embajador de Colombia en Chile, Juan Heredia, hereda a la muerte de su padre una casa ubicada en Viña del Mar. Contrata a la empresa constructora BellaMar Ltda. para que realice una remodelación y ampliación de la casa. Al término de la obra Heredia paga su deuda girando un cheque que es protestado por falta de fondos. Analice el caso.

1. **Hechos jurídicamente relevantes:** embajador de Colombia en Chile, herencia de inmueble en Viña del Mar, remodelación del inmueble, pago con cheque protestado por falta de fondos.
2. **Solución jurídica:** en este caso el Embajador de Colombia estaría cometiendo el delito de giro doloso de cheques, por lo que, el embajador gozaría inmunidad penal absoluta salvo, que Colombia renuncie a esa inmunidad. Sin embargo, se podría ejercer alguna acción personal civil en su contra.

IV. Normas para el Cumplimiento en Chile de Sentencias dictadas por Tribunales Extranjeros.

A. Cumplimiento de Sentencias Dictadas por Tribunales Extranjeros en Chile: existen distintos sistemas en el derecho comparado mundial. Según si dan o no valor a las sentencias extranjeras se clasifican en: (i) sistemas avalorativos, es decir, no dan valor a esas sentencias; y (ii) sistemas valorativos, es decir, sí reconocen esas sentencias si cumplen ciertos requisitos. A su vez, los sistemas valorativos se subclasifican en:

1. **Sistemas valorativos absolutos:** dan eficacia automática a la sentencia extranjera si cumple ciertos requisitos. El Art. 431 CB le reconoce eficacia a la sentencia respecto del efecto de cosa juzgada, que no sea ejecución. El Art. 431 CB dispone que las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante que por sus pronunciamientos no sean ejecutables, producirán en los demás los efectos de cosa juzgada si reúnen las condiciones que a ese fin determina este Código, salvo las relativas a su ejecución.
2. **Sistemas valorativos relativos:** en ellos se da valor a la sentencia extranjera con una declaración judicial o administrativa previa que verifica que la sentencia extranjera cumple con las condiciones que la *lex fori* exige para validarlas.

Estos sistemas se diferencian por las condiciones de reconocimiento exigidas y por el tipo de autoridad que interviene en el reconocimiento:

1. **Según el tipo de condición de reconocimiento exigida:**
 - a. Examen de fondo y fondo de la sentencia (criticado).

- b. Reciprocidad, se les otorga la misma fuerza que se les da a las sentencias de ese país en el país de donde provenga el fallo.
- c. Principio de regularidad internacional de los fallos, se da valor a la sentencia si cumple con requisitos mínimos establecidos por la ley del foro, para garantizar el debido proceso en su dictación en el extranjero.

2. Según el tipo de autoridad que la dicta:

- a. Judicial, en un procedimiento contencioso.
- b. Administrativa, en un procedimiento administrativo a cargo de una entidad pública.

B. Sistema Chileno de Reconocimiento de Sentencias Extranjeras: en Chile, el reconocimiento de sentencias extranjeras requiere del trámite de obtención del exequátur en un procedimiento judicial contencioso que valide esa sentencia. Es decir, se adopta un sistema valorativo relativo en base a la reciprocidad y a la regularidad internacional del fallo a cargo de la máxima autoridad judicial, la Corte Suprema.

El exequatur es el pase o visto buenos dado a la sentencia extranjera para darle fuerza ejecutiva en un país. Lo otorga la Corte Suprema chilena en una sentencia que pone fin a un juicio de exequátur. Esa sentencia adquiere el valor de título ejecutivo que puede usarse para iniciar después un juicio ejecutivo de cumplimiento ante el tribunal ordinario chileno competente: Art. 251 CPC (normalmente, el del domicilio del demandado en Chile).

El Art. 251 CPC dispone que mandada cumplir una resolución pronunciada en país extranjero, se pedirá su ejecución al tribunal a quien habría correspondido conocer del negocio en primera o en única instancia, si el juicio se hubiera promovido en Chile. Es decir, el tribunal al que le habría correspondido conocer del negocio en primera o única instancia, si el juicio se hubiera promovido en Chile. Este Tribunal debe ordenar el cumplimiento de la sentencia y otras diligencias que sean consecuencias de ésta, como inscripciones y subinscripciones.

B.1. Materia de Exequatur: requieren de exequatur las sentencias definitivas e interlocutorias que ponen término al juicio o establecen derechos definitivos para las partes, similares a las sentencias nacionales, las sentencias civiles contenciosas y no contenciosas y las sentencias ordinarias, arbitrales o especiales. No requieren de exequátur los autos o decretos o medidas prejudiciales o precautorias, ni las sentencias penales (excepto, respecto de los efectos civiles contenidos en las sentencias penales). Los autos o decretos y demás solicitudes de tribunales extranjeros para realizar diligencias en Chile se tramitan por la vía del exhorto internacional.

B.2. Efectos de la Sentencia que Requiere de Exequatur: las sentencias tienen, por lo general, tres efectos: (i) ejecutivo; (ii) de cosa juzgada; y (iii) probatorio. No todos estos efectos requieren de exequátur para hacerse valer en el extranjero. La sentencia extranjera requiere de exequátur cuando se pretende hacer valer su fuerza ejecutiva en Chile. Se discute si es necesario el exequátur para hacer valer su efecto de cosa juzgada, ya que el Art. 431 CB parece darles efectos inmediatos a las sentencias de países partes.

El Art. 431 CB dispone que las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante que por sus pronunciamientos no sean ejecutables, producirán en los demás los efectos de cosa juzgada si reúnen las condiciones que a ese fin determina este Código, salvo las relativas a su ejecución.

Parte de la doctrina opina que sí requiere de exequatur porque esta excepción produce el efecto de enervar la acción judicial en Chile. Para hacer valer el efecto probatorio de la sentencia extranjera, no se requiere exequátur basta presentarla legalizada o apostillada y traducida para que ésta dé plena prueba de su existencia y tenor.

B.3. Normas Aplicables al Exequatur de Sentencias Extranjeras en Chile: el sistema chileno de reconocimiento de sentencias extranjeras es un sistema de normas, subsidiario y excluyente, contenido en el Art. 242 CPC al Art. 246 CPC.

1. **Tratados (Art. 242 CPC):** las resoluciones pronunciadas en país extranjero tendrán en Chile la fuerza que les concedan los tratados respectivos; y para su ejecución se seguirán los procedimientos que establezca la ley chilena, en cuanto no aparezcan modificados por dichos tratados. Para otorgar y tramitar el exequátur a una sentencia extranjera se aplica primero el procedimiento establecido en y los requisitos exigidos en los Tratados vigentes. Chile es parte de los siguientes Tratados, que regulan el reconocimiento de sentencias extranjeras:
 - a. Código de Bustamante (Art. 423 al Art. 433).
 - b. Convención de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, Nueva York 1958.
 - c. Convención Interamericana sobre arbitraje comercial Internacional, Panamá 1975.
2. **Reciprocidad (Art. 243 CPC y Art. 244 CPC):** en caso de inexistencia de Tratado, se aplica el criterio de: reciprocidad positiva (Art. 243 CPC) y reciprocidad negativa (Art. 244 CPC).
 - a. **Art. 243 CPC:** si no existen tratados relativos a esta materia con la nación de que procedan las resoluciones, se les dará la misma fuerza que en ella se dé a los fallos pronunciados en Chile.
 - b. **Art. 244 CPC:** si la resolución procede de un país en que no se da cumplimiento a los fallos de los tribunales chilenos, no tendrá fuerza en Chile.Estas reciprocidades son difíciles de probar por lo que, en ausencia de Tratado, se acostumbra a recurrir a la revisión de los requisitos de regularidad del fallo extranjero exigida por el Art. 245 CPC.
3. **Principio de Regularidad Internacional de los Fallos (Art. 245 CPC):** si no hay tratados ni se puede probar la reciprocidad, la parte que solicita el exequátur debe probar que la sentencia cumple con los requisitos mínimos del Art. 245 CPC. Estos requisitos mínimos garantizan que la sentencia extranjera se dictó en un debido proceso y ante un tribunal competente. La norma dispone que en los casos en que no pueda aplicarse ninguno de los tres artículos precedentes, las resoluciones de tribunales extranjeros tendrán en Chile la misma fuerza que si se hubieran dictado por tribunales chilenos, con tal que reúnan las circunstancias siguientes:
 - a. Que no contengan nada contrario a las leyes de la República. Pero no se tomarán en consideración las leyes de procedimiento a que haya debido sujetarse en Chile la substanciación del juicio. Es decir, exige que la sentencia no se oponga al orden público chileno ni a las normas de policía chilenas.

- b. Que tampoco se opongan a la jurisdicción nacional. Es decir, que la materia fallada en el extranjero no era de la exclusiva competencia de los tribunales chilenos y debió ser fallada por éstos.
- c. Que la parte en contra de la cual se invoca la sentencia haya sido debidamente notificada de la acción. Con todo, podrá ella probar que, por otros motivos, estuvo impedida de hacer valer sus medios de defensa. Es decir, que la sentencia extranjera no haya sido dictada en un juicio seguido en rebeldía de la parte contra la cual se pretende hacer valer y que ésta se haya podido defender en el juicio extranjero.
- d. Que estén ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan sido pronunciadas. Es decir, que la sentencia produzca el efecto de cosa juzgada en el país donde se dictó.

Las exigencias de este artículo se aplican a todas las sentencias ordinarias extranjeras, con excepción de aquellas que provengan de tribunales de países partes del Código de Bustamante. Ellas no se aplican a sentencias arbitrales extranjeras porque ellas quedan regidas por las Convenciones Interamericana de Panamá 1975, de N. York 1958 o la Ley 19.971 sobre arbitraje Comercial Internacional (Art. 35).

B.4. Cuadro de Tratados y Normas Aplicables al Exequatur de Sentencias Extranjeras: según orden de prelación.

Sentencias Ordinarias		Sentencias Arbitrales	Arbitrales Comerciales	Arbitrales Civiles
CB (Art. 423 y ss.) si provienen de un Estado parte del CB.			Conv. Panamá 1975 (vigente en Latinoamérica y EE.UU), deroga tácitamente convenciones anteriores: CB y Conv. N. York.	
			Conv. N York 1958 (vigente en muchos países del mundo).	Conv. N York 1958 compatibilidad Art. VII con CB.
CPC (Art. 243 y ss.) si provienen de otro país.			Ley 19.971 de Arb. Comercial internacional (Art 35).	C. Bust Art 432. (países con reserva de NY respecto de sentencias civiles)
			-	Art. 246 CPC

Las sentencias ordinarias que provienen de países partes del CB, se someten al CB que tiene exigencias similares al Art. 245 CPC. Las demás sentencias ordinarias se someten al CPC. En estas sentencias el peso de la prueba del cumplimiento de los requisitos de regularidad del fallo recae sobre el solicitante del exequátur.

Las sentencias arbitrales civiles que provienen de algún país Latinoamericano se someten a la convención de NY, con excepción de algunas sentencias provenientes de países que ratificaron la Convención de N York con reserva indicando que sólo se aplicaba a sentencias comerciales, por ej.

EE.UU., Argentina, Ecuador, Cuba, Guatemala, Honduras, entre otros. Si no se aplica esta Convención, se les aplica el CB, si el laudo proviene de un país parte o el CPC (Art. 246).

Las sentencias arbitrales civiles que provienen de otros países, se someten a la Convención de Nueva York, salvo que haya reserva; si la hay, se someten al procedimiento del Art. 246 CPC.

Las sentencias arbitrales comerciales que provienen de Latinoamérica o Estados Unidos se someten a la convención de Panamá. Las de otros países, se someten a la Convención de Nueva York, si el Estado es parte de esta convención, de lo contrario, se someten a la Ley 19.071, Art. 35.

El Art. 5 de la Convención de Panamá y el Art. 5 de la Convención de Nueva York establecen que para que se pueda otorgar el exequátur de una sentencia arbitral extranjera hay que comprobar que se cumplan con ciertos requisitos. El peso de la prueba en este caso recae sobre el demandado. O sea, el demandado tiene que probar que la sentencia arbitral no cumple con los requisitos mínimos establecidos en las convenciones para validarse en Chile. Por tanto, para el demandante o solicitante del exequátur es fácil conseguir la ejecución de la sentencia arbitral.

El Art. 5 de la Convención de Panamá de 1975 dispone que:

1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si ésta prueba ante la autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la ejecución:
 - a. Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley del Estado en que se haya dictado la sentencia.
 - b. Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no haya sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no haya podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa.
 - c. Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el acuerdo de las partes de sometimiento al procedimiento arbitral; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no hayan sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras.
 - d. Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan ajustado a la ley del Estado donde se haya efectuado el arbitraje.
 - e. Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o haya sido anulada o suspendida por una autoridad competente del Estado en que, o conforme a cuya ley, haya sido dictada esa sentencia.
2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba:
 - a. Que, según la ley de este Estado, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje,

- b. Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean contrarios al orden público del mismo Estado.

La sentencia arbitral comercial que proviene de un país no parte de las dos Convenciones anteriores, se somete a los requisitos del Art. 35 de la Ley 19.971 sobre Arbitraje Comercial Internacional. Estos requisitos son los mismos que los exigidos por las dos convenciones y su prueba recae sobre el demandado.

El procedimiento del exequátur está regulado en el CPC (Art. 247 al Art. 250 y el Código de Bustamante para países partes (Art. 423 al Art. 433).

B.5. Tramitación de Exhortos y Cartas Rogatorias: está regulado en el Art. 76 CPC y en la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias (promulgada por decreto 644, Min. Relaciones Exteriores, D. Of 18-10-1976), la que es compatible con las normas del Código de Bustamante (Art. 388 a Art. 393) que también los regula. La tramitación de estos exhortos internacionales debe hacerse ante la Segunda Sala de la Corte Suprema (Sala Penal y asuntos varios).

Se tramitan por vía de exhortos internacionales las solicitudes que hace un tribunal a otro en el extranjero para realizar ciertas diligencias, por ejemplo, diligencias probatorias (confesión, interrogación testigos, cotejo de documentos, inspecciones o verificaciones, entre otros), diligencias de notificación, entre otros.

El Art. 76 CPC dispone: Cuando hayan de practicarse actuaciones en país extranjero, se dirigirá la comunicación respectiva al funcionario que deba intervenir, por conducto de la Corte Suprema, la cual la enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste a su vez le dé curso en la forma que esté determinada por los tratados vigentes o por las reglas generales adoptadas por el Gobierno. / En la comunicación se expresará el nombre de la persona o personas a quienes la parte interesada apodere para practicar las diligencias solicitadas, o se indicará que puede hacerlo la persona que lo presente o cualquiera otra. / Por este mismo conducto y en la misma forma se recibirán las comunicaciones de los tribunales extranjeros para practicar diligencias en Chile.

Por ejemplo, producto de una demanda en Chile se debe notificar a una persona domiciliada en Buenos Aires, para ello se debe solicitar al tribunal que evacúe exhorto para que el tribunal de Buenos Aires notifique. El exhorto se va a tramitar previa certificación por la Segunda Sala de la CS y apostilla del Ministerio de RR.EE.

B.6. Ejercicios Prácticos:

(1.) Señale qué cuerpo legal es aplicable al reconocimiento en Chile de una sentencia arbitral dictada por un árbitro del Tribunal Londinense de Arbitraje y qué condiciones debe reunir para que la Corte Suprema le otorgue ese reconocimiento.

(2.) Señale qué cuerpo legal es aplicable al reconocimiento en Chile de una sentencia de la Corte de Casación Francesa y qué requisitos debe reunir para su reconocimiento.

(3.) Señale qué cuerpo legal es aplicable al reconocimiento en Chile de una sentencia ordinaria Brasileña.

(4.) Un abogado canadiense, representante de una empresa canadiense que es acreedora de una empresa forestal chilena, domiciliada en Arauco, le solicita a Ud. tramitar en Chile una orden precautoria de embargo de bienes, ordenada por un tribunal canadiense. Indique qué consejo legal le daría.